

Curso Examen de Grado
Módulo 9: Los Procedimientos.

Presentación.

Módulo 9: Los Procedimientos.

Los procedimientos abarca principalmente el estudio del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía y del Juicio Ejecutivo por Obligación de Dar, regulados en los Libros II y III del Código de Procedimiento Civil, ambos piedras angulares del Derecho Procesal por su aplicación subsidiaria. Sin embargo, este módulo también abarca las medidas prejudiciales, los incidentes y los medios de prueba en particular.

Al final del módulo se espera que los alumnos conozcan cada uno de los procedimientos que se estudiarán, pudiendo ser capaces de discernir su ámbito de aplicación y sus diversas etapas, como las reacciones o defensas de las partes litigantes, en especial del demandado y las consecuencias de sus posibles actitudes. En cuanto a las medidas prejudiciales el alumno deberá conocerlas detalladamente, en especial su finalidad, para que al momento de preparar la entrada al juicio interponga la adecuada.

También deberán conocer cada uno de los medios de probatorios, su oportunidad procesal y su valor probatorio.

Los contenidos se abordarán a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Generalidades.
- Unidad 2: Medidas Prejudiciales.
- Unidad 3: Juicio Ordinario de Mayor Cuantía.
- Unidad 4: Teoría General de la Prueba.
- Unidad 5: Medios de Prueba en Particular.
- Unidad 6: Los incidentes.
- Unidad 7: Juicio Sumario.
- Unidad 8: Juicio Ejecutivo de Mayor Cuantía.
- Unidad 9: Juicio Ejecutivo por Obligación de Dar.
- Unidad 10: Juicio Ejecutivo por Obligación de Hacer.
- Unidad 11: Juicio Ejecutivo por Obligación de no Hacer.
- Unidad 12: Ejecución de las Resoluciones Judiciales.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando la unidad 1.

Unidad 1: Generalidades.

Tema 1: Generalidades en torno a lo que es un juicio. Conceptos.



Previo al estudio de los distintos procedimientos que contempla el Código de Procedimiento Civil, es menester analizar ciertos conceptos que facilitarán su posterior estudio.

a) Proceso: *Es un medio idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de juicio de autoridad, un conflicto de relevancia jurídica mediante una resolución que, eventualmente, puede adquirir la fuerza de la cosa juzgada, y podrá ser cumplido coercitivamente.*

El proceso es abstracto, no corresponde a un procedimiento en particular o a un juicio determinado, por lo que se puede sostener que es uno, único, inclasificable e indivisible, a diferencia de lo que ocurre con los procedimientos.

b) Litigio: Es un término que con frecuencia usa el legislador, así por ejemplo, el artículo 263 C.P.C. señala que en la conciliación el juez debe obrar como amigable componedor, tratando de obtener un avenimiento total o parcial en el *litigio*.

Su concepto tiene un contenido doctrinario aportado por *Francesco Carnelutti*, quien lo define como “*un conflicto de intereses subjetivos de relevancia jurídica*”, en consecuencia, el litigio es previo al procedimiento, por eso nuestro concepto es ligeramente diferente “*conflicto de intereses subjetivos de relevancia jurídica, antecedente del proceso*”.

c) Procedimiento: Es el *conjunto de trámites, ritos o formalidades a través de las cuales se desarrolla el proceso*. El procedimiento es un caminar que se desarrolla en el tiempo compuesto por un conjunto de actuaciones, en las que intervienen las partes, el juez y los terceros. El procedimiento, como conjunto de ritos, se caracteriza porque éstos se van concatenando en una doble perspectiva: i) desde un punto de vista lógico, donde una actuación es antecedente de la siguiente y; ii) desde un punto de vista teleológico, donde todo el conjunto apunta hacia la solución del conflicto.

La relación entre proceso y procedimiento es una relación de contenido (el proceso) y continente (el procedimiento), o dicho de otra manera, el proceso se desenvuelve a través de un determinado procedimiento.

d) Juicio: Es el *procedimiento específico a través del cual se desarrolla el proceso*, o sea, un conjunto de trámites, actuaciones o ritualidades que tienen características propias, que las convierten en un procedimiento determinado adquiriendo un nombre y una fisonomía propia, así por ejemplo existe el

juicio ordinario de mayor, menor o mínima cuantía, el juicio sumario, el juicio ejecutivo por obligación de dar, etc.

Desde un punto de vista etimológico, juicio viene de la voz latina *iudicare*, que en su sentido más amplio significa juzgar o decir el derecho. Sin embargo, *juicio* es un término que se ha ido abandonando por el legislador, así el Código del Trabajo actualmente regula el Procedimiento de Aplicación General y el Procedimiento Monitorio.

Tema 2: Clasificaciones de los Juicios.

2.1 Según la naturaleza de la pretensión.

Según la naturaleza de la pretensión se distingue entre juicios declarativos, constitutivos y de condena.

a) Juicios declarativos: *Son aquellos donde se persigue despejar una situación jurídica determinada*, así por ejemplo, frente a la duda de si un acto o contrato es oponible o válido, se puede iniciar un juicio que declare su inoponibilidad o nulidad.

Es importante señalar que dentro de esta categoría hay algunos juicios denominados *juicios declarativos de mera certeza*, que son aquellos que frente a una situación jurídica controvertida y eventualmente desconocida por un tercero, se pretende despejar de dudas, y lograr así el valor de la seguridad jurídica.

b) Juicios constitutivos: *Son aquellos que pretenden la creación de situaciones jurídicas nuevas*, por ejemplo, la interdicción de un disipador.

Es importante destacar, como rasgo común para los juicios declarativos y los juicios constitutivos, es que para el cumplimiento de la sentencia, una vez ejecutoriada, no es necesario el cumplimiento coercitivo. En los juicios declarativos la sentencia se basta a sí misma, por cuanto despejó la incógnita que se pretendía resolver con el juicio. En los juicios constitutivos el cumplimiento se realiza a través de simples anotaciones administrativas.

c) Juicios de condena: En estos casos el actor pretende que el demandado sea colocado en situación de deudor de una obligación de dar, hacer, o no hacer. A diferencia de las dos categorías anteriores, en el juicio de condena puede sobrevenir un procedimiento coercitivo, por cuanto si el deudor es condenado y no cumple voluntariamente, se podrá desencadenar el procedimiento respectivo para, incluso por la fuerza, llegar al cumplimiento de la sentencia.

Es importante destacar, que estas clasificaciones no son recíprocamente excluyentes entre sí, es posible que convivan en un mismo proceso dos categorías: juicio declarativo y de condena, esto porque en nuestra legislación se admite la pluralidad de acciones, es decir, que en la misma demanda se entablen dos o más acciones siempre y cuando sean compatibles, o incluso siendo incompatibles con tal que se entablen una en subsidio de la otra.

Dentro de los procedimientos de condena, hay uno de particular importancia que es el juicio ejecutivo, éste es un género que se divide en categorías según sea la prestación que se debe (dar o hacer). El juicio

ejecutivo se caracteriza porque sólo se podrá hablar de juicio si el deudor se opone al cumplimiento, en caso contrario se habla de apremio.

2.2 Según la materia del juicio.

Según la materia del juicio estos se clasifican en civiles y penales. Sin embargo, es una división arcaica que no corresponde a la realidad actual, emana del Derecho Romano donde los conflictos se dividían en civiles y penales. En nuestro ordenamiento, el concepto de juicios civiles es un concepto residual en el sentido que *juicio civil es todo lo que no es juicio penal*. La evolución ha consistido en hacer una serie de distinciones atendiendo a la materia involucrada, por ejemplo, juicios laborales, juicios de familia, juicios tributarios, etc., además, por tratarse de materias específicas son conocidas por un tribunal especial.

Los juicios penales nacen con la *noticia criminis* y no del delito porque sólo al final del procedimiento se sabrá si se está o no frente a uno. La noticia criminis es el conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de delito.

Cabe señalar que el Código Procesal Penal no clasifica los juicios, sino que regula *procedimientos*, así establece un Procedimiento Ordinario, que es de general aplicación, y procedimientos especiales (Libro Cuarto).

2.3 Según la naturaleza del tribunal que conoce del juicio.

a) Juicios arbitrales: Esta clasificación es certera, porque efectivamente *hay ciertos y determinados juicios que, por voluntad de las partes o por disposición de la ley, son conocidos por árbitros - arbitadores, de derecho o mixtos-*.

b) Juicios comunes y juicios especiales. Esta clasificación es errática, ya que al decir juicio común se está indicando que es conocido por los tribunales comunes, y por el contrario, juicios especiales serían conocidos por tribunales especiales. Sin embargo, en ciertas ocasiones existen tribunales ordinarios que conocen de juicios especiales, y tribunales especiales que conocen de juicios ordinarios.

2.4 Según los trámites a que están sujetos los juicios.

Esta clasificación atiende, por una parte, a los principios de la concentración y desconcentración, y por otra, a los principios de la mediación y la inmediatez.

a) Juicios ordinarios: El juicio ordinario por antonomasia es el juicio ordinario de mayor cuantía, y todos los demás juicios son excepciones o confirmaciones de éste. Es esencialmente desconcentrado y conserva en su esencia la estructura del procedimiento romano canónico, con etapas perfectamente distinguibles unas de otra.

b) Juicios sumarios: Estos juicios se caracterizan porque en ellos prima el criterio de la concentración: sus etapas se han ido simplificando y los plazos se han ido acortando.

c) **Juicios especiales:** Estos juicios son múltiples, refiriéndose a una materia particular en un procedimiento concentrado.

Es menester destacar que, a falta de ley especial se aplica el juicio ordinario de mayor cuantía, pero éste no es sólo fuente subsidiaria como juicio o procedimiento, sino que también fuente complementaria respecto de trámites, actuaciones o ritos no tratados en un juicio particular. En otras palabras, el juicio ordinario de mayor cuantía es doblemente supletorio, como procedimiento en sí y en sus trámites en particular (artículo 3 C.P.C.).



2.5 Juicios singulares y especiales.

a) **Juicios singulares:** Son aquellos donde desde el inicio aparecen claramente establecidas cuáles son las partes contendientes, sin perjuicio, que durante su desarrollo puedan aparecer terceros.

b) **Juicios universales:** Son aquellos donde los que se presentan al juicio son un número inicialmente indeterminado de partes y que sólo se van a determinar a lo largo de su desarrollo, por ejemplo, el juicio de quiebra y el procedimiento de convenio judicial preventivo.

Tema 3: Elementos Constitutivos de los Juicios.

Los elementos constitutivos de los juicios, son fundamentalmente tres: el tribunal, las partes y el conflicto.

Tanto el tribunal como las partes, son estáticas y mediante el procedimiento se les otorga dinamismo. Vale reiterar que es de la esencia de éste que tenga etapas, ya que es un desplazamiento ordenado en el tiempo, con la intención de que cada etapa pasada se cierre de una vez y para siempre, y para esto existen dos grandes mecanismos: el impulso procesal y la preclusión.

Unidad 2: Medidas Prejudiciales.

Las medidas prejudiciales se analizarán como etapa de preparación del juicio ordinario de mayor cuantía, sin embargo, también son aplicables a otros procedimientos, por ejemplo, en el procedimiento de desposeimiento que se intenta en contra del tercero poseedor de la finca hipotecada, en este caso, la acción de desposeimiento siempre va precedida de un período de preparación; en el juicio ejecutivo cuando el acreedor no cuenta con título ejecutivo y quiere preparar la ejecución debe comenzar con una “gestión preparatoria del juicio ejecutivo”.

Tema 1: Concepto.

La etapa de preparación está representada por las llamadas **medidas prejudiciales**, que *son las providencias que puede o debe adoptar el tribunal, a petición de parte, para hacer posible o facilitar a quien será demandante o demandado el ejercicio de sus futuras acciones o reacciones.*

1.1 Análisis del concepto.

a) Las medidas prejudiciales son providencia. Es decir, son resoluciones que adopta el tribunal y, en general, en la clasificación de las resoluciones son autos, porque resuelven una cuestión accesoria (incidente) sin establecer derechos permanentes en favor de las partes, ya que pueden modificarse y son esencialmente provisorias.

b)...que puede o debe adoptar el tribunal. El gran número de medidas prejudiciales queda entregada a la prudencia del tribunal el concederlas o no, pero hay ciertas medidas prejudiciales que el tribunal necesariamente debe adoptar.

c)...a petición de parte. Las medidas prejudiciales se adoptan sólo a petición de parte. En esta materia rige *in integrum* el principio de la pasividad, y el tribunal no puede, en consecuencia, adoptar de oficio medidas prejudiciales.

d)...para hacer posible o facilitar a quien será demandante o demandado. Las medidas prejudiciales pueden ser adoptadas ya sea en beneficio de quien será el demandante, que es la regla general, pero también en beneficio de quien fundadamente teme ser demandado.

e)...el ejercicio de sus futuras acciones o reacciones. El objeto de las medidas prejudiciales es facilitar o hacer posible la correspondiente acción o reacción. En ciertos casos las medidas prejudiciales sólo facilitan la iniciación del juicio, lo que podría también lograrse por otra vía más dificultosa, pero en otros casos, sin esta medida el juicio no sería posible.

Las medidas prejudiciales no están taxativamente enumeradas por el legislador, por lo que hay cierta discrecionalidad de acuerdo con las circunstancias. Esto es particularmente válido tratándose de medidas prejudiciales precautorias donde claramente el legislador les ha dado el carácter de no taxativas.

Tema 2: Clasificación de las Medidas Prejudiciales.

2.1 Medidas prejudiciales propiamente tales o preparatorias.

Estas medidas prejudiciales claramente tienen por objeto facilitar o hacer posible el ejercicio de las correspondientes pretensiones (acción) o contrapretensiones (reacción).



2.2 Medidas prejudiciales probatorias.

Tienen por objeto reunir antecedentes fácticos frente al riesgo de que las probanzas puedan desaparecer y, en consecuencia, no puedan producirse dichas probanzas en el término probatorio, por ejemplo, un testigo en grave estado de salud.

2.3 Medidas prejudiciales precautorias.

Dentro de la gran gama de medidas prejudiciales son las de mayor aplicación práctica y son aquellas que tienen por objeto asegurar el resultado de la acción deducida, o sea, adoptar providencias, medidas, resguardos para que la acción que se va a deducir se pueda traducir en hechos concretos que satisfagan la pretensión.

En nuestra legislación, por regla general, no existe el acceder provisionalmente a la pretensión, de manera que las medidas prejudiciales importan tomar las providencias del caso para que la declaración judicial en su momento pueda ser eficazmente cumplida.

Tema 3: Paralelo.

3.1 Semejanzas.

Todas las medidas prejudiciales deben plantearse antes del inicio del respectivo juicio (la relación procesal no puede estar trabada). Respecto del tiempo u oportunidad, puede ser antes de la presentación de la demanda, o bien, antes de su notificación.

3.2 Diferencias.

a) En relación con su finalidad. Las medidas prejudiciales probatorias pretenden reunir anteladamente pruebas que pueden desaparecer. Las medidas prejudiciales propiamente tales, tienen por objeto facilitar o hacer posible la correspondiente acción o reacción y las prejudiciales precautorias, asegurar el resultado de la acción deducida.

b) ¿Cuándo se conceden? Las medidas prejudiciales precautorias, a juicio del legislador, se pueden adoptar sólo **en casos graves y urgentes**, es decir, cuando hay presunciones graves del derecho que se reclama. Esto significa que la medida de que se trata debe plantearse de tal manera que lleve a la creencia indubitada que la pretensión del futuro actor es fundada, y solamente la concederá el juez si concluye que esto es así (humo de buen derecho).

En cambio, tratándose de medidas prejudiciales propiamente tales o probatorias, no se requiere gravedad ni urgencia, debiendo concederse siempre, salvo que estén fuera de la casuística que la ley específicamente establece.

Tema 4: Tribunal Competente.



Las medidas prejudiciales se consideran cuestiones accesorias a la principal, aunque surgen antes que ésta, y como cuestiones accesorias que son se aplica la regla de la extensión en virtud de la cual el tribunal que es competente para conocer de la cuestión principal será también competente para conocer de la cuestiones accesorias.

Cuando las partes han designado un tribunal arbitral y el árbitro no se encuentra instalado, y la parte va donde el juez de letras para que la conceda, esta medida prejudicial concedida por el juez de letras no vale, sólo es válida la deducida ante el propio árbitro.

Si la medida prejudicial es concedida, la demanda posterior debe ser presentada ante el tribunal que conoció de la medida prejudicial¹, en cambio, si es denegada, se presentará la demanda de acuerdo a las reglas generales.

Tema 5: Procedimientos en que son aplicables las Medidas Prejudiciales.

Frente a la pregunta de si las medidas prejudiciales son posibles en toda clase de juicio o sólo en el juicio ordinario de mayor cuantía, se debe señalar que desde el punto de vista sistemático el asunto no merece duda, porque efectivamente en la medida en que el juicio ordinario de mayor cuantía es supletorio, naturalmente hay que concluir que las medidas prejudiciales proceden en cualquier juicio.

Sin embargo, la duda podría surgir por el texto del artículo 273 C.P.C. que dice que: *“el juicio ordinario podrá prepararse...”*. Esta referencia al juicio ordinario, a algunos pudo hacerlos dudar si las medidas prejudiciales son comunes a todo procedimiento civil o solamente al juicio ordinario.

En definitiva, la conclusión es que las medidas prejudiciales son aplicables a toda clase de procedimiento, incluso se pueden impetrar tratándose del juicio ejecutivo. Esta conclusión se ve reforzada por lo establecido en el inciso final del artículo 698 C.P.C., norma que se encuentra en el juicio de menor cuantía y que se refiere a cómo se concede la apelación en los incidentes sobre medidas prejudiciales.

¹ Norma que es aplicación del artículo 178 C.O.T. que señala que no es necesario la distribución de causa cuando se ha iniciado la cuestión con una medida prejudicial, pero este artículo no es del todo claro, porque se refiere a la distribución de causas, pero la jurisprudencia y la práctica han hecho que siempre que se haya iniciado la cuestión con una medida prejudicial, habiendo o no distribución de causa, la demanda deberá entablarse ante el tribunal que concedió la respectiva medida.

Tema 6: Medidas Prejudiciales Propiamente Tales.

6.1 Concepto.

Son las providencias que puede o debe adoptar el tribunal, a petición de parte, para hacer posible o facilitar a quien será demandante o demandado, el ejercicio de sus futuras acciones o reacciones.

6.2 Análisis de las medidas prejudiciales propiamente tales.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 273 "El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda:

6.2.1 Declaración jurada.

1° Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes.

Lo que se pretende con esta medida prejudicial es establecer una relación procesal válida y eficaz, para esto el futuro demandante solicita declaración jurada en relación con la capacidad para comparecer en juicio del demandado. Dentro de este mismo numerando, se habla de personería, que significa capacidad para representar a otra persona, sea natural o jurídica. Alude también al nombre o domicilio de sus representantes.

En consecuencia, como aparece de lo explicado, son tres las situaciones diferentes a que se refiere la declaración jurada:

- a) La capacidad del futuro demandado para comparecer en juicio**, por ejemplo, en caso de duda si el futuro demandado es mayor o menor de edad, o si el futuro demandado ha sido o no declarado en interdicción;
- b) La personería**, es decir, si el citado tiene facultad para representar a otra persona (natural o jurídica);
- c) El nombre y domicilio de sus representantes**, aquí se le pide a la persona que, bajo juramento, señale el nombre y domicilio de su representante.

El artículo 62 C.P.C. regula la forma del juramento, pero lo que la ley no señala es la manera en qué deben plantearse las preguntas, y se ha concluido que **no se requiere de pliego cerrado**, como en la absolución de posiciones, sino que basta con un pliego abierto o con plantear las preguntas directamente en la presentación de la solicitud de la medida prejudicial propiamente tal.

Es interesante analizar que ocurre en caso de mendacidad, es decir, si la persona que presta juramento falta a la verdad en su declaración. En este caso se distinguen dos posiciones:

- a)** Hay quienes dicen que en este caso el sujeto cometió perjurio, delito que castiga el Código Penal en su artículo 200 que consiste en prestar declaración falsa bajo juramento ante autoridad. No hay que confundirlo con el falso testimonio que es la conducta del testigo que bajo juramento falta a la verdad.
- b)** Hay otros que sostienen que en la ley procesal civil, quien miente en su beneficio no comete delito.

Este es un tema altamente opinable, pero en general nuestra jurisprudencia se ha inclinado por la segunda tesis.

Frente a la renuencia o rebeldía de la persona citada a declarar bajo juramento o si su declaración no es categórica (evasiva), el artículo 274 dispone que podrán imponerse al desobediente multas (que no excedan dos sueldos vitales) o arrestos (hasta de dos meses), determinado prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento.

6.2.2 Exhibición de la cosa.

2º La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar.

Aquí lo que se pretende es que haya una relación procesal útil, esto es, que tenga la virtud de producir el efecto que se está persiguiendo.

Cuando este artículo se refiere a la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar, cabe preguntarse si **estamos hablando de una cosa mueble o inmueble**. Para nosotros se trata de una cosa mueble, porque hay que tener en vista el artículo 275 inciso 2º que se refiere a cómo se cumple la medida y dada su redacción se trata de cosas muebles (“el lugar donde se encuentre”), además se trata de una acción real, por ejemplo, reivindicación de un automóvil.

En cuanto al **cumplimiento de esta medida prejudicial**, hay que estarse a lo que establece el artículo 275 C.P.C.:

La exhibición, en el caso del número 2º del artículo 273, se hará mostrando el objeto que deba exhibirse, o autorizando al interesado para que lo reconozca y dándole facilidades para ello, siempre que el objeto se encuentre en poder de la persona a quien se ordene la exhibición.

Si el objeto se halla en poder de terceros, cumplirá la persona a quien se ordene la exhibición, expresando el nombre y residencia de dichos terceros, o el lugar donde el objeto se encuentre.

- a) Si la cosa se encuentra en manos de la persona a quien se ordena la exhibición, ésta cumple mostrando el objeto o autorizando al interesado para que lo reconozca dándole las facilidades para ello.
- b) Si la cosa se encuentra en manos de terceros, dicha persona cumple indicando el nombre y la residencia de los terceros o señalando el lugar donde puede encontrarse el objeto.

Si la persona se rehúsa a hacer la exhibición, el artículo 276 señala las medidas de apremio que son las del artículo 274, esto es, multa o arresto, y se agrega el allanamiento del local donde se encuentre el objeto cuya exhibición se pide.

El artículo 282 se refiere a la situación que se produce cuando la persona a la que se le ha ordenado la exhibición dice **ser mero tenedor**; en este caso puede también ser obligado:

- a) A declarar bajo juramento el nombre y la residencia de la persona en cuyo nombre tiene la cosa,
- b) A exhibir el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito a que declare bajo juramento que carece de él.

Si se niega a practicar cualquiera de las diligencias anteriores operan los apremios del artículo 274 (multa, arresto, allanamiento).

6.2.3 Exhibición de antecedentes.

3º La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas.

Aquí se está frente a una enumeración no taxativa, ya que la disposición establece en su parte final “...u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas”.

Es importante analizar que la alusión a instrumentos públicos o privados es una distinción técnica y no vulgar. Son instrumentos públicos los que la ley califica como tales, que son los otorgados ante competente funcionario con las solemnidades legales; y por instrumento privado, lo que no son públicos. Estos últimos no son sinónimos de secretos o reservados.

Cuando la ley ordena la exhibición de instrumentos públicos o privados hay que analizar si esta exhibición es irrestricta o si tiene límites. Tratándose de instrumentos públicos la reserva no es nunca aplicable, por lo tanto, siempre deberán ser exhibidos.

En el caso de los instrumentos privados pueden o no ser reservados, dependiendo de su naturaleza. Nuestro legislador ha establecido como regla general que los instrumentos privados no son reservados, sino que se requiere de una disposición legal, o por lo menos una sistemática legal que les dé tal carácter. Esto se desprende de la redacción del artículo 273 N° 3.

El artículo 277 señala qué ocurre en caso de que la persona a quien incumba su cumplimiento desobedezca (siempre que existan en su poder los instrumentos o libros):

a) La persona pierde el derecho de hacerlos valer después en su propia defensa. Sin embargo hay dos excepciones, pudiendo hacerlos valer:

- i) si la otra parte los invoca en su defensa,
- ii) si justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes o porque se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición.

b) Por remisión del artículo 277 al artículo anterior (artículo 276) y este a su vez, al artículo 274 se aplican al rebelde los apremios que ya se han mencionado: multa de hasta dos sueldos vitales, arresto hasta por dos meses y allanamiento del local donde se halle el objeto cuya exhibición se pide.

En relación con el artículo 273 está el artículo 283 que es una disposición que se aplica cuando se realiza la exhibición y dice que si el actor lo exige se dejará en el proceso (expediente): a) copia de las piezas que se presenten o de su parte conducente y b) una razón de la clase y estado actual de los objetos exhibidos.

6.2.4 Libros de contabilidad.

4º Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio.

Es importante esta medida, porque tiene gran aplicación en juicios entre comerciantes y en operaciones de carácter mercantil.

La contabilidad como cuerpo es siempre reservada y solamente se puede solicitar la exhibición de determinadas partidas de la contabilidad, pudiendo ser objeto de controversia si se accede o no a la exhibición.

Si se ordena la exhibición y la persona se rehúsa, se aplican las siguientes sanciones:

- a) La sanción genérica que ya conocemos: multa, arresto y allanamiento (remisión del artículo 277 al 276 y éste al artículo 274).
- b) También por aplicación del artículo 277 el renuente no puede hacer valer los libros de contabilidad en su defensa, salvo las excepciones ya analizadas.
- c) Rigen los artículos 42 y 43 del Código de Comercio en virtud de los cuales si un comerciante se rehúsa a exhibir su contabilidad en la parte ordenada, se entenderá que los libros de contabilidad del otro comerciante producirán plena fe en contra del rebelde, siempre que éstos hayan sido llevados conforme a derecho (según las normas del Código de Comercio y tributarias).

6.2.5 Reconocimiento jurado de firma.

5º El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado.

Esta es una medida prejudicial propiamente tal, pero con características de medida prejudicial probatoria, porque efectivamente el reconocimiento, cuando se produce, trae consecuencias fácticas en contra de quien ha reconocido su firma. Este reconocimiento de firma debe referirse a instrumentos privados y no a instrumentos públicos, por cuantos éstos por su carácter producen plena fe sobre en cuanto a los hechos que en él se consignan.

En el reconocimiento jurado de firma, la persona respecto de la cual se decreta la medida prejudicial debe concurrir al tribunal y declarar bajo juramento si la firma que se le atribuye es o no suya. El artículo 62 C.P.C. recoge la fórmula del juramento ("Juráis por Dios...").

En cuanto a cómo se realiza esta diligencia, está regulado por el artículo 278 que se remite a las normas del juicio ejecutivo, específicamente al artículo 435. Si un acreedor no dispone poseer título ejecutivo, puede iniciar una gestión preparatoria con el objeto de otorgar tal calidad al instrumento.

El reconocimiento de firma puede ser:

- a) Expreso:** cuando el deudor o pretendido suscriptor del documento explícitamente reconoce la firma;
- b) Tácito:** cuando el deudor no concurre al llamado judicial o concurriendo da respuestas evasivas.

Es importante destacar que tratándose del reconocimiento jurado de firma, el deudor es citado sólo en una oportunidad, y al efecto se fija día y hora para la diligencia, que por ser la primera gestión se le notifica personalmente o por el artículo 44. Una vez notificado el pretendido deudor o suscriptor puede asumir diversas actitudes:

- a) Reconocer su firma (reconocimiento expreso);
- b) No concurrir o dar respuestas evasivas, caso en el cual se tiene por reconocida la firma (reconocimiento tácito);
- c) Negar la firma, en este caso fracasa la gestión.

¿Hay comisión de delito si el llamado a reconocer firma la niega?

La jurisprudencia en forma mayoritaria ha señalado que no hay comisión de delito, aunque se esté bajo juramento, al igual que en el caso de la confesión. Pero tratándose de títulos de crédito sí hay ilícito penal.

Es muy importante detenerse en el inciso final del artículo 273, porque señala que los cuatro primeros numerandos que contienen medidas prejudiciales, son de concesión facultativa, pudiendo el tribunal concederlas o no según las circunstancias. En cambio, la del N° 5 (reconocimiento de firma) es diligencia necesaria, así cada vez que se le solicite el tribunal debe ordenarla.

La diligencia expresada en el número 5° se decretará en todo caso, las de los otros cuatro sólo cuando, a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante pueda entrar en el juicio.

6.2.6 Constitución de apoderado.

El artículo 285 C.P.C. contiene una medida prejudicial propiamente tal que tendrá lugar cuando se dé la situación que prevé el artículo 284 inciso 1º, el cual señala que si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país podrá exigírsele como medida prejudicial que absuelva posiciones (medida prejudicial probatoria), pero también se puede solicitar que constituya en el lugar donde va a entablarse el juicio apoderado que le represente y responda por las costas y multas en que sea condenado, bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes.

Es importante relacionar el artículo 285 con el artículo 28 C.P.C., que señala la responsabilidad de los mandatarios judiciales (procuradores judiciales), en el sentido de que sólo responden por el pago de las costas procesales (no por las costas personales, multas, indemnizaciones), sin perjuicio de la responsabilidad que sobre ellas tenga el mandante. En el caso del artículo 285 el mandatario judicial constituido tiene una responsabilidad agravada, ya que debe responder por las costas y las multas.

Tema 7: Medidas Prejudiciales Probatorias.

Se encuentran reguladas en los artículos 281, 284 y 286 C.P.C.

7.1 Concepto.



Son las providencias, que debe o puede decretar el tribunal, a petición de parte, para hacer posible o facilitar a quien será demandante o demandado, la reunión antelada de pruebas, es decir, reunir ciertos y determinados antecedentes fácticos frente al riesgo de que las probanzas respectivas puedan desaparecer.

7.2 Análisis de las medida prejudiciales probatorias.

7.2.1 Inspección personal del tribunal, informe de peritos, certificado de ministro de fe.

El artículo 281 señala que *“Puede pedirse prejudicialmente la inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el mismo tribunal, o certificado del ministro de fe, cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer”*.

Este artículo señala tres medidas prejudiciales probatorias:

- i) Inspección personal del tribunal.
- ii) Informe de peritos.
- iii) Certificado de un ministro de fe.

7.2.1.1 Motivos para decretar estas medidas

Debe haber peligro inminente de un daño o perjuicio, o que se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer, por ejemplo, la designación de peritos para que establezcan la causa de la no germinación de las semillas.

7.2.1.2 Requisitos para llevarla a cabo

Para decretar estas diligencias y salvaguardar la bilateralidad de la audiencia, el artículo 281 ordena que previo al cumplimiento (ejecución) de la diligencia de que se trata, se dé conocimiento a la persona a quien se pretende demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que las decreta o donde deban ejecutarse. En los demás casos (no se encuentra en ninguna de aquellos lugares) se deberá proceder con intervención del defensor de ausentes (artículo 281 inciso 2º).

La notificación, al demandado o al defensor de ausentes, en su caso, debe ser personal o conforme al artículo 44, por tratarse de la primera resolución que se dicta en el procedimiento. El defensor de ausentes es un funcionario dentro de la administración de justicia, y se encuentra junto al defensor de obras pías y el defensor de menores. Normalmente tienen su oficio en el territorio jurisdiccional del juez de letras. En la vida práctica cumple este rol el defensor público que es un auxiliar de la administración de justicia regulado en los artículos 365 y siguientes del C.O.T.

7.2.1.3 Análisis de las distintas medidas prejudiciales probatorias

a) Inspección personal del tribunal. Este medio de prueba se analizará extensamente a propósito de los medios de prueba en particular, sin embargo, es menester señalar que produce plena prueba respecto de los hechos constatados por el tribunal.

b) Informe de peritos. En este caso hay una regla muy particular que la distingue de las formas tradicionales de designación de peritos, y es que los peritos, según la norma general, son designados por las partes, y en forma subsidiaria o a falta de acuerdo, por el tribunal. En este caso el tribunal derechamente designa al perito, indicando el objeto o materia del respectivo peritaje.

c) Certificado de un ministro de fe. La disposición no exige una determinada calidad del ministro de fe, por lo que puede tratarse de un notario, de un receptor judicial, de un secretario, etc.

El ministro de fe sólo puede certificar la veracidad de un hecho que le conste, pero no puede calificarlo jurídicamente.

En relación a la fuerza probatoria del certificado del ministro de fe se debe señalar que no produce plena prueba, sino que sólo constituye una presunción judicial (artículo 427).

Artículo 427. *Sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario.*

7.2.2 Absolución de posiciones.

La confesión es el reconocimiento de un hecho que produce consecuencias en contra del confesante, en otras palabras, que produce efectos perjudiciales para el que confiesa.

La confesión admite dos grandes criterios de clasificación.

a) Expresa, tácita o ficta.

b) Espontánea y provocada. La primera es el reconocimiento del hecho perjudicial que se realiza sin estímulo previo. La segunda, provocada, es la confesión denominada absolución de posiciones y consiste en llamar a la parte contraria a la presencia judicial a fin de que conteste una serie de preguntas que el otro litigante le plantea en pliego cerrado.

La absolución de posiciones, como medida prejudicial probatoria, está regulada en el artículo 284, que dispone que si se teme fundadamente que la persona a quien se va a demandar se ausente, en breve tiempo del país, se la puede llamar para que absuelva posiciones sobre hechos calificados previamente de conducentes por el tribunal. Calificada la conducencia de las preguntas, aquél sin ulterior recurso señala día y hora para que la diligencia se lleve a cabo.

Artículo 284 inciso 1º. *Si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, podrá exigírsele como medida prejudicial que absuelva posiciones sobre hechos calificados previamente de conducentes por el tribunal, el que sin ulterior recurso, señalará día y hora para la práctica de la diligencia.*

Si el emplazado no absuelve posiciones y se ausenta del territorio de la República dentro de los 30 días siguientes a la notificación, sin dejar mandatario con facultades bastantes para que absuelva posiciones, se le tendrá por confeso, durante el juicio, de las preguntas que se hayan planteado en forma asertiva (no interrogativa), salvo que se justifique suficientemente la ausencia sin haber cumplido la orden del tribunal.

Artículo 284 inciso 2º. *Si se ausenta dicha persona dentro de los treinta días subsiguientes al de la notificación sin absolver las posiciones, o sin dejar apoderado con autorización e instrucciones bastantes para hacerlo durante la secuela del juicio, se le dará por confeso en el curso de éste, salvo que aparezca suficientemente justificada la ausencia sin haber cumplido la orden del tribunal.*

Es importante señalar que las posiciones se acompañan en pliego abierto, cosa que no ocurre en la absolución de posiciones tradicional y esto porque el tribunal previamente debe declarar la conducencia de las preguntas, luego se cierra el pliego y lo mantiene en reserva hasta la audiencia.

7.2.3 Declaración de testigos

Como regla general la declaración de testigos es una medida probatoria, pero aquí está contemplada como medida prejudicial probatoria, en consecuencia, antes de la demanda se puede solicitar el examen de aquellos testigos que por razón de impedimentos graves, haya fundado temor de que no puedan recibirse oportunamente, por ejemplo, el testigo que está gravemente enfermo.

El que solicita la diligencia, indicará los puntos sobre los que pretende que declaren los testigos y el tribunal calificará su conducencia.

Artículo 286 inciso 1º. *Se podrá, asimismo, solicitar antes de la demanda el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones, por razón de impedimentos graves, haya fundado temor de que no puedan recibirse oportunamente. Las declaraciones versarán sobre los puntos que indique el actor, calificados de conducentes por el tribunal.*



El artículo 286 inciso 2º establece que en función de la bilateralidad de la audiencia, la diligencia se debe poner en conocimiento a la parte a quien se va a demandar, siempre que se encuentre en el lugar donde se expidió la orden o donde deba tomarse la declaración, si no fuere así se procederá con intervención del defensor de

ausentes.

Tema 8: Tramitación de las Medidas Prejudiciales propiamente tales y Probatorias.

8.1 Requisitos que debe cumplir quien solicita una medida prejudicial.

El artículo 287 indica que para decretar tales medidas deberá, el que las solicite, señalar *la acción que se propone deducir* y exponer someramente sus *fundamentos*, además, por lógica tendrá que indicarse *a quién se demandará*.

8.2 Tramitación propiamente tal.

Presentada la solicitud, y en virtud de los antecedentes expuestos, como regla general el tribunal resuelve de plano, es decir, sin previa audiencia de la parte contra quien se pide, salvo en los casos en que expresamente se exige su intervención (artículo 289). En todo caso el tribunal puede ordenar diligencias para acreditar los motivos que justifican la medida.

Artículo 289. *Las diligencias expresadas en este Título pueden decretarse sin audiencia de la persona contra quien se piden, salvo los casos en que expresamente se exige su intervención.*

Luego, se debe notificar la resolución que resuelve la petición de la medida prejudicial a la contraparte en los casos en que expresamente se exige su intervención (artículo 289), lo que sucede cuando la medida se llevará a cabo con terceros y no con el demandado.

La resolución que decreta una medida prejudicial es un auto, en consecuencia, es esencialmente modificable por el propio tribunal que lo dictó, así la parte contraria (esto es la persona a quien perjudicaría su realización) puede oponerse mediante el recurso de reposición. La resolución que

resuelve la reposición es apelable en el solo efecto devolutivo, apelación que debe interponerse en forma subsidiaria al recurso de reposición.

Como regla general las medidas prejudiciales corresponde solicitarlas a quien va a ser demandante. Sin embargo, a título excepcional y sólo respecto de algunas medidas prejudiciales, el legislador permite a quien tema fundadamente ser demandado solicitar su concesión para así preparar su defensa (artículo 288). El futuro demandado podrá solicitar las medidas señaladas en los artículos 281, 284 y 286, es decir, todas las medidas prejudiciales probatorias, y además, la medida prejudicial propiamente tal del Nº 5 del artículo 273 (reconocimiento de firma) que también tiene carácter de medida prejudicial probatoria.

Tema 9: Medidas Precautorias.

Las medidas precautorias pueden ser **propriadamente tales** o **prejudiciales precautorias**. La diferencia entre ambas radica **en que las primeras proceden después de trabada la relación procesal, en cambio, las prejudiciales precautorias antes de la demanda o antes de su notificación.**

Las medidas precautorias se inscriben, a su vez, en un tema de mayor envergadura que se denomina **“aseguramiento de los juicios”** o **“medidas de aseguramiento”**. Estas medidas dicen específica relación con la actividad jurisdiccional, porque ésta persigue la tutela definitiva de un derecho, que derivará de la sentencia firme o ejecutoriada que acoja la respectiva pretensión. Pero, frente al hecho de que esta tutela definitiva no pueda producirse, ya sea por circunstancias sobrevinientes, ya sea por mala fe del demandado o por cualquier otra causa, el legislador ha contemplado la posibilidad de una tutela provisional, o sea, adoptar ciertos y determinados resguardos durante el juicio, para efectivamente lograr que la tutela definitiva se convierta en realidad.

Hay que hacer notar que tutela provisional son resguardos que se adoptan para hacer posible la tutela definitiva, pero estos resguardos no son por regla general en nuestro derecho, el acceder provisionalmente a la pretensión.

Nuestra forma de tutela provisional significa, como regla muy general, no innovar en una determinada situación, es decir, **mantener un status quo** para hacer posible la tutela definitiva, así por ejemplo, si se va a iniciar una acción reivindicatoria y se quiere asegurar que, cuando se obtenga sentencia que ordene la reivindicación del bien, dicho bien esté en el patrimonio del demandado, se podrá solicitar la medida de tutela de prohibición de gravar o enajenar el bien o la prohibición de celebrar actos o contratos a su respecto.

Cuando se dice de acceder provisionalmente a la pretensión, la situación es diferente, porque ahí se innova, se cambia la situación existente en forma provisoria, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en forma definitiva.

Como ya dijimos en nuestra legislación la tutela cautelar es solamente la no modificación de una determinada situación de hecho, o sea, es la mantención de un *status quo*; sin embargo, hay algunos ejemplos muy escasos de la concesión o aceptación provisional de la pretensión, y uno de los ejemplos está precisamente en el juicio sumario, donde frente a la rebeldía del demandado el tribunal puede acceder provisoriamente a la demanda, con lo cual se acepta provisoriamente la pretensión, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.



9.1 Concepto de medidas precautorias.

Las medidas cautelares o medidas precautorias son *providencias que puede o debe adoptar el tribunal, a petición de parte, para hacer posible al demandante la eventual y posterior tutela definitiva, es decir, para asegurar el resultado de la acción deducida.*

a) La medida cautelar siempre debe emanar de una resolución judicial, por eso son “providencias del tribunal”. En cuanto a su naturaleza jurídica, esta resolución es un auto por cuanto es esencialmente modificable si cambian las circunstancias.

b) Sólo se adoptan a petición de parte (principio de la pasividad).

c) La regla general es que estas medidas sean de adopción facultativa, o sea, el tribunal es libre para decretar o no medidas cautelares, sin embargo en ciertos procedimientos las medidas cautelares necesariamente deben adoptarse, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, donde si se reúnen los requisitos legales se inicia la ejecución, comenzando el cuaderno de apremio con el embargo, otro ejemplo se encuentra en la ley de quiebras, donde si ésta es declarada se decretan medidas cautelares necesarias, que se traducen en la incautación de todos los bienes del fallido.

d) Su objetivo es hacer posible la eventual y posterior tutela definitiva. En el caso de las medidas prejudiciales precautorias, su objetivo específico es hacer posible al demandante la posterior tutela definitiva, y en el caso de las precautorias propiamente tales, asegurar el resultado de la acción deducida. De esto arrancan dos consecuencias: i) Según sea la tutela perseguida, será también la medida precautoria, de ahí que las medidas precautorias no tengan una numeración taxativa, pues en función del contenido de la pretensión, que no tiene límites en cuanto a su forma, será también el contenido de la medida cautelar solicitada. Esto es una diferencia con las medidas prejudiciales propiamente tales o probatorias; i) Las medidas precautorias como sólo persiguen la tutela definitiva, deben estar circunscritas a los bienes estrictamente necesarios para obtener dicha tutela (no son un castigo anticipado).

9.2 Clasificación de las medidas cautelares.

Se pueden clasificar en dos grandes categorías:

a) Medidas cautelares en procedimiento autónomo. *Son aquellas que por su naturaleza provocan o dan lugar a un procedimiento que es esencialmente tutelar.* Son ejemplos de estas medidas cautelares el juicio de quiebra, la guarda y aposición de sellos, los recursos de protección y amparo, la denuncia de obra ruinosa.

b) Medidas cautelares en procedimiento dependiente. *Son aquellas que se solicitan y se conceden como consecuencia o adheridas a otro procedimiento.*

Dentro de las medidas cautelares en procedimiento dependiente, algunas son *necesarias* y otras son *eventuales*. La regla general es que sean eventuales, quedando entregada al tribunal su concesión o su denegatoria. Sin embargo, hay medidas cautelares que son necesarias, como ocurre con el embargo en el juicio ejecutivo por obligación de dar, que es dependiente del juicio ejecutivo y el juez, reuniéndose los requisitos legales, necesariamente debe decretarlo.

9.3 Características de las medidas cautelares en procedimiento dependiente.

a) Son de adopción eventual según las características o situaciones concretas de que se trate, siendo el tribunal libre para concederlas o denegarlas.

b) Las medidas precautorias no están taxativamente enumeradas, sino que dependerán de la naturaleza de la acción.

Artículo 298. *Las medidas de que trata este Título se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio, y para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley...*

Artículo 300. *Estas providencias no excluyen las demás que autorizan las leyes.*

c) Son providencias que adopta el tribunal y que en materia civil siempre adopta a petición de parte, nunca de oficio.

d) Tienen por finalidad hacer posible la eventual y posterior tutela definitiva (asegurar el resultado de la acción deducida).

e) Las medidas precautorias son admisibles en cualquier juicio no sólo en el juicio ordinario de mayor cuantía.

f) Se conceden o deniegan a través de un procedimiento sumarísimo de cognición concentrada (de plano).

g) Para su concesión se requiere verosimilitud o plausibilidad de la pretensión invocada. Se requiere que el tribunal en un examen *prima facie* concluya que efectivamente la pretensión que se está haciendo valer ante él está revestida de fundamento plausible (“humo de buen derecho”).

h) Las medidas cautelares son esencialmente provisorias, y en consecuencia desde el punto de vista procesal la resolución que las decreta es un auto (resolución que resuelve una cuestión accesoria sin establecer derechos permanentes a favor de las partes). En consecuencia, la mantención o alzamiento de esta medida depende de varios factores:

- i) que se mantenga o desaparezca el peligro o riesgo que se ha procurado evitar, por lo tanto, si se otorga caución suficiente la medida debe alzarse.
- ii) que se mantenga o se haga clara la plausibilidad de la pretensión reclamada, por ejemplo, si se concede una medida precautoria y en el curso del juicio, terminado que sea el término probatorio, se hace claro que la pretensión es descabellada, en cualquier momento podrá alzarse esta medida, y viceversa, si en un comienzo la medida precautoria fue denegada porque no se veía clara la plausibilidad de la pretensión, puede ser que en el transcurso del juicio se acredite dicha plausibilidad y se conceda la medida.
- iii) Deben limitarse a los bienes estrictamente necesarios para hacer efectiva la tutela de la pretensión (artículo 298 primera parte).

9.4 Oportunidad para pedir las medidas precautorias.

a) Tratándose de medidas precautorias propiamente tales pueden pedirse en cualquier estado del juicio, aún cuando no esté contestada la demanda, pero el demandado debe estar debidamente emplazado.

b) En el caso de las medidas prejudiciales precautorias deben solicitarse antes de que la relación procesal esté trabada, es decir, antes de presentar la demanda (regla general) o antes de su notificación.

El artículo 290 en su inciso 1º indica que pueden pedirse “una o más medidas precautorias”, en consecuencia, pueden solicitarse todas aquellas que sean necesarias para lograr la tutela definitiva.

En relación a quién puede solicitarlas, sólo puede hacerlo el demandante o futuro demandante.

9.5 Requisitos o limitaciones de las medidas precautorias.

Esta materia tiene mucha importancia porque las medidas precautorias son esencialmente funcionales, ya que tienen por objeto asegurar el resultado de la acción deducida.

Los requisitos copulativos para su solicitud son (artículo 298):

a) Que existan motivos graves y calificados que hagan necesaria su concesión, por lo tanto, para que el tribunal las decrete es menester que en un examen *prima facie* llegue a la conclusión de que la pretensión del demandante esté revestida de fundamento plausible (humo de buen derecho). En concordancia con la funcionalidad de las medidas cautelares éstas deben limitarse a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio.

b) Deben acompañarse comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama.

c) El artículo 298 en su parte final dispone que *“Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen”*. Esta norma ha originado dificultades de interpretación, teniendo dos lecturas posibles:

i) La caución es facultativa cuando se trata de medidas no expresamente autorizadas y no se exigiría tratándose de medidas previstas por la ley;

ii) La caución es necesaria cuando se trata de medidas no expresamente autorizadas, y facultativa en el resto de los casos.

La interpretación que normalmente siguen los tribunales es que la caución es eventual sólo cuando se trata de medidas no expresamente autorizadas, y en los demás casos, cuando se trata de medidas expresamente autorizadas, no es lícito exigir la caución.

Lo que sí es importante destacar es que tratándose de medidas prejudiciales precautorias debe rendirse fianza u otra garantía suficiente para responder por los perjuicios que se originen y las multas que se impongan (artículo 279 N° 2).

La **no taxatividad** de las medidas precautorias arranca de dos disposiciones, el artículo 298 que señala expresamente *“y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley”*, y el artículo 300 que dispone *“Estas providencias no excluyen las demás que autorizan las leyes”*.

9.5.1 Excepción a la regla de acompañar los comprobantes.

La regla general de acompañar comprobantes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama y la plausibilidad de la respectiva presunción tiene una muy calificada excepción prevista en el artículo 299, en virtud de la cual en casos graves y urgentes pueden los tribunales conceder medidas precautorias sin que se acompañen dichos comprobantes. Pero la medida así concedida no puede exceder de 10 días, plazo en el cual el demandante debe acompañarlos.

En todo caso cuando el tribunal concede así la medida, exigirá siempre caución para responder por los perjuicios que resulten.

Artículo 299. *“En casos graves y urgentes podrán los tribunales conceder las medidas precautorias de que trata este Título, aun cuando falten los comprobantes requeridos, por un término que no exceda de diez días, exigiendo caución para responder por los perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán de hecho canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280”*.

En la parte final de este artículo hay una remisión al artículo 280 que está contenido en el título de las medidas prejudiciales y específicamente se refiere a las medidas prejudiciales precautorias, se debe entender esta remisión de la siguiente forma, si en el plazo de 10 días quien obtuvo la medida no acompaña los comprobantes o el tribunal estima que dichos comprobantes no son suficientes, la medida queda de hecho cancelada y se entenderá doloso el proceder del demandante y quedará sujeto a las

indemnizaciones correspondientes. Aquí se trata de dolo civil, pero el dolo civil en este caso es constitutivo de delito civil, lo que sustancialmente agrava la responsabilidad de quien lo cometió.

9.6 Tramitación de las medidas precautorias propiamente tales.

Las medidas precautorias se tramitan en cuerda, cuaderno o ramo separado, es decir, todo lo que se actúe en torno a las medidas precautorias constituye un cuaderno adicional respecto del expediente correspondiente.

La tramitación propiamente tal se encuentra regulada en el artículo 302, norma ha dado origen a dos interpretaciones:

a) Histórica. Arranca de una interpretación equivocada del artículo 302 C.P.C. que se encabeza con la frase *“El incidente a que den lugar las medidas decretadas de este título se tramitara en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada”*. Se señalaba que las medidas precautorias debían tramitarse como incidente, en consecuencia, frente a la petición de una medida precautoria debe concederse traslado a la parte contraria, evacuado éste se recibiría o no el incidente a prueba y posteriormente se fallaría dictando el auto correspondiente, concediendo o denegando la medida.

Esta interpretación chocaba con la realidad, pues las medidas precautorias normalmente están rodeadas de una situación de urgencia para precaver un mal que se teme, y en consecuencia, bien podría ocurrir que mientras se tramitaba el incidente se produjera el evento que se temía, por ejemplo, que se enajenara el bien raíz o se destruyera el bien o el deudor cayera en insolvencia. Entonces para prevenir esta situación, los que sustentaban esta posición dijeron que se tramitaba como incidente pero concediéndose entre tanto, es decir, sin perjuicio de lo que se resolviera en definitiva.

b) Moderna. La doctrina anterior ha sido abandonada y hoy en día, las medidas precautorias se conceden o se deniegan de plano, sin bilateralidad de la audiencia. Pero dado que es necesario conciliar esta posición con el inciso 1º artículo 302, una vez concedida que sea la medida, los afectados pueden oponerse por la vía del recurso de reposición, apelando en subsidio, y ahí tiene lugar el incidente del artículo 302 el que sería eventual.

Concedida que sea la medida, la regla general es que debe ser notificada al afectado y posteriormente se cumple. A esta conclusión se llega por la aplicación del artículo 38 C.P.C. que señala que las resoluciones judiciales sólo producen efecto a partir de su notificación. En principio sería suficiente la notificación por el estado diario, sin embargo, el artículo 302 inciso final dispone que si el tribunal lo ordena dicha notificación debe practicarse por cédula.

No obstante, el legislador se planteó la posibilidad que durante el lapso que media entre la resolución y su posterior notificación podría ocurrir el riesgo o sobrevenir el hecho que se temía y autorizó a título excepcional que la medida pudiera llevarse a efecto antes de la notificación a la persona afectada, pero siempre que existan razones graves para ello lo ordene.

Para que esta situación no se mantenga, el legislador fijó un plazo de 5 días para notificar la medida que se cumplió entretanto, si no se notifica dentro de ese plazo la medida queda sin efecto de pleno derecho. Sin embargo, el tribunal por motivos fundados puede ampliar este plazo (artículo 302 inciso 2º).

Cabe hacer notar que el plazo de 5 días para notificar es aplicable sólo a las medidas precautorias propiamente tales y no a las prejudiciales precautorias, porque en éstas el demandante debe formular formal demanda dentro del plazo de 10 días.

Artículo 302. *El incidente a que den lugar las medidas de que trata este Título se tramitará en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada.*

Podrán, sin embargo, llevarse a efecto dichas medidas antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El tribunal podrá ampliar este plazo por motivos fundados.

La notificación a que se refiere este artículo podrá hacerse por cédula, si el tribunal así lo ordena.

9.7 Paralelo entre las medidas precautorias y las medidas prejudiciales precautorias.

a) Las medidas precautorias sólo pueden solicitarse a partir de la notificación de la demanda, es decir, ya existiendo juicio, en cambio, las medidas prejudiciales precautorias deben solicitarse antes de la notificación de la demanda o antes de la presentación de la demanda (artículo 290 inciso 1º en relación con el artículo 273 inciso 1º);

b) Tanto las medidas precautorias como las prejudiciales precautorias no están taxativamente numeradas por la ley, en consecuencia, se puede solicitar cualquier medida que mire a asegurar el resultado de la acción deducida (conclusión a la que se llega porque hay una remisión sin reserva del artículo 279 al Título V del Libro II en el cual se encuentran los artículos 298 y 300).

c) A diferencia de lo que ocurre con las medidas precautorias donde hubo discusión en cuanto a su tramitación, en las medidas prejudiciales precautorias no hay discusión, pues ellas se conceden o se deniegan de plano.

9.8 Requisitos para la concesión de una medida prejudicial precautoria.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 279 son requisitos para la concesión de una medida prejudicial precautoria:

a) Que existan motivos graves y calificados que hagan necesaria su concesión

b) Que el demandante determine el monto de los bienes sobre los que debe recaer la medida, es decir, debe precisar exhaustivamente cuál es la parte del patrimonio que queda afecto a la medida prejudicial precautoria, pues no es posible, como regla muy general, el congelamiento de todo el patrimonio de una persona.

c) Quien solicita la medida, si ésta es concedida, rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal, para responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan.

El tribunal frente a la solicitud, provee: “previamente constitúyase la caución ofrecida”; y calificará si la caución ofrecida es suficiente. Si es fianza, que es la regla general, se constituye ante el Secretario del tribunal, que para este efecto lleva un libro especial: “libro de fianzas”, donde el fiador comparece como tal acreditando su solvencia.

d) Además, hay que cumplir con los requisitos del artículo 287 común a todas las medidas prejudiciales: *expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos.*

9.9 Actitudes del tribunal frente a la solicitud de una medida prejudicial precautoria.

a) Si la medida es denegada, se pueden deducir los recursos procesales correspondientes, esto es, reposición apelando en subsidio. Teóricamente, el tribunal conserva competencia para conocer de la cuestión principal, o sea, la demanda tendrá que presentarse ante el tribunal que conoció de la medida aunque ésta haya sido denegada.

b) Si la medida es concedida surge para el demandante la carga procesal de presentar formal demanda dentro de plazo de 10 días y solicitar que se mantengan las medidas decretadas como precautorias propiamente tales. El plazo puede ampliarse hasta por 30 días por motivos fundados (artículo 280 inciso 1°).

Se cumple con la carga procesal por el sólo hecho de presentar la demanda dentro del plazo fijado, no es necesaria su notificación.

Cuando se pide que se mantenga la medida como precautoria es recomendable hacerlo en dos presentaciones: i) en un otrosí de la demanda; ii) en escrito separado, que quedará agregado al cuaderno de medidas prejudiciales precautorias, que se mantendrá ahora como cuaderno de medidas precautorias (artículo 280 inciso 2°).

El tribunal frente a la solicitud de que se mantenga la medida prejudicial como precautoria, puede acceder o no, si accede a ella queda concedida como precautoria, sin perjuicio, de las posibles oposiciones.

Si el futuro demandante no presenta su demanda dentro del plazo fijado, o si presentando la demanda no solicita la mantención de la medida prejudicial como precautoria, o si solicitando la mantención el tribunal la deniega, se considera que su actuación ha sido dolosa y responde de los perjuicios causados (artículo 280).

La apelación cuando se deduce, se concede en el sólo efecto devolutivo siguiendo así la regla general de la tramitación de los incidentes (Nº 2 artículo 194 C.P.C.).

9.10 Análisis de las medidas precautorias.

9.10.1 Artículo 290 Nº 1. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda.

En esta medida intervienen tres personas: i) el demandante que pide el secuestro; ii) el demandado que será objeto del secuestro de ciertos y determinados bienes, y iii) el secuestre, que es la persona que ejerce el cargo de cuidado de cierto bien, y que tiene las mismas facultades del depositario.

Según el **artículo 291** habrá lugar al secuestro:

- a) En el caso del artículo 901 C.C., que se refiere a la acción reivindicatoria sobre una cosa mueble.
- b) *Cuando se entablen otras acciones con relación a cosa mueble determinada y haya motivo de temer que se pierda o deteriore en manos de la persona que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder.* Aquí no se trata de una acción real contra el poseedor, sino de una acción que puede ser personal en contra del mero tenedor, por ejemplo, cuando se pide la restitución de una cosa (mueble) dada en arrendamiento, invocando el término del contrato.

Es importante el artículo 292 porque señala que al secuestro le son aplicables las normas del párrafo 2º del Título I del Libro III contempladas en relación al depositario de los bienes embargados.

El depositario se convierte en administrador de los bienes embargados y hay toda una mecánica que contempla cómo se realiza esa administración, normativa que es aplicable también al secuestro.

Es importante tener presente que las medidas cautelares no dan preferencia al acreedor, ergo si se declara el secuestro o la retención de bienes, el acreedor no es preferente respecto de esos bienes, en otras palabras, no se entiende que los bienes están constituidos en prenda, sino que sigue en su calidad de acreedor de acuerdo a los títulos respectivos. Esto es una diferencia sustancial con otras instituciones también del procedimiento civil, como la declaración del derecho legal de retención, ya que cuando éste se declara, la persona que obtiene esta declaración se la considera acreedor preferente, sea prendario o hipotecario según la naturaleza del respectivo bien retenido.

9.10.2 Artículo 290 Nº 2. El nombramiento de uno o más interventores.

El artículo 293 reglamenta las hipótesis en que tiene lugar el nombramiento de interventor.

“Hay lugar al nombramiento de interventor:

1º En el caso del inciso 2º del artículo 902 del Código Civil;

Esta disposición se refiere a la acción reivindicatoria (dominio u otro derecho real) sobre inmuebles señalando que *el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar todo deterioro de la cosa, y de los muebles y semovientes anexos a ella y comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo, o las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía.*

Aquí hay una gran diferencia con el secuestro, ya que el interventor, como regla general no es administrador de las cosas intervenidas, en tanto que el secuestro, precisamente por la mención que se hace a las reglas del depositario en el juicio ejecutivo, sí es administrador. Esto se explica porque si se intenta una acción reivindicatoria sobre un inmueble, todavía hay mucho que discutir por delante, ya que no por el hecho que la acción tenga plausibilidad el poseedor va a perder la administración del bien, sino que solamente queda sujeto a intervención.

2º En el del que reclama una herencia ocupada por otro, si hay el justo motivo de temor que el citado inciso expresa;

En este caso se está regulando la posibilidad del interventor cuando se entable la acción de petición de herencia, ésta al igual que la acción reivindicatoria, es una acción real, y pretende quien la inicia que se reconozca su calidad de heredero respecto de otro que aparentemente la ostenta.

Si las circunstancias hacen que se tema de la preservación de los bienes hereditarios o las facultades del demandado no ofrecen suficiente garantía, es posible designar interventor.

3º En el del comunero o socio que demanda la cosa común, o que pide cuentas al comunero o socio que administra;

Aquí hay una pequeña impropiedad en el lenguaje jurídico, pues no se puede demandar la cosa común, sino cuotas sobre la cosa común; y en el caso de la sociedad la cosa no es común, sino de la sociedad.

4º Siempre que haya justo motivo de temer que se destruya o deteriore la cosa sobre que versa el juicio, o que los derechos del demandante puedan quedar burlados;

Esta es una situación de carácter genérico, por cuanto siempre que haya una situación de peligro o de temor debidamente justificado se puede, naturalmente, designar interventor.

5º En los demás casos expresamente señalados por las leyes”.

En relación con este número, es necesario señalar que en la práctica no encontramos ningún caso.

En cuanto **a las facultades del interventor judicial** hay que señalar que no es administrador de los bienes sujetos a intervención, sino que es “un mirón y acusete” (Darío Benavente), ya que es un intruso que está dedicado a mirar como se administran los bienes, a llevar cuenta de esa administración y dar noticia al juez de cualquier irregularidad en la administración.

Las facultades del interventor se encuentran señaladas en el artículo 294 incisos 1º y 2º:

- *Llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado.*
- *Dar al interesado o al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la administración de dichos bienes, caso en el cual podrá decretarse el depósito y retención de los productos líquidos en un establecimiento de crédito o en poder de la persona que el tribunal designe, sin perjuicio de las otras medidas más rigurosas que el tribunal estime necesario adoptar.*

El artículo 294 al pie de página hace referencia al artículo 507 Código Orgánico de Tribunales, la que debe entenderse hecha al artículo 517, que señala que cada vez que el legislador ordena que bienes sean depositados en un establecimiento de crédito, se cumple con esta obligación depositándolos en el Banco del Estado de Chile a la orden del tribunal.

9.10.3 Artículo 290 N° 3. La retención de bienes determinados.

En la retención de bienes también intervienen tres personas, el demandante, el demandado y el retencionista, que es la persona encargada de hacer efectiva la retención.

Como lo señala el artículo 295 la retención puede recaer sobre dineros o cosas muebles, y el retencionista puede ser el propio demandante, el demandado o un tercero.

Es curioso que la retención pueda decretarse en manos del propio demandado, y cabe preguntarse qué sentido tendría esta medida, sin embargo, se debe tener presente que, en primer lugar, se limita la facultad de disposición, y en segundo lugar, eventualmente pueden surgir responsabilidades penales. Si



el demandado retencionista desobedece la orden de retención puede cometer el delito de desacato, que es el desobedecimiento de una orden del tribunal.

Los bienes que pueden ser objeto de retención son los siguientes:

- a) Los bienes que son materia del juicio;
- b) Otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procurará ocultarlos.
- c) En los demás casos determinados por la ley.

Artículo 295. *La retención de dineros o cosas muebles podrá hacerse en poder del mismo demandante, del demandado o de un tercero, con relación a los bienes que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía, o haya motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes, y en los demás casos determinados por la ley.*

Podrá el tribunal ordenar que los valores retenidos se trasladen a un establecimiento de crédito o de la persona que el tribunal designe cuando lo estime conveniente para la seguridad de dichos valores.

Se desprende de esta norma que los tribunales deben ser más liberales para otorgar la retención cuando se refiere a bienes materia del juicio, pero en caso contrario, se deben acreditar un conjunto de circunstancias que hagan particularmente riesgosa la situación.

El inciso final del artículo 295, también señala que los valores retenidos (dineros) deben trasladarse a un establecimiento de crédito (BancoEstado) o a la persona específica que el tribunal designe.

9.10.4 Artículo 290 N° 4. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

Esta medida precautoria no versa sólo sobre la prohibición de gravar o enajenar bienes determinados, sino que es más amplia ya que comprende también la prohibición de celebrar actos o contratos. Si solamente se tratará de la primera hipótesis bien podría la persona afecta a la medida arrendar el bien, porque eso no es gravar ni enajenar, pero dada la amplitud de la norma también se comprende la prohibición de darlo en arrendamiento.

El artículo 296 señala que puede decretarse la medida con relación a los bienes materia del juicio u otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. Como ya se señaló precedentemente, el tribunal tratándose de bienes materia del juicio ha de tener un criterio más laxo, que tratándose de otros bienes del demandado.

El artículo 296 en su inciso 2º señala una remisión muy importante al artículo 1464 N° 4 del C.C., artículo que señala que hay objeto ilícito en la enajenación de los bienes cuya propiedad se litiga. En consecuencia, teniendo en cuenta sólo la disposición del C.C. podría concluirse que por la sola circunstancia de haber litigio respecto de un determinado bien, hay objeto ilícito en su enajenación. Sin embargo esta norma se encuentra fundamentalmente modificada por el inciso 2º artículo 296, ya que para que se produzca el efecto del objeto ilícito no basta que se litigue sobre la propiedad de la cosa, sino que es necesario que se haya decretado judicialmente a su respecto prohibición de celebrar actos o contratos.

Artículo 296. *La prohibición de celebrar actos o contratos podrá decretarse con relación a los bienes que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio.*

Para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el número 4° del artículo 1464 del Código Civil, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos.

➡ **Oponibilidad de la medida**

La oponibilidad es el efecto que produce la medida precautoria respecto de terceros.

Nuestra legislación protege al tercero de buena fe y, en consecuencia, si se decreta una medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos y el tercero lo ignora, el contrato es válido.

Consciente el legislador de esta situación, la regula particularmente en el artículo 297, y al respecto distingue: oponibilidad tratándose de bienes raíces y oponibilidad tratándose de bienes muebles.

Cuando se trata de bienes raíces, la medida es oponible respecto de terceros sólo a partir de su inscripción en el registro conservatorio respectivo (inciso 1°). Conforme al artículo 53 N° 3 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, estas prohibiciones cuando se refieren a inmuebles, son de aquellos títulos que **pueden** inscribirse.

Por su parte, tratándose de bienes muebles, como por regla general no están sujetos a registros conservatorios, salvo algunos como los automóviles, la prohibición produce efectos respecto de terceros cuando éstos tengan conocimiento de la medida decretada al tiempo del contrato. Pero respecto del demandado, la medida siempre produce efecto, y será responsable de fraude si procede a sabiendas (además, como desobedece una resolución judicial es responsable del delito de desacato).

Unidad 3: Juicio Ordinario de Mayor Cuantía.

Tema 1: Características.

- a) Es un procedimiento de carácter netamente civil, por cuanto la pretensión es propiamente civil.
- b) Es un procedimiento contencioso, es decir, es de su esencia la contienda, conflicto o litigio entre partes.
- c) Desde el punto de vista de la pretensión, el juicio ordinario de mayor cuantía puede ser declarativo, si la pretensión se satisface por la simple declaración que despeja una situación jurídica determinada; puede ser constitutiva, si se pretende la creación de un estado jurídico nuevo y; será de condena, si el actor quiere que el demandado sea puesto en situación de deudor de una obligación de dar, hacer o no hacer.
- d) El juicio ordinario tiene un doble carácter supletorio. En primer lugar, como se trata de un procedimiento de pleno desarrollo se aplica siempre que no haya ley o norma especial, dicho de otra manera los procedimientos especiales o distintos del juicio ordinario de mayor cuantía se aplican sólo cuando hay norma particular. En segundo lugar, el juicio ordinario es supletorio en función de sus trámites en particular, por ejemplo, en muchos procedimientos especiales no hay normas particulares sobre el examen de los testigos o sobre la manera de provocar la confesión, en consecuencia, se aplican las reglas contenidas en el juicio ordinario.

Tema 2: Etapas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía.

2.1 Etapa de medidas prejudiciales.

Es típicamente una etapa eventual.

Como se señaló en el capítulo anterior las medidas prejudiciales pueden ser propiamente tales, precautorias y probatorias.

2.2 Etapa de discusión.

Está normalmente compuesta por cuatro escritos fundamentales: demanda, contestación, réplica y dúplica. Estos escritos pueden aumentar en uno si sobreviene reconvención, en cuyo evento se van alternando los escritos de doble contenido agregando al final el escrito de dúplica de reconvención.

La discusión es una etapa necesaria, ya que en todo juicio ordinario de mayor cuantía debe haber discusión, sin embargo, estos trámites pueden tenerse por evacuados en rebeldía si la parte no los evacúa dentro de plazo. En todo caso, la rebeldía de una de las partes, no exime a la otra de realizar el trámite de que se trata, por ejemplo, si la demanda se tiene por contestada en rebeldía subsistirá para el demandante la necesidad de replicar.

Dentro de este período, puede surgir también un período de excepciones dilatorias, que no tienen por objeto dilatar el juicio aunque en el hecho y en la práctica puedan tener esta consecuencia, sino que persiguen la constitución de una relación procesal válida y eficaz.

2.3 Etapa de conciliación.

Esta materia se encuentra regulada en los artículos 262 y ss., como regla general, es una etapa necesaria. Sin embargo, no es necesaria en ciertos y determinados procedimientos e incluso en algunos procedimientos el llamado a conciliación está prohibido.

Tiene lugar una vez terminado que sea el período de discusión, debiendo el tribunal llamar a las partes para intentar una conciliación, sea total o parcial.

2.4 Etapa de prueba.

Tiene una enorme importancia, porque los juicios se desarrollan en torno a los hechos de la causa y la normativa aplicable. Los hechos de la causa ocurren fuera y antes del proceso, en consecuencia, hay que revelarlos dentro de éste, mediante los distintos medios probatorios señalados por el legislador.

El período de prueba, es un período eventual porque dos son las circunstancias en virtud de las cuales puede no producirse: a) que no existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, esto ocurrirá, por ejemplo, cuando las partes están de acuerdo en los hechos y el conflicto es puramente de derecho; b) no obstante haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, las partes de común acuerdo pueden resolver no abrir el término probatorio y pedir que derechamente se omita esta etapa.

2.5 Etapa de discusión sobre la prueba

Es un período eventual denominado “término de observaciones a la prueba” (en lenguaje arcaico se llamaba “los alegatos de bien probado”). Es eventual porque sólo se abrirá cuando ha mediado prueba.

2.6 Etapa de fallo.

En el juicio ordinario de mayor cuantía se inicia con un trámite esencial, la citación para oír sentencia, que es una resolución que en forma simple dice “cítese a las partes a oír sentencia”. Esta citación no obliga a nadie a concurrir a algún lugar, sino que solamente tiene la virtud de cerrar definitivamente el debate en la instancia respectiva, por ende ya no se pueden rendir probanzas, salvo las calificadas excepciones legales.

Esta etapa termina con la dictación del fallo respectivo, que es una sentencia definitiva por cuanto pone fin a la instancia resolviendo el asunto controvertido.

La etapa de fallo también es eventual, porque podría haber mediado otra forma de resolución de conflicto (soluciones autocompositivas).

2.7 Etapa de impugnación del fallo.

En esta etapa tienen lugar los recursos procesales, cuya finalidad es impugnar resoluciones judiciales.

Las vías de impugnación, vistas en su sentido genérico, son fundamentalmente dos:

a) Recursos de nulidad (recurso de casación en la forma y en el fondo). Estos recursos buscan anular la respectiva resolución, sea por defectos formales o de fondo, solicitando la dictación de una nueva resolución.

b) Recursos de reforma: aceptan la validez formal y sustancial de la resolución, pero pretenden su modificación.

Esta etapa es también eventual, porque son las partes las que inspiradas en el principio dispositivo las que resolverán en cada caso si se alzan o se conforman con el fallo.

Sin embargo, hay situaciones excepcionales donde se produce una especie de impugnación más allá de la voluntad de las partes, en efecto, ciertas y determinadas resoluciones judiciales deben ser consultadas al tribunal superior jerárquico respectivo. La consulta, que no es un recurso procesal, produce los mismos efectos que la apelación. En otros casos, la ley establece la facultad de los tribunales para casar de oficio. Terminada la etapa de impugnación el expediente vuelve al tribunal que dictó la resolución en única o primera instancia a fin de que proceda a su cumplimiento.

2.8 Etapa de cumplimiento.

Se inicia con la resolución que dicta el tribunal de primera o única instancia, el “cúmplase”, resolución que se notifica normalmente por el estado diario.

La etapa de cumplimiento también es una etapa eventual, ya que hay resoluciones que se bastan a sí mismas (declarativas), otras que se cumplen por la vía administrativa (constitutivas) y solamente requerirán de cumplimiento las sentencias de condena que no hayan sido cumplidas por el condenado.

Tema 3: Período de Discusión.

La fase de discusión en el juicio ordinario de mayor cuantía, está normalmente compuesta por los cuatro escritos fundamentales: demanda, contestación, réplica y dúplica. Con todo, puede surgir un escrito adicional a los ya mencionados, y que tiene su origen en la reconvención (dúplica reconvencional).

3.1 La demanda.

La demanda es *el acto jurídico procesal mediante el cual se ejercita la pretensión*, aunque no es el único medio, por ejemplo, el recurso de protección.

Conforme lo dispone el artículo 253 C.P.C., *todo juicio ordinario comenzará con la demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro*. Esta norma señala que lo normal es que el juicio ordinario de mayor cuantía se inicie con la demanda, pero puede también iniciarse con las llamadas medidas prejudiciales.

La demanda es indudablemente la pieza capital para quien pretende ejercitar su pretensión, y se ha dicho que quien yerra en la demanda no puede posteriormente subsanarla, pues se reducen sus expectativas, pudiendo eventualmente desaparecer, salvo claro que el demandado oponga la excepción dilatoria de ineptitud del libelo, la que de ser acogida permitirá al actor corregir su demanda.



Glosario

3.1.1 Requisitos de la demanda

El legislador ha señalado en el artículo 254 C.P.C. los requisitos específicos que debe reunir la demanda, a los que deben agregarse los requerimientos comunes a toda presentación judicial (suma, vocativo, individualización, desarrollo, petición y parte conclusiva) y, en ciertos casos, la llamada presuma.

La presuma tiene lugar cuando hay varios tribunales competentes asiento de Corte para conocer del asunto, pues en ese caso la demanda o medida prejudicial debe ser ingresada a la secretaría respectiva de la Corte de Apelaciones, para que su Presidente la distribuya en alguno de los tribunales competentes (artículo 176 C.O.T.). Las menciones de la presuma son: materia, procedimiento, individualización de las partes litigantes y del abogado patrocinante del demandante.

Cumplidos los requisitos de todo escrito judicial, y cumplidos los requisitos de la presuma cuando ella corresponde, se deben cumplir los requisitos del artículo 254:

La demanda debe contener:

1º La designación del tribunal ante quien se entabla.

Se satisface este requisito indicando en forma abreviada la jerarquía del tribunal (SJL, ILTMA., EXCSMA.).

2º El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación.

Se debe individualizar al demandante, a la persona que comparece por él y debe señalarse la naturaleza de la representación, esto es, indicar el título en virtud del cual el compareciente representa o pretende representar al actor (mandato judicial, general, estatutos, etc.). El título de la respectiva representación debe normalmente acreditarse acompañando a la demanda misma los documentos justificatorios.

3º El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.

En este caso también, aunque la ley no lo señala, cuando el demandado es representado por otra persona, debe indicarse la individualización de su representante y los títulos que la justifican y en lo posible se deberán acompañar los títulos respectivos.

Estas tres primeras menciones son de enorme importancia, porque cada una de ellas constituye un vértice del triángulo de la relación procesal (elementos subjetivos), el tribunal en la cúspide y las partes como ángulos del respectivo triángulo.

En consecuencia, estas indicaciones miran a la existencia de una válida y eficaz relación procesal, y por lo tanto, el tribunal de oficio puede no dar curso a la demanda que no contenga estas indicaciones para evitar así la nulidad procesal (artículo 256). Como es una facultad, si el tribunal no lo hace, el demandado puede reclamar a través de la excepción de ineptitud del libelo.

Los dos siguientes requisitos no miran a la validez de la relación procesal, sino a las expectativas del demandante, en el sentido que si no los cumple a cabalidad, sus posibilidades o expectativas se erosionan en forma substancial.

4º La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya.

El demandante debe señalar, primeramente el entorno fáctico y, en segundo lugar, los fundamentos de derecho en que se apoyará la pretensión.

Desde el punto de vista táctico no es particularmente aconsejable hacer una exposición exhaustiva, sino que recoger los rasgos esenciales de los hechos que interesa invocar, porque si uno trae a colación demasiados hechos se puede desdibujar la controversia en perjuicio de las expectativas del demandante. En cuanto a los fundamentos de derecho, éstos no son vinculantes para el tribunal, y en consecuencia, las invocaciones que en tal sentido realice la parte son meramente de expectativa respecto de su pretensión. Esto tiene mucha importancia porque basta que se señalen los hechos y la pretensión, aunque jurídicamente no se la encuadre a la perfección, para que efectivamente el tribunal adquiera competencia para resolver la pretensión.

5º La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

De acuerdo a la estructura general de toda presentación judicial que las peticiones van en la conclusión, la que por vieja práctica judicial va precedida por las palabras “por tanto”.

Como ya se señaló respecto de los numerales 4 y 5 el tribunal no puede de oficio negarse a admitir la demanda a tramitación, pero el demandado puede reclamar la inconcurrencia de estos requisitos por la vía de la excepción dilatoria de ineptitud del libelo.

3.1.2 Paralelo entre demanda y sentencia.

Ambos actos procesales son diferentes en cuanto a su génesis y su objeto, sin embargo, tienen una estructura similar: la individualización de las partes, la individualización del conflicto y las peticiones o decisiones que en ella se contemplan. Por esto se ha dicho, con cierta razón, que la demanda es un proyecto de sentencia que plantea el actor.

3.1.3 Demanda con reserva.

La regla general frente a cualquier demanda es que la pretensión del demandante debe ser completa y explícita, en consecuencia, en la parte petitoria se debe indicar precisa y determinadamente lo que se pretende que la sentencia acoja².

Este principio tiene una excepción prevista en el artículo 173 C.P.C., denominada demanda con reserva.

El legislador se ha puesto en la hipótesis que el demandante pretende la restitución de frutos (naturales o civiles) o la indemnización de perjuicios (contractuales o extracontractuales); caso en el cual puede:

a) Demandar efectivamente la devolución de los frutos o la indemnización de los perjuicios, planteando en la misma demanda cuál es el monto y la naturaleza (especie) de los mismos. Así la sentencia se pronunciará, en primer lugar, sobre la obligación de restituir o de indemnizar, y en segundo lugar, sobre

² Si la acción es declarativa debe señalar clara y determinadamente la declaración que persigue; si es constitutiva, qué derecho pretende que se constituya; y si es de condena, debe indicarse la obligación de dar, hacer o no hacer que persigue que sea reconocida.

la especie y monto de los frutos o perjuicios a pagar. En este caso, la discusión será íntegra (procedencia y monto). Si el demandante no prueba el monto de los frutos a restituir o de los perjuicios a indemnizar (o las bases que deban servir para su liquidación) **el tribunal declarará sin lugar el pago.**

b) El demandante puede intentar sólo una acción declarativa, para que se establezca en la sentencia si el demandado debe o no restituir frutos o indemnizar perjuicios, reservándose para el cumplimiento incidental del fallo o para otro juicio diverso a su elección, la fijación del monto de los frutos o perjuicios a pagar.

En otras palabras, el demandante en el primer caso intenta simultáneamente una acción declarativa y una acción de condena, en el segundo caso, intenta sólo una acción declarativa y la acción de condena queda reservada a elección del demandante para un juicio diverso o para el cumplimiento incidental del fallo.

El legislador permitió hacer esta división de acción declarativa y de condena, en primer lugar, porque los perjuicios pueden estar en curso y, en consecuencia, no se les puede determinar y, en segundo lugar, por la dificultad en la prueba.

El cumplimiento del fallo, corresponde al tribunal que haya dictado la sentencia en primera o única instancia, por lo tanto, el incidente de condena se planteará ante el mismo tribunal que pronunció la sentencia por aplicación de la regla de la extensión (artículo 111 C.O.T). El plazo para hacer valer esta pretensión es de un año, contado desde que la ejecución se hizo exigible, desde que se encuentre firme o ejecutoriada o desde que cause ejecutoria.

Quien solicita el cumplimiento incidental del fallo, obtendrá del tribunal una resolución que dirá “*como se pide, con citación*” y el perdedor del juicio, tendrá solamente el término de citación para oponerse al cumplimiento incidental.

Cuando se pide por la vía del cumplimiento incidental la fijación del monto de la indemnización o de la cantidad de frutos a restituir, el tribunal provee dos frentes: como se pide, con citación al cumplimiento incidental del fallo; traslado, en cuanto a la fijación de los perjuicios o el monto de los frutos a restituir.

Así, la persona contra la cual se pide el cumplimiento incidental le surgen dos posibilidades de oposición:

a) oponerse, dentro del término de citación, al procedimiento incidental; **b)** responder el traslado contravirtiendo el monto de los perjuicios que se demandan o el monto de los frutos cuya restitución se pretende.

Es decir, en este procedimiento incidental se debaten dos cosas separadas, la procedencia o improcedencia del procedimiento incidental y el monto de los perjuicios a pagar o monto de los frutos a restituir. Esta posible doble oposición se falla en una sola sentencia que se pronunciará sobre si procede o no el cumplimiento incidental y, además, sobre la naturaleza y monto de los perjuicios a indemnizar, y la naturaleza y monto de los frutos a restituir.

3.1.4 Documentos que acompañan a la demanda.

El artículo 255 señala que los documentos que se acompañan a la demanda deben impugnarse, cualquiera que sea su naturaleza, dentro del término de emplazamiento.

En estricto rigor, la forma de acompañar un instrumento en juicio depende de la naturaleza del mismo. La regla general es que se acompañen con citación, lo que significa que la parte contraria tiene un plazo fatal de tres días para observarlos. Hay otros documentos que se acompañan bajo el apercibimiento de tenerse por reconocidos si no fuesen objetados dentro de sexto día (artículo 346 N° 3), específicamente los instrumentos privados que emanan de la parte contraria.

El plazo para objetar los documentos acompañados a la demanda es el término de emplazamiento, que para este efecto es fatal. Cabe señalar, que el término del emplazamiento no siempre coincide con el término para contestar la demanda, porque si se oponen excepciones dilatorias el término para contestar la demanda puede ser sustancialmente mayor y los documentos deben ser objetados dentro del término de emplazamiento.

3.1.5 Término de emplazamiento en el juicio ordinario de mayor cuantía.

El término de emplazamiento está constituido por dos elementos:

- a) La notificación de una determinada resolución.
- b) El transcurso de un plazo o la fijación de una oportunidad para la realización de un acto procesal.

Así, por ejemplo, el término de emplazamiento para el apelante está compuesto por dos elementos: la concesión del recurso de apelación, resolución que se notifica por el estado diario, y, por el plazo para comparecer ante la segunda instancia, que de cinco días por regla general.

En el juicio ordinario de mayor cuantía, el término de emplazamiento es la oportunidad que tiene el demandado para contestar la demanda, pero también es el plazo para oponer excepciones dilatorias.

Cabe señalar que el término de emplazamiento del juicio ordinario de mayor cuantía, tiene aplicación en su misma extensión y forma en otros procedimientos. Además, cuando el legislador dispone que tal o cual actuación debe realizarse dentro del término de emplazamiento, se está remitiendo a las reglas contempladas en el juicio ordinario de mayor cuantía, por ejemplo:

- i) Litis consorcio activa sobreviniente. Los terceros que no fueron parte de la primitiva demanda, tienen el término de emplazamiento para hacer valer sus derechos (artículo 21 C.P.C.).
- ii) Citación de evicción. El citado de evicción tiene el término de emplazamiento para comparecer al juicio (artículo 586 C.P.C.).

Presentada la demanda, el tribunal analiza que cumpla con los requisitos del artículo 254, especialmente los tres primeros, si la estima admisible dicta una resolución muy simple: “*traslado*” (artículo 257).

Desde el punto de vista de su historia y de su etimología el término *traslado* significa copia³. En el lenguaje forense, cuando se habla de traslado, significa que se concede a la parte contraria la oportunidad procesal correspondiente para que haga valer sus derechos. Este concepto se une con el concepto de copia, porque en la formación del proceso, cada vez que se debe notificar a la otra parte una resolución, se le tiene que dejar, por regla general, copia de los escritos, y frente a la demanda que,

³ Algunas disposiciones del C.C. usan el término traslado como sinónimo de copia, por ejemplo, el artículo 1707.

normalmente será la primera resolución, el traslado se materializa entregándole copia al demandado de todo lo actuado, para que pueda hacer uso de sus respectivos derechos.

Notificada la resolución que provee la demanda se inicia el término de emplazamiento, cuya regulación se encuentra en los artículos 258, 259 y 260 inciso 2°, normas que atienden al lugar dónde se practicó aquélla:



a) Plazo base de 15 días, cuando la demanda ha sido notificada en la comuna en que tiene asiento el respectivo tribunal;

b) Plazo adicional de 3 días, cuando la notificación se realiza dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, pero fuera de la comuna en que éste tiene su asiento;

c) Plazo complementario, cuyo número de días dependerá de lo establecido en la tabla de emplazamiento, cuando la notificación se realiza fuera del territorio jurisdiccional del tribunal.

La tabla de emplazamiento es un acto que emana de la Corte Suprema, quien cada cinco años indica los días de aumento que corresponde agregar al emplazamiento según el lugar efectivo de notificación, sea en Chile o en el extranjero.

d) Plazo complementario, cuando hay pluralidad de demandantes, caso en cual el plazo se aumenta en 1 día por cada tres demandantes sobre diez que existan en el juicio, en otras palabras, cuando hay trece demandantes se aumenta el plazo en un día, cuando hay dieciséis en dos días y así sucesivamente, pero el plazo adicional no puede exceder de 30 días.

El artículo 260 señala qué ocurre cuando son dos o más los demandados. En este caso, sea que actúen conjunta o separadamente, el término de emplazamiento es común y, en consecuencia, se extingue al extinguirse el más largo de los términos. Esta regla tiene una importante excepción creada por la jurisprudencia, sin que haya norma legal que la justifique, que se da en el juicio ejecutivo en que, aunque sean dos o más los ejecutados, se ha entendido que el término del emplazamiento es individual.

3.1.6 Ampliación o modificación de la demanda

a) El artículo 261 señala que notificada la demanda a cualquiera de los demandados y **antes de la contestación**, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes. Éstas se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación y sólo desde la fecha en que ésta se practique correrá el término para contestar la demanda primitiva.

Se ha discutido cuál es el ámbito de estas posibles ampliaciones o rectificaciones. Una sentencia de la Corte Suprema declaró que se pueden referir al contenido de la demanda en su más amplio sentido, pero no se puede modificar la persona del demandado, dicho de otra manera, lo que es adicionable o modificable son los elementos objetivos de la relación procesal, pero no los elementos subjetivos.

Al apoderado a quien se le ha otorgado poder en la primera demanda o demanda primitiva puede realizar la ampliación o modificación sin el consentimiento del demandante, ya que esta facultad no está dentro de las menciones excepcionales que requiera poder especial.

b) El artículo 312, se refiere al escrito de réplica del juicio ordinario de mayor cuantía, que es una segunda oportunidad que tiene el demandante para ampliar, modificar o adicionar su pretensión, pero sin que pueda alterar las acciones que sean objeto principal del pleito.

Aquí son mayores limitaciones que las establecidas en el caso anterior, ya que estas adiciones o modificaciones no pueden alterar las acciones que fueron objeto principal del pleito.

Este artículo se refiere a los escritos de réplica y dúplica, pero aquí lo analizamos sólo desde la perspectiva de la demanda.

c) El artículo 308 C.P.C., se refiere a la aceptación de excepciones dilatorias. En este caso, acogidas que sean las excepciones el demandante debe subsanar los errores en que incurrió en el libelo, siendo por ende una nueva oportunidad para modificar la demanda.

d) Si bien esta hipótesis no tiene consagración legal, es indudable que antes de notificar la demanda, esto es antes de trabar la relación procesal, el actor puede modificar su demanda, y en este caso sin limitación alguna. El fundamento radica en que el demandante puede retirar su demanda sin consecuencias jurídicas, ya que es un acto netamente material, entonces con mayor razón podrá modificarla.

3.2 Posibles conductas del demandado frente a la demanda.

El demandado frente a la demanda puede adoptar distintas conductas, las que no son excluyentes unas de otras, por ejemplo, puede contestar la demanda oponiendo excepciones perentorias y también puede reconvenir.

Las posibles conductas del demandado son las siguientes:

a) Oponer excepciones dilatorias.

b) No hacer nada (silencio), que es una forma de defensa negativa tácita

c) Contestar la demanda y dentro de la contestación puede:

c.1) Allanarse a la demanda, es decir, someterse a la pretensión ajena.

c.2) Defenderse negativamente, esto es, negar los hechos que sirven de fundamento a la respectiva pretensión.

c.3) Oponer excepciones de fondo, que son circunstancias de hecho y de derecho que invoca el demandado para enervar las pretensiones del actor.

c.4) Deducir reconvencción, que es la demanda que interpone el demandado en contra de su demandante.

Como se señaló precedentemente estas conductas no son todas necesariamente excluyentes entre sí, pero algunas sí lo son, por ejemplo, no se puede oponer excepciones dilatorias y, al mismo tiempo, deducir demanda reconvenccional.

3.3 Excepciones dilatorias.

3.3.1 Clasificación doctrinaria de las excepciones.

Doctrinariamente las excepciones se clasifican en:

- a) Excepciones procesales o de rito. Son aquellas que atacan la relación procesal y, por lo tanto, quien las invoca se está oponiendo al nacimiento del proceso, pero no a la pretensión misma.
- b) Excepciones sustanciales o de mérito. Estas excepciones no miran a la validez o eficacia de la respectiva relación procesal, sino que se oponen al fondo de la pretensión, aceptan que se dicte una sentencia, pero pretenden que esta sentencia deseche la pretensión.

3.3.2 Clasificación legal de las excepciones.

En nuestra legislación se distinguen los siguientes tipos de excepciones:

- a) **Excepciones dilatorias.** Son excepciones procesales o de rito, por lo tanto, miran a la relación procesal y se oponen al nacimiento del proceso.
- b) **Excepciones perentorias.** No miran a la relación procesal, aceptan el proceso pero se oponen a la pretensión, esto es, instan a que la pretensión del actor sea desestimada.
- c) **Excepciones anómalas.** Son aquellas que también miran a la pretensión, pero por su especial entidad o importancia, pueden ser interpuestas en otras oportunidades que las señaladas para las excepciones perentorias.
- d) **Excepciones mixtas.** Son excepciones sustanciales en cuanto al fondo o contenido, pero procesales en cuanto a la oportunidad en que se pueden interponer; es decir, no obstante ser excepciones perentorias, se pueden oponer en la misma oportunidad que las excepciones dilatorias.

3.3.3 Excepciones dilatorias en el Código de Procedimiento Civil.

Como se señaló anteriormente las excepciones dilatorias son aquellas que tienen por objeto corregir defectos que afectan la relación procesal o reclamar de la ausencia de un presupuesto procesal, es decir, son excepciones procesales o de rito, pues se oponen al nacimiento del proceso. Sin embargo, esta aseveración no es absolutamente correcta, pues dentro de las excepciones dilatorias hay una que no tan sólo mira al proceso mismo, sino que a asuntos sustanciales, nos referimos al beneficio de excusión.

Cabe indicar que el artículo 303, a pesar de su redacción “*Sólo son admisibles como excepciones dilatorias*” que da a entender una enumeración es taxativa, no lo es tal por cuanto es meramente ejemplar, lo que se deduce de su numerando sexto, el que califica como excepción dilatoria a todas aquellas circunstancias que digan relación con la corrección del procedimiento, sin alterar el fondo de la acción deducida.

a) La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda.

El número 1 del artículo 303 se refiere tanto a la *incompetencia absoluta* como a la *relativa* del tribunal. Sin embargo, la entidad o importancia de una u otra especie de incompetencia es manifiesta y, por esto el legislador ante la incompetencia absoluta da otras oportunidades o vías para reclamarla, por ejemplo, como incidente de nulidad procesal o de oficio por el tribunal. En cambio, la incompetencia relativa debe

ser opuesta como excepción dilatoria, porque si así no se hace, y se realiza cualquier otra gestión, se produce la prórroga tácita de la competencia.

Existen dos caminos para reclamar la incompetencia del tribunal:

- i) La *vía declinatoria*, que se hace valer ante el tribunal que se considera incompetente, para que reconozca su incompetencia y decline el conocimiento del asunto a otro tribunal.
- ii) La *vía inhibitoria*, que se hace valer ante el tribunal que se estima competente, para que éste inhiba en el conocimiento del asunto al tribunal que se considera incompetente.

Las excepciones dilatorias constituyen una vía declinatoria para reclamar la incompetencia del tribunal.

b) La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.

El número 2 del artículo 303 trata dos situaciones distintas.

b.1) Falta de capacidad del demandante. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es inherente a la persona, es decir, es un atributo de la personalidad y, en consecuencia, toda



persona tiene capacidad de goce. Lo normal es que la capacidad de goce concurra, de manera que cuando hablamos de falta de capacidad nos referimos a la falta de capacidad de ejercicio. Cabe advertir, que al hablar de falta de capacidad de ejercicio, puede ocurrir que el demandante siendo incapaz comparezca habiéndose subsanado esta deficiencia, por ejemplo, mediante las formalidades habilitantes (autorización del representante).

b.2) Falta de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Quien aparece demandando o quien comparece por el demandante es una persona distinta del demandante mismo y se está adjudicando la calidad de representante de él. Pues bien, cuando alguien se dice representante, debe invocar la personería correspondiente y si ésta no existe o no está debidamente acreditada, se podrá oponer esta excepción.

c) La litis pendencia.

Esta excepción se encuentra contemplada en el número 3 del artículo 303.

En materia procesal dan fisonomía al proceso tres elementos:

- i) La persona del **accionante**, es quien hace valer la pretensión y podrá ser una persona natural o jurídica.
- ii) La **cosa pedida**, el cual no es el objeto material reclamado, sino que el beneficio jurídico que se pretende.
- iii) La **causa de pedir**, esto es, el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, en otras palabras, el antecedente jurídico inmediato del beneficio reclamado.

Litis pendencia significa que la acción que se hace valer en un determinado juicio es igual a la acción que se interpuso en un juicio anterior que no está fallado. En este caso el demandado puede oponerse al

nacimiento de este segundo juicio oponiendo esta excepción. Si el primer juicio estuviese fallado, la excepción que se debería interponer sería la excepción de cosa juzgada.

En una demanda se pueden intentar pluralidad acciones, por ende bien puede ocurrir que se produzca la triple identidad con un juicio anterior, respecto de algunas acciones y no respecto de otras. Ante esta situación se puede invocar la litis pendencia parcial, la que de ser acogida traerá como consecuencia que el segundo juicio se suspenderá sólo respecto de las acciones en relación con las cuales se produce litis pendencia y subsistirá respecto de las demás.

d) La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda.

Esta excepción prevista en el número 4 del artículo 303 guarda estrecha armonía con el artículo 254 que señala los requisitos de la demanda. Aquí el término libelo está tomado en su sentido técnico procesal como sinónimo de demanda y no en su sentido común que significa un escrito con claro contenido peyorativo.

El artículo 254 contiene cinco requisitos de la demanda, y el tribunal puede de oficio, no dar curso al proceso en caso de inconcurrencia de cualquiera de los tres primeros requisitos por expresa autorización del artículo 256.

Esta excepción se refiere a todos y cada uno de los requisitos que enumera el artículo 254. En consecuencia, bien podrá ser mejor no oponer la excepción dilatoria cuando se refiera a los numerales cuarto y quinto, porque precisamente el defecto de la demanda perjudicará al propio demandante y será un beneficio para el demandado. En cambio, si se opone la excepción se le dará la oportunidad para corregir su libelo.

e) El beneficio de excusión.

El beneficio de excusión (número 5 del artículo 303) guarda relación con el contrato de fianza.

La fianza es un contrato de garantía, por ende una caución, esto es una obligación que se contrae con el objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. El fiador es aquel que se obliga subsidiariamente a la obligación del deudor principal, asumiendo la responsabilidad de cumplir si éste no cumple, sea total o parcialmente.

Para hacer efectivo este derecho del fiador (cumplir subsidiariamente), se ha contemplado el beneficio de excusión como excepción dilatoria, ergo si es directamente demandado por el acreedor, puede exigir que se agoten las acciones en contra del deudor principal y solamente si éste no paga o paga parcialmente, se podrá dirigir contra él.

El beneficio de excusión tiene de alguna manera un carácter mixto, ya que no solamente mira la situación de rito o procesal, sino que también mira cuestiones de carácter sustancial, como son la solvencia y el eventual pago del deudor principal.

Si la excepción del beneficio de excusión es acogida, el proceso en que se demandó al fiador queda en suspenso hasta que se solucione el problema con el deudor principal, pero podría terminar cuando el deudor principal paga la totalidad de la obligación.

f) En general, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida.

Este numeral le da el carácter de genérico o ejemplar a la enumeración del artículo 303 y envuelve muchas situaciones, por ejemplo, la falta de patrocinio debidamente constituido, la falta de poder debidamente constituido, el inadecuado procedimiento, cesión de crédito no debidamente notificado, no agotamiento previo por vía administrativa, etc.

Cabe preguntarse si se puede invocar la *falta de legitimidad para actuar* como excepción dilatoria. Aquella es una institución de carácter sustantivo que tiene importantes repercusiones procesales y significa que para ejercitar ciertas pretensiones se debe tener una calificación particular, por ejemplo, sólo puede ejercer la acción de nulidad del matrimonio alguno de los cónyuges, por ende, si un tercero interpone esta acción de nulidad, se dirá que existe falta de legitimidad para actuar.

La jurisprudencia chilena ha sostenido que la excepción en comento sólo puede ser reclamada como excepción perentoria o de fondo. Sin embargo, estimamos que bien podría considerársela como un caso de excepción dilatoria y, muy específicamente, por la invocación del numerando sexto del artículo 303, porque en definitiva será desechada la pretensión en la sentencia definitiva, después de haberse tramitado un proceso de lato conocimiento.

3.3.4 Oportunidad y forma de oponer las excepciones dilatorias

La regla general está contenida en el artículo 305 inciso 1°, disposición que señala que las excepciones dilatorias deben interponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento fijado por los artículos 258 a 260.

Esta regla tiene dos excepciones contenidas en los incisos 2° y 3° del artículo 305:

a) Inciso 2°. *“Si así no se hace se podrán oponer en el progreso del juicio sólo por la vía de alegación o defensa y se estará a lo dispuesto en los artículos 85 y 86”.*

Esta segunda oportunidad necesariamente se tiene que hacer valer por vía incidental, o sea, se plantea un incidente que diga relación con la respectiva excepción dilatoria, por ejemplo, el incidente de incompetencia del tribunal o incidente de falta de capacidad, etc. Los artículos 85 y 86 subrayan que este incidente está sujeto a las mismas limitaciones preclusivas de los incidentes en general.

b) Inciso 3°. *“Las excepciones 1a. y 3a. del artículo 303 podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente”*

Este inciso se refiere sólo a dos excepciones dilatorias que pueden ser opuestas en segunda instancia, la incompetencia del tribunal y la litis pendencia. Por la forma de redacción de la norma, y más aún si se le compara con el inciso 2°, se debe concluir que la oposición de dilatorias en segunda instancia no está limitada a las reglas preclusivas generales de los incidentes ya que no hay referencia a los artículos 85 y 86.

3.3.5 Tramitación y naturaleza jurídica de la resolución que falla una excepción dilatoria

De acuerdo a lo previsto por el artículo 307, las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes, es decir, se da traslado a la parte demandante por el término de 3 días para que exprese lo que estime conveniente a sus derechos, y evacuado que sea el traslado o en su rebeldía, puede o no recibirse la excepción a prueba para posteriormente ser fallada.

El artículo en comento no se pronuncia acerca de la naturaleza jurídica de la resolución que falla las excepciones dilatorias. Se ha estimado que es una sentencia interlocutoria, sea si se acogen o se desechan. Refuerza este argumento el mismo artículo 307, que señala que la resolución que las desecha es apelable (en el solo efecto devolutivo) y, la apelación procede por regla general, en contra de sentencias interlocutorias.

Sin embargo, una sentencia de la Corte Suprema declaró que es un auto, lo que creemos que es erróneo, por cuanto si fuera esa su naturaleza jurídica la apelación sería subsidiaria de la reposición, lo que no es correcto ya que de la misma norma se desprende que es apelable derechamente.

Como ya se anticipó, el artículo 307 inciso 2° dispone que la resolución que desecha las excepciones dilatorias es apelable en el solo efecto devolutivo, en consecuencia, el juicio sigue su curso, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. Si se analizara aisladamente esta norma se debería concluir que la resolución que las *acoge* sería apelable en *ambos efectos*, lo que no se condice con lo establecido en artículo 194 N° 2, que indica que todas las apelaciones de autos y sentencias interlocutorias, salvo en norma expresa en contrario, se conceden en el solo efecto devolutivo.

El artículo 306 señala cómo se fallan las excepciones dilatorias: todas en una sola resolución (todas a la vez), con todo, si entre las opuestas está la de incompetencia del tribunal y el tribunal la acoge, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás, precisamente porque es incompetente.

Todas las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la de incompetencia y el tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás. Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 208.

Esta norma contiene una remisión al artículo 208 C.P.C. que se refiere a la apelación y a la competencia del tribunal de alzada, el que puede pronunciarse sobre todas las cuestiones ventiladas y resueltas en primera instancia, pero también puede pronunciarse sobre cuestiones ventiladas en primera instancia y no resueltas por ser incompatibles con las resueltas, por ende, si se acoge la excepción de incompetencia, el tribunal de alzada conociendo de la apelación puede estimar que el tribunal es competente y si esto ocurre, entrará a pronunciarse también sobre las demás excepciones dilatorias opuestas aunque no hubiesen sido resueltas en primera instancia.

Artículo 208. *Podrá el tribunal de alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal inferior.*

3.3.6 Efectos en el curso del juicio si las excepciones dilatorias son acogidas

En tal evento la solución no es única, sino que casuística dependiendo de cuál sea la excepción dilatoria acogida.

a) Incompetencia del tribunal. Termina definitivamente el juicio y todo lo actuado es nulo, porque la incompetencia en materia procesal civil acarrea la nulidad de todo lo obrado. Ergo, si el demandante quiere perseverar en su pretensión deberá iniciar un nuevo juicio ante tribunal competente. En todo caso, se ha estimado en forma casi unánime que la demanda interpuesta ante tribunal incompetente y debidamente notificada interrumpe la prescripción.

b) Falta de capacidad del demandante. La solución es idéntica al caso anterior porque la falta de capacidad o de representación, impide la formación de la relación procesal y, en consecuencia, lo actuado en ese proceso va a ser nulo, salvo que la falta de personería pueda ser subsanada acompañando la respectiva fuente de la misma, v.g. mandato, resolución judicial.

c) Litis pendencia. Hay que distinguir si la litis pendencia acogida es total o parcial. Si la litis pendencia acogida es parcial, seguirá el juicio respecto de las otras acciones y se paralizará respecto de aquellas que motivaron la excepción. Por el contrario, si es total, se paraliza el procedimiento mientras dura el otro juicio, y si en éste se dicta sentencia firme, la litis pendencia se convierte en cosa juzgada. Si el otro juicio termina por abandono del procedimiento, el juicio donde se había acogido la litis pendencia continúa.

d) Ineptitud del libelo. Se paraliza el procedimiento en espera de la corrección de la demanda por parte del actor. Si la demanda se corrige, el proceso continuará. Si no se corrige, se paraliza el proceso por el tiempo que demore dicha corrección, pudiendo producirse el abandono del procedimiento.

e) Beneficio de excusión. La regla general es que se paraliza el procedimiento hasta esperar las resultas del juicio en contra del deudor principal, y si éste satisface completamente la obligación, naturalmente, el procedimiento donde se acogió la excepción terminará.

Cabe señalar que no se puede demandar en el mismo juicio al deudor principal y subsidiariamente al fiador. Las acciones son distintas, y en nuestro procedimiento se permiten acciones distintas subsidiarias, pero no se permiten demandados subsidiarios.

f) Circunstancias que se refieran a la corrección del procedimiento. El análisis es casuístico, debiendo analizar el caso en particular para determinar si se produce o no la paralización definitiva o temporal del procedimiento.

3.3.7 Efectos si las excepciones dilatorias son desechadas o se subsana el vicio

A esta situación se refiere el artículo 308, *desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá diez días el demandado para contestarla, cualquiera sea el lugar en donde le haya sido notificada.*

Este plazo se cuenta desde que se notifica por el estado la resolución que desecha las excepciones dilatorias o se subsanan los defectos, porque si se deduce apelación ésta se concede en el solo efecto devolutivo, en consecuencia, no suspende el cumplimiento de la resolución.

3.4 Excepciones mixtas.

Estas excepciones se denominan mixtas, porque no siendo propiamente dilatorias se interponen y se tramitan conjuntamente con aquéllas. El por qué, porque de alguna manera miran al nacimiento del procedimiento.

Las excepciones mixtas son la transacción y la cosa juzgada. Ambas excepciones son dos caras de una misma medalla. La transacción como equivalente jurisdiccional que es, produce cosa juzgada. En consecuencia, la excepción mixta es la cosa juzgada, derivada de una sentencia firme o de una transacción.

Las excepciones mixtas se oponen en la misma oportunidad que las excepciones dilatorias y si hay dilatorias conjuntamente con éstas, se tramitan incidentalmente y son falladas mediante una sentencia interlocutoria. La particularidad se presenta cuando el tribunal estima que son de lato conocimiento, pues en ese caso puede ordenar que se conteste derechamente la demanda y reservar su fallo para la sentencia definitiva (artículo 304 Código de Procedimiento Civil).

Aunque el legislador no lo dice expresamente, lo razonable es que estas excepciones se renueven en la contestación de la demanda para que así claramente surja la necesidad de que el tribunal se pronuncie en la sentencia definitiva.

3.5 Silencio.

Es consecuencia de la ausencia (rebeldía) del demandado, y la ley lo parangona a la defensa negativa, en otras palabras, el silencio es una forma de defensa negativa tácita.

Se llega a esta conclusión luego de examinar el artículo 318 que dispone: *“Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer”*. En efecto, ante la rebeldía del demandado y si el tribunal estima que puede haber controversia debe recibir la causa a prueba.

3.6 Contestación de la demanda.

La contestación de la demanda se encuentra regulada en Título VII, del Libro II, artículos 309 y siguientes del C.P.C.

Al igual que la demanda, el escrito de contestación es formal pues debe cumplir ciertos y determinados requisitos, pero éstos no son requisitos de admisibilidad, sino que miran solamente al interés del demandado. Si el demandado no cumple con la carga procesal de satisfacer el requerimiento formal que le indica el artículo 309, solamente sufrirá consecuencias o perjuicios para el mismo.

La estructura del escrito de contestación, desde el punto de vista lógico, es similar con la estructura de la demanda.

Artículo 309. La contestación a la demanda debe contener:

1. *La designación del tribunal ante quien se presente;*
2. *El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;*
3. *Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan; y*

En relación a este numeral el legislador parte del supuesto que el demandado opone excepciones (perentorias) invocando hechos invalidativos o impositivos de la pretensión, **pero el demandado puede asumir otras conductas distintas a la de oponer excepciones** y, en consecuencia, la lectura de este requisito es que si el demandado va a oponer excepciones debe hacerlo en la contestación de la demanda y debe en esa oportunidad exponer con claridad los hechos en que funda sus excepciones y los antecedentes de derecho en que estas están apoyadas.

4. *La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.*

En esta parte la contestación puede ser más escueta que la demanda misma, porque en ésta deben indicarse con precisión todas y cada una de las peticiones, en cambio, en la contestación bastará que se diga “*que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas*”.

En el escrito de contestación el demandado puede asumir diversas actitudes, a saber, allanarse a la demanda, defenderse negativamente, oponer excepciones perentorias o de fondo, reconvenir u oponer excepciones anómalas.

3.7 Allanamiento.

El allanamiento se encuentra regulado en el artículo 313, que es el último del Título VII . Se le puede definir como *el reconocimiento de los hechos, consignados en la demanda, por parte del demandado*.

El allanamiento admite un doble criterio de clasificación. En primer lugar puede ser expreso o tácito. Será *expreso*, si el demandado pura y simplemente reconoce los hechos consignados en la demanda y manifiesta su voluntad de someterse a la pretensión del demandante, y *tácito*, cuando compareciendo el demandado, no controvierte en forma sustancial y pertinente los hechos que sirven de fundamento a la pretensión. En segundo lugar, puede ser total o parcial. Será *total*, cuando se extiende a todas y cada una de las pretensiones del actor, y *parcial*, cuando se refiere a una o más de las pretensiones, pero no a todas.

Es necesario subrayar que se produce allanamiento tácito sólo cuando el demandado está presente en el juicio, ya que su no comparencia da lugar a otra figura, el silencio, que tiene efectos diversos a los del allanamiento.

3.7.1 Efectos del allanamiento

Artículo 313 inciso 1°: *“Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o si en sus escritos no contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacuado el traslado de la réplica”.*

Es menester enfatizar que el allanamiento sólo produce efectos en el ámbito de los hechos, tiene consecuencias fácticas y no necesariamente jurídicas. De esta manera, el allanamiento no ahorra el esfuerzo de dictar sentencia, el tribunal deberá dictarla de todas maneras y es perfectamente posible que desestime la pretensión del actor, lo que podrá ocurrir si la decisión se funda en razones puramente de derecho.

Es importante también tener presente, que los efectos del allanamiento, en cuanto a no recibir la causa a prueba, está fundamentalmente modificado cuando el conflicto de que se trata envuelve intereses de carácter social. Lo que no es consecuencia de disposiciones legales específicas, sino que de elaboración doctrinaria y jurisprudencial. Por ejemplo, si se produce un juicio de divorcio, donde el contenido social del conflicto es naturalmente gravitante, no obstante que el marido o la mujer reconozcan los malos tratos ya sean físicos o de palabra, será siempre necesario recibir la causa a prueba.

En consecuencia, no habiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, producto del allanamiento, se hace innecesario el trámite de la réplica, de suerte tal que evacuada la réplica, el tribunal citará a las partes a oír sentencia.

Finalmente hay que tener presente que en determinadas circunstancias la solución directa no es posible ya que pueden existir intereses de terceros comprometidos, siendo necesario el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Por ejemplo, A vende a B un inmueble, B se la vende a C, pero B no le paga el precio a A. Éste dispone de la acción resolutoria en contra de B y de la acción reivindicatoria en contra de C. Si B reconoce que no pagó el precio, se allana a la demanda, pero este allanamiento no producirá sus efectos porque afectaría a un tercero que no fue parte del acto o contrato cuya resolución se persigue.

3.8 Defensa negativa.

Esta conducta del demandado consiste en negar los hechos que sirven de fundamento a la respectiva pretensión. Esta negativa puede referirse a todos y cada uno de los hechos, o bien, a ciertos y determinados hechos.

Puede ocurrir también que en la defensa negativa se controviertan las consecuencias jurídicas de los hechos invocados, en este caso, aunque se está más bien en el campo de las alegaciones o defensas, es una forma o manera de defensa negativa.

Cuando se produce la defensa negativa es indispensable recibir la causa a prueba, y su efecto, es que el demandante será quien quedará cargado con el peso de la prueba, correspondiéndole acreditar los extremos fácticos que sirven de fundamento a su respectiva pretensión.

3.9 Excepciones de fondo.

A este tipo de excepciones se las llama también excepciones de mérito o perentorias, pues no se oponen al nacimiento del proceso, sino que a la pretensión.

Las excepciones perentorias o de fondo no están taxativamente enumeradas por la ley, son todas aquellas que busquen destruir la respectiva pretensión. Sin embargo, los modos de extinguir las obligaciones pueden constituir desde el punto de vista procesal excepciones perentorias o de fondo, y cuando esto sucede se habla de excepciones nominadas, porque las excepciones van a tomar el nombre del respectivo modo de extinguir. Pero esto es sólo un capricho de carácter procesal-civil, porque son dos instituciones perfectamente distintas los modos de extinguir y las excepciones perentorias.

Así, hay excepciones perentorias que no son modos de extinguir, por ejemplo, la inoponibilidad, la inexistencia, la excepción de contrato no cumplido, etc.

También es importante tener presente que en el lenguaje de los procesalistas civiles, se consideran como excepciones de fondo a algunas que participan de características vinculadas a las excepciones dilatorias, por ejemplo, la falta de legitimidad para obrar, cosa juzgada o la transacción. Creemos que este tipo de excepciones se oponen al proceso más que a la pretensión misma.

Las excepciones de fondo son compatibles con la defensa negativa, y en tal evento, naturalmente las excepciones de fondo se plantearán como subsidiarias de la defensa negativa. En todo caso, hay que tener cuidado en manejar simultáneamente estas dos vías, porque podría darse verse envuelta claramente una mala fe procesal, por ejemplo, frente a la pretensión de cobrar un millón de pesos, se hace valer defensa negativa: *“¿millón de pesos? ¿Qué millón de pesos? No, nunca me han prestado ese millón de pesos”*, y subsidiariamente se hace valer la excepción perentoria de pago: *“¿el millón de pesos? Pero si ya lo pagué”*, ambas excepciones son incompatibles desde el punto de vista ético, y el tribunal mirará con mucha sospecha una defensa negativa seguida de una excepción de carácter perentoria.

Si se hacen valer sólo excepciones de fondo, sin defensa negativa, significa que los hechos que sirven de fundamento a la pretensión se están aceptando, pero se están invocando nuevos hechos invalidativos, modificatorios o extintivos, que se oponen a dicha pretensión. Cuando se invocan estos hechos extintivos, modificatorios o que acarrear la ineficacia, las posibles conductas del demandante frente a las excepciones de fondo son:

- a) Allanarse a dichas excepciones, y se producirá el mismo fenómeno que frente al allanamiento respecto de la demanda, aquí claramente no existirá controversia.
- b) Controvertir los hechos en que se fundan las excepciones de fondo, siendo necesario recibir la causa a prueba, quedando cargado con el peso de la prueba el demandado debiendo acreditar los extremos fácticos de su contrapretensión.
- c) Agregar hechos o circunstancias contramodificatorias o contraextintivas, con lo cual nuevamente él se carga con el peso de la prueba para efectivamente establecer la veracidad de aquellos nuevos hechos.

Sobre el particular, los escritos de réplica o dúplica tienen la enorme importancia de contribuir a fijar con mayor precisión el ámbito fáctico de la pretensión, pudiendo importar un enorme ahorro respecto de la prueba para las partes.

3.10 Reconvención.

La reconvención de encuentra regulada en los artículos 314 a 317 C.P.C. y es *la demanda que deduce el demandando en contra del demandante*.

Si bien está tratada a propósito del juicio ordinario de mayor cuantía, tiene aplicación en otros procedimientos, con ciertas y determinadas limitaciones, debido al carácter supletorio de aquél.

3.10.1 Oportunidad y forma de la reconvención.

En cuanto a su oportunidad, la reconvención debe deducirse en el escrito de contestación de la demanda. En este caso el escrito de contestación contiene dos materias perfectamente diferenciables: contestación misma (en lo principal) y reconvención (otrosí).

La reconvención, que es una demanda, tiene que cumplir con requisitos formales, y es así como el artículo 314 se remite al artículo 254, en tal sentido la reconvención debe reunir los mismos requisitos de la demanda. Además, el artículo 314 se remite al artículo 261, esta remisión no es del todo comprensible ya que este artículo regula la modificación de la demanda una vez que ha sido notificada y antes de contestada, entonces pareciera o querer decir que la reconvención también se podría modificar antes de la contestación de la reconvención.

Artículo 314. Si el demandado reconviene al actor, deberá hacerlo en el escrito de contestación, sujetándose a las disposiciones de los artículos 254 y 261; y se considerará, para este efecto, como demandada la parte contra quien se deduzca la reconvención.

Como la reconvención debe cumplir con los requisitos del artículo 254, también es posible que se opongan excepciones dilatorias a su respecto, entonces el demandante (en lo principal) en vez de contestar la reconvención y replicar en lo principal, opone excepciones dilatorias dentro del plazo de seis días.

Cuando las excepciones dilatorias a la reconvención son desechadas, o bien se corrigen los vicios, el demandado reconvencional tiene que replicar en el plazo habitual de la réplica y contestar la reconvención, esto es, en el plazo que de 6 días, contados desde que se notifique por el estado diario la resolución que desecha las excepciones dilatorias o tiene por subsanados los vicios.

Si se acogen las excepciones dilatorias el demandante reconvencional tiene que subsanar los defectos de su demanda, en el plazo de 10 días contados desde que han sido acogidas las excepciones, si no lo hace, ya porque no quiere, ya porque no son subsanables, se tiene por no presentada la reconvención para



todos los efectos legales y por el solo ministerio de la ley. Esto es una gran diferencia con las excepciones dilatorias a la demanda principal, en efecto cuando las excepciones dilatorias son acogidas, queda entregada a la voluntad del demandante corregir o no los vicios y no existe la sanción en comento.

¿Por qué esta gran diferencia? La respuesta es simple, cuando las excepciones dilatorias a la reconvención son acogidas se paraliza el procedimiento, y como el juicio mira al interés del demandante, el demandado puede no interesarle hacerlo

avanzar, y después de seis meses podría alegar el abandono del procedimiento, entonces para evitar esta “tentación procesal” el legislador ha impuesto la sanción ya analizada.

3.10.2 Tramitación del juicio con reconvención.

La demanda reconvenzional se tramita conjuntamente con la demanda principal. Por consiguiente, frente a la demanda reconvenzional se le da traslado al demandante, para que replique en la demanda principal y conteste la reconvención; luego, se le da traslado al demandado para que duplique la demanda principal y replique en la reconvención, y finalmente, el último traslado es para que el demandante duplique en la reconvención. Todos los plazos son de seis días hábiles.

DEMANDANTE	DEMANDADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	DEMANDANTE
	15 + 3 + TE	6 días	6 días	6 días
Demanda	Contestación de demanda	Réplica	Dúplica	
	Demanda reconvenzional	Contestación reconvención	Réplica reconvención	Dúplica reconvención

Este paralelismo en la tramitación se refleja también en lo dispuesto inciso final del artículo 316, el cual señalar que no se dará aumento extraordinario para rendir prueba fuera del territorio de la República en la reconvención, si no se concede dicho aumento extraordinario en la cuestión principal.

Artículo 316. *La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 172.*

De la réplica de la reconvención se dará traslado al demandante por seis días.

No se concederá, sin embargo, en la reconvención aumento extraordinario de término para rendir prueba fuera de la República cuando no deba concederse en la cuestión principal.

3.10.3 Fallo de la cuestión principal con la reconvención.

La demanda reconvenzional se falla conjuntamente con la demanda principal, es decir, todo se falla es una misma sentencia.

A pesar de ello, el artículo 316 hace una especial remisión al artículo 172, norma que permite excepcionalmente, cuando en un juicio se ventilan cuestiones que pueden ser resueltas independientemente y ello no ofrece dificultad para la marcha del juicio, que se puedan fallar separadamente, es decir, la regla general es que la demanda reconvenzional se falla conjuntamente con la demanda principal en una misma sentencia, pero el tribunal puede fallarlas por separado cuando esto no entorpece la marcha del juicio. Esta es una decisión que puede tomar el juez y no necesariamente se requiere petición de parte.

3.10.4 Competencia para reconvenir.

Esta materia se encuentra regulada en los artículos 315 C.P.C. y 311 C.O.T.

Para su mejor entendimiento se analizará de acuerdo a los distintos elementos de la competencia absoluta y relativa.

a) Territorio. Este elemento no se toma en cuenta, en consecuencia, el juez que es competente para conocer de la cuestión principal, es competente también para conocer de la demanda reconvenzional, cualquiera que sea el domicilio del demandado reconvenzional. El fundamento es por la aplicación de la regla de la extensión, prevista en el artículo 111 inciso 2° C.O.T.

b) Materia. El juez de la cuestión principal es competente para la cuestión reconvenzional sólo si la materia respectiva está dentro de su competencia; por ejemplo, el juez del Quinto Juzgado Civil de Santiago conoce una demanda de cobro de dinero de una obligación de carácter civil y el demandado reconviene por prestaciones laborales, en este caso el juez civil no puede conocer de esa reconversión.

c) Cuantía. El juez que conoce de lo principal es competente también para conocer de la demanda reconvenzional cuando la cuantía de la reconversión cae de lleno en su competencia o, si por dicha cuantía la cuestión habría sido conocida por un juez inferior, por el contrario, si por la cuantía debiera conocer un tribunal superior, el juez no es competente.

d) Fuero. Este elemento tampoco se toma en cuenta, precisamente por la regla de la extensión, así el juez competente para conocer de la cuestión principal lo es también para conocer de la reconversión cualquiera sea la calidad o dignidad del demandado reconviniendo o del demandante reconvenzional.

Artículo 315. *No podrá deducirse reconversión sino cuando el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando sea admisible la prórroga de jurisdicción. Podrá también deducirse aun cuando por su cuantía la reconversión deba ventilarse ante un juez inferior.*

Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconversión separadamente de los que son materia de la demanda.

No es necesario que exista vinculación jurídica o lógica entre la demanda principal y la demanda reconvenzional, pudiendo ser cuestiones totalmente diferentes.

Como principio de carácter general, para que la demanda reconvenzional sea admisible debe estar sometida al mismo procedimiento que la demanda principal. Esto no significa que ambas estén sometidas necesariamente a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, pueden estar sometidas a otras reglas más breves o más simplificadas.

Con todo, se ha afirmado que cuando la acción reconvenzional tiene una tramitación más concentrada, el demandante reconvenzional puede renunciar a esta tramitación y seguir las normas procedimentales de la cuestión principal. Por ejemplo, si la demanda principal debe tramitarse conforme a las reglas del juicio ordinario y la demanda reconvenzional debe tramitarse de acuerdo a las reglas del juicio sumario, el demandante reconvenzional puede renunciar a esa tramitación más concentrada y someterse a las normas del juicio ordinario de mayor cuantía.

3.11 Excepciones anómalas.

Las excepciones anómalas, son excepciones perentorias que por su importancia pueden ser opuestas en otras oportunidades que la contestación de la demanda. En efecto, es tal su importancia, que a los ojos del legislador pudo haber sido injusto no haber dado otra oportunidad al demandado.

Estas excepciones se encuentran contempladas en el artículo 310 y son las siguientes:

a) Prescripción. Esta excepción puede referirse a la prescripción de una obligación como también a la prescripción de una acción, no siendo lo mismo, ya que esta última no significa necesariamente la prescripción de la obligación, pudiendo permanecer como obligación natural.

b) Cosa juzgada y transacción. Es lógico que estas dos excepciones sean anómalas, porque bien puede ocurrir que la cosa juzgada se produzca con posterioridad a la contestación de la demanda. Lo mismo es extensible para la transacción.

c) Pago efectivo de la deuda cuando se funde en un antecedente escrito. El demandado puede pagar una vez iniciado el juicio, siendo éste eficaz para enervar la pretensión respectiva. Es importante que exista un antecedente escrito (le da plausibilidad a la respectiva excepción).

Las excepciones anómalas se pueden oponer en *primera instancia* hasta antes de la notificación de la citación para oír sentencia, ya que ésta cierra definitivamente el debate. En *segunda instancia* hasta antes de la vista de la causa, que se inicia al momento de colgarse el número de orden que tiene la causa en el día respectivo.

Si las excepciones anómalas se oponen antes de recibir la causa a prueba, se tramitarán conjuntamente con la cuestión principal y la resolución que recibe la causa a prueba también se referirá a estas excepciones anómalas. Si se oponen después de recibida la causa a prueba se tramitarán incidentalmente, y en tal evento, en el incidente respectivo se podrá recibir a prueba el que será fallado en la sentencia definitiva.

Si la excepción anómala se opone en segunda instancia se le dará tramitación incidental, entonces podrá o no haber prueba, y será en la sentencia definitiva donde el tribunal se pronunciará en única instancia respecto de la excepción.

Artículo 310. *No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa; pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en primera instancia, o de la vista de la causa en segunda.*

Si se formulan en primera instancia, después de recibida la causa a prueba, se tramitarán como incidentes, que pueden recibirse a prueba, si el tribunal lo estima necesario, y se reservará su resolución para definitiva.

Si se deducen en segunda, se seguirá igual procedimiento, pero en tal caso el tribunal de alzada se pronunciará sobre ellas en única instancia.

3.12 Réplica y dúplica.

De la contestación de la demanda se da traslado al actor para que replique por el término de seis días, y de la réplica se da traslado al demandado, por igual término, para que evacúe el trámite de dúplica (artículo 311).

Vale la pena recordar el artículo 312 que señala que es posible modificar la demanda y la contestación, en los escritos de réplica y dúplica, con el límite que no se pueden alterar las acciones y excepciones que sean objeto principal del juicio.

*En los escritos de réplica y dúplica, podrán las partes **ampliar, adicionar o modificar** las acciones y excepciones que se hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que se puedan alterar las que sean objeto principal del pleito* (artículo 312).

Es un criterio casuístico el determinar cuáles son las acciones y excepciones que son objeto principal del pleito y, en consecuencia, cuáles son posibles de ampliar, adicionar o modificar. Igual observación cabe respecto de la dúplica donde también se pueden ampliar, adicionar y modificar las excepciones.

Tema 4: Período de Conciliación.

La conciliación se encuentra regulada en el Título II del Libro II, artículos 262 a 268 C.P.C.

Antes de la Ley Nº 19.134 de 1994 este trámite era, por regla general, un trámite voluntario, sin embargo, hoy es un trámite obligatorio o necesario terminado que sea el período de discusión, salvo las excepciones legales. No obstante lo anterior, el tribunal puede en cualquier estado de la causa, como trámite de carácter voluntario instar a la conciliación.

La conciliación se inscribe dentro del gran campo de las soluciones autocompositivas, esto es, la solución del conflicto a través del acuerdo de las partes en contienda, cuyas manifestaciones son:

a) La transacción, que es un contrato en virtud del cual se pone término a un conflicto pendiente o se precave un litigio eventual, mediante concesiones recíprocas. Su característica fundamental es que se celebra fuera del proceso.

b) El avenimiento, que pone término a un proceso pendiente, y se realiza dentro del proceso. El avenimiento tiene dos expresiones perfectamente distinguibles.

i) El avenimiento propiamente tal, que es el acuerdo al cual llegan las partes dentro del proceso, pero sin intervención del órgano jurisdiccional; y

ii) La conciliación, que es el avenimiento como consecuencia de la participación activa del órgano jurisdiccional (puede producirse en 1º o 2º instancia e incluso ante la Corte Suprema).

El avenimiento puede ser total, si abarca a todas las partes y a todos los asuntos en contienda, conduciendo al término del respectivo procedimiento, o bien parcial, si se refiere sólo a algunas partes o algunos de los asuntos en contienda, y en este caso continuará el juicio respecto de las materias no avenidas o las personas no comprendidas en el acto.

El avenimiento produce el efecto de la cosa juzgada y constituye en sí mismo título ejecutivo perfecto (artículo 434 N° 3).

4.1 Procedencia del llamado a conciliación

Como ya se ha señalado el artículo 262 lo establece como un trámite esencial y obligatorio en *todo juicio civil, en que sea admisible la transacción*.

Aquí claramente hay una remisión del avenimiento a la transacción, y aunque son instituciones diversas sólo es avenible (conciliable) lo que es transigible. Pero el legislador ha ido más lejos y ha señalado que aún si el asunto es transigible hay algunos procedimientos donde no debe llamarse a conciliación como trámite esencial u obligatorio, y estos procedimientos corresponden a los Títulos I, II, III, V y XVI del Libro III, procedimientos que se refieren a:

- a) Juicio ejecutivo por obligaciones de dar, hacer y no hacer (I y II).
- b) Derecho legal de retención (III). Este es un procedimiento especial, en virtud del cual un acreedor puede constituirse en preferente cuando se declara a su favor el derecho legal de retención respecto de ciertos bienes, con lo cual el bien, según sea su naturaleza jurídica, se considera hipotecado o pignorado. Así por ejemplo, el arrendatario tiene derecho a ser restituido por el arrendador de ciertas mejoras que introduzca en el bien (mejoras necesarias y en ciertos casos las mejoras útiles), si el arrendador no cumple con esta obligación el arrendatario puede pedir que se declare en su beneficio el derecho legal de retención sobre el inmueble arrendado, que se considerará hipotecado; el posadero tiene derecho a que el huésped le pague el consumo que le ha causado su alojamiento, en tal caso las valijas y todo lo que ha introducido éste en la posada responden de esa obligación, ergo el posadero puede solicitar que se declare el derecho legal de retención sobre todo el equipaje del huésped, equipaje que se considerará pignorado.
- c) Citación de evicción (V).
- d) Juicios de hacienda (XVI). Son aquellos juicios en los cuales tiene interés el Fisco y son de conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia. En este caso no cabe el llamado a conciliación, ya que por regla muy general, en virtud de normas contenidas en la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, está prohibida la transacción en juicios de hacienda.
- e) Tampoco es necesaria la conciliación en el caso del artículo 313, artículo que no trata de un procedimiento especial, sino que se refiere a dos situaciones, cuando hay allanamiento a la demanda y cuando las partes solicitan, terminado que sea el período de discusión, que derechamente se cite a oír sentencia.
- f) Cuando no sea admisible la transacción, por ejemplo, en los juicios sobre estado civil de las personas.

4.2 Rol de juez en la conciliación.

En la fase de conciliación el juez debe jugar un papel activo, como lo señala el artículo 262, en efecto debe proponer *personalmente bases de arreglo*, y para y tal efecto debe llamar a las partes a una audiencia para un día no anterior al 5º día ni posterior al 15º contado desde la notificación de la resolución. Esta resolución debe notificarse *por cédula* ya que ordena la comparecencia personal de las partes.

Esta regla tiene una excepción aplicable a aquellos procedimientos donde la contestación de la demanda se realiza en un comparendo (juicio sumario, algunos interdictos posesorios, juicios especiales del

contrato de arrendamiento), donde no se cita a una audiencia especial para la conciliación, sino que ésta tiene lugar en el comparendo de contestación.

Artículo 262. *En todo juicio civil, en que legalmente sea admisible la transacción, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan los Títulos I, II, III, V y XVI del Libro III, una vez agotados los trámites de discusión y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.*

Para tal efecto, las citará a una audiencia para un día no anterior al quinto ni posterior al decimoquinto contado desde la fecha de notificación de la resolución. Con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite.

El precedente llamado a conciliación no obsta a que el juez pueda, en cualquier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria, una vez evacuado el trámite de contestación de la demanda.

Por su parte, el artículo 263 contiene tres ideas que deben destacarse:

a) Señala que le juez obrará como “*amigable componedor*”, término que es altamente criticable porque puede llevar a confusión, ya que al árbitro arbitrador se le denomina amigable componedor, y aquí claramente el papel que realiza el juez no es de árbitro arbitrador sino de conciliador, en el sentido de ir acercando las posiciones de las partes.

b) Que el juez trate de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio.

c) Finalmente la disposición dice que *las opiniones que emita el juez no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa*, esto tiene importancia porque existen causales de impugnancia y de recusación que dicen relación con que el juez haya manifestado su dictamen previamente con conocimiento de causa (artículos 195 N° 8 y 196 N° 10 C.O.T.).

Artículo 263. *El juez obrará como amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa.*

4.3 Forma de comparecer a la audiencia.

Deben concurrir las partes por sí o por apoderado, aunque el apoderado no tenga poder para transigir, pero en tal evento, si efectivamente se llega a la conciliación, se requerirá que la parte posteriormente ratifique el avenimiento. Sin embargo, el juez puede exigir la comparecencia personal de las partes, asistidas por sus abogados (artículo 264 inciso 1°).

El inciso 2° artículo 264 analiza la situación de que en el juicio respectivo haya pluralidad de partes, y en tal evento, la audiencia se realizará con las partes que concurren. Si la conciliación se logra, el juicio continuará con las partes no hubieren asistido o no hubieren aceptado la conciliación.

El artículo 265 señala la posibilidad que la audiencia pueda ser suspendida para que las partes deliberen entre sí, por media hora; y también puede ser postergada para dentro de tercero día, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, y se dejará testimonio de estas suspensiones o prórrogas en el expediente. En todo caso, a la nueva audiencia comparecen las partes sin nueva notificación.

El artículo 266 da la facultad al juez para que actúe de oficio, pudiendo ordenar que se agreguen aquellos antecedentes y medios probatorios que estime pertinentes.

4.4 Acta de conciliación.

De la conciliación total o parcial **se levanta acta, en la cual se consignan**_que consignan sólo las especificaciones del arreglo, el acta debe ser suscrita por el **juez**, las **partes** que lo deseen y el **secretario**, y se estimará como **sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales** (artículo 267).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 434 N° 3 C.P.C., el acta de avenimiento suscrita ante el juez y con la firma del secretario es título ejecutivo perfecto.

La firma del secretario es un requisito de validez, ya que el acta de conciliación es una actuación judicial y como tal debe estar autorizada por el ministro de fe interviniente.

Si se rechaza la conciliación, o no se efectúa el comparendo, por ausencia de todas las partes, el secretario certifica este hecho, y debe entregar los autos al juez para que reciba la causa a prueba, si fuere procedente (artículo 268).

Tema 5: Período de Prueba.

El período de prueba tiene lugar una vez que ha finalizado el período de discusión y se ha verificado el comparendo de conciliación, sin resultado o con resultado parcial. Aunque la ley no lo dice, de acuerdo con el principio de pasividad en materia procesal civil los tribunales sólo actúan a petición de parte, por ende, la recepción de la causa a prueba es consecuencia de una petición específica de alguna o de ambas partes.

Además de agotadas las etapas anteriores, es menester que *haya* controversia entre las partes, controversia que redunde en hechos sustanciales y pertinentes, o que estando en rebeldía el demandado, *pudo haber controversia*.

Artículo 318. *Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que **hay o puede haber** controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.*

El artículo 313 inciso 2° contiene una calificada excepción, donde no obstante haber controversia el tribunal no recibe la causa a prueba, excepción que tiene lugar cuando las partes de común acuerdo solicitan al tribunal que falle el pleito sin más trámite.

Cabe señalar que no debe recibirse la causa a prueba cuando no hay controversia sobre hechos sustanciales y pertinentes, ya sea porque hay un allanamiento expreso o tácito del demandado, ya porque la controversia sólo se refiere a materias de derecho.

Habiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos el tribunal dicta la resolución que recibe la causa a prueba.

5.1 Resolución que recibe la causa a prueba.

Es una resolución compleja que debe cumplir con los requisitos comunes a toda resolución judicial, pero además con requisitos específicos:

- a) Declarar que recibe la causa a prueba. Formalmente dirá *“Vistos, se recibe la causa a prueba por el término legal”*;
- b) Fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos;
- c) Por costumbre judicial, en esta resolución se fijan las audiencias en que se recibirá la prueba testimonial, así la resolución dirá *“Se fija para la recepción de la prueba testimonial los últimos cinco días del probatorio, a tal hora”*.

La mención de mayor importancia es la fijación de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, para tal efecto el tribunal tiene que remitirse a los escritos fundamentales, en consecuencia, examinará la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, y determinará cuáles son las cuestiones fácticas que deben ser probadas por las partes.

A veces los tribunales, erradamente, fijan como hechos a acreditar cuestiones de derecho, por ejemplo, *“validez o nulidad del contrato celebrado entre las partes”*.

Es interesante mencionar que se ha creado una línea divisoria entre lo que son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y los puntos de prueba; distinción que no tiene clarísimo asidero en nuestra ley, porque el artículo 318 se refiere indistintamente tanto a los hechos como a los puntos de prueba. De lo anterior se podría entender que para el legislador punto de prueba y hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos están en una relación de sinonimia, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia están contestes en que *los puntos de prueba son las circunstancias específicas respecto de un determinado hecho*, fijado como tal en la resolución que recibe la causa a prueba; dicho de otra manera, los hechos fijados en la resolución pueden ser desagregados en diversos puntos de prueba.

La distinción no es baladí, porque el legislador señala respecto de la prueba testimonial un límite en cuanto al número de testigos que pueden declarar por cada hecho, en consecuencia, desde una perspectiva práctica, es necesario que cuando un hecho se desglosa en varios puntos de prueba se haga la distinción, así el testigo podrá declarar sobre los distintos puntos que forman parte de un mismo hecho, sin aplicarse la limitación mencionada.

5.2 Naturaleza jurídica de la resolución que recibe la causa que a prueba.

A pesar de su nombre, “*auto de prueba*”, la resolución que recibe la causa a prueba es una sentencia interlocutoria de segunda clase (o grado), porque se pronuncia sobre un trámite que servirá de base para la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria. Misma naturaleza jurídica comparte la resolución que recibe un incidente a prueba.

Las sentencias interlocutorias, sean de primera o segunda clase, cuando se encuentran firmes o ejecutoriadas producen el efecto de cosa juzgada, en consecuencia, la resolución que recibe la causa a prueba una vez firme o ejecutoriada produce el efecto de la cosa juzgada en el sentido de que quedan establecidos los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, de manera tal que la sentencia definitiva no podrá entrar en contradicción con la interlocutoria de prueba, porque si así ocurre se estaría vulnerando el principio de la cosa juzgada.

La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48.



5.3 Errores en la recepción de la causa a prueba.

Los errores en que puede incurrir un juez al momento de recibir la causa a prueba, son los siguientes:

- a) No recibir la causa a prueba debiendo hacerlo.
- b) Recibir la causa a prueba no debiendo hacerlo.
- c) Errar en la fijación de los hechos.

Las vertientes posibles de error recaen sobre primera parte de la resolución que recibe la causa a prueba (a y b) o respecto de la segunda parte (c). Esta distinción tiene gran importancia, porque la manera de reaccionar frente a cada error es diferente.

a) No recibir la causa a prueba debiendo hacerlo.

La no recepción de la causa a prueba puede ser explícita o implícita. Será explícita cuando el juez se niega derechamente a recibir la causa a prueba (“no ha lugar”), o bien, implícitamente, cuando cita a las partes para oír sentencia.

¿Qué recurso procesal procede en este caso?

Sólo procede recurso de apelación de acuerdo a lo previsto en el inciso 1° del artículo 326, que dispone “*es apelable la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba*”. Esta apelación se concede en el solo efecto devolutivo.

En relación con la remisión del artículo 326 al inciso 2° del artículo 313, hay que señalar que el juez implícitamente está negando la recepción de la causa a prueba, pero esta resolución no es apelable porque las partes están de acuerdo en que el juicio se falle sin más trámite, por lo tanto, no hay agravio y, si no hay agravio, no hay recurso.

b) Recibir la causa a prueba no debiendo hacerlo.

En este caso el tribunal fija hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y ordena recibir la causa a prueba, cuando no hay hechos que presenten esos caracteres, por ejemplo, cuando la discusión es netamente jurídica.

En cuanto a los recursos que proceden, hay que señalar que no es admisible el recurso de reposición, porque la reposición sólo cabe contra autos y decretos y la resolución que recibe la causa a prueba es una interlocutoria. Siendo un tema opinable, podemos decir que tampoco procedería recurso de apelación por mandato del artículo 326 inciso 2º, que señala que son inapelables las resoluciones que disponen la práctica de una diligencia probatoria, y en la medida que está ordenando recibir la causa a prueba implícitamente está ordenando la práctica de diligencias probatorias.

c) Errar en la fijación de los hechos.

Los posibles errores pueden ser tres, fijar menos hechos de los que corresponden, fijar más hechos de los que corresponden y errar en la formulación de los hechos.

Cuando el tribunal yerra en los hechos, la parte agraviada puede deducir el recurso de reposición, y subsidiariamente, el recurso de apelación. Que proceda el recurso de reposición es doblemente excepcional, primero, porque se admite reposición respecto de una sentencia interlocutoria (sólo son reponibles los autos y los decretos), y segundo, porque el recurso debe ser interpuesto dentro de tercero día, y la regla general es que sea interpuesto dentro de quinto día.

En el recurso se pedirá que se elimine el hecho que indebidamente se incluyó, que se incluya el hecho omitido o que se formule correctamente un hecho.

Frente a esta reposición el tribunal tiene la alternativa de darle tramitación incidental o de resolverla de plano (artículo 319 inciso 2º). Si la reposición es desechada y la parte planteó apelación subsidiaria, la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo (artículo 319 inciso final). Si el tribunal acoge la reposición, contra esta resolución la parte contraria no tiene a su vez recurso de reposición, sino que tiene que apelarla derechamente y en tal caso la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, y esto por expreso mandato del artículo 326 en la segunda parte del inciso 1º.

Artículo 319. *Las partes podrán pedir reposición, dentro de tercero día, de la resolución a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen otros.*

El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente.

La apelación en contra de la resolución del artículo 318 sólo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo.

5.4 Ampliación de la prueba.

La prueba, esto es, los hechos a acreditarse, por regla general, quedan fijados en la resolución que recibe la causa a prueba. Sin embargo, es posible la ampliación de la prueba en dos casos:

a) Cuando dentro del término probatorio ocurre un hecho sustancialmente relacionado con el asunto que se ventila. En otros términos, se recibió la causa a prueba, quedó firme la respectiva resolución y empezó a correr el término probatorio y dentro de éste ocurre un hecho que necesita ser acreditado porque está relacionado con el asunto que se ventila (inciso 1º artículo 321).

b) Es también admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados antes de recibirse la causa a prueba, con tal que jure el que los alega que sólo en ese momento han llegado a su conocimiento (inciso 2º artículo 321).

La petición de ampliación de la prueba se tramita de acuerdo a las reglas de los incidentes, en cuaderno separado y sin suspender el término probatorio. Deducido el incidente se da traslado a la contraparte por tres días, quien en ese momento puede alegar nuevos hechos, siempre y cuando reúnan los requisitos ya analizados o tengan relación con los hechos nuevos alegados por el solicitante (artículo 322 incisos 1º y 2º).

La resolución que ordena la ampliación no es susceptible de reposición, porque es una sentencia interlocutoria, y tampoco es susceptible de apelación, por aplicación del inciso 2º del artículo 326, ya que estaría ordenando diligencias probatorias y estas resoluciones son inapelables.

Cuando se produce el fenómeno de la ampliación de la prueba, bien podría ocurrir que el término probatorio ordinario ya hubiese transcurrido, y en tal evento se puede abrir un término probatorio especial para acreditar los nuevos hechos (artículo 327 inciso 2º).

5.5 Término probatorio.

Es el lapso destinado para que las partes pidan y/o suministren las pruebas que ellas han solicitado (artículo 327 inciso 1º).

Importante característica es que el término probatorio es la última oportunidad, por regla general, para solicitar la práctica de diligencias probatorias, ergo se pueden solicitar con antelación al probatorio, pero no una vez extinguido éste.

En relación con la oportunidad para realizar el diligenciamiento de prueba, el término probatorio no es fatal para practicar las diligencias de prueba, salvo cuando expresamente lo señale el legislador, como ocurre con la prueba testimonial.

En otros procedimientos distintos al juicio ordinario de mayor cuantía, no se habla de término probatorio, sino que de oportunidad probatoria, porque la prueba se rinde en una sola oportunidad (el comparendo o audiencia).

5.5.1 Características del término probatorio.

a) Es un **término eventual**, surgirá sólo si se recibe la causa a prueba.

b) *Normalmente es un término legal*, su duración la fija la ley, pero también puede ser judicial o convencional.

c) *Es reducible por acuerdo de las partes* (artículo 328 inciso 2º). Cuando la reducción del término probatorio se acuerda por mandatario, éste debe estar premunido de facultades especiales, porque importa renuncia a un término legal.

d) Es *común*, es decir, se inicia (y termina) simultáneamente para todas las partes. Sin embargo, los términos probatorios extraordinarios y especiales están establecidos para la parte respecto de la cual se conceden, sin perjuicio de que la parte contraria puede asistir a todas las actuaciones dentro de dichos términos probatorios.

e) **No se suspende**, por expreso mandato del artículo 339, salvo expresa solicitud de todas las partes.

5.5.2 Clasificación del término probatorio.

El término probatorio puede ser:

- a) Ordinario (artículo 328).
- b) Extraordinario (artículos 329 a 338)
- c) Especial (artículos 327 inciso 1º, 339, 340).

5.6 Término probatorio ordinario.

Su inicio está regulado en el artículo 320 inciso 1º, a propósito del plazo para presentar la lista de testigos, es una norma mal planteada, concebida y redactada.

Para determinar el comienzo del término probatorio ordinario hay que hacer una distinción:

- a) No se deduce reposición en contra de la resolución que recibe la causa prueba. El término probatorio se inicia a partir de la notificación de esta resolución, la que debe notificarse por cédula (artículo 48). Como es un término común el plazo se al momento de practicarse la última notificación.
- b) Se deduce reposición en contra de la resolución que recibe la causa prueba. El término probatorio se inicia cuando se notifica por el estado diario la última resolución que se pronuncia sobre las posibles reposiciones.

Hay un manifiesto error en la redacción de a norma, porque dice el texto que el plazo se inicia desde que hay pronunciamiento respecto de la última solicitud de reposición, cuando debió haber dicho cuando se dicta la última resolución que se pronuncia sobre las reposiciones, porque bien puede ocurrir que una reposición presentada con antelación sea resuelta con posterioridad a otra. En consecuencia, la forma correcta de contar es desde el momento que se notifica por el estado diario la última resolución que se pronuncia sobre las reposiciones.

5.6.1 Duración del término probatorio ordinario

El término probatorio ordinario tiene una duración de 20 días, no se suspende ni se interrumpe, pero pueden si las partes reducirlo actuando de común acuerdo y en caso de comparecer con mandatario, este debe estar premunido de facultades especiales (incisos 1º y 2º del artículo 328 en relación con el artículo 7 inciso 2º C.P.C.).

5.6.2 Objeto del término probatorio ordinario

El término probatorio ordinario tiene por objeto solicitar y rendir toda clase de pruebas en cualquier lugar que esto ocurra, lo que se desprende del artículo 334 que señala que durante el término ordinario se puede rendir prueba en cualquier parte de la República y fuera de ella.

El término probatorio es la última oportunidad para solicitar la práctica de diligencias probatorias, pero la única oportunidad, porque antes de él es posible solicitar ciertas diligencias (artículo 327 inciso 1°).

Una cosa es que sea fatal para pedir diligencias de prueba y otra muy distinta es que sea fatal para llevar a cabo dichas diligencias, en otras palabras, la prueba solicitada oportunamente puede rendirse después del término probatorio, salvo la prueba testimonial que necesariamente debe rendirse dentro del probatorio y dentro de las audiencias que fijó el tribunal en el auto de prueba.

5.7 Término probatorio extraordinario.

Es el establecido para rendir prueba fuera de la comuna o agrupación de comunas donde se sigue el juicio, sea dentro del territorio de la República o fuera de éste.

5.7.1 Duración del término extraordinario.

Su duración es la del término ordinario más el término de emplazamiento para la o las localidades donde se va a rendir la prueba. De esta suerte el término extraordinario puede tener diferente duración en un mismo juicio, porque puede haber término extraordinario por ejemplo, para rendir prueba en Buenos Aires y en Nueva York y en París, en ese evento el término extraordinario va a ser el término ordinario más el emplazamiento para las respectivas ciudades que son distintos según la tabla de emplazamiento (artículo 329).

Artículo 329. *Cuando haya de rendirse prueba en otro territorio jurisdiccional o fuera de la República, se aumentará el término ordinario a que se refiere el artículo anterior con un número de días igual al que concede el artículo 259 para aumentar el de emplazamiento.*

Es muy importante tener presente que el término extraordinario en cuanto a su complemento, sólo permite rendir prueba en el lugar para el cual fue otorgado (artículo 335).

5.7.2 Oportunidad y forma del término probatorio extraordinario.

Debe ser pedido antes que expire el término ordinario, debiendo señalarse el lugar dónde se rendirá la prueba.

El término extraordinario se subclasifica en:

a) Para rendir prueba dentro del territorio de la República. Este término probatorio se concede siempre que se solicite, sin consignación previa, salvo que haya justo motivo para creer que se está pidiendo maliciosamente con el propósito de retardar la marcha del juicio (artículo 330).

Frente a la solicitud, el tribunal accede a esta petición “con citación”, lo que significa que la parte contraria tiene un plazo fatal de tres días para oponerse a la solicitud, si se opone se genera un incidente que deberá ser resuelto el tribunal; si no hay oposición, la parte que obtuvo el término extraordinario podrá llevar a cabo las diligencias de prueba en el lugar para el cual fue concedido (artículo 336 inciso 1°).

Si se produce incidente, se aplica la regla general de éstos, tramitándose en pieza separada y no suspende el término probatorio (artículo 336 inciso 2°). Con todo, los días que dure la tramitación de dicho incidente no se computan para los efectos de descontarlos del término probatorio extraordinario (artículo 336 inciso final).

Si la prueba que se rinde es impertinente o no se rinde prueba alguna, la parte esta obligada a pagar a la otra, los gastos en que haya incurrido para presenciar la prueba, esta condena debe imponerse en la sentencia definitiva, pero la parte puede ser exonerada de este pago si justifica que tuvo motivos razonables para no rendir la prueba (artículo 337).

b) Para rendir prueba fuera del territorio de la República: El legislador mira con particular recelo la circunstancia de rendir prueba fuera del territorio de la República, lo cual fluye del artículo 331, donde se señalan las condiciones que copulativamente deben concurrir para que se otorgue este término probatorio extraordinario.

Son condiciones para que se conceda este término probatorio:

- a)** Que de los escritos fundamentales del período de discusión aparezca que los hechos han acaecido en el país respecto del cual se solicita el término extraordinario, o que allí existen los medios probatorios que se pretenden obtener.
- b)** Si se trata de prueba instrumental, que se determine la clase y condición de los instrumentos de que piensa valerse el solicitante y se señale el lugar donde se encuentran.
- c)** Si se trata de prueba testimonial, que se exprese el nombre y residencia de los testigos o se justifique algún antecedente que haga presumible la conveniencia de obtener sus declaraciones.

Concurriendo estos requisitos copulativos, la parte interesada presenta su solicitud al tribunal y lo decretará con audiencia a diferencia del otro término extraordinario que se concede con citación, en consecuencia, la contraparte tendrá un plazo de tres días para manifestar lo que estime conveniente respecto de sus derechos (inciso 1º artículo 336), una vez evacuado el traslado o en su rebeldía, el tribunal se pronunciará derechamente sobre la solicitud. Como puede observarse en este caso el incidente es necesario y no eventual

También rige el artículo 337, en el sentido de que quien obtuvo este término extraordinario para fuera de la República y no rinde la prueba o rinde una prueba impertinente, será obligado a pagar a la parte contraria los gastos en que haya incurrido para presenciarla. Esta condenación debe imponerse en la sentencia definitiva, pero la parte puede ser exonerada de este pago si justifica que tuvo motivos razonables para no rendir la prueba.

Una sustancial diferencia con la concesión del término extraordinario para rendir prueba dentro del territorio de la República, es que en este caso se exige una consignación previa, es decir, debe consignarse junto con la solicitud una determinada cantidad de dinero en la cuenta corriente del tribunal. Esta consignación no puede fijarse en menos de medio sueldo vital ni en más de dos sueldos vitales, la que irá a beneficio fiscal si ocurre alguna de las circunstancias que señala el artículo 338, circunstancias que manifiestan mala fe por parte del litigante:

- a) Que no se ha hecho diligencia alguna para rendir la prueba pedida.
- b) Que los testigos no tenían conocimiento de los hechos, ni se han hallado en situación de conocerlos.
- c) Que los testigos o documentos no han existido nunca en el país en que se ha pedido que se practiquen las diligencias probatorias.

5.7.3 Tramitación del término probatorio extraordinario.

Junto con la solicitud de término probatorio término extraordinario, la parte debe pedir el envío del respectivo exhorto, sea nacional o internacional, e indicar en él las facultades que se conceden al tribunal exhortado, ya que al ser su competencia delegado deben indicarse con precisión sus facultades, asimismo, debe solicitarse en la presentación si es necesaria la citación judicial de los testigos.

5.8 Términos probatorios especiales.

El fundamento de los términos probatorios especiales es que el término probatorio ordinario no se suspende y tampoco es ampliable, salvo las excepciones ya analizadas. Frente a esta grave limitación, el legislador ha tenido que contemplar la posibilidad de términos probatorios especiales, los que sólo proceden en los casos expresamente regulados y previa resolución judicial que los conceda.

Los términos probatorios especiales que contempla el Código son:

a) **Entorpecimiento.** El entorpecimiento, desde el punto de vista procesal, es el caso fortuito o fuerza mayor, esto es, el acaecimiento de un hecho o de una circunstancia que imposibilita la realización de una determinada actuación. Si el entorpecimiento se refiere a la prueba, surge la posibilidad de un término probatorio especial para rendir la prueba que no se pudo rendir oportunamente. El entorpecimiento debe alegarse al momento de presentarse el obstáculo o dentro de los tres días siguientes (incisos 2° y 3° artículo 339).

b) **Prueba testimonial** (artículo 340). El término probatorio es fatal para rendir la prueba testimonial, pero bien puede ocurrir que ésta se inicie dentro del probatorio, pero no pueda completarse íntegramente dentro de él, en tal evento puede solicitarse un término probatorio especial para terminar la testimonial oportunamente iniciada. Este derecho puede solicitarse sólo una vez, dentro del término probatorio o dentro de los tres días siguientes a su vencimiento.

Si el entorpecimiento deriva de la no presencia del juez, el secretario debe certificar este hecho a petición verbal de cualquiera de las partes y en mérito de ese certificado el tribunal debe fijar un nuevo día para la recepción de la prueba.

c) **Artículo 339 inciso final.** Esta disposición se refiere a la situación que se produce cuando se ha solicitado reposición, con apelación subsidiaria en contra de la interlocutoria de prueba. La apelación se concede en el solo efecto devolutivo, en consecuencia, sigue tramitándose el juicio. Bien puede ocurrir que la Corte de Apelaciones revoque la resolución recurrida y, por ejemplo, agregue un hecho nuevo o modifique un hecho consignado en la resolución respectiva. Ergo, cuando el expediente vuelva a primera instancia, el juez a quo deberá abrir un término especial de prueba, al que se refiere el inciso final del artículo 339. Este término especial no puede exceder de ocho días y no requiere solicitud de parte.

Agrega la disposición una obviedad, en el sentido de que la prueba anteriormente rendida y que no esté afectada por la resolución del tribunal de alzada, naturalmente tendrá pleno valor.

d) **Medidas para mejor resolver** (artículo 159 incisos penúltimo y último). El artículo 159 regula las medidas para mejor resolver, que puede decretarlas el tribunal una vez citadas las partes para oír sentencia y siempre que crea necesario o indispensable agregar otros elementos de prueba para esclarecer debidamente el aspecto fáctico del conflicto.

Estas medidas son excepción al principio de la pasividad de los tribunales, pues deben decretarlas de oficio y cuando se ordenan las partes deben cumplirlas dentro de cierto plazo, para lo cual el tribunal puede abrir un término especial de prueba no superior a ocho días, improrrogables y limitado a los puntos que el propio tribunal decida (artículo 159 inciso penúltimo).

Como regla general, tratándose de medidas para mejor resolver, todo lo que se resuelva en torno a ellas es inapelable, sin embargo, la fijación de este término especial de prueba es precisamente apelable en el solo efecto devolutivo (artículo 159 inciso final).

e) Tacha de los testigos (artículo 376). En relación con la prueba testimonial se puede producir lo que se denomina la tacha del testigo, es decir, hacer valer alguna de las causales de inhabilidad que establece el legislador. Estas tachas se invocan en un incidente que se produce dentro del juicio, y es perfectamente posible que el tribunal estime que es necesario rendir prueba acerca de la tacha deducida. En tal evento, la regla general es que esta prueba se rinda dentro del término ordinario, pero si éste ha concluido o no es suficiente, se puede ampliar como un término especial de prueba hasta por diez días, y este término ampliado, incluso puede ser aumentado extraordinariamente cuando sea necesario rendir prueba fuera de la comuna o agrupación de comunas en que tiene su asiento el tribunal.

f) Revocación de la confesión (artículo 402 incisos 2° y 3°). Para el C.P.C. la confesión es la reina de las pruebas y, por ende, no se admite prueba en contra de los hechos personales confesados por la parte. Sin embargo, el litigante que ha confesado puede revocar su confesión, relativa a hechos personales como no personales, alegando error de hecho, para lo cual el tribunal puede abrir un término especial de prueba.

g) Prueba en segunda instancia (artículo 207). En principio no es admisible prueba en segunda instancia, salvo los casos contemplados en el artículo 207 inciso 1º: excepciones anómalas opuestas (remisión al artículo 310), prueba documental (remisión al artículo 348) y confesional (remisión al artículo 385).

Pero también el tribunal de segunda instancia, una vez citadas las partes para oír sentencia, puede decretar medidas para mejor resolver. Dentro de éstas concurriendo los requisitos que señala el legislador, puede ordenar recepción de prueba testimonial, para lo cual debe abrir un término especial de prueba por el plazo que prudencialmente fije y que no puede exceder de ocho días. La lista de testigos se presentará dentro de segundo día, contado desde que se notifique por el estado diario la resolución que ordena la prueba,

Es importante mencionar el artículo 325 que se refiere a la prueba que se rinde ante tribunales colegiados. En este caso, la prueba se puede rendir ante todo el tribunal, o bien, ante uno de sus integrantes designado para tal efecto.

h) Artículo 327 inciso 2°.

En los casos contemplados en los artículos 310, 321 y 322 el tribunal, de estimar necesaria la prueba, concederá un término especial de prueba que se regirá por las normas del artículo 90, limitándose a quince días el plazo total que establece en su inciso tercero y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 431.

La remisión al artículo 310 debe entenderse hecha a las excepciones anómalas, y la remisión a los artículos 321 y 322 a la ampliación de la prueba.

En consecuencia, si se deducen excepciones anómalas después de recibida la causa a prueba o tiene lugar la ampliación de la prueba, el tribunal puede conceder un término especial de prueba, el que se rige por las reglas de los incidentes (referencia al artículo 90), sin embargo, si ha de rendirse prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal el término extraordinario no puede superar los quince días. Finalmente, la remisión del artículo 327 al artículo 431 significa que no es motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación de la sentencia el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal.

5.9 Norma de carácter general aplicable a toda la prueba.

Toda diligencia probatoria debe realizarse previo decreto del tribunal que conoce la causa, notificado a las partes (artículo 324).

Esta norma tiene por objeto asegurar el contradictorio paritario, porque se da oportunidad a la parte contraria para que se oponga a la práctica de la diligencia probatoria o para que fiscalice su correcta rendición. Además, debe ser complementada por los artículos 795 números 5 y 6 y 800 números 2 y 5, que se refieren al recurso de casación en la forma fijando los trámites esenciales en primera y en segunda instancia, trámites que si se omiten hacen posible que prospere el recurso.

Entre estos trámites, se encuentra una norma que señala que toda diligencia probatoria debe ordenarse por medio de una resolución y con citación de la parte contraria, y que la agregación de los documentos, también debe efectuarse con citación de la parte contraria u otra oportunidad para que los impugne.

Ordenar la diligencia con citación o agregar el instrumento con citación o con un plazo mayor, significa que se otorga a la parte contraria un término fatal de tres días para oponerse a la realización de la diligencia probatoria u objetar el documento. Por ejemplo, si se pide que se decrete una inspección personal del tribunal, el tribunal deberá proveer “como se pide, con citación” y deberá notificar por el estado diario la respectiva resolución, en consecuencia, la parte contraria tendrá la oportunidad de oponerse a la respectiva diligencia. Esto es válido respecto de todas las diligencias de prueba y es válido también respecto de los instrumentos, los que también deben acompañarse con citación o con un plazo mayor que el de tres días para los efectos de ser observado.

Tema 6: Período de Observaciones a la Prueba.

En el proceso romano-canónico esta etapa del proceso se llamaba *alegatos de bien probado*. Luego pasó a nuestro ordenamiento jurídico, y hoy lo encontramos regulado en el artículo 430, en virtud del cual las partes pueden presentar escritos de observaciones a la prueba.

El contenido del escrito tiene por objeto resaltar las bondades de la prueba presentada y desfavorecer la prueba de la parte contraria.

Es un trámite facultativo, debiendo presentarse el escrito respectivo dentro del plazo fatal de diez días, contados desde la finalización del término probatorio; si se presenta fuera de plazo, es inadmisibles y el tribunal puede devolverlo a la parte por extemporáneo. La referencia al término probatorio, es al término

probatorio ordinario, no al extraordinario ni a los especiales, en primer lugar, porque no hay mención expresa, y en segundo lugar, porque el artículo 431 modificado en 1988 se refiere al término probatorio ordinario.

Artículo 430. *Vencido el término de prueba, y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.*

Tema 7: Citación Para Oír Sentencia.

Otrora era un trámite establecido sólo para el juicio ordinario de mayor cuantía, pero **actualmente es un trámite esencial en casi todos los procedimientos.**

La virtud de este trámite es que citadas las partes para oír sentencia, se entiende cerrado el debate entre las partes. No significa convocatoria, sino que sólo pone en alerta a las partes, en el sentido de que la sentencia definitiva “ya viene”.

Esta resolución, cuya naturaleza jurídica es ser una sentencia interlocutoria de segundo grado, se notifica por el estado diario, según el artículo 432, y debe dictarse vencido el término de observaciones a la prueba, siendo indiferente si existen o no diligencias pendientes. En su contra sólo procede recurso de reposición, dentro de tercero día y fundado en error de hecho. La resolución que resuelve el recurso de reposición, ya sea acogiendo o denegándolo, es inapelable.

Artículo 432.- *Vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia.*

En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable.

Es necesario relacionar el artículo 432 con el artículo 326, que establece que es apelable la resolución que explícita o implícitamente deniega la recepción de la causa a prueba. Entonces, la regla es que sólo cabe reposición en contra de la resolución que cita a las partes a oír sentencia, pero si la citación es consecuencia de la negativa implícita de recibir la causa a prueba, procede apelación.

Como se señaló la citación para oír sentencia cierra el debate no siendo admisibles otras probanzas de las partes, no obstante esta regla el artículo 433 contiene varias excepciones.

a) Artículos 83 y 84. Se refieren a la nulidad procesal, la que, en ciertos casos, puede referirse al procedimiento todo o sólo respecto de ciertas actuaciones. Estos incidentes de nulidad, pueden ser planteados no obstante la citación para oír sentencia.

b) Artículo 159. Se refiere a las medidas para mejor resolver, las que sólo pueden decretarse a partir de la citación para oír sentencia.

c) **Artículo 290.** Dice relación con las medidas precautorias, en el sentido que el tribunal puede pronunciarse respecto de éstas para su concesión o alzamiento.

d) En relación con los documentos, la ley ha establecido que siguen corriendo los plazos para impugnarlos aunque ya se haya citado a las partes para oír sentencia, y si hay impugnación ésta se tramita en cuaderno separado y será fallada en la sentencia definitiva.

Artículo 433. *Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 83, 84, 159 y 290. Los plazos establecidos en los artículos 342 N° 3, 346 N° 3 y 347 que hubieren comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia, continuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá dentro de ellos, ejercer su derecho de impugnación. De producirse ésta, se tramitará en cuaderno separado y se fallará en la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 431.*

Tema 8: Medidas Para Mejor Resolver.

Las medidas para mejor resolver son de iniciativa del tribunal y tienen aplicación tanto en primera como en segunda instancia, con la salvedad que la prueba testimonial tiene características especiales ante el tribunal de alzada.

El legislador en una reforma del año 1989 restringió la facultad para decretar medidas para mejor resolver con la finalidad de no retardar la dictación del fallo. Antes podían ser ordenadas a partir de la citación para oír sentencia y hasta antes de la dictación del fallo, hoy en cambio, el plazo es desde la citación para oír sentencia hasta el vencimiento del plazo para dictar sentencia.

La ley fija como plazo para que el tribunal dicte sentencia definitiva sesenta días, plazo que no es fatal, ya que el juez puede lícitamente dictar sentencia después de su vencimiento, aunque puede configurarse responsabilidad funcionaria por el retardo.

Artículo 159. *Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio, medidas para mejor resolver.*

Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 431 podrán dictar alguna o algunas de las siguientes medidas:

1º *La agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes;*

Esta agregación debe hacerse otorgándole a la parte contraria el derecho de impugnación.

2º *La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y que no resulten probados;*

Se hará uso de la facultad de provocar la confesión mediante la absolución de posiciones. Aunque no se regula la forma de proceder, debe entenderse que hay una remisión a las reglas de la confesión

provocada. Es el tribunal el que fórmula el pliego de posiciones y el mismo debe guardarlo hasta el momento de la diligencia, pudiendo plantear las preguntas en forma asertiva o interrogativa.

3º *La inspección personal del objeto de la cuestión;*

4º *El informe de peritos;*

5º *La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios; y*

El tribunal no puede citar a testigos que no hayan declarado en el juicio, aunque hayan estado sus nombres en las listas presentadas por las partes. Esta es una radical diferencia con las medidas para mejor resolver en segunda instancia.

6º *La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso 3º del artículo 37.*

En este último caso y siempre que se hubiese remitido el expediente original, éste quedará en poder del tribunal que decreta esta medida sólo por el tiempo estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de ocho días este término si se trata de autos pendientes.

Para efectos de este número, es necesario sacar copias (fotocopias) autorizadas del original, el cual sólo se retiene para su examen por un plazo máximo de ocho días, si se trata de autos pendientes.

La resolución que se dicte deberá ser notificada por el estado diario a las partes y se aplicará el artículo 433, salvo en lo estrictamente relacionado con dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de la notificación de la resolución que las decreta. Vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite.

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba, no superior a ocho días, que será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento, se aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. Vencido el término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite.

Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo informe de peritos o abriendo el término especial de prueba que establece el inciso precedente. En estos casos procederá la apelación en el solo efecto devolutivo.

Las medidas para mejor resolver se notifican por el estado diario y son una excepción al silencio de las partes cuando se ha producido la citación para oír sentencia.

Para evitar las dilaciones las partes tienen un plazo fatal de veinte días para cumplir la medida decretada, contado desde la notificación de la resolución que la decreta. Las medidas que no sean cumplidas, se tendrán como no decretadas y el tribunal dictará sentencia sin más trámite.

El inciso penúltimo se refiere a una situación de poca ocurrencia y es la hipótesis que frente a una medida para mejor resolver decretada y cumplida, sea necesario esclarecer nuevos hechos; en este caso el tribunal podrá abrir un término especial de prueba, que no podrá exceder de 8 días.

El inciso final declara la inapelabilidad de la resolución que ordena una medida para mejor resolver, excepto cuando se trata del informe de peritos o para abrir un término probatorio especial. En estos casos se concede apelación en el solo efecto devolutivo.

El artículo 207 se refiere a la prueba en segunda instancia. Excepcionalmente, se puede decretar prueba testimonial no rendida en primera instancia sobre hechos importantes y estrictamente necesarios para una acertada resolución del conflicto. El tribunal, debe señalar determinadamente los hechos sobre los que debe recaer la prueba, debe abrir término especial por un número de días no superior a ocho y la lista de testigos debe presentarse dentro de segundo día de notificada la resolución por el estado diario.

Artículo 207. *En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna.*

No obstante y sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio.

En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de ocho días. La lista de testigos deberá presentarse dentro de segundo día de notificada por el estado la resolución respectiva.

Tema 9: Dictación del Fallo.

En esta etapa el juez se ve debe dictar sentencia definitiva, que es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión que ha sido objeto del juicio. El plazo para dictarla es de sesenta días contados desde la citación para oír sentencia, plazo que no es fatal para el tribunal. Por disposición del artículo 48 se notifica por cédula al apoderado de las partes.

Por disposición del artículo 431 no es motivo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal, o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución del juicio, caso en el cual la debe reiterar como medida para mejor resolver. En todo caso, si dicha prueba se recibiera por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agrega al expediente para que sea considerada en segunda instancia, si hubiere lugar a ella.

A dictación del fallo es una etapa eventual y sólo procederá cuando el juicio no haya terminado por otra causal, por ejemplo, desistimiento de la demanda, abandono del procedimiento, arbitraje o soluciones autocompositivas.

Unidad 4: Teoría General de la Prueba.

Tema 1: Generalidades.



La teoría general de la prueba se entiende asociada al juicio ordinario de mayor cuantía, y específicamente asociada a la fase probatoria, pero naturalmente esta teoría excede con mucho esta división sistemática, va mucho más allá de la fase propiamente probatoria del juicio ordinario de mayor cuantía, en consecuencia, en esta parte se ve el fenómeno probatorio en general (comprendiendo el fenómeno probatorio civil y el fenómeno probatorio penal).

En función de la teoría general de la prueba es útil recordar la **evolución histórica** en cuanto a las grandes expresiones procesales: el proceso romano, el proceso germano, el proceso romano-canónico y los fenómenos que se producen durante el siglo XIX que alteran fundamentalmente la perspectiva procesal general.

1.1 El proceso romano.

El proceso romano en sus dos fases (in iure e in iudicio) tiene como característica en cuanto a la apreciación de la prueba, el que se aplica el principio de la **apreciación racional de la prueba**, por lo que, no habían normas legales de apreciación de la prueba, ni siquiera principios rectores, sino que su apreciación quedaba entregada al criterio del magistrado llamado a resolver el respectivo asunto controvertido.

1.2 El proceso germano.

El proceso germano, tenía en este aspecto un enorme contenido de **carácter místico** y su expresión más ejemplar es la **ordalía**, que era una manera de provocar el **juicio de Dios**, para que a través de manifestaciones tangibles se pudiera establecer la responsabilidad y en definitiva aceptar o rechazar un juicio condenatorio. Las ordalias no iban dirigida a convencer al juzgador de una determinada cuestión fáctica, sino que en sí mismas importaban una decisión.

Esta curiosa expresión de carácter místico ha llevado a algunos a pretender asimilar la prueba legal con el fenómeno germano, porque en el sistema legal de apreciación de la prueba es la ley la que substituye la convicción del juzgador y se dan ciertos y determinados parámetros probatorios que el juzgador necesariamente debe seguir. Pero las normas legales sobre apreciación de la prueba se han ido produciendo y se han ido plasmando a través de la acumulación de experiencia racional, de manera que también en ella hay un estrato de racionalidad y no un estrato místico como había claramente en las ordalias.

Encontramos también, en el proceso germano, el sistema de los **cojuradores** que tiene una remota vinculación con lo que es hoy día la prueba testimonial; los cojuradores, sin embargo, no deponían respecto de hechos, sino de la **credibilidad y la buena fama del respectivo encausado**, eran en el fondo

una expresión de solidaridad con el respectivo encausado. Podríamos decir que tiene alguna similitud con los testigos de conducta en los procesos penales, testigos que no deponen respecto de hechos sino del buen nombre e irreproachable conducta anterior del procesado.

1.3 El proceso romano canónico.

El proceso romano canónico tiene una importancia muy capital desde el punto de vista de **la evolución de la prueba** y específicamente, desde el punto de vista de la **apreciación de la prueba**, porque por primera vez se aparta del sentido místico del proceso germano y del sentido puramente racional del proceso romano y se van creando ciertas **normas de apreciación de la prueba que se imponen al juzgador**, o sea, **es una normativa anterior a los hechos y anterior al proceso, que va señalando cuáles son los criterios de apreciación**.

Los canonistas empiezan a jugar con **fracciones en cuanto a la apreciación**, y así hablan, por ejemplo, de medios probatorios que producen plena prueba, medios que producen semiplena prueba o medios que producen un vehemente indicio o base de presunción. Este fraccionamiento también se aprecia cuando los medios se enfrentan entre sí, y así por ejemplo, dos semiplenas pruebas pueden constituir plena prueba, en un verdadero juego lógico de fracciones altamente complejo.

Este proceso tiene mucha importancia desde esta perspectiva, porque es origen de todo un conjunto de expresiones que todavía están presentes en nuestros códigos (“base de una presunción”, “indicio”); y porque nuestra legislación positiva también se encuentra profundamente empapada por esta visión, y tanto en materia penal como en materia civil predomina el criterio de apreciación legal de la prueba, aunque es cierto que este criterio está profundamente morigerado en materia penal, en una perspectiva de defensa al procesado, y está morigerado en materia civil porque el legislador le otorga un amplio campo al juzgador para apreciar la prueba. Pero claramente vemos aún expresiones de prueba legal en todo nuestro sistema probatorio.

El sistema de los canonistas entra, de alguna manera en crisis, siendo objeto de duras críticas por parte de los estudiosos, lo que trajo una serie de consecuencias:

a) Nacimiento de procesos simplificados: el proceso romano-canónico se desarrollaba con gran lentitud en el tiempo, y la posibilidad de una y otra y otra etapa sucesiva, que incluso se podían reabrir, y la posibilidad de numerosos recursos procesales, hacían que la solución del respectivo conflicto pudiera arrastrarse por años. En estos procedimientos de carácter abreviado, se ve también la voluntad de simplificar los criterios de resolución, y se empieza a vislumbrar la posibilidad de normas más flexibles en cuanto a la apreciación de la prueba.

b) En el siglo XIX se nota en el pensamiento europeo un **predominio del método científico**, prefiriéndolo por el puramente lógico; el siglo XIX también contribuye muy fuertemente a crear los Estados Nacionales a través de los procesos unificatorios, procesos que también contribuyen muy fundamentalmente a una visión distinta de la expresión procesal en general.

c) El pensamiento de la Revolución Francesa, que dentro del campo de lo jurídico es quizás la contribución más poderosa que se ha hecho a nuestra disciplina en general, plantea por primera vez, en forma universal, la igualdad jurídica de los hombres. La codificación de Napoleón tiene una importancia

muy capital, porque Napoleón codificó no solamente para Francia, sino que los ejércitos napoleónicos llevaron este pensamiento (y estos códigos) a otros lugares de Europa.

d) La aparición de la Escuela Histórica del Derecho contribuye a plasmar esta visión distinta.

e) Dentro del campo procesal penal encontramos al Marqués de Pecaria, pensador y jurista italiano que contribuyó muy fundamentalmente a la humanización de las penas.

Todo este conjunto de circunstancias hacen que nuestros procedimientos tengan una muy rápida evolución, la que tiene particular importancia en lo que dice relación con la prueba. Así las estructuras generales de los procedimientos penales y civiles del mundo occidental se plasman fundamentalmente a partir del siglo XIX en una rara uniformidad dentro de su diversidad.

Dentro de los sistemas procesales penales profundamente influenciados por los criterios probatorios, tenemos dos grandes expresiones: el sistema procesal penal inquisitivo y el sistema procesal penal acusatorio.

Se ha dicho que la adopción por los respectivos países de uno u otro sistema, ha dependido mucho de la estructura política respectiva, y así se ha afirmando que el primero es característico de los estados autocráticos, en tanto que el segundo es característico de las grandes democracias. Si bien es cierto, que tras esta afirmación hay algún grado de realidad, no es menos cierto que hay ciertos cruces sobre el particular, y regímenes claramente autocráticos tenían un sistema penal acusatorio, y regímenes claramente democráticos han tenido un sistema inquisitivo. Sin embargo, vale de alguna manera decir que el origen de uno u otro sistema reconocen sus raíces en la respectiva expresión política.

1.4 Sistema acusatorio.

Frente al fenómeno delictivo (noticia criminis) se abre un período preliminar, y no jurisdiccional de investigación, a cargo de un funcionario que no es del orden judicial y que se puede denominar fiscal, miembro del ministerio público, acusador público, etc., y este funcionario va acumulando los antecedentes de la investigación correspondiente. Durante este período preliminar se pueden ir adoptando ciertas y determinadas medidas de resguardo respecto del acusado, la víctima, bienes del encausado, bienes de posibles terceros civilmente responsables; estas medidas de resguardos, que en algunos casos significan restricciones a la libertad individual y que en otras significan restricciones a la libre disponibilidad de los bienes, no las va adoptando el propio funcionario no jurisdiccional encargado de la investigación, sino que las va adoptando un juez cercano a este funcionario.

Terminado este período preliminar y no jurisdiccional, se inicia propiamente el juicio acusatorio y ahí el fiscal que realizó la investigación junto con el encausado se pone en pie de absoluta igualdad y se produce un enfrentamiento entre ellos, y este juicio se realiza verbalmente frente a un tribunal ante el cual es necesario producir toda la prueba respectiva.

Este tribunal puede ser un jurado (formado en consecuencia por ciudadanos no letrados), puede ser un tribunal letrado, puede ser la combinación de ambos o un jurado encabezado por un juez que lo dirija.

Toda la prueba se rinde en las respectivas audiencias orales, teóricamente no hay otra prueba ni hay posibilidad de apreciar otra prueba que no sea la que se rinde precisamente en las correspondientes audiencias orales, en consecuencia, esta prueba es susceptible de ser controvertida en el acto mismo en

que se va produciendo, lo que tiene particular importancia respecto de la prueba testimonial y la prueba de peritos, porque los testigos y los peritos concurrirán a la audiencia respectiva y serán sucesivamente interrogados por el acusador y el defensor, y eventualmente por el juez.

Es muy importante tener presente que la regla muy general en materia de procedimientos acusatorios es que la prueba se aprecia libremente, y casi se podría decir que lo consustancial al procedimiento acusatorio es que la prueba se aprecie libremente por los jueces del proceso oral respectivo; de manera que aquí no hay regla de valoración, y se valoran por los jueces según su absoluta y libre voluntad y perspectiva. Sin embargo, es muy importante destacar que si bien no hay regla de valoración hay estrictas reglas en cuanto a su admisibilidad, que son dos materias perfectamente distintas; las reglas de admisibilidad son lógicamente anteriores y previas a las reglas de apreciación, ya que determinan si cierto medio probatorio cabe o no en el respectivo proceso, y si no cabe dentro del proceso, naturalmente no puede ser posteriormente ponderada. Ha habido aquí una importante evolución, y así se han ido plasmando reglas de admisibilidad que dicen relación con la protección de los derechos humanos, y se ha estimado que pruebas que significan un desconocimiento de los derechos fundamentales no pueden ser admisibles como tales; esta mecánica de la admisibilidad de la prueba no arranca de las normas legales, sino que de decisiones jurisdiccionales.

Naturalmente que en estos procesos claramente se dan el principio de la oralidad, el principio de la inmediación y el principio de la concentración procesal.

Es interesante destacar que en estos procedimientos, cuando se realizan ante jurado, la decisión está entregada al jurado, pero siempre hay un juez conductor del proceso que exige su razonable y lógico desarrollo, y va decidiendo la admisibilidad o no de los medios de prueba.

1.5 Sistema inquisitivo o por instrucción.

Este sistema predominó en nuestro país respecto de la etapa del sumario, pero no así en la etapa del plenario en que predomina el sistema acusatorio.

El sistema inquisitivo puro no se da en ninguna parte del mundo, donde toda la investigación era secreta, y el acusado no sabía que cargos se le formulaban y al que finalmente le imponían una pena determinada.

En el principio inquisitivo hay también un período preliminar de investigación, pero a diferencia del caso anterior es fundamentalmente un período jurisdiccional, o sea, son actos jurisdiccionales los que se van realizando y hay un juez de instrucción que es órgano jurisdiccional. En este período no actúa ningún acusador, ni fiscal ni particular, y esta instrucción preliminar es razonada y metódica, inspirada por el principio del consecutivo discrecional, o sea, es el propio juez instructor el que va realizando la investigación, acumulando los antecedentes para acreditar el respectivo ilícito y la responsabilidad del encausado.

Durante este período se pueden ir adoptando, por el propio juez instructor, ciertas y determinadas medidas que miran a limitar la libertad del encausado, a adoptar resguardos por su responsabilidad civil o resguardos ante eventuales terceros responsables civiles, o a adoptar medidas de protección respecto de la víctima. Estas medidas que adopta el juez de instrucción pueden ir agravándose con lo que dice

relación con las limitaciones de la libertad individual, y así pueden ser primero simples citaciones para constituir posteriormente arraigos, detenciones y prisión preventiva.

La prueba se va produciendo por la acumulación de la actividad del juez instructor, y ésta en definitiva se apreciará conforme a las reglas de la prueba legal.

Este sistema es esencialmente escrito, desconcentrado y rige el principio de la mediación procesal.

Termina esta investigación preliminar con la dictación de la sentencia, sin dar mayores posibilidades de defensa.

1.6 Evolución del proceso civil.

A partir del siglo XIX hay dos grandes modificaciones: el proceso romano canónico se simplifica, pero conservando el proceso civil, en muchos países, su estructura fundamental, y paralelamente se crean una serie de procedimientos simplificados; y por otro lado se mantiene en lo civil el criterio de apreciación legal de la prueba, pero fundamentalmente morigerado.

Sin embargo, hay también en los procesos civiles una evolución muy substancial en otros países del mundo, donde se ha ido llegando a criterios de oralidad, inmediación y de extraordinaria concentración y donde fundamentalmente se aprecia la prueba en conciencia.

1.7 Sistema Nacional.

En materia **procesal civil** tenemos todavía intacta la tradición del proceso romano canónico simplificado, sin perjuicio de algunos procedimientos más sencillos en cuanto a su desarrollo. Estos en general son ágiles, incluso el juicio ordinario de mayor cuantía, pero se forman verdaderos “cuellos de botella” al momento de la decisión en las diferentes instancias.

Tema 2: Relación Entre Prueba y Verdad.

2.1 Introducción.

Los hechos ocurren fuera y antes del proceso, y en consecuencia es necesario revelarlos dentro de éste; esta representación de los hechos pretende en definitiva llevar a la convicción que la representación de éstos en el proceso corresponde efectivamente a lo ocurrido, o sea que lo que aparece revelado en el proceso son las estructuras fácticas del respectivo conflicto. En consecuencia, hay una relación lógica entre verdad y prueba, porque dicho de otra manera la prueba pretende reflejar lo verdaderamente ocurrido o la reconstitución histórica de lo verdaderamente ocurrido.

La verdad desde el punto de vista procesal corresponde a las verdades sensibles y tangibles, muy distinta de las verdades superiores tras la cual van los filósofos. Es interesante destacar que para el filósofo la verdad es el fin en sí mismo, en tanto que para el jurista sólo un medio para resolver en forma idónea el respectivo conflicto; en consecuencia, la verdad desde el punto de vista procesal es más modesta.

La verdad desde el punto de vista de nuestra disciplina tiene mucho que ver con la labor que realiza el historiador, porque este también reconstruye un determinado entorno fáctico tomando diferentes fuentes, las que se denominan clásicamente “las fuentes de la historia”; las que son las fuentes para la

historia son los medios probatorios para el proceso. Pero se distinguen estas labores en que para el historiador muchas veces su tarea se completa y agota con la reconstitución histórica y para el jurista, en cambio, la verdad es solamente el medio para lograr resolver acertadamente el respectivo conflicto. Como otra similitud encontramos que en materia histórica existe la crítica externa que mira a la autenticidad del respectivo testimonio, y la crítica interna que mira a la veracidad del mismo, previamente calificado como auténtico; también en materia procesal está la búsqueda de las verdades contingentes y que tiene estos dos componentes: crítica externa para calificar su autenticidad y de crítica interna para medir su veracidad.

Si la prueba es la manera de lograr acercarnos a la verdad de lo realmente ocurrido, tanto más eficaz será la prueba cuanto más seguramente infunda en nuestro espíritu estar en posesión de dicha verdad, esto es, cuando lleva a la convicción que efectivamente la representación de la verdad lograda es absolutamente coincidente con lo realmente ocurrido.

Si partimos de este postulado, es interesante señalar que respecto de verdades contingentes (o sea de hechos ocurridos antes y fuera del proceso) se puede estar en tres situaciones: de ignorancia, de duda o de certeza:

a) Situación de ignorancia: nada se sabe y nada se puede afirmar respecto de aquellos hechos ocurridos antes y fuera del proceso.

b) Situación de duda: se produce cuando hay razones para afirmar la ocurrencia del hecho contingente, y también hay razones para negarlo, o sea, no se está seguro que el hecho haya ocurrido. Esta posición es a su vez subclasificable en:

b.1) Duda en función de lo posible: en este caso los motivos para afirmar la ocurrencia del hecho son similares a los motivos para negar la ocurrencia del hecho;

b.2) Duda en función de lo probable: si los motivos para afirmar o negar la ocurrencia de un hecho son mayores que los motivos en sentido contrario.

c) Situación de certeza: se da cuando se tiene la seguridad que esa verdad representada es absolutamente coincidente con lo que en realidad ocurrió.

La certeza es un estado anímico, psicológico que consiste en que el sujeto no duda que su representación de lo ocurrido es absolutamente coincidente con la verdad; esta es la posición a la cual debe llegar en definitiva el juez investigador.

La certeza naturalmente es falible, porque se puede caer en dos formas de error: dar por cierto lo que realmente no ocurrió, o no dar por cierto lo que realmente ocurrió. Estas dos formas de error hacen necesario que la certeza tenga que ser criticada mediante un análisis riguroso de crítica interna, y si la certeza soporta este análisis se llega a una etapa distinta que se ha denominado la **convicción**, o sea el estado psicológico o anímico de estar en posesión de la verdad después que la certeza ha sufrido el examen lógico correspondiente.

La certeza es una y única, pero para llegar a ella existen dos grandes vertientes:

- los **sentidos**, en virtud de los cuales es posible captar el respectivo medio o fuente probatoria, y
- la **inteligencia**, en virtud de la cual es posible la elaboración intelectual correspondiente.

Si bien es cierto que la certeza es una, única e indivisible, los caminos para llegar a ella en función de estas dos fuentes son distintos, y así encontramos como posibles caminos:

- i) la certeza física,
- ii) la certeza físico histórica,
- iii) la certeza físico lógica, y
- iv) la certeza físico histórica lógica.

En la **certeza física** los sentidos captan directamente el objeto que se está investigando y, en consecuencia, la elaboración intelectual en este caso es mínima. Por ejemplo, si el juez se constituye en un lugar para determinar si hay o no un pozo, y si efectivamente lo hay son los sentidos los que lo llevan a la certeza y la elaboración intelectual es mínima.

En la **certeza físico histórica** el juez se enfrenta a un testimonio que se refiere directamente al hecho que se trata de constatar, este testimonio puede ser la declaración de un testigo, un documento, una fotografía, una película; en este caso los sentidos juegan en cuanto a que captan el testimonio y la inteligencia en cuanto a que hace la crítica de éste. Por ejemplo, el juez no ve el pozo sino que oye a dos testigos que dicen que en ese lugar hay un pozo.

La **certeza físico lógica** consiste en que el juez capta directamente un hecho, pero el hecho que capta es distinto del que trata de establecer, pero este hecho distinto presupone el otro. Aquí juegan los sentidos en cuanto a que captan el hecho distinto y la elaboración intelectual en cuanto a que partiendo de ese hecho distinto se afirma la existencia del hecho que se trata de establecer. Por ejemplo el juez capta una bomba que bota agua.

La **certeza físico histórica lógica** consiste en que el investigador capta un testimonio, pero este no se refiere al hecho que se trata de establecer, sino a un hecho distinto, pero que lo presupone. Aquí juegan los sentidos en cuanto a que captan el testimonio y la inteligencia en cuanto a que se critica interna y externamente, y en que partiendo del hecho distinto se afirma el hecho que se quiere establecer. Por ejemplo, el juez escucha a dos testigos que no saben si existe un pozo, pero testifican que había una bomba que largaba agua.

La mayor o menor falibilidad de la certeza dependerá del camino que se siga para alcanzarla, de todos estos caminos el primero es donde el margen de error es menor, porque la posibilidad de que el observador yerre es mínima; y el más falible es el último porque los sentidos captan el testimonio, lo critican y afirman el hecho distinto a través de la elaboración intelectual.

La función de esta gran estructura lógica es porque tradicionalmente los medios probatorios han tenido distinta fuerza de convicción, y porque las legislaciones han graduado distintamente la fuerza probatoria de los diferentes medios. Ejemplos de las distintas vías son:

- de certeza física: la inspección personal del tribunal,
- de certeza físico histórica: los testimonios presenciales que directamente se refieren al hecho,
- de certeza físico lógica: las presunciones,
- de certeza físico histórica lógica: los testigos de oídas.

El elemento variable es la elaboración intelectual, ya que el elemento físico es un elemento constante, y el medio probatorio será más falible o menos confiable mientras más composición de elaboración intelectual en sí mismo contenga.

2.2 Clasificaciones doctrinarias de los medios de prueba.

Podemos categorizar los medios de prueba en cuatro grandes universos:

- a) Medio de prueba material directo:** dice relación con la certeza física del hecho que se trata de establecer.
- b) Medio de prueba personal directo:** el testimonio, ya sea propiamente tal o documental. En este caso el testimonio se refiere directamente al hecho que se trata de establecer.
- c) Medio de prueba material indirecto:** dice relación la certeza físico-lógica, o sea, observa un hecho distinto del que se trata de establecer, pero a partir de esa observación del hecho distinto llega a afirmarse el hecho que se quiere constatar.
- d) Medio de prueba personal indirecto:** es el testimonio que se refiere a un hecho distinto del que se quiere establecer, pero a partir de ese hecho distinto, se llega a afirmar la existencia del hecho que se quiere establecer.

De acuerdo con esta categorización, resulta claro que los medios de prueba tienen distinta eficacia, siendo el primero el más eficaz y el último el más falible. Esta es la razón de ser de la graduación de la eficacia distintos medios de prueba.

2.3 Verdad material y verdad formal.

No son sólo formas distintas de verdad, sino que son en definitiva grados distintos de satisfacción por parte del juzgador. Cuando el juzgador va tras la verdad material, solamente estará satisfecho si llega efectivamente a la certeza y posteriormente a la convicción que su representación de la verdad corresponde exactamente a lo que realmente ha ocurrido. En cambio, el juzgador se satisface sólo con la verdad formal, cuando para que su juicio o para su decisión puede incluso, asaltarle ciertas dudas en cuanto a si su representación corresponde o no a lo ocurrido.

El juzgador debe estar necesariamente en posesión de la verdad material cuando el conflicto tiene un gran contenido social y no solamente interesa a las partes contendientes, sino que a la sociedad global; en cambio, el juzgador puede satisfacerse con la verdad formal cuando el conflicto es altamente disponible y sólo mira al interés de las partes contendientes. Por ejemplo, en materia procesal penal, el juzgador debe ir tras la verdad material, porque en el conflicto de carácter penal, el interés social tiene su máxima importancia; en cambio, en el conflicto civil, en materia meramente disponible, el juez se satisfará con la verdad que las partes le aporten y esta verdad será la verdad formal.

No en todos los asuntos de carácter civil rige el principio de la verdad formal, porque si hay algunos asuntos de carácter civil donde el interés público se encuentra más comprometido, el juez tendrá particular interés en descubrir la verdad material y no satisfacerse con la formal.

En relación con la importancia de esta distinción, podemos decir que además del esfuerzo que debe realizar el juzgador, el mérito de la sentencia en materia penal es mucho mayor que el mérito de la

sentencia en materia civil. La verdad de la sentencia en materia penal, especialmente de la sentencia penal condenatoria se considera inamovible, en cualquier otra discusión incluso entre terceros, porque se tiene la seguridad de que el juzgador llegó a la verdad material. En cambio, en materia civil, los hechos establecidos en una sentencia no producen pruebas respecto de terceros e incluso, respecto de las partes contendientes, en lo que aquella sentencia afirma distinto de lo resuelto; constituye simplemente una presunción de verdad y admite prueba en contrario.

2.4 Verdad suficiente.

Es aquella porción de la realidad que han aportado las partes al juzgador y que éste estima suficiente para asentar en ella su respectivo juicio absolutorio o condenatorio.

En torno a este tema hay un principio de gran importancia: el principio de la **carga de la prueba** que entra a jugar cuando el juzgador constata que las pruebas que le han rendido las partes no le permiten ver con claridad el sustrato fáctico del respectivo conflicto. En tal evento entran a jugar subsidiariamente las reglas de la carga de la prueba y el juzgador se preguntará quien es el que debe aportarle las pruebas para que el vea claro: el que está cargado con el peso de la prueba, y si ese no cumplió sufrirá una consecuencia desfavorable y la decisión del juzgador será contraria a su respectiva pretensión o contrapretensión.

El fenómeno de la prueba es en sí mismo inspirador de ciertos principios formativos del procedimiento y además determina como otros principios formativos entran a jugar en el procedimiento de que se trata, o sea, hay principios formativos del proceso que miran específicamente a la prueba y otros principios formativos que se vinculan muy estrechamente al fenómeno de la prueba.

Tema 3: Principios Formativos en Relación con la Prueba.

Según la **apreciación de la prueba** tenemos los principios de:

- a) Prueba legal.
- b) Libre convicción.
- c) Sana crítica.

Para entender este principio formativo, hay que tener presente que el fenómeno de la prueba en sí mismo puede estar regulado en sus distintas fases o ámbitos, y así por ejemplo, puede estar regulado respecto de: cuáles son los distintos medios de prueba, cuál es la fuerza de convicción de los medios de prueba, cuál es la forma de producir la prueba, cuál es la forma de apreciar la prueba, cuál es la parte que está cargada con el peso de la prueba.

3.1 Principio de la prueba legal.

Consiste en que el legislador antes del inicio del respectivo procedimiento y antes del surgimiento del respectivo conflicto, señala cuál es el valor probatorio de los distintos medios de prueba; dicho de otra manera, la valoración de la prueba, en el sistema estricto de prueba legal, no queda entregado al

juzgador, sino que se realiza anteladamente por el legislador, señalando cuál es la fuerza de convicción de cada uno de los medios de prueba.

En materia procesal civil, rige en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de prueba legal morigerado en el sentido que si bien es cierto que el legislador ha señalado anteladamente el valor de los medios de prueba, le ha dado un amplio margen al juez, para que dentro de ciertos y determinados parámetros, pueda él también realizar una labor de valoración.

Hoy en día, después de un examen más o menos superficial se podría decir que aparece como aberrante que el legislador anteladamente fije el valor de los distintos medios de prueba y se podría, en consecuencia, sustentar que un sistema judicial ideal sería naturalmente aquel que le entrega al juzgador la posibilidad de absoluta y libre valoración. Sin embargo, la apreciación merece ser particularmente reflexionada porque el sistema de prueba legal en materia civil, va estrechamente unida al principio de la seguridad jurídica, por ejemplo, en nuestro sistema procesal la escritura pública produce plena prueba de haberse otorgado y produce plena prueba respecto de que los otorgantes hicieron las declaraciones en ella contenida, si nosotros sustentáramos por ejemplo el sistema de libre convicción en materia civil, bien podría ocurrir que un sólo testigo destruyera el valor de una escritura pública, si el juez en definitiva le da más crédito a él que a la actuación solemne de la escritura pública. En consecuencia, sobretodo en el mundo de las obligaciones de los actos procesales es necesario mantener el principio de la prueba legal en función de la seguridad jurídica.

En materia procesal penal, se ha mantenido en algunas legislaciones, el sistema de la prueba legal condenatoria y la prueba moral absolutoria porque es lejos el criterio más garantista para el procesado. Hay una tendencia en el mundo entero y Chile no ha estado al margen de ella, donde paulatinamente en materia procesal penal se ha ido abandonando el sistema de prueba legal para ir a un sistema de libre convicción. De este modo en el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal se considera el principio de la libre convicción.

3.2 Principio de la libre convicción.

Permite al juzgador dar a todos y a cada uno de los medios de prueba el valor que él soberanamente estime conveniente y adecuado en el caso de que se trate, sin estar sujeto a ninguna clase de parámetros. Este sistema se da muy escasamente en materia civil, pero sí se da en materia procesal penal, precisamente en el juicio de jurados, donde el jurado con toda libertad aprecia las pruebas según su real saber y entender.

3.3 Sana crítica.

En este principio el juzgador no es enteramente libre para darle a cada uno de los medios de prueba en particular la fuerza de convicción que él estime del caso, sino que, debe aplicar un criterio de racionalidad y señalar en cada situación cuáles son los motivos que lo llevan a ponderar en uno u otro sentido los respectivos medios de prueba.

Este sistema, lo tenemos en algunos asuntos civiles muy importantes, como por ejemplo en el recurso de protección, donde expresamente se señala que el tribunal que lo resuelva apreciará la prueba en

conciencia (sana crítica), o sea, no queda limitado por valores probatorios vinculantes. Otro campo muy importante de es el campo laboral.

Lo que exige este principio es la apreciación razonada y motivada que explique por qué se prefiere un medio de prueba sobre otro.

En general, cuando estamos frente a la apreciación libre de la prueba, ésta va de la mano con el principio de la **oralidad**, o sea, el tribunal, recibe en su presencia la prueba respectiva y la aprecia libremente. En este caso también va de la mano con el principio de la **inmediación**, es decir, la relación directa sin intermediario entre el órgano jurisdiccional y las partes contendientes.

Por el contrario, cuando estamos frente al principio de prueba legal, lo normal es que rija el principio de la **escrituración**, rija también el principio de la **pasividad** y por último, rija el principio de la **mediación**, o sea, la relación con intermediario entre el órgano jurisdiccional y las partes contendientes.

De esta manera hay un compromiso constante, en lo que dice relación con los principios formativos del procedimiento y la prueba en general.

El interés social comprometido es un elemento muy determinante en cuanto al sistema probatorio aceptado; así se explica que cuando el interés social está muy seriamente comprometido, como lo es en el proceso penal, hay en el mundo entero una tendencia a la libre apreciación o por lo menos a la apreciación de la prueba en conciencia.

3.4 Unidad y diversidad de los principios probatorios.

Existen ciertos elementos comunes, tanto en materia probatoria civil, como en materia probatoria penal:

- a) El primer elemento es que en ambos campos la prueba se refiere esencialmente a los **hechos**, ya que el derecho como regla general, no se prueba.
- b) También es principio común que tanto en materia procesal civil, como en materia procesal penal se pretende el llegar a la **verdad**, o sea aproximarse a lo realmente ocurrido.
- c) Tanto en materia procesal civil, como en materia procesal penal existe el criterio de los **medios de prueba**, o sea, ciertos elementos que contempla el legislador para producir la necesaria convicción.
- d) En ambos campos se encuentra regulado el **fenómeno probatorio** en general.

Sin embargo, existen ciertos elementos diferenciadores entre el sistema probatorio civil y el sistema probatorio penal:

- i) Respecto de la verdad, en materia procesal penal se va tras la **verdad material** en cambio en materia procesal civil, se va, como regla general, tras la verdad formal. En el campo procesal civil, el principio de la verdad suficiente también es aceptado en el sentido que como aplicación de la pasividad, el juez debe conformarse con aquella porción de verdad que las partes contendientes le quieran proporcionar.
- ii) En materia procesal penal, los hechos que no necesitan ser probados son los menos, o sea los **hechos eximidos de prueba** son los menos, en cambio en materia procesal civil, los hechos eximidos de prueba son muchos y variados, como por ejemplo, el hecho confesado o el hecho reconocido. En materia procesal penal, precisamente por la búsqueda de la verdad material, ningún hecho por confesado que esté no deja de ser objeto de prueba.

Con todo, no obstante las diferencias señaladas, el fenómeno probatorio es igual tanto en lo civil como en lo penal, pero tiene expresiones diferentes fundamentalmente por la naturaleza del conflicto envuelto en el procedimiento.

Tema 4: Objeto de la Prueba.

Al entrar en este tema, es necesario contestar la pregunta **qué debe probarse**, es decir, sobre qué recae la prueba. En general en todo conflicto hay dos grandes universos:

1. Los hechos de la causa,
2. El derecho aplicable a los hechos.



Esta es la regla general, porque bien podría plantearse un determinado conflicto donde no hubiese discusión respecto de los hechos, sino que del derecho, o bien podríamos encontrar un conflicto donde las partes estuvieran de acuerdo respecto de la normativa aplicable, pero estuviese en desacuerdo respecto del aspecto fáctico del conflicto.

4.1 Los hechos de la causa.

Hecho es todo suceso del hombre o acontecer de la naturaleza a los cuales el ordenamiento jurídico vincula determinados efectos. Las dos posibles vertientes de los hechos son: el suceso del hombre y los hechos de la naturaleza; ambas vertientes deben producir una consecuencia común, que es que el ordenamiento jurídico vincule a tales circunstancias determinados efectos jurídicos.

La prueba sólo recae sobre hechos, como regla muy general y no sobre el derecho. Esta afirmación tiene que ser calificada en el sentido de que la prueba civil recae sobre ciertos y determinados hechos que reúnen ciertas características, en tanto que la prueba penal recae sobre otros hechos que también reúnen ciertas características.

Un hecho civil debe ser probado cuando es substancial, pertinente, controvertido y no está eximido de la necesidad de ser probado.

1. **Substancial:** significa que tenga gravitación en relación con el conflicto de que se trata.
2. **Pertinente:** significa que debe guardar relación con el conflicto.
3. **Controvertido:** significa que a su respecto debe haberse producido un juego dialéctico de afirmación y de negación. Sin embargo, cuando decimos “hecho controvertido”, la calificación no es del todo exacta, porque para ser rigurosos tendríamos que hablar de *hecho controvertible*, toda vez que, la defensa negativa tácita o el silencio, no importan propiamente controversia, pero se asimila a la controversia.
4. **No debe encontrarse eximido de ser probado:** hay ciertas categorías de hechos civiles que se encuentran eximidos de la necesidad de ser probados (serán estudiados más adelante).

Respecto de los hechos en materia penal, también se requiere que sean **substanciales** y **pertinentes**, pero no interesa que el hecho sea o no controvertido, porque como el investigador penal va tras la

verdad material, aún cuando el hecho sea admitido, reconocido o confesado, no por ello queda excluido de la respectiva indagación penal. Por otro lado, también en materia procesal penal hay ciertos **hechos excluidos de prueba**, como son por ejemplo, los hechos presumidos, el hecho público y notorio, el hecho evidente, pero en general, en materia procesal penal, precisamente por la naturaleza de la verdad que se persigue, los hechos excluidos de prueba, son más restringidos que en materia procesal civil.

4.2 Prueba del derecho.

4.2.1 Prueba del derecho nacional.

Es necesario a este respecto hacer una distinción con relación a qué fuente del derecho nos estemos refiriendo. Lo que se va a explicar a continuación se refiere a la ley como fuente del derecho y no a otras fuentes, porque la ley tiene normas particulares respecto a la no necesidad de probarla, en tanto que otras fuentes del derecho no tienen normas particulares y en consecuencia deben ser probadas. Por ejemplo, si como fuente del derecho se invoca a la jurisprudencia o la costumbre, se tendrá que probar en cada caso la jurisprudencia o la costumbre; en cambio, respecto de la ley nacional, no se necesitará probarla.

La no necesidad de probar la ley nacional, arranca de lo dispuesto en el artículo 8 CC., artículo que señala que la ley se presume conocida por todos, y esta presunción de conocimiento se inicia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En todo caso, es necesario aclarar que esta presunción de conocimiento de la ley es en verdad una ficción de conocimiento de la misma, que se ha adoptado por una razón de seguridad jurídica.

No obstante que el derecho nacional no necesita prueba, es necesaria una pequeña aclaración, en el sentido que aunque las ediciones de las leyes son muy cuidadas y aunque los códigos son una y otra vez revisados, ocurre con cierta frecuencia que se verifican errores en los textos, y en consecuencia en ciertos casos no es que se pruebe la ley, sino que se debe probar su genuino texto. Estos textos genuinos de la ley se pueden encontrar en los depósitos que existen en el Ministerio de Justicia y en el Congreso Nacional. En conclusión, el conocimiento de la ley, no descarta la posibilidad del error en la transcripción del texto de la ley.

La presunción de conocimiento de la ley tiene como excepción el Código de justicia Militar.

4.2.2 Prueba del derecho extranjero.

Respecto del derecho extranjero no rige la ficción del artículo 8 C.C., sino que debe probarse.

En cuanto a este tema rigen 2 importantes fuentes en nuestro ordenamiento:

a) Artículo 411 N° 2 CPC: Esta disposición se refiere al informe de peritos como medio probatorio y señala en qué casos puede oírse informe de peritos. En el N° 1 se señala el caso típico que se da cuando se debaten cuestiones que para su debida apreciación necesitan de conocimientos especiales sobre alguna ciencia o arte; pero el N° 2, señala que podrá también oírse informe de peritos sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.

En el caso del N° 2, la ley señala como facultativo el oír informe de peritos y no como necesario u obligatorio, porque es norma de Derecho Internacional Privado, que si el juez conoce la norma

extranjera, puede aplicarla derechamente, aún cuando a su respecto no se produzca prueba de informe de peritos. Pero si no conoce la ley extranjera tendrá que recurrir a este mecanismo.

Es importante señalar que es lícito al juez aplicar en el proceso sus conocimientos privados de alguna legislación extranjera, porque lo que le está prohibido es que aplique sus conocimientos privados de hechos del proceso, pero no del derecho relacionado con el mismo.

b) Artículos 408 a 411 Código de Bustamante: Las normas de este Código de Bustamante son supletorias de la legislación nacional, pero no modificatorias del derecho nacional. Esta precisión es importante, porque si concluyéramos que las normas del Código de Bustamante son modificatorias, ellas no deberían ser aplicadas, porque de acuerdo con la reserva en virtud de la cual Chile aprobó este código, la legislación chilena siempre se prefiere al Código de Bustamante y cuando hablamos de legislación chilena, la reserva fue particularmente amplia, porque se refería tanto a la legislación vigente como a la legislación futura.

Comparando el artículo 411 CPC con los arts. 408 a 411 Código de Bustamante, se ve que no hay una fundamental antinomia entre ellos, sino que son textos claramente compatibles, y en consecuencia debemos concluir que las reglas del Código de Bustamante son supletorias y por tanto cabe aplicarlas, sin perjuicio de poder aplicar también el artículo 411 CPC

Sin embargo, hay una importante reserva sobre el particular, en el sentido que el Código de Bustamante es un tratado multilateral y en consecuencia sólo liga a los países contratantes, de suerte que estos mecanismos de prueba del derecho extranjero, son sólo aplicables cuando se trata de legislación extranjera de uno de los estados contratantes, es decir, aquellos estados respecto de los cuales rige en plenitud el código en cuestión. Por ejemplo, Estados Unidos no ratificó el Código de Bustamante y en consecuencia, para la prueba de la legislación norteamericana, no se puede recurrir a las normas de este código.

No obstante que el Código de Bustamante sólo rige respecto de los estados contratantes, se ha dicho por nuestra Corte Suprema que éste contiene claros principios de Derecho Internacional y como en ciertos y determinados casos, los conflictos deben resolverse conforme a dichos principios, el Código de Bustamante tiene también aplicación más allá de los estados contratantes, pero no en lo que dice relación con la prueba de la legislación extranjera.

El Código de Bustamante tiene la particularidad que en lo que dice relación con la prueba de la legislación extranjera, no tan sólo contempla la prueba de su texto, sino que también puede ser objeto de prueba el sentido y alcance de la norma respectiva, o sea, no tan sólo es su texto, sino que también su interpretación lo que puede ser probado.

4.3 Prueba de la costumbre.

Que las fuentes del derecho no se prueban, es una afirmación que sólo es válida respecto de la ley, porque las demás fuentes deben ser probadas. Entre estas otras fuentes del derecho que requieren prueba está la costumbre.

La costumbre es la práctica útil, no contraria a derecho ni a la moral pública y generalmente aceptada en el medio en que se invoca, que obedece a satisfacer una necesidad jurídica, es decir, la práctica

constante de ciertas y determinadas maneras de actuar, constituye costumbre cuando esa determinada manera de actuar obedece a una necesidad de satisfacer algún requerimiento de carácter jurídico.

Respecto de la prueba de la costumbre es fundamental distinguir entre costumbre de carácter civil y costumbre de carácter mercantil. Esta distinción es importante porque existe una diferencia entre la costumbre como fuente del derecho en una situación y la costumbre como fuente del derecho en la otra, o dicho de otra manera, la costumbre como fuente del derecho civil tiene un débil efecto, en tanto que la costumbre como fuente del derecho mercantil, tiene un fuerte efecto. Esto se debe a nuestra estructuración jurídica racional que arranca muy claramente del derecho francés, donde se quiso erradicar prácticamente todo lo que eran las jurisdicciones particulares y unificar los criterios jurídicos en torno a patrones generalmente aceptados.

En Chile, en materia civil, sólo rige la costumbre cuando la ley expresamente se remite a ella, tal como lo señala el artículo 2 C.C.

El legislador no fija normas de ninguna especie para la costumbre en materia civil; en consecuencia, la costumbre civil se puede probar libremente por cualquier medio probatorio, e incluso más, en ciertas y determinadas situaciones la costumbre podría ser considerada como un hecho público y notorio.

En tanto que en materia mercantil, la costumbre tiene mucho mayor rigor y esto arranca de lo establecido en el artículo 4 C. Comercio, que señala a la costumbre como fuente supletoria del derecho, es decir, la costumbre en materia mercantil no sólo es aplicable cuando la ley se remite a ella, sino que también en el silencio del derecho.

Respecto de la costumbre en materia mercantil, el juez puede aplicarla de oficio cuando le conste su existencia, circunstancia que autoriza el artículo 5 inciso 1° del Código de Comercio. Esta norma se explica, porque cuando se dictó el Código de Comercio, el legislador de la época visualizó tribunales especiales que eran los tribunales de comercio y en consecuencia, en estos tribunales de comercio, era perfectamente posible que el juez conociera la costumbre mercantil y por tanto sin necesidad de prueba, en la medida que al juez le constara la costumbre mercantil, se podía derechamente declarar su existencia y aplicarla.

Si al juez del asunto mercantil no le consta la costumbre, ésta debe ser probada:

- por 2 sentencias judiciales que declaren su existencia; o
- por 3 escrituras públicas que hagan referencia a ella, con la limitación de que estas escrituras públicas deben ser de fecha anterior a los hechos que se invocan en el respectivo juicio. (artículo 5 inciso 1° y 2° del Código de Comercio).

Finalmente señalemos que la legislación indígena hace una expresa remisión al derecho indígena consuetudinario, o sea, la costumbre pasa a ser fuente directa del derecho en materia indígena, tanto en materia civil como en materia penal y no hay norma en la ley indígena sobre la prueba de la costumbre, de manera que nuevamente en este caso se estará a las reglas generales.

4.4 Hechos que no requieren prueba.

La regla general es que en nuestro ordenamiento sólo se prueban los hechos que sean substanciales pertinentes y controvertibles, pero haciendo un examen más fino hay ciertos hechos que se dice que no requieren prueba. Estos hechos son:

- el hecho confesado o admitido;
- el hecho insustancial o impertinente;
- el hecho presumido de derecho;
- el hecho evidente;
- el hecho público y notorio;
- el hecho normal;
- el hecho negativo.

a) Hecho confesado o admitido.

Se puede establecer una íntima relación entre el hecho confesado y el hecho admitido, porque en el fondo admitir un hecho que produce efectos en contra de quien lo admite es una forma de confesión.

Se ha dicho que el hecho confesado o el hecho admitido no requiere prueba, pero esta afirmación hay que mirarla con cierto cuidado, porque es válida solamente cuando el conflicto cae en el ámbito de lo disponible, si el conflicto no cabe dentro del ámbito de lo disponible la confesión no exime de prueba respecto del respectivo hecho; así por ejemplo en materia penal la confesión, que es forma de acreditar la participación, no constituye prueba o no exime de probar el hecho, sino que ella debe ser plenamente concordante con los demás antecedentes del proceso y además verosímil.

En consecuencia el aforismo “a confesión de parte, relevo de prueba”, tiene plena validez y eficacia cuando se trata del ámbito de lo disponible, pero no la tiene cuando hay un interés social implícito en el respectivo conflicto.

La admisión o confesión de un hecho puede ser :

- expresa: cuando el confesante explícitamente lo reconoce, o
- tácita: cuando **estando presente** no lo controvierte; porque la simple ausencia o el simple silencio no constituye confesión (en Derecho quien que calla no otorga; ausencia y silencio constituyen una defensa tácita de negativa).

En nuestro sistema procesal civil hay formas de confesión ficta, confesión que se logra a través de un mecanismo que se denomina la absolución de posiciones, en que frente a ciertas y determinadas circunstancias y por la rebeldía de quien ha sido convocado a absolver posiciones puede producirse la confesión ficta, que produce los mismos efectos que produce la confesión explícita.

b) Hecho insustancial o impertinente.

Es lógico que si el hecho no es substancial y no es pertinente, sobre el no debe haber prueba; en esta materia rige *in integrum* el principio de la economía procesal, y no se caerá en el dispendio de probar hechos que no sean substanciales y pertinentes.

El calificar un hecho como substancial y pertinente es un cuestión casuística. En un conflicto un mismo hecho puede no ser substancial y en otro conflicto el mismo hecho puede ser substancial.

c) Hecho presumido de derecho.

El artículo 47 inc., final C.C. señala la fuerza probatoria de la presunción de derecho, en el sentido que, el hecho presumido de derecho no admite prueba en contrario.

La presunción funciona como un mecanismo lógico que está compuesto por tres elementos perfectamente diferenciables que son:

- i) hecho indicador o indicio,
- ii) regla de lógica y experiencia, y
- iii) hecho presumido.

En toda presunción sea legal, judicial o de derecho, siempre encontramos estos tres elementos.

En la presunción de derecho el hecho que se presume de derecho no necesita ser probado, y aún más no se admite prueba en contrario; pero el hecho indicador o indicio si debe ser probado. Así por ejemplo, si se presume de derecho que la concepción ocurrió en un período entre 300 y 180 días anteriores al nacimiento, el hecho indicador es el nacimiento, naturalmente que debo probarlo, pero no se permite prueba en contrario a quien pretenda establecer una época distinta de concepción.

En materia procesal civil las presunciones de derecho tienen efectivamente cabida ya sea como presunciones propiamente tales o como ficciones que el legislador ha planteado como presunciones, como ocurre con el conocimiento de la ley (artículo 8 C.C.). En cambio en materia procesal penal, las presunciones de derecho están prohibidas, no se puede presumir de derecho la responsabilidad penal y esta prohibición de presumir de derecho en materia procesal penal hoy día tiene rango constitucional.

d) Hecho evidente

Los lógicos lo han definido como “aquel que se impone por su sola luminosidad”, o sea que tienen tal vigor en cuanto a su construcción que se impone por su sola luminosidad; y un antónimo al hecho evidente sería el hecho increíble o sea el que se rechaza *in limine* precisamente porque resulta repulsivo desde el punto de vista lógico.

Dentro del hecho evidente hay una serie de categorías:

i) Patente Absoluto: solamente tiene aplicación respecto de verdades intelectuales, pero no la tiene respecto de cuestiones contingentes. Por ejemplo, es evidente patente absoluto que el todo es mayor que la parte, o es evidente patente absoluto que una cosa no puede ser y no ser a la vez. No tiene mayor cabida dentro de nuestra disciplina.

ii) Patente Relativo: también se impone por su sola luminosidad, pero está supeditado a los conocimientos de la técnica o de la ciencia. Por ejemplo, es un hecho evidente patente relativo que un varón no puede dar a luz, pero esta afirmación está supeditado al avance de la ciencia y tecnología. Esta categoría puede tener aplicación en nuestra disciplina.

iii) Condicionado Absoluto: esto significa que probando uno de los extremos del hecho se afirma indudablemente su consecuencia. Por ejemplo, un hecho de esta categoría es que un analfabeto no

puede ser autor de un anónimo, o sea si se prueba la calidad de analfabeto de una determinada persona, naturalmente pasa a ser evidente que esta no puede ser autor de un determinado anónimo. Otro hecho evidente condicionado absoluto es la coartada, si se prueba que una persona estaba en un determinado lugar, es evidente condicionado absoluto que al mismo tiempo no podía estar en otro lugar. Probado uno de los extremos, se hace no controvertible el extremo que se trata de acreditar.

iv) Condicionado Relativo: significa que probado uno de los extremos el otro no necesita probarse, pero está supeditado al actual nivel de conocimiento científico o tecnológico. Por ejemplo, es un hecho evidente condicionado relativo que si una persona está a las cuatro de la tarde en Santiago, no puede estar a las 5 de la tarde en París, pero naturalmente esta circunstancia está determinada por el avance de la tecnología.

Todos estos hechos evidentes no deben ser probados, pero en los dos últimos si se puede admitir prueba en contrario si uno logra destruir los basamentos científicos o tecnológicos en los cuales la conclusión se asienta.

e) Hecho público y notorio.

Se encuentra en estrecha relación con el hecho evidente. Se ha dicho que este es aquel que cae dentro del margen exigible de información y cultura del respectivo tribunal, y que es al mismo tiempo compartido en el mismo medio.

Se debe destacar que este conocimiento se refiere al tribunal y no necesariamente a las partes, o sea, basta que el hecho para calificarlo como público y notorio lo sea respecto del tribunal aunque no lo sea respecto de las partes.

No es materia de prueba que el hecho sea o no público y notorio, sino que es materia de calificación del respectivo tribunal. Naturalmente que esta calificación del tribunal puede estar sujeta a censura por los recursos procesales correspondientes.

Es muy importante destacar que el hecho público y notorio está dentro de los márgenes exigibles de información y cultura, esto significa que el tribunal para llegar a afirmar la existencia del hecho público y notorio necesita emplear un mínimo de esfuerzo, es decir, que sea fácilmente accesible la información necesaria para afirmar la pública notoriedad del respectivo hecho.

Para calificar un hecho de público y notorio no se necesita la inspección directa del tribunal, sino que el hecho puede haber ocurrido y tomar carácter de **hecho histórico**; así por ejemplo, es un hecho público y notorio, precisamente por ser un hecho histórico que Charles de Gaulle fue presidente de Francia. Naturalmente esa circunstancia no cae bajo la observación directa del respectivo tribunal, pero con toda razón, porque está dentro de los márgenes exigibles de información y cultura, el tribunal puede dar por establecido el respectivo hecho público y notorio.

El hecho público y notorio es un concepto esencialmente relativo, y depende del medio cultural y de información que en cada caso esté involucrado; así puede ser público y notorio para un tribunal de Chiloé que ciertas y determinadas especies arbóreas están en extinción, porque efectivamente desde el punto de vista cultural del medio social de ese tribunal puede estar en condiciones de afirmarlo, en cambio este mismo hecho podrá ser indispensable probarlo en otro tribunal distinto.

Hay distintas categorías o tipos de hechos que caen dentro de esta gran jerarquía de hechos públicos y notorios:

- i) hecho histórico,
- ii) hecho geográfico, y
- iii) hecho local rural.

Respecto de los hechos históricos y los hechos geográficos, podemos decir que su carácter es mucho más amplio, porque es mucho mayor el número de tribunales que podrán afirmar su existencia. En tanto que respecto de los hechos locales rurales, su ámbito de aplicación es más restringido.

Respecto al hecho que está eximido de prueba el hecho público y notorio, es necesario referirse en primer lugar al artículo 89 CPC, artículo que está en el título noveno del libro primero, que se refiere a los incidentes y específicamente a la prueba de ellos. Esta norma dice que si se promueve un incidente y el hecho involucrado en este consta en el proceso o es un hecho de pública notoriedad, el tribunal bien puede no recibir el incidente a prueba y derechamente fallar, o sea, el tribunal puede dar por establecido un hecho siempre que este sea público y notorio.

Es importante tener presente que esta norma está establecida a propósito de los incidentes, y en consecuencia surge la pregunta si el principio de que el hecho público y notorio no requiere prueba es aplicable sólo a los incidentes o es una norma general. En relación con esta pregunta se ha concluido que es una norma de aplicación general, de manera que no obstante estar contenida en la prueba de los incidentes se aplica en toda clase de procedimientos de carácter civil, y así cada vez que el tribunal declara que un hecho es público y notorio no requiere a su respecto recibir prueba de ninguna naturaleza.

Se ha planteado también si el hecho público y notorio se puede invocar en materia procesal penal o precisamente por la búsqueda de la verdad material que preside el proceso penal este hecho público y notorio debe ser probado en esta clase de procedimientos. En este caso se ha concluido que el principio es el mismo, y en consecuencia el tribunal en materia procesal penal también puede calificar un hecho como público y notorio y darlo por establecido sin que a su respecto se haya rendido prueba de ninguna naturaleza; por ejemplo, es un hecho público y notorio la quiebra de bancos del año 1982.

En cuanto al hecho público y notorio es indispensable manejarse con cautela, y en la duda el juzgador debe calificarlo como no público y notorio ya que es una regla de carácter excepcional.

La ley exige en ciertos y determinados casos la notoriedad de una circunstancia, por ejemplo la ley exige para ciertas y determinadas situaciones la posesión notoria del estado civil de hijo legítimo o de cónyuge, o para la habilidad de los testigos del testamento se requiere que el medio respectivo lo tenga como testigo hábil, aunque efectivamente pudiera no serlo. Cuando la ley exige la notoriedad de una determinada circunstancia, esta nada tiene que ver con el hecho público y notorio, sino que ésta debe ser acreditada, así por ejemplo si la ley exige que se pruebe la posesión notoria del estado civil de casado, es esto lo que se tiene que probar.

e.1) Paralelo entre el hecho evidente y el hecho público y notorio.

i) El hecho evidente puede referirse a verdades intelectuales; en cambio el hecho público y notorio se refiere siempre a verdades sensibles.

ii) Al hecho evidente se llega como consecuencia de un raciocinio, hay siempre un esfuerzo silogístico; en tanto que al hecho público y notorio se llega como consecuencia de un conocimiento, no hay una elaboración lógica.

e.2) Paralelo entre hecho público y notorio y conocimiento privado del juzgador.

Cuando el tribunal afirma la existencia de un hecho público y notorio, está recurriendo a su conocimiento privado; en consecuencia es posible temer un traslape entre el conocimiento privado del juzgador y el hecho público y notorio.

Sin embargo hay un elemento que es esencialmente diferenciador, que es el que tratándose del hecho público y notorio este conocimiento debe ser generalmente compartido por el medio cultural respectivo, en tanto que el conocimiento privado del juzgador no es generalmente compartido.

De esta manera los justiciables, es decir, los que reciben las consecuencias de la actividad jurisdiccional, pueden fiscalizar si un hecho determinado y declarado por el tribunal es efectivamente público y notorio, o si corresponde a su conocimiento privado. El mayor o menor grado de estar compartido por el medio, puede convertir al hecho, en consecuencia, de conocimiento privado del juzgador en hecho público y notorio.

f) Hecho normal.

Es una cuestión que ha sido profundamente estudiada por el derecho anglosajón, y ellos han acuñado la expresión “estándar jurídico”, que es el proceder normal dentro de ciertas y determinadas categorías de personas o situaciones; por ejemplo si vemos una transacción entre comerciantes, el estándar jurídico indicará que esa transacción es a título oneroso y no gratuito, porque las transacciones entre comerciantes van presididas por una voluntad recíproca de lucro, y así si se necesita acreditar a que título se hizo una transacción entre comerciantes, basta con que se acredite que se hizo entre comerciantes para que se presuma que fue a título oneroso; si por el contrario se señala que esa transacción fue a título gratuito, se está tratando de establecer un hecho distinto del estándar o normalidad jurídica, y se deberá en consecuencia probarlo.

Este concepto de estándar se vincula estrechamente con la construcción de las presunciones, porque precisamente las normas de lógica y experiencia son reflejo de un determinado estándar jurídico y en consecuencia sirven para llegar a construir la respectiva presunción. También se vincula al concepto de estándar jurídico, el concepto de peso de la prueba, porque quien afirma la normalidad de un determinado hecho no necesita acreditarlo, y quien sostiene lo contrario está cargado con el peso de la prueba.

g) Hecho negativo.

Se ha dicho por siglos por los lógicos, que el hecho negativo no puede ser probado lo que es una enorme falsedad.

En primer lugar respecto de este hecho debemos distinguir entre el hecho mismo y la manera de proponerlo, porque un hecho se puede proponer como positivo o negativo; así por ejemplo, si se dice

que el día jueves 21 de mayo estaba en Temuco, se está diciendo que ese mismo día no se estaba en Arica, pero esta es la forma de proponerlo.

El hecho negativo siempre envuelve la posibilidad de un hecho positivo en contrario. Este hecho no se puede probar, solamente cuando el hecho positivo contrario es indefinido, por ejemplo si se dice que todos los días se toma café al desayuno, es un hecho positivo indefinido que no se puede probar, porque se tendría que probar que durante toda la vida, todos los días, se ha tomado café, lo que es una falsedad. El hecho positivo o negativo puede probarse siempre que se trate de un hecho definido; y no puede ser probado cuando es un hecho indefinido. Por ejemplo si se dice que se estaba en Buenos Aires a tal hora, tal día o que no se estaba en Buenos Aires a tal hora, es un hecho negativo pero que puede ser probado, probando el hecho positivo definido.

Tema 5: Carga de la Prueba, Onus Probandi.

El concepto de carga de la prueba nace vinculado al Derecho Civil y por los tratadistas clásicos es tratado dentro de esta disciplina, lo que explica que nuestro Código Civil inspirado en esta visión de la primera mitad del siglo XIX se refiera específicamente a este tema. Sin embargo esta concepción civilista en torno al tema del peso de la prueba sufre una evolución, y podríamos señalar que la concepción de la carga procesal contribuye a elaborar este concepto.

En una perspectiva procesal, **carga** es un requerimiento de conducta establecido en beneficio del propio cargado, de suerte que su omisión sólo le acarrea problemas a él. Este concepto general es enteramente aplicable al de carga de la prueba, ya que la **carga de la prueba** es un requerimiento de conducta para poder probar, y el incumplimiento de este requerimiento sólo acarrea perjuicios para el respectivo cargado.

Es importante referirse al ámbito de aplicación de los conceptos de carga de la prueba, y al efecto tenemos que distinguir entre los procedimientos dispositivos y los procedimientos inquisitivos.

Respecto de los **procedimientos dispositivos**, lógicamente con alteración del principio de carga de la prueba nace el principio de **carga de la afirmación**, lo que significa también un requerimiento de conducta en el sentido que el cargado debe afirmar los hechos que sirven a su respectiva pretensión o contrapretensión.

Lógicamente nace primero la carga de la afirmación antes que la carga de la prueba, porque la carga de la prueba se referirá precisamente a los hechos afirmados como sustento de la pretensión o contrapretensión, en la medida que esos hechos no estén exentos de la necesidad de prueba; en consecuencia no siempre la carga de la afirmación va unida a la carga de la prueba, porque es perfectamente posible concebir que frente a una determinada afirmación no se requiera prueba, en la medida que los hechos afirmados se encuentren relevados de la necesidad de probanza.

Dentro del sistema dispositivo, cuando entran a jugar los criterios sobre carga de la prueba, encontramos dos hipótesis distintas:

a) Que al juzgador le sea aportada por las partes, sin mirar quien sea el aportante, una cantidad de pruebas indispensables para lograr llegar él a la verdad suficiente. En este caso él está en condiciones de fallar y en consecuencia conforme a esta verdad suficiente aportada, emitirá su decisión ya sea aceptando total o parcialmente la pretensión, ya sea aceptando total o parcialmente la contrapretensión.

b) Que al juzgador no le sea aportada por las partes aquella porción indispensable de verdad que lo coloque en situación de poder fallar. Como en el sistema dispositivo prima el criterio de la pasividad, el juez no puede ir tras la verdad, y en esta situación, teóricamente, hay dos soluciones:

i) Lo que se ha denominado la aplicación del principio *non liquet*, principio que significa la expresión del juzgador de no ver claro, líquido, transparente, y en consecuencia él mismo se exime de la obligación de fallar. Pero en nuestro ordenamiento como regla muy general, no opera este principio porque entra gravemente en conflicto con el principio de la inexcusabilidad; dicho de otra manera, aún cuando el juzgador no vea lo suficientemente claro, debe necesariamente fallar, sino dejaría incumplido este requerimiento esencial y vulneraría el principio de la inexcusabilidad. A pesar de esto encontramos ejemplos de aplicación de este principio, lo que ocurre principalmente en materia procesal penal, donde el juez puede sobreseer temporalmente y suspender el curso del respectivo procedimiento cuando no esté agotada la investigación, cuando no está completamente justificada la existencia del hecho punible o no esté debidamente acreditada la participación culpable.

ii) Cuando el juez se ve enfrentado a esta situación de no ver claros los hechos entra a jugar la regla de carga de la prueba y de acuerdo con el siguiente raciocinio: el juez se pregunta quien tenía la carga de la prueba, y sobre esta parte hace recaer las consecuencias dañosas del incumplimiento y por lo tanto rechaza su pretensión o contrapretensión según corresponda.

Dicho de otra manera, las reglas sobre *onus probandi* son subsidiarias en la medida que sólo se aplicarán si no se han reunido los antecedentes necesarios para fallar, y en este juego subsidiario se verá quien tenía la carga de la prueba y sobre él se harán recaer las consecuencias dañosas, que será el rechazo de la pretensión o contrapretensión.

Respecto de los **procedimientos inquisitivos** podemos señalar que aquí no hay carga de la afirmación, las partes no tienen el requerimiento de conducta de afirmar una determinada pretensión o contrapretensión, toda vez que es el órgano el que va tras la verdad material. Por otra parte, como rige *in integrum* el principio de la oficialidad, las partes no tienen la necesidad de probar sino que la necesidad de probar deriva de la indagación que realiza el tribunal de oficio. Esta necesidad de indagar, no es propiamente peso de la prueba sino que solamente el cumplimiento y la realización del *ius inquirendi* o necesidad de investigar por parte del respectivo órgano jurisdiccional.

En consecuencia en materia de procedimientos inspirados en el principio inquisitivo, no rigen ni se aplican las normas sobre carga de la prueba, sino que ellas son solamente aplicables en los procedimientos dispositivos.

5.1 Quién debe soportar la carga de la prueba.

Sobre el particular hay diferentes doctrinas:

a) Doctrina sustentada por Jeremías Bentham ya en el siglo XIX, señalando que tenía el requerimiento de conducta de probar para quien era menos dificultoso el hacerlo.

Este criterio naturalmente era tremendamente casuístico y el mismo tiempo tremendamente subjetivo, de manera que hoy día se recuerda como una curiosidad doctrinaria.

b) Sustentada por los juristas Binding y Demonje, señalaba que estaba cargado con el peso de la prueba quien sustentaba la anormalidad, o dicho de otra manera quien estaba en la afirmación de la normalidad jurídica estaba eximido de probar, y solamente quien sustentaba la hipótesis contraria estaba cargado con la necesidad de hacerlo.

Esta afirmación tiene un sustento lógico importante, porque el principio de la normalidad de alguna manera se vincula con las presunciones. Sin embargo esta concepción tiene un criterio excesivamente casuístico y subjetivo.

c) Sustentada por Rosenberg, dice que corresponde probar a quien invoca la norma, de suerte que lo que debe acreditar son los presupuestos fácticos de la respectiva norma, ya que toda norma jurídica tiene dos elementos perfectamente distinguibles: un supuesto fáctico y un determinado mandato.

Esta concepción naturalmente que hay que relacionarla con que el sustrato fáctico de la respectiva norma sería necesario probarlo siempre que no se trate de hechos revelados de prueba.

Se le ha criticado a esta concepción que la pretensión o contrapretensión en su caso, no necesariamente se sustenten en una norma y en consecuencia bien puede ocurrir que no haya norma aplicable al respectivo conflicto y sin embargo deban aplicarse también los principios de carga de la prueba. De esta manera la doctrina de Rosenberg es insuficiente para explicar el principio de peso de la prueba.

d) Encontramos también la doctrina generalmente aceptada, que dice que deben probarse los hechos que sirven de sustento a la respectiva pretensión o contrapretensión, salvo que se trate de hechos eximidos de prueba.

Lo normal es que en todo conflicto haya un determinado sustrato fáctico, y ya sea quien propugna por la pretensión o por la contrapretensión en su caso, deberá acreditar los hechos que sirven de sustento al respectivo conflicto.

Lo interesante es que los hechos en función de la pretensión y en función de la contrapretensión tienen diferentes categorías o son susceptibles de algún tipo de clasificación; y así los hechos que invoca quien pretende son hechos **constitutivos**, los hechos que invoca quien reacciona son hechos **extintivos**, pero quien pretende puede invocar hechos **contraextintivos** y la parte contraria puede invocar hechos **invalidativos**, y quien pretende puede invocar nuevos hechos **invalidativos**, y así seguir en este ejercicio dialéctico.

De esta manera cada uno, el pretendiente y el contrapretendiente, acreditarán los hechos de su pretensión o contrapretensión en la medida que no estén eximidos de prueba.

5.2 Sistema nacional.

Está recogido en el Código Civil siguiendo la concepción clásica que veía el tema de la carga de la prueba como una cuestión substancial y no procesal.

El artículo 1698 C.C. consagra el principio de la carga de la prueba: **“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”**. Pero esta definición es susceptible de algunas críticas:

- a) no incumbe probar las obligaciones, lo que incumbe probar son los hechos de los se pueden derivar ciertas y determinadas obligaciones;
- b) no solamente se debaten obligaciones en un determinado conflicto, porque si el conflicto es declarativo o constitutivo no hay obligaciones que se estén discutiendo, pero sin embargo será siempre necesario aplicar principios de carga de la prueba;
- c) aceptando que el único ámbito de discusión fueran las obligaciones, la contrapretensión no siempre está basada en modos de extinguir las obligaciones, sino que puede estar basada en otros antecedentes (por ejemplo sostener que la obligación nunca existió).

Esta concepción civilista del peso de la prueba es, desde el punto de vista procesal, absolutamente insuficiente porque se refiere sólo a las obligaciones en vez de referirse a hechos y a otra clase de pretensiones distintas de las obligaciones, y porque se refiere sólo a medios extintivos y no a otra forma de contrapretensión.

Doctrinariamente debe sostenerse como principio de carga de la prueba que está cargado **quien sostenga la respectiva pretensión o contrapretensión, salvo que los hechos que sirvan de sustento estén eximidos de prueba.**

En virtud de la aplicación de los principios de la carga de la prueba, está cargado con ella el demandante o el demandado en su caso, o incluso ambas partes; la pregunta que se ha planteado es si es posible **invertir el peso de la prueba**. Hay una expresión de inversión del peso de la prueba frente a la presunción legal: cuando una parte se encuentra favorecido por una presunción simplemente legal, se encuentra eximido del peso de la prueba, pero en el fondo se revierte la carga ya que la parte desfavorecida puede probar en contra de la presunción.

Pero la pregunta va más allá, en el sentido si las partes pueden convencionalmente invertir el peso de la prueba, y esto será posible solamente cuando la ley expresamente lo permita, pero no se puede realizar convencionalmente si la ley así no lo refiere, porque de otro modo se atentaría contra el principio del debido proceso. Sin embargo se citan en materia mercantil uno que otro ejemplo donde la ley permitiría eventualmente invertir el peso de la prueba, específicamente en la aceptación de la letra de cambio cuando va precedida de la declaración de haberse recibido provisión de fondo.

5.3 Limitaciones a la prueba.

Las limitaciones a la prueba son ciertas cortapisas puestas por ley que impiden acreditar ciertos hechos o valerse de algunos medios probatorios. Las limitaciones a la prueba pueden ser de dos grandes clases:

- a) en cuanto impedir probar ciertos hechos, y
- b) en cuanto a usar ciertos y determinados medios probatorios.

En general, las limitaciones a la prueba en cuanto a impedir probar ciertos hechos son escasos, y en la disciplina jurídica en general esta tendencia está en clara retracción; así por ejemplo hoy está superada la norma que impedía indagar sobre la paternidad.

Las limitaciones a la prueba solamente pueden tener como fuente a la ley, o sea, no hay otras limitaciones a la prueba que las que la ley haya específicamente señalado; aunque también es cierto que puede ser que en la casuística haya ciertas enumeraciones meramente ejemplares.

Las limitaciones a la prueba pueden ser absolutas o relativas. Son **limitaciones absolutas** cuando está prohibido acreditar un hecho o usar un medio probatorio bajo todo respecto. Son **limitaciones relativas** cuando está prohibido acreditar un hecho o usar un medio probatorio solamente en ciertas circunstancias y conflictos.

Entre las razones por las que se establecen, encontramos: una razón de política legislativa, el legislador estima en ciertos y determinados casos, en función de la discreción, de la seguridad jurídica, que es conveniente limitar la prueba; la posible desconfianza que tenga el legislador frente a ciertos y determinados medios de prueba, por ejemplo la prueba testimonial en materia civil; para evitar la colisión entre las partes, sobre todo cuando el conflicto de que se trata lleva envuelto un gran interés social; así por ejemplo en un juicio de divorcio no basta el simple reconocimiento por parte del otro cónyuge de la causal para dar lugar a la demanda; y por último razones de carácter moral o ético.

Encontramos como ejemplos de limitaciones a la prueba:

- a) las presunciones de derecho, en el sentido que, según el artículo 47 inc., final C.C., está vetado probar en contra de una presunción de derecho. Limitación ésta que es aplicable no sólo a las presunciones de derecho propiamente tales, sino también a las ficciones calificadas como presunciones;
- b) el artículo 157 C.C. que se refiere al juicio de separación de bienes entre marido y mujer, donde la confesión de uno de los cónyuges no es suficiente para acreditar los hechos que sirven de sustento a la respectiva pretensión. Esta limitación es un homenaje a los terceros de buena fe, para evitar la corrupción entre las partes y para evitar que se atente contra las obligaciones contraídas de buena fe por el tercero;
- c) respecto de la prueba testimonial en materia civil, el artículo 1708 C.C. señala que deben constar por escrito las obligaciones civiles más allá de cierto mínimo monto, y que no se podrán probar por testigos las obligaciones que debieron constar por escrito, salvo ciertas excepciones;
- d) el artículo 1701 C.C. establece que cuando el instrumento público es solemnidad del respectivo acto o contrato, este acto o contrato no se puede probar sino en virtud del indispensable instrumento;
- e) para acreditar el cuerpo del delito (el hecho punible) se pueden usar todos los medios de prueba menos la confesión, y para acreditar la participación se pueden usar todos los medios de prueba incluso la confesión. Esta regla de admisibilidad significa una gran garantía para el procesado;
- f) dentro de las limitaciones a la prueba hay una que merece particular mención: el **secreto** como limitación a la prueba. En general nuestro sistema legal repugna el secreto, o sea, en general rige el principio de la publicidad respecto de todo el ordenamiento jurídico, de manera que las normas sobre

secreto deben ser siempre interpretadas en forma restrictiva. Sin embargo nuestro ordenamiento jurídico acepta en ciertos y determinados casos el secreto, como es el caso del secreto profesional del abogado.

Tema 6: Leyes Reguladoras de la Prueba.

Respecto de esta cuestión hay dos tendencias polares en el mundo: **la tendencia de la libertad de regulación**, o sea, donde el legislador no ha fijado normas en relación con la prueba, la que queda entregada enteramente a la decisión jurisdiccional; la otra tendencia es la de la **regulación legal de la prueba**, lo que significa que todas y cada una de sus fases es objeto de una normativa más o menos exhaustiva. Y como tendencia de carácter intermedio, hay sistemas donde el fenómeno probatorio en general es más o menos regulado, dejando mayor o menor margen de libertad de decisión al campo propiamente jurisdiccional.

El sistema chileno es un sistema de **prueba legal morigerado**, en el sentido que no llega al extremo de una regulación exhaustiva de este fenómeno, sino que deja entregado en cierta medida a la decisión jurisprudencial o a la decisión jurisdiccional específica la respectiva cuestión.

6.1 Cuáles son los medios de prueba.

Hay legislaciones donde los medios de prueba están taxativamente numerados, en tanto que hay otras donde existe libertad en cuanto a los medios de prueba; así por ejemplo el CPC colombiano hace una enumeración gigantescamente larga de los medios de prueba, en tanto que otras legislaciones son mucho más específicas y señalan como medios de prueba cualquier explicación que envuelva una forma de convicción.

En nuestro medio chileno, se sigue el sistema clásico de la enumeración taxativa de los medios de prueba; pero lo que ha ocurrido es que por la vía de una interpretación extensiva se han ido asimilando expresiones como nuevos medios probatorios, como por ejemplo la fotografía, la radiografía, el video, que se han ido asimilando a la prueba documental o han tenido cabida por la prueba pericial.

6.2 Admisibilidad de los medios de prueba.

Una cuestión es determinar cuáles son los medios de prueba y una segunda cuestión es determinar si un medio que es legal es o no admisible en una situación en particular. Los criterios de admisibilidad son en general criterios casuísticos, en el sentido que en ciertos y determinados conflictos o en ciertas y determinadas circunstancias es o no admisible un medio de prueba en particular.

En general los criterios de admisibilidad son criterios legales, de suerte que es o no admisible una prueba sólo si el legislador la ha aceptado o rechazado como tal.

6.3 Normas sobre la carga de la prueba.

Aquí también existen distintos criterios: legal y jurisprudencial. En Chile la carga de la prueba es un criterio de carga legal, en la medida que es el legislador quien señala quien está cargado con el *onus probandi*.

El inclinarse por el criterio legal es un homenaje al principio de la seguridad jurídica.

6.4 Forma de producir la prueba.

Esto mira fundamentalmente a las normas de carácter procedimental que fijan como se logra en definitiva hacer realidad dentro del proceso los distintos medios de prueba; por ejemplo en el caso de los testigos, cuando es la oportunidad de presentar la lista de testigos, de que manera debe presentarse esta lista, como se los interroga, etc.

Es muy raro encontrar una legislación donde no existan normas procedimentales al respecto, en general, y en Chile en particular, las normas sobre producción de la prueba son verdaderamente extensas.

6.5 Normas sobre apreciación de la prueba.

Aquí hay tres posiciones: la posición más estricta es el criterio de prueba legal donde el legislador anteladamente fija el valor y en consecuencia la fuerza de convicción de cada medio; la posición antinómica es la libre convicción, lo que significa que es el juez en cada caso el que sigue criterios de su propio convencimiento; posición intermedia es la apreciación de la prueba en conciencia, que significa la ponderación lógica de los medios probatorios, tanto individualmente como en conjunto.

En Chile estos cinco aspectos son los que conforman las leyes reguladoras de la prueba, o sea, podemos decir que las leyes reguladoras de la prueba son las normas que sistematizan y en definitiva presiden todo el fenómeno probatorio en su conjunto y en cada una de sus etapas o expresiones.

Estas normas puede ser infringidas, y puede producirse la infracción:

- a) en cuanto a los medios de prueba, la infracción puede ser o aceptar como medio de prueba uno que el legislador rechaza, o rechazar como medio de prueba uno que el legislador acepta;
- b) en cuanto a la admisibilidad de los medios de prueba, la infracción puede consistir en declarar inadmisibles un medio de prueba en un caso concreto, o bien declarando admisible un medio de prueba que en ese caso concreto era inadmisibles;
- c) en relación con las normas sobre la carga de la prueba, la infracción puede ser errando al decir cuál de las partes estaba cargada con el respectivo peso de la prueba;
- d) en cuanto a la manera de producir la prueba la infracción puede consistir no respetando las regulaciones que el legislador ha señalado para cada uno de los medios en particular;
- e) y en cuanto a las normas sobre apreciación de la prueba la infracción será ya sea valorando una prueba más allá de los márgenes que el legislador permite o desconociendo el valor probatorio con infracción a la norma valorativa respectiva.

Las leyes reguladoras de la prueba cuando son infringidas, dan motivo a los respectivos reclamos y recursos procesales, porque en este caso se quebranta el ordenamiento jurídico y no cumple el juez con

la obligación de resolver conforme a derecho. En general todos los recursos procesales y todas las formas de reclamo son adecuados cuando se produce el quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba, y son particularmente adecuados los reparos por la vía incidental, por la vía de la nulidad y por la vía de la apelación.

El recurso de casación y las leyes reguladoras de la prueba son importantes porque primero la jurisprudencia y posteriormente el legislador, a través de una modificación al CPC, aceptó que la infracción a las leyes reguladoras de la prueba podían ser antecedentes justificatorios de un recurso de casación en el fondo; lo que es interesante porque este mira sólo a las infracciones a la ley y no mira a los posibles errores de hecho en que puedan haber incurrido los jueces de fondo. Pero este principio debe compatibilizarse en el sentido que la infracción de las leyes reguladoras de la prueba que influyen en como se determinaron los hechos, puede ser causal de casación en el fondo; y va a ser causal cuando haya una infracción en cuanto a los medios de prueba, la normas sobre admisibilidad, al peso de la prueba y en cuanto a su valoración, siempre que claramente se quebrante una norma valorativa específica, así por ejemplo para que un hecho se pueda dar por establecido en virtud de prueba pericial en materia penal se requieren un conjunto de circunstancias, y si no se cumple con este requisito y la sentencia da por establecido el hecho, claramente se infringen las normas de valoración.

El recurso de casación en el fondo jamás tiene cabida cuando se reclama en la forma como se produjo la prueba, o sea, las normas procedimentales en cuanto a producción de la prueba son típicamente normas “ordenatorio litis” y en consecuencia podrán ser reclamadas por la nulidad procesal, por la vía incidental, por la respectiva apelación e incluso por la casación en la forma.

Tema 7: Etapas o Momentos Probatorios.

Las etapas o momentos probatorios son: ofrecimiento de la prueba, petitorio de prueba, diligenciamiento de prueba, impugnación de la prueba, observaciones a la prueba y apreciación de la prueba.

a) Ofrecimiento de la prueba. En nuestro ordenamiento jurídico es en general excepcional, no se requiere que la parte previamente ofrezca prueba, sino que derechamente se va al petitorio de prueba. Sin embargo hay ciertos y determinados procedimientos donde necesariamente debe haber un ofrecimiento de prueba, y quien no cumple con este requerimiento queda posteriormente vedado de pedirla y rendirla; por ejemplo el demandado en el juicio ejecutivo que opone excepciones debe indicar en su escrito de excepciones cuales son las pruebas que ofrece.

b) Petitorio de Prueba. Es la actividad que realiza la parte para rendir la respectiva prueba; y naturalmente que el petitorio de prueba será distinto según sea el medio de prueba que se trate. El petitorio de prueba es muy importante, porque permite una doble fiscalización: en cuanto a la oportunidad, debe necesariamente producirse en algún determinado momento procesal y si no se observará no será admisible por inoportuno; en cuanto a la admisibilidad del respectivo medio de

prueba, porque en la medida que él sea inadmisibile, la oportunidad para oponerse es el momento que se está pidiendo.

c) Diligenciamiento de Prueba: la prueba se realiza de la manera como el legislador antelada y detalladamente ha señalado para cada uno de los medios de prueba en particular; o sea el diligenciamiento es la realización dentro del proceso de la prueba respectiva, y la regulación está referida a cada uno de los medios en particular. Hay diligenciamientos más complejos, como es el caso de la prueba testimonial, y hay diligenciamientos más simples como es el acompañamiento de documentos.

d) Impugnación de la Prueba: es la oportunidad que se le da a la parte contraria (contra quien se pretende probar) para que impugne ya sea el ofrecimiento, ya sea el petitorio o ya sea el diligenciamiento; y estas impugnaciones pueden ser de carácter **formal**, por ejemplo señalar que no ha habido aviso previo del ofrecimiento de prueba, o discutir la oportunidad para rendir la prueba, o discutir la admisibilidad de un medio probatorio, o discutir su producción o diligenciamiento, o la falsedad o falta de autenticidad del respectivo medio probatorio; o puede ser impugnación **substancial** alegando mendacidad (falta de verdad deliberada en el respectivo medio probatorio) o falta de verdad derivada de otra circunstancia que la mendacidad.

e) Observaciones a la Prueba: se otorga a ambas partes para que realcen la prueba rendida y critiquen o controviertan la prueba rendida por la contraparte.

Arcaicamente este período se denominaba el “alegato de bien probado” en el proceso romano canónico. En el juicio ordinario de mayor cuantía, está específicamente regulado en cuanto a su duración.

f) Apreciación de la prueba: corresponde al sentenciador, y la apreciación de la prueba no es tan sólo una tarea de carácter subjetivo entregada a su fuero interno, sino que debe reflejarse en los respectivos raciocinios o considerandos de prueba de la sentencia; y aquí debemos recordar sobre el particular no tan sólo la exigencia que señala nuestro legislador cuando indica los requisitos de la sentencia, sino muy particularmente el auto acordado de la Corte Suprema sobre forma de la sentencia, donde de manera muy taxativa se señala la necesidad de que el sentenciador aprecie la prueba en la parte considerativa del fallo.

Unidad 5: Medios de Prueba en Particular.

Tema 1: Concepto.

Medio probatorio o medio de prueba, es todo elemento en el cual el juez puede asentar legítimamente su convicción, para dar por establecidos los hechos en que fundamenta su pronunciamiento.

El medio de prueba es un **elemento de carácter objetivo**, que tiene la **virtud de revelar dentro del proceso, lo que ha ocurrido antes y fuera de él**. El proceso siempre nace después del conflicto y como eventual consecuencia de él; y además tiene, normalmente, un sustrato fáctico y un sustrato jurídico, el primero es el que es necesario revelar dentro del proceso y esto se hace mediante los medios de prueba. Las fuentes en que están fijados los medios de prueba son:

- Código Civil;
- Código de Procedimiento Civil;
- Código de Procedimiento Penal y Procesal Penal;
- Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante;
- Código de Comercio;
- Normas especiales, como por ejemplo la ley antinarcóticos, ley de abuso de publicidad.

Estas normas no deben entenderse unas en subsidio de las otras, sino que **todas juegan armónicamente entre sí**; pero rige entre ellas el **principio de la especialidad**, de manera que según la naturaleza del respectivo conflicto, podrán preferirse algunos medios probatorios sobre otros. Así por ejemplo, en un conflicto de carácter mercantil, los medios probatorios son los que señala, en primer término, el Código de Comercio y después se aplicaran los otros en función del principio de la especialidad.

Tema 2: Clasificaciones de los Medios de Prueba.

2.1 En cuanto a su oportunidad.

a) **Preconstituídos**: Son los que **se han producido antes del respectivo juicio**, por ejemplo, los instrumentos.

b) **Judiciales**: **Son los que se producen durante el juicio**; por ejemplo: la prueba de testigos por regla general.

Esta clasificación tiene importancia, porque implícitamente el legislador prefiere el medio de prueba preconstituido al medio de prueba judicial.

2.2 En cuanto al sujeto que la produce.

a) Prueba de partes.

b) Prueba del Tribunal.

Como regla general, en nuestro sistema, en **materia procesal civil**, el principio rector es el de **prueba de parte**, o sea, la actividad probatoria está entregada a la iniciativa y al esfuerzo de las respectivas partes y sólo a título **excepcional** se aceptan las **medidas** llamadas **para mejor resolver**, que son de iniciativa del tribunal para allegar al juicio ciertos elementos fácticos.

2.3 En cuanto a su eficacia.

- a) Medios de prueba que producen plena prueba.
- b) Medios de prueba que no producen plena prueba.

Esta clasificación arranca de un criterio de prueba legal en cuanto a la valoración, o sea, **el legislador**, anteponiéndose al criterio del juzgador, **ha fijado qué medios de prueba producen plena prueba y qué medios de prueba no la producen.**

Con anterioridad a nuestro sistema del CPC había una categoría intermedia que se puede observar en otros sistemas legales, y que son los medios de prueba que producen **semiplena prueba**, hoy descartados de nuestro sistema. Esto significaba que eran medios de prueba que **tenían en sí mismos una determinada fuerza de convicción** y que **uniendo dos medios de prueba**, que cada uno de ellos produjera semiplena prueba, **se podía llegar a la plena prueba.**

2.4 En cuanto a la posibilidad de neutralizar la fuerza probatoria del respectivo medio.

- a) Medios probatorios que **no admiten prueba en contrario.**
- b) Medios probatorios que **admiten prueba en contrario.**

Es distinto medio de prueba que produce plena prueba, a medio probatorio que no admite prueba en contrario. Por ejemplo, el instrumento público produce plena prueba respecto de determinados aspectos, pero admite prueba en contrario. En cambio, la confesión produce también plena prueba, pero no admite prueba en contrario. **El admitir o no admitir prueba en contrario tiene relación con el valor probatorio, pero no es lo mismo.**

La regla muy general es que los medios de prueba admitan prueba en contrario y sólo no la admitirán cuando el legislador expresamente lo señale.

2.5 En cuanto a su fuente.

- a) Medios de pruebas **reales**: se dan cuando **el elemento de convicción es un objeto determinado.**
- b) Medios de prueba **personales**: **se dan cuando el elemento de convicción es un testimonio**, es decir, un dicho o lo que dice una persona, ya sea que lo diga verbalmente o por escrito, ya sea que lo diga un tercero o una parte.

2.6 En cuanto a su relación con el hecho que se trata de probar.

- a) Medio de prueba **indirecto**: es aquel que **tiende a acreditar otro hecho distinto del que se trata de establecer**, pero ese hecho distinto permite deducirlo.
- b) Medio de prueba **directo**: se da cuando **se acredita el hecho mismo que se trata de establecer.**

Combinando las dos últimas clasificaciones podemos tener prueba real directa e indirecta y prueba personal directa e indirecta. La real directa llevará a la certeza física, la real indirecta a la certeza físico-lógica, la personal directa a la físico-histórica y la personal indirecta al físico histórico lógico.

Estos criterios lógicos son los que han inspirado al legislador para asignarle mayor o menor mérito probatorio a cada uno de los medios de prueba.

Tema 3: Prueba Instrumental.

3.1 Concepto de instrumento.

La prueba instrumental o documental, es aquella que se produce gracias a documentos o instrumentos.

Respecto de lo que es un instrumento hay dos doctrinas:

a) La concepción estructural o clásica: dice que *es instrumento todo objeto en el que se exteriorizan hechos mediante signos permanentes y materiales del lenguaje*. En consecuencia, no importa a esta doctrina el soporte ni tampoco la naturaleza cualquiera que sea el signo. El instrumento en esta concepción está compuesto de dos elementos: soporte y signo del lenguaje que no necesariamente es papel y letra.

b) La concepción funcional: dice que *es instrumento todo objeto representativo de cosas o hechos sin que importe la materialidad del soporte ni la forma de la representación*.

La diferencia de la concepción funcional con la concepción estructural es que en la última el signo va siempre unido al lenguaje, en cambio, en la primera el signo puede o no ir unido al lenguaje. En consecuencia, en la concepción funcional la radiografía, el dibujo, la fotografía, etc., constituyen documentos.

La concepción nacional es estructural y como nace del siglo XIX, parte de **dos supuestos**: *el soporte que es normalmente papel y el signo que son letras de un alfabeto*. O sea, la concepción nacional ve al instrumento como el elemento que refleja signos permanentes unidos al lenguaje. Sin embargo, **esta concepción estructural clásica**, que claramente se nota en el C.C. y CPC **ha tenido una evolución jurisprudencial** y por esta vía se ha ido **acercando a la concepción funcional**, en el sentido que **es instrumento todo elemento demostrativo de un hecho y no necesariamente unido al lenguaje**.

La prueba instrumental tiene un enorme valor en nuestro sistema legal, porque normalmente es preconstituida, en consecuencia, es más pura en el sentido que no nace de los intereses o prefabricaciones en función de un juicio, y además, deriva en una voluntad seria de obligarse, en consecuencia, el legislador atribuye a este elemento una mayor fuerza probatoria.

3.2 Clasificación de los instrumentos.

3.2.1 En cuanto a su función:

a) Instrumentos que se exigen por vía de prueba: significa que se exige o se acepta el instrumento como forma de acreditar un determinado hecho, y la regla general, es que los instrumentos sean exigidos por esta vía y no como solemnidad.

b) Instrumentos que se exigen por vía de solemnidad (artículo 1701 C.C.): significa que la ausencia del respectivo instrumento, hace imposible acreditar la existencia del respectivo hecho o contrato, por ejemplo, la compraventa debe hacerse mediante instrumento público y si éste falta, no se podrá acreditar su existencia por ningún otro medio probatorio.

El artículo 1701 C.C. dice que *la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esta solemnidad y se mirarán como no celebrados o ejecutados, aún cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno*. Esta norma se refiere al instrumento público, pero **hay casos en que el instrumento privado es también solemnidad**. En consecuencia, cuando la escrituración es solemnidad, la falta de instrumento privado no permite acreditar el respectivo hecho; por ejemplo, la promesa de celebrar un contrato debe constar por escrito como solemnidad y, en consecuencia, su omisión no puede suplirse.

3.2.2. En cuanto a su fuente.

a) **Instrumentos públicos** (artículo 1699 C.C. relación con el artículo 17 C.C.)

b) **Instrumentos privados**.

3.3 Instrumentos públicos.

3.3.1 Concepto.

El artículo 1699 se refiere a los instrumentos públicos en general; y el artículo 17 a los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Artículo 1699 C.C.: *“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario.”*

Se critica esta norma en cuanto establece una relación de sinonimia entre instrumento público e instrumento auténtico, lo que es indudablemente un error conceptual, porque instrumento público es una categoría de instrumentos, en tanto que la autenticidad es un atributo que puede o no concurrir. La falta de autenticidad del instrumento público es una de las posibles vías de impugnación del mismo, pero no se puede confundir la categoría con el atributo: *“no todo instrumento público es auténtico, ni todo instrumento auténtico es público”*, por lo que puede haber un instrumento auténtico que sea privado.

3.3.2 Requisitos del instrumento público.

a) **Autorizado por el competente funcionario:** es decir, **que a él concorra un funcionario público**, vinculándose la fe del Estado al respectivo instrumento. La calidad de funcionario público la da la ley, y significa que el funcionario cumple tareas públicas sin que importe la fuente de su designación, el monto de su remuneración, el régimen laboral al que está sometido, el estatuto funcionario aplicable, etc.

El funcionario público debe ser competente, y como la ley es la fuente de la competencia, es ella la que fija la competencia del respectivo funcionario público, lo que puede hacer con dos criterios:

i) **Criterio substancial:** La ley indica cuál es el **ámbito u órbita de posible actuación**, o sea, cuáles son las actividades que dentro de su órbita puede realizar.

ii) Criterio territorial: La ley señala cuál es **ámbito espacial donde puede cumplir dicha actuación**, por ejemplo, todo el territorio de la República. Ciertos funcionarios públicos chilenos tienen como ámbito espacial un país extranjero, v.g. un cónsul chileno.

b) Autorizado con las solemnidades legales: Si la ley ha fijado ciertas y determinadas solemnidades para el instrumento, éstas deben ser cuidadosamente cumplidas, bajo sanción de nulidad. Lo normal es que los instrumentos públicos requieran solemnidades legales (requisitos de carácter formal), pero también es posible que no las requiera, y en este caso, basta que sea autorizado por competente funcionario para calificarlo como tal.

Artículo 1699 inc. 2º C.C.: “Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público se llama escritura pública.”

La escritura pública es una especie dentro del género instrumento público, y tiene las características de ser otorgada ante escribano (notario u otro funcionario al cual le está permitido por ley que ante él se otorguen escrituras públicas) y de ser incorporada a un protocolo o registro público (el que se va formando por la sucesión de las escrituras públicas que se otorgan ante el respectivo notario).

Cuando la ley exige que el instrumento público sea autorizado por el competente funcionario, no exige que dicho funcionario sea un ministro de fe, es decir, puede serlo o no. Así por ejemplo, cuando el profesor firma un acta de examen está otorgando un instrumento público, porque él es un funcionario público en su calidad de académico de la universidad, está en el ámbito de sus atribuciones y está cumpliendo una función pública como es la de enseñar a los alumnos, pero él, no es ministro de fe, porque la calidad de ministro de fe debe otorgársela la ley; sin embargo, basta que él intervenga como funcionario competente en la función pública respectiva para que el instrumento sea público.

Que el funcionario sea o no, ministro de fe, no tiene importancia para determinar el valor probatorio del instrumento público. Lo que ocurre es que si el funcionario público es además ministro de fe, adquiere responsabilidades adicionales.

3.3.3 Instrumento público otorgado en el extranjero.

El artículo 17 C.C. se refiere al instrumento público otorgado en país extranjero, en consecuencia, en Chile también es instrumento público el otorgado en el extranjero, siempre que se observen las regulaciones de dicho país en cuanto a la competencia del funcionario y a la función respectiva, además de la observación de las correspondientes solemnidades.

***Artículo 17 C.C.:** “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.”*

La autenticidad significa acreditar que efectivamente el funcionario interviniente estaba presente en el otorgamiento del acto, lo que se realiza mediante un procedimiento denominado en nuestro sistema como **legalización**.

*Artículo 17 inc. 2º C.C.: “La **forma** se refiere a las solemnidades externas, y la **autenticidad** al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.”*

Un instrumento público otorgado en país extranjero, debe estar sometido a dos conjuntos de pruebas de acreditación:

a) Debe establecerse que ese instrumento es público **de acuerdo a las normas del país donde fue otorgado**, o sea, hay que remitirse a las normas del país donde fue otorgado para determinar su naturaleza.

b) Es necesario establecer que intervinieron en él, **las personas que dicen otorgarlo y el funcionario público autorizante**, para establecer esto último se necesita la **legalización**, que es una cadena de actuaciones que se van realizando sucesivamente en el país de su otorgamiento y después en Chile. El Código en el artículo 345 señala 3 posibilidades de como completar la cadena:

i) **Que en el país de otorgamiento exista agente diplomático o consular chileno**: por ejemplo, una escritura pública otorgado en Buenos Aires, en primer lugar en Argentina se debe completar una determinada cadena según sus normas, así la firma del notario argentino se acreditará como auténtica con la firma del ministro de justicia argentino, y esta firma, con la del ministro de RREE argentino, y esta a su vez, por el agente diplomático o consular chileno. Llegado el documento a Chile se legaliza o acredita la firma del cónsul por el ministerio de RREE chileno.

ii) **Que en el país de otorgamiento no exista agente diplomático o consular chileno, pero sí de una nación amiga que se haya encargado de los intereses de Chile**: se realiza la misma tarea ante el agente diplomático o consular de país amigo y posteriormente esa firma se legaliza por el ministerio de RREE del país amigo o por el agente diplomático o consular acreditado en Chile en ese país y después interviene el ministerio de RREE chileno.

iii) **Que la legalización se realice con la intervención del agente diplomático o consular extranjero acreditado en Chile del país donde seguramente se otorgó el instrumento**: no se recurre al agente diplomático o consular chileno, sino que se va sólo al ministerio de RREE del país donde se otorgó el documento, luego se trae el instrumento y se autentifica esa firma por el agente diplomático o consular de ese país acreditado en Chile, y posteriormente en el ministerio de RREE.

Todo esto se protocoliza en cumplimiento a lo establecido en el 420 C.O.T.

Artículo 345. Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1 El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2 El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por

conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y

3 El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

La situación al revés no está regulada en el CPC, pero para que los instrumentos públicos otorgados en Chile tengan valor fuera, se sigue exactamente el mismo sistema pero a la inversa, es decir, que llegue al ministerio de RREE del país en que se quiere hacer valer.

3.4 Instrumentos privados.

El criterio que ha usado nuestro legislador para llegar al concepto de instrumento privado es de **carácter residual: son instrumentos privados todos los que no sean instrumentos públicos.**

Sin embargo, este criterio residual hoy está en retirada por cuanto hay una categoría intermedia que son los **instrumentos oficiales**, en los que no existe la intervención de un funcionario público o su competencia no esté fijada por la ley, pero **tienen un cierto sello de autenticidad que permite darles mayor categoría que a los instrumentos privados.**

Ejemplos:

- Un tribunal consulta a un banco determinadas circunstancias, técnicamente la respuesta del banco es un instrumento privado, pero la experiencia ha señalado que los bancos son instituciones serias.
- Un ministerio consulta a otro funcionario como han ocurrido determinados hechos. Dentro de la órbita del funcionario no está precisamente el dar esta información, pero en la medida que la da, no es un instrumento público porque no está dentro de la órbita legal, pero si es un instrumento de carácter oficial.

Es práctica frecuente **que los instrumentos privados se autoricen ante notario** y la ley en ciertos casos otorga un **mérito especial** a ese instrumento. Así por ejemplo:

- Para los efectos de la prenda agraria, el contrato de prenda agraria se convierte en título ejecutivo por la circunstancia de que las firmas de los otorgantes estén autorizadas ante notario.
- Si las firmas en una letra de cambio están autorizadas ante notario, esta circunstancia convierte al instrumento en título ejecutivo.

Estos ejemplos son situaciones específicas donde la ley otorga un mérito especial al instrumento privado ante notario, por lo que es necesario preguntarse **cuál es la regla general.**

Artículo 425 inc. 1º C.O.T.: “Los notarios podrán autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, siempre que den fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes y dejen constancia de la fecha en que se firman. Se aplicará también en este caso la regla del artículo 409 –impresión digital-.”

Este precepto permite la práctica señalada, pero el **instrumento privado aunque haya sido autorizado ante notario mantiene su calidad de tal** y sólo se contará con un testigo que da fe de que efectivamente las firmas estampadas corresponden a las personas mencionadas en dicho instrumento.

Sin embargo, cuando el notario certifica la autenticidad de la firma, el atestado notarial en esa parte es instrumento público, porque interviene un funcionario público competente y dentro de la órbita de sus atribuciones, por lo que el notario asumirá todas las responsabilidades inherentes.

El **inc. 2º** reafirma lo que hemos señalado, en el sentido de que los testimonios autorizados por el notario no da el carácter de público al instrumento privado:

Artículo 425 inc. 2º C.O.T.: “Los testimonios autorizados por el notario, como copias, fotocopias o reproducciones fieles de documentos públicos o privados, tendrán valor en conformidad a las reglas generales.”

La nota al pie de éste artículo tiene importancia como dato anecdótico:

- La ley 18181 del año 1982, señala que ciertos y determinados documentos privados a los que tradicionalmente se les exigía que fueran autorizados ante notario, hoy pueden ser presentados como tales sin dicha autorización, por ejemplo: declaraciones juradas, declaraciones de supervivencia o actos similares.
- La ley 19088 del año 1991 señala que si ante la administración pública se presenta un instrumento privado o público y además una fotocopia de dicho instrumento, el funcionario público que lo recibe tiene la obligación de certificar la correspondencia entre la fotocopia y el instrumento acompañado, por ejemplo: cuando en una diligencia se acompañan fotocopias de la libreta de familia que es un instrumento público, el funcionario debe certificar la correspondencia recíproca.

3.5 Prueba instrumental en el juicio civil

Previamente es necesario detenernos **en la iniciativa de prueba**, que por regla general es de las **parte**, y excepcionalmente del **juez**.

El legislador en cuanto a la **iniciativa de parte** se pone en dos hipótesis:

a) Que la parte, que quiera invocarlo y hacerlo valer, tenga el instrumento de que se trate:

En este caso **lo acompañará en la oportunidad procesal correspondiente**, que por regla general es hasta el término probatorio inclusive y dependiendo de la categoría del instrumento se acompañará con citación o de otra forma, para permitir a la contraparte hacer las observaciones correspondientes.

Es del caso señalar que existen instrumentos, públicos o privados, que teniendo tanta importancia para el respectivo litigante, justifican que se solicite su custodia, por lo que junto con acompañarse el instrumento, se pide la custodia del mismo. Si el tribunal accede el instrumento queda en caja de seguridad y bajo la responsabilidad del secretario.

Lo normal es que los instrumentos queden agregados al expediente (cosidos), pero es posible que queden separados, por ejemplo, cuando se acompañan libros o cuando se forma un cuaderno especial que se denomina el cuaderno de documentos.

b) Que el instrumento *esté en poder de la otra parte o de un tercero*.

Esta situación se encuentra regulada en el **artículo 349 CPC**, debiendo procederse a la denominada **exhibición de documentos**.

Si el documento está en poder de la otra parte o de un tercero, se puede solicitar la exhibición del instrumento, pero este derecho sólo se puede invocar si el instrumento tiene relación directa con la cuestión debatida y siempre que no tenga el carácter de confidencial o secreto. En tal evento se solicita la exhibición y el tribunal fija un día y una hora para que se realice la exhibición, y la parte o el tercero, debe concurrir al tribunal para exhibir el documento, dejándose testimonio escrito o copia (o fotocopia) del respectivo instrumento (en la misma forma como se procede en la medida prejudicial de exhibición).

Si el instrumento está en poder de un tercero, éste puede solicitar que la exhibición se realice en su domicilio, y en tal caso el tribunal encargará a un ministro de fe, generalmente el receptor, para que se constituya en el domicilio de quien debe exhibir el instrumento y tome testimonio de él.

Si la orden de exhibición es desobedecida, al desobediente (parte o tercero) se le puede apremiar en la misma forma que la establecida en el artículo 274 CPC (medidas prejudiciales) con multas o arrestos, medidas que se pueden repetir hasta que se cumpla con la orden de exhibir. Además, si el desobediente es la parte contraria tiene una sanción adicional que es la establecida en el artículo 277 CPC, que si se niega a exhibir ese documento, no podrá posteriormente hacerlo valer en su beneficio, salvo que la otra parte lo haga valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición.

Artículo 349 CPC: “Podrá decretarse, a solicitud de parte, exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales.

Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta de quien la solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas.

Si se rehúsa la exhibición sin justa causa, podrá apremiarse al desobediente en la forma establecida por el artículo 274; y si es la parte misma, incurrirá además en el apercibimiento establecido por el artículo 277.

Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, podrá éste exigir que en su propia casa u oficina se saque testimonio de los instrumentos por un ministro de fe.”

En materia civil excepcionalmente la **iniciativa** de la prueba instrumental recae en el propio **tribunal**, conforme a lo dispuesto en el **artículo 159 N°1 CPC**, el cual se refiere a las medidas de mejor resolver y entre éstas, **la agregación de cualquier documento que estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes, que esté en poder de las partes o en poder de terceros**.

3.6 Oportunidad de la prueba instrumental.

Esto hoy se encuentra modificado y consignado en el artículo 348 CPC. Los instrumentos se pueden acompañar, en **primera instancia**, hasta el término probatorio inclusive y, en **segunda instancia**, hasta la vista de la causa.

a) En primera instancia:

Los instrumentos pueden ser acompañados **antes del inicio del término probatorio**, por ejemplo, en la demanda, en la contestación de la réplica o la duplica, e incluso, en un período posterior, **pero la última oportunidad es el término probatorio**, de manera que una vez expirado éste no se puede rendir prueba instrumental.

La ley se refiere sólo al término probatorio ordinario, porque si hubiese querido referirse al término probatorio **extraordinario** o al **especial**, lo habría dicho **expresamente**. Sin embargo, no es un punto pacífico.

Si se trata de la exhibición de un documento que se encuentra en poder de la parte contraria o de un tercero, el término probatorio sólo es fatal para solicitar la exhibición, o sea, si se solicita la exhibición dentro del término probatorio, se está cumpliendo con el requerimiento legal, aunque la exhibición pueda ser realizada por un tercero. La razón es obvia, porque el litigante malicioso podría deliberadamente retardar la exhibición dejando en indefensión a la parte contraria.

b) En segunda instancia:

Se ha entendido que es **antes del inicio de la vista de la causa**, puede ser el mismo día, pero antes del inicio de dicho evento. La vista de la causa es un trámite complejo, que es seguido por la relación y el alegato.

Durante la vista misma (relación o alegatos), **no se pueden acompañar instrumentos**, salvo que se acompañen para el sólo hecho de que los vea el tribunal, pero sin que tengan propiamente fuerza probatoria.

El inc. 2º del artículo 348 CPC, tiene una regla importante respecto de los instrumentos acompañados en segunda instancia: no suspende la vista de la causa, aún cuando se acompañen con citación y la circunstancia de ser acompañados con citación sólo tiene la virtud de retardar la decisión hasta que venza el término de la citación.

Artículo 348 inc. 2º: “La agregación de los que se presenten en segunda instancia, no suspenderá en ningún caso la vista de la causa; pero el tribunal no podrá fallarla, sino después de vencido el término de la citación, cuando haya lugar a ella.”

3.7 Instrumentos en lengua extranjera.

a) *Cuando el que acompaña el documento lo hace **sin traducción***: En este caso se aplica el inc. 1º del artículo 347 CPC, por lo que **el tribunal designará un perito** para que realice la traducción, **a costa de quien acompañó el instrumento** y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre costas.

Artículo 347. Los instrumentos extendidos en lengua extranjera se mandarán traducir por el perito que el tribunal designe, a costa del que los presente, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas en la sentencia.

b) *Cuando el que acompaña el instrumento lo hace **con traducción***:

*Artículo 347 inc. 2º CPC: “Si al tiempo de acompañarse se agrega su traducción, **valdrá ésta**; salvo que la parte contraria exija, dentro de **seis días**, que sea **revisada por un perito**, procediéndose en tal caso como lo dispone el inciso anterior.”*

3.8 Significado de instrumentos públicos.

En cuanto al significado de instrumentos públicos, el CPC y el C.O.T. han aplicado un criterio extensivo y casuístico para calificar ciertos instrumentos como públicos, aunque en estricto rigor no lo sean.

3.8.1 Casuística CPC.

Artículo 342 inc.1º CPC: “Serán considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter.”

Esta norma señala dos cosas muy importantes:

- “Serán considerados como instrumentos públicos...” parte advirtiendo que la enumeración contiene algunas categorías que no son propiamente instrumentos públicos;
- “...en juicio”, es decir, sólo serán considerados en función de medio probatorio en el respectivo juicio, pero no para todos los efectos legales.

1. Los documentos originales.

Aquí el documento original es claramente el **instrumento público mismo**. Por ejemplo, si el instrumento público es la escritura pública, el original será la matriz incorporada en el protocolo o registro público.

2. Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer;

Esto significa que también es instrumento público **la copia del mismo**, siempre que en dicha copia, o en la dación de dicha copia, se observen las **prescripciones legales correspondientes**. Por ejemplo, copia de la matriz de una escritura pública.

3. Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas;”

Se consideran como instrumentos públicos las **copias simples o no autorizadas**, siempre **que se acompañen bajo apercibimiento** de tenerse como auténticas si no fuesen objetadas dentro de tercero día.

No basta que la copia simple se acompañe con citación, sino que se debe decir expresamente que se acompaña bajo apercibimiento de tenerse por auténtica si no fuese objetada dentro de tres días, y si efectivamente se dicta esta resolución y se notifica por el estado diario, una vez transcurrido el tiempo, la copia simple adquiere en el juicio respectivo la calidad de instrumento público. Si la copia simple es objetada, no adquiere dicha calidad sino una vez practicado el cotejo.

4. Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria;

Si se acompaña una copia simple bajo apercibimiento de tenerse por auténtica si no es objetada dentro de tercero día, y sobreviene la objeción, todavía es posible que esa copia se convierta en instrumento público a través del **cotejo**, que **es la comparación entre la copia simple objetada con el original, o la comparación entre la copia simple objetada con otra copia del original autorizada**.

El cotejo no es una **operación** de carácter pericial, sino **de carácter mecánica**, que significa hacer la comparación o paralelo. El cotejo se realiza por el funcionario designado por el tribunal, el cual comparará palabra por palabra. El artículo 344 CPC señala los sujetos que deben realizar el cotejo:

Artículo 344 CPC: “El cotejo de instrumentos se hará por el funcionario que haya autorizado la copia presentada en el juicio, por el secretario del tribunal o por otro ministro de fe que dicho tribunal designe.

El cotejo de instrumentos **nada tiene que ver** con el **cotejo de letras que sí es de carácter pericial**, por el cual se determina si una escritura o firma corresponde o no a la persona a quien se le atribuye.

5. Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior;”

Se trata de **testimonios respecto de instrumentos públicos, obtenidos por orden del tribunal y autorizados por el secretario u otro funcionario competente**. Se obtiene de los originales o de copias autorizadas.

Respecto de las copias que se acompañan en general, cuando son incompletas, la parte contraria tiene siempre el derecho de pedir que se completen con las partes que se hubiesen omitido. Esto se aplica no sólo a la copia que se acompañó en parte, sino también a los testimonios parciales.

Artículo 343 Cuando las copias agregadas sólo tengan una parte del instrumento original, cualquiera de los interesados en el pleito podrá exigir que se agregue el todo o parte de lo omitido, a sus expensas, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas.

6. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.

Este artículo debe ser complementado con el artículo 348 bis.

Artículo 348 bis. *Presentado un documento electrónico, el Tribunal citará para el 6° día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios.*

Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que los presente.

En caso que el documento sea objetado, en conformidad con las reglas generales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda. Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423.

En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, N° 3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción.

3.8.2 Casuística COT.

Existe una gran **diferencia** con lo anterior porque los instrumentos que se consideran como públicos según el artículo 342 CPC, sólo lo **son en función de ese específico juicio**; en cambio, en el C.O.T. asimila como instrumentos públicos **para todos los efectos legales**. Por ende, los efectos del reconocimiento de instrumento público del artículo 342 CPC son de carácter restringido; en cambio, los efectos del reconocimiento del artículo 420 C.O.T. son amplios.

El C.O.T. da la categoría de instrumentos públicos a ciertos y determinados instrumentos que, en su esencia, pueden serlo o no serlo. Pero establece como requisito *sine qua non*, para otorgar tal categoría, el hecho que se **protocolicen**.

La protocolización dice relación con el **protocolo notarial**, o sea, con el protocolo que lleva el notario u otros funcionarios públicos que cumplen las funciones de notario excepcionalmente, como son, en el primer caso, el oficial del registro civil, y en el segundo, un cónsul de Chile.

El protocolo es el libro esencial del notario y se forma por la agregación sucesiva, en estricto orden cronológico, de las escrituras públicas otorgadas ante él.

La **protocolización** consiste en agregar al final del protocolo, a requerimiento de parte, ciertos y determinados instrumentos.

La diferencia que existe entre la escritura pública y el instrumento protocolizado, es que la primera es el cuerpo del protocolo, en cambio, el instrumento protocolizado se agrega al final del respectivo mes, también en orden correlativo, a requerimiento de parte. De este requerimiento de parte, el notario, debe dejar testimonio en el protocolo, o sea, que el interviniente comparece ante él, que firmó ante él y que le entregó el instrumento para ser protocolizado.

Excepcionalmente se puede protocolizar un instrumento a petición de los otorgantes de una escritura pública, y en tal caso, no se requiere un testimonio separado o aislado, sino que, el propio testimonio que se deja en la escritura pública del requerimiento de protocolización es suficiente. Encontramos como ejemplos:

- Cuando se vende un bien raíz que tiene ciertas y determinadas características, el vendedor se puede remitir a un plano y dejar testimonio en la misma escritura, del hecho de haberse requerido la protocolización del plano, en cuyo evento, el plano se agrega materialmente al final del protocolo.
- Una carta que se estima de gran importancia se puede protocolizar, requiriéndose que el funcionario exija comparecencia en el protocolo, dejando testimonio.

a) Efectos de la protocolización.

1. Se **preserva** definitivamente un determinado instrumento, porque el notario debe guardarlo celosamente para siempre.
2. **Se pueden otorgar copias** de un testimonio cuando se requieran.
3. **Adquieren fecha cierta respecto de terceros**, a partir del día en que se requiere la protocolización.

b) Análisis del artículo 420.

Artículo 420 *“Una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos:*

1. Los testamentos cerrados y abiertos en forma legal;

Los testamentos solemnes pueden ser cerrados o abiertos, y la característica diferenciadora de unos y otros es que en los testamentos abiertos cualquiera puede imponerse de las manifestaciones de voluntad del testador, en cambio, en el testamento cerrado la manifestación de voluntad está contenida en un sobre cerrado, donde intervienen un notario, ciertos testigos y se guarda con precaución para ser abierto sólo después del fallecimiento del causante.

La **apertura del testamento** se realiza ante **el juez de letras del lugar donde tuvo su último domicilio el causante**, toda la actuación es de carácter solemne y **todo lo obrado** en el expediente respectivo es posteriormente **protocolizado**. Así se convierte en un instrumento público lo que no tiene nada de particular porque en la actuación misma del otorgamiento del testamento cerrado ha intervenido un notario y en las actuaciones posteriores de apertura ha actuado un juez de letras con su respectivo secretario.

2. Los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas siempre que su protocolización se haya efectuado a mas tardar, dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento;

También los testamentos solemnes abiertos pueden ser otorgados en hojas sueltas. En este caso no es necesario que intervenga un notario, pero sí que hayan 5 testigos.

Estos instrumentos que técnicamente son instrumentos privados, la ley les da carácter de público cuando se procede a su protocolización en el plazo que señala la disposición.

3. Los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, previo decreto del juez competente;

Los testamentos menos solemnes son el testamento **militar, marítimo y verbal**, se otorgan bajo determinadas circunstancias que hacen presumir la urgencia respecto del acto de que se trata. La tramitación de estos testamentos menos solemnes también llevan al carácter de instrumentos públicos en virtud de su protocolización, aunque técnicamente no lo sean.

4. Las actas de oferta de pago;

Esta es una institución que se vincula al **pago por consignación**.

La oferta de pago es una actuación que se realiza con intervención de un ministro de fe, sin previo decreto judicial y se levanta un acta, la que debe protocolizarse y vale como instrumento público a partir de ese momento.

5. Los instrumentos otorgados en el extranjero, las transcripciones y las traducciones efectuadas por el interprete oficial o los peritos nombrados al efecto por el juez competente debidamente legalizadas, que sirvan para otorgar escrituras en Chile.”

Este número se refiere a los instrumentos otorgados en el extranjero. Cuando se cumplen ciertos requisitos y se protocolizan valen como instrumentos públicos; aún cuando la norma se refiere a los instrumentos en general, si se concuerda este número con el artículo 345 C.P.C, se llega a la conclusión que la referencia sólo debe entenderse hecha a los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, que valdrán previa protocolización en Chile.

3.9 Forma de acompañar en juicio los instrumentos públicos.

Los instrumentos públicos deben ser acompañados **con citación o bajo el apercibimiento respectivo**, siempre que dicho apercibimiento sea más amplio que el de la citación; así por ejemplo, si se acompaña una copia simple y se pretende que se convierta en este juicio en instrumento público, se acompañará bajo apercibimiento de tenerse por reconocido si no fuese objetado dentro de tercero día.

Al tratar nuestro legislador el recurso de **casación en la forma** señalada en el artículo 795 N° 5 y 800 N°4, dispuso que la citación, respecto de los instrumentos públicos que se acompañan, **es trámite esencial en primera y en segunda instancia**, de suerte que la omisión de ese trámite puede acarrear la nulidad procesal correspondiente.

Respecto de la forma de acompañar los instrumentos públicos, es útil tener presente lo que se señala en el artículo 255 C.P.C; este artículo permite acompañar en la demanda los instrumentos respectivos, y en tal evento el término para impugnarlo se amplía (término de emplazamiento).

3.9.1 Causales de impugnación de un instrumento público.

Se acompaña al juicio con citación, dentro de este término o uno mayor en los casos en que procede. Los motivos o razones en virtud de las cuales se puede impugnar son:

a) Nulidad: La nulidad del instrumento público puede ser de carácter:

- i) **Específico:** esto ocurre cuando la ley señala algunas causales propias de nulidad de los instrumentos públicos, por ejemplo, las escrituras públicas no pueden contener estipulaciones a favor del notario.
- ii) **Genérico:** proceden ya sea por incumplimiento de solemnidades, cuando efectivamente la ley las ha señalado o por incompetencia del funcionario otorgante, tanto territorial o substancial.

La nulidad del instrumento puede plantearse por:

- i) **Vía principal:** cuando se demanda o se reconviene la nulidad del instrumento público, por ejemplo, se demanda la nulidad de un testamento abierto porque no intervino el notario.
- ii) **Vía incidental:** se dice de nulidad del instrumento dentro del término de citación o del más amplio con que ha sido acompañado.

Ambas formas son igualmente eficaces, en un caso sobrevendrá una sentencia definitiva que acoja o rechace la pretensión de nulidad, en otra sobrevendrá una interlocutoria que acoge o rechaza la pretensión de nulidad, pero ambas firmes y ejecutoriadas producen el efecto de cosa juzgada.

Respecto de la nulidad del instrumento público, sea genérica o específica, la ley no establece limitaciones en cuanto a los medios de prueba, o sea, cualquiera y todos los medios de prueba son idóneos para acreditar la nulidad.

Es necesaria hacer la distinción entre el instrumento público y el acto o contrato contenido en el instrumento público. Si el instrumento público es solemnidad del acto o contrato de que se trata, la nulidad del instrumento público acarrea nulidad del acto o contrato. Si el instrumento no es solemnidad del acto o contrato, su nulidad no acarrea nulidad del acto o contrato, sin perjuicio, de que pueden o no concurrir otras causales de nulidad (artículo 1701 C.C.).

b) Falsedad: se produce si el instrumento no ha sido realmente autorizado u otorgado en la forma que en él se expresa, o sea hay fraude. Respecto de esta impugnación hay que distinguir dos situaciones:

- i) El instrumento público, en general, puede ser impugnado por falsedad y ésta **puede probarse por cualquier medio de prueba** (artículo 355).

Artículo 355. En el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplantaciones hechas en él, se admitirán como medios probatorios, tanto el cotejo de que tratan los cinco artículos precedentes, como los que las leyes autoricen para la prueba del fraude.

En la apreciación de los diversos medios de prueba opuestos al mérito de un instrumento, el tribunal se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente Título, y con especialidad a las consignadas en el párrafo 8.

- ii) Cuando el instrumento público es una **escritura pública**, la prueba **testimonial** está sometida a **restricciones**. Cabe hacer notar que el artículo 429 se refiere a la falsedad de la escritura pública (que el funcionario, las partes o los testigos no concurrieron a su otorgamiento) y no a la sinceridad de las declaraciones contenidas en ella, se está tratando de controvertir

En este caso la prueba testimonial **no puede ser inferior a 5 testigos**, lo habitual es que dos testigos constituyan plena prueba, y además, deben ser especialmente **calificados** (artículo 384), **deben acreditar que las partes que se dicen concurrentes a la escritura o el notario o el testigo fallecieron con anterioridad a la fecha de la escritura pública, o bien, se encontraban ausentes del lugar el día de su otorgamiento y los setenta días posteriores.**

En las escrituras públicas hay fechas de otorgamiento, de suscripción y de autorización. El otorgamiento es la materialidad de extender la escritura en el protocolo, y cuando cualquiera de los otorgantes la suscribe adquiere inmediatamente fecha; los demás otorgantes pueden firmarla hasta sesenta días después de esa fecha y el notario puede autorizarla indefinidamente después, no tiene plazo.

La apreciación de esta prueba se hará de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de manera que aunque concurren estos 5 testigos estrellas y digan lo que el código exige que digan, el juez no está obligado.

Artículo 429 (432). Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la concurrencia de cinco testigos, que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, que acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento o el escribano, o alguno de los testigos instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los setenta días subsiguientes.

Esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica.

La disposición de este artículo sólo se aplicará cuando se trate de impugnar la autenticidad de la escritura misma, pero no las declaraciones consignadas en una escritura pública auténtica.

c) Falta de integridad (artículo 343): ésta se refiere a las **copias** que tengan el carácter de instrumentos públicos. Si la copia **sólo contiene una parte del instrumento original**, se la puede impugnar por falta de integridad y, en consecuencia, exigir **que la copia se complete agregando lo omitido** y quien solicite que se complete debe pagar las costas correspondientes, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

Artículo 343. Cuando las copias agregadas sólo tengan una parte del instrumento original, cualquiera de los interesados en el pleito podrá exigir que se agregue el todo o parte de lo omitido, a sus expensas, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas.

d) Insinceridad (artículo 1709 CC y 129 C. Comercio). Se refiere a **las declaraciones que formulan las partes**, no a las que formula el funcionario autorizante.

La fe pública del instrumento dice relación con las **declaraciones que formula el funcionario autorizante**, pero no cubre la veracidad de las declaraciones que formulan las partes, en consecuencia, respecto del **instrumento público** está comprometida la fe pública en cuanto **al hecho de haberse otorgado**, a la fecha del instrumento, que efectivamente **concurrieron a él las personas que se dicen concurrentes** y en

cuanto a que esas personas que se dicen concurrentes **formularon las declaraciones que en él se contiene.**

Cuando se impugna por esta causa lo que se está afirmando es que las declaraciones que formularon las partes no son verdaderas. Así por ejemplo, si hay una escritura pública de compraventa, donde se dice que el precio es la cantidad de tanto que se paga al contado, la declaración de las partes no queda cubierta por la fe pública y, en consecuencia, si se impugna esa escritura por falta de sinceridad se dirá que el precio no se pagó al contado.

3.9.2 Impugnación de un instrumento público por terceros.

Respecto de terceros el instrumento público no produce fe respecto de la sinceridad de las declaraciones; en consecuencia, los terceros se encuentran en libertad de impugnar el instrumento público por falta de sinceridad, y todos los medios probatorios serán idóneos para acreditar efectivamente que dichas declaraciones no corresponden a la verdad.

3.9.3 Impugnación de un instrumento público por las partes.

Respecto de las partes, la cuestión cambia radicalmente y, en principio, las declaraciones formuladas en el instrumento público producen plena fe respecto de las partes, esto es, tienen mérito probatorio suficiente en el sentido que dichas declaraciones son verdaderas. Sin embargo, esta plena fe puede ser destruida por prueba en contrario.

Es necesario hacer ciertas **distinciones** respecto a los hechos consignados en el instrumento público y respecto a las obligaciones y descargos en relación con esas obligaciones; y hay que hacer distinciones entre las cláusulas o declaraciones meramente enunciativas y las cláusulas dispositivas; y todavía, hay que hacer una distinción respecto de las cláusulas meramente enunciativas, si guardan o no relación con las cláusulas dispositivas.

Esta materia se verá al tratar el valor probatorio del instrumento público.

Hay que tener presente que para producir prueba en contra de las declaraciones contenidas en instrumento público, las partes, en principio, se pueden valer de cualquier medio probatorio. Sin embargo, en materia obligacional civil hay limitaciones respecto de la prueba testimonial, no así en el ámbito mercantil.

3.10 Significado de instrumentos públicos.

Ya hemos señalado que es **instrumento privado** *todo lo que no es instrumento público.*

No obstante este concepto residual, hoy en día se ha ido creando por la vía de la costumbre y de alguna manera por la jurisprudencia el “*documento oficial*”, al que ya hemos hecho referencia.

La característica esencial del instrumento privado es que como no intervienen en él funcionarios públicos a quienes la ley les haya encomendado esta intervención, falta en ellos la autenticidad emanada del sello del Estado, y es precisamente esto lo que a los ojos del legislador disminuye su valor probatorio. En consecuencia, el instrumento privado para que tenga valor, en principio debe ser reconocido por la parte a quien se le atribuye y sólo en virtud de este reconocimiento adquiere cierta y determinada jerarquía probatoria.

El instrumento privado *per se* sin este reconocimiento no tiene valor probatorio y su mecanismo de reconocimiento está señalado en el CPC

Tratándose de instrumentos privados rige lo señalado a propósito de la custodia de los mismos.

Artículo 346: “Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos”.

...se tendrán... esto indica que no siempre hay un reconocimiento explícito, sino que puede haber un reconocimiento tácito y un reconocimiento judicial.

1. Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;

El legislador se pone en dos hipótesis que el reconocimiento expreso emane: a) de la parte a quien se atribuye el instrumento privado; b) de un tercero a quien se atribuye el instrumento privado.

Claro está, que si la parte reconoce el instrumento privado que se le atribuye, dicho valor probatorio será máximo; en cambio, si es un tercero el que reconoce como auténtico el documento que se le atribuye, este valor probatorio será menor.

2. Cuando igual declaración se ha hecho en instrumento público o en otro juicio diverso;

Estamos nuevamente ante un reconocimiento expreso, que puede emanar de un tercero o de la parte misma, pero este reconocimiento a diferencia del anterior es necesario que conste en instrumento público o en otro juicio. Si el tercero o la parte reconoce el instrumento privado expresándolo así en instrumento público o en otro juicio diverso, se le tendrá por reconocido.

3. Cuando puesto en conocimiento de la parte contraria no se alegue su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal para este efecto apercebir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento privado si nada expone dentro de dicho plazo;”

Se trata de un reconocimiento tácito que sólo puede operar cuando se le atribuye a la parte contraria, no a un tercero.

Puesto el documento en conocimiento de la parte contraria el tribunal le debe otorgar un plazo de seis días para que formule sus observaciones (falsedad o falta de integridad), en este plazo puede ocurrir:

a) Que no sobrevenga impugnación: entonces transcurrido este plazo fatal, se tiene por reconocido el instrumento.

b) Que sobrevenga impugnación del instrumento: por alguna de las dos causales (falsedad o falta de integridad). Surge aquí un incidente sobre la autenticidad del instrumento, el que será resuelto mediante una sentencia interlocutoria.

4. Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.

Esto guarda relación con el número anterior. El instrumento privado se acompaña bajo apercibimiento y la contraparte lo impugna y en el incidente de impugnación se acreditó la autenticidad del documento. Obviamente la resolución judicial producirá sus efectos cuando se encuentre firme o ejecutoriada.

Si sobreviene la impugnación del instrumento se forma un incidente para acreditar si el instrumento es o no auténtico, y en este incidente son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, hay una prueba que el legislador particularmente reglamentó y se denomina el “cotejo de letras”.

Es importante no confundir el *cotejo de letras* con el *cotejo de instrumentos*, que es una labor de carácter material que significa comparar el texto de un instrumento con su respectiva matriz. El cotejo de letras es una operación de carácter pericial y consiste en determinar que una escritura o firma emana o no de la persona a quien se le atribuye. Genéricamente se llama a esta operación “*pericia caligráfica*”, aún cuando es preferible denominarla como “*pericia instrumental*”.

El cotejo de letras tiene gran importancia respecto de los instrumentos privados, pero también puede producirse en relación con instrumentos públicos. Si el instrumento público tiene matriz, no cabe ahí el cotejo de letras, sino el cotejo de instrumentos; en cambio, si no tiene matriz puede efectivamente discutirse si la firma estampada corresponde o no a la persona y también la matriz del instrumento público puede haber sido sujeto a falsedades y en este caso también el cotejo de letras podrá referirse a la matriz (artículo 350).

Artículo 350. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue por la parte a quien perjudique o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o la de cualquier documento público que carezca de matriz.

En este cotejo procederán los peritos con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 hasta 423 inclusive.

3.10.1 Procedimiento del cotejo de letras.

Respecto de la forma para realizar el cotejo es necesario comparar la letra o la firma del documento dubitado con la letra o la firma de un documento indubitado.

Esta comparación la hace el perito.

El instrumento indubitado lo propone la parte que está pidiendo la diligencia de cotejo (artículo 351). Pueden ser 2 o más los documentos indubitados y éstos pueden ser:

- a) los que las partes aceptan como tales de común acuerdo;
- b) los instrumentos públicos no tachados de apócrifos o suplantados; y
- c) los instrumentos cuya letra o firma haya sido reconocida en conformidad a los números 1 y 2 del artículo 346.

Determinados los documentos indubitados, se procede a la labor pericial correspondiente.

Como la escritura es consecuencia de un proceso psicológico motor complejo y como son muchos los factores que pueden influir en su deformación, el informe de peritos puede tener valor probatorio o no

dependiendo del criterio del juez, quien después de oír a los peritos revisores debe hacer la comprobación por sí mismo (artículo 353).

Artículo 353. *El tribunal hará por sí mismo la comprobación después de oír a los peritos revisores y no tendrá que sujetarse al dictamen de éstos.*

En consecuencia, el cotejo de letras no constituye por sí solo prueba suficiente, pero podrá servir de base de una presunción judicial.

Artículo 354). *El cotejo de letras no constituye por sí solo prueba suficiente; pero podrá servir de base para una presunción judicial.*

En el incidente sobre autenticidad del instrumento el cotejo es uno de los medios posibles y no excluye a los demás (artículo 355). Si hay contradicción entre las distintas pruebas, el juez se inclinará por aquella que estima más apegada a la verdad, aplicando sobre el particular los principios generales.

Artículo 355. En el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplantaciones hechas en él, se admitirán como medios probatorios, tanto el cotejo de que tratan los cinco artículos precedentes, como los que las leyes autoricen para la prueba del fraude.

En la apreciación de los diversos medios de prueba opuestos al mérito de un instrumento, el tribunal se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente Título, y con especialidad a las consignadas en el párrafo 8.

3.10.2 Forma de acompañar los instrumentos privados.

Para analizar este tema es necesario **distinguir**:

a) Si instrumento privado que se acompaña, se pretende que emana de la parte contraria: se acompaña bajo el **apercibimiento del artículo 346 N° 3**, o sea, de tenerse por reconocido si no fuese objetado por falta de autenticidad o de integridad en el sexto día.

b) Si el instrumento privado se pretende que emana de un tercero: se acompaña **con citación**, dando cumplimiento a lo establecido en los arts. 795 N°5 y 800 N°5, que señalan que es trámite esencial que los instrumentos se acompañen con citación de la parte contraria.

Dentro de este término de citación, naturalmente no cabe alegar la falta de autenticidad y la falta de integridad, porque el documento en sí mismo no tiene valor probatorio, sino que la parte contraria debe hacer presente que se trata de instrumento privado emanado de un tercero y, por lo tanto en sí mismo no tiene o carece de mérito probatorio.

3.10.3 Fecha del instrumento privado respecto de terceros.

El instrumento privado no lleva envuelto en sí la fe del Estado, en consecuencia, su contenido no produce efecto respecto de terceros; sin embargo, hay ciertas circunstancias que hacen que el instrumento privado adquiera fecha cierta respecto de terceros, la que no necesariamente es la fecha instrumento. Estas circunstancias son (artículo 1703 C.C.):

a) **El fallecimiento de alguno de los que lo han firmado**, obviamente el instrumento privado tiene fecha cierta a partir de dicho evento, en el sentido que no puede tener una fecha posterior;

- b) **Desde el día que ha sido copiado en un registro público;**
- c) **Desde el momento en que son acompañados en juicio**, cualquiera que sea el juicio;
- d) **Cuando se ha tomado razón de él o se ha inventariado por un funcionario competente en su calidad de tal.**

Esta disposición debe complementarse con el artículo 419 del C.O.T. que señala que, sin perjuicio de la razones en virtud de las cuales un instrumento privado adquiere fecha cierta de acuerdo al artículo 1703 C.C, también adquiere fecha cierta a partir de su protocolización.

Además de estas circunstancias, el Código de Comercio establece una causal específica de fecha cierta respecto de los instrumentos privados, en el artículo 127:

“Las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aun fuera de los casos que enumera el artículo 1703 del Código Civil.”

Dentro de las escrituras privadas que emanan de los comerciantes, hay algunas que tienen gran trascendencia que son las facturas, las boletas, las guías de despacho; estos documentos por modestos que sean si efectivamente guardan relación con los libros del comerciante tienen fecha cierta en relación con terceros.

3.11 Valor probatorio de los instrumentos.

3.11.1 Valor probatorio de los instrumentos públicos (arts. 1700 inc. 1º C.C. y 1706 C.C.)

*Artículo 1700 C.C.: “El instrumento público hace **plena fe** en cuanto al **hecho de haberse otorgado y su fecha**, pero **no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados**. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes.*

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular.”

Artículo 1706 C.C.: “El instrumento público o privado hace fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.”

Sobre el particular hay que ver en el instrumento público los cuatro siguientes aspectos:

- a) en cuanto a su fecha,
- b) en cuanto al hecho de haberse otorgado,
- c) en cuanto al hecho que las partes intervinientes formularon las declaraciones en él consignadas,
- d) en cuanto a la veracidad o fe de dichas declaraciones.

Respecto de los **tres primeros aspectos**, esto es, fecha, el haberse otorgado y que las partes formularon las declaraciones en el instrumento, **hacen plena fe, erga omnes**, o sea, hacen plena fe no sólo respecto de los **otorgantes** sino también respecto de **terceros**. Esto deriva de su calidad de “público”, porque envuelve la fe del Estado, en consecuencia, está cubierto por una garantía de autenticidad. El hecho que haga plena prueba, **no significa que no pueda producirse prueba en contrario**.

Respecto de las **declaraciones mismas**, hay que distinguir:

- a) Respecto de **terceros**, las declaraciones **no producen prueba en cuanto a su veracidad**. Esta consecuencia deriva de la relatividad de los actos y contratos, en el sentido que los actos y contratos son vinculantes sólo para las partes y sus sucesores, pero no son vinculantes respecto de terceros.
- b) Respecto de las **partes**, hay que distinguir si se trata de declaraciones **dispositivas** o **enunciativas**. Se entiende por **declaraciones dispositivas** aquellas donde **se consigna la esencia misma del instrumento**; las **declaraciones enunciativas** son las que sirven sólo como complemento y que muchas veces se refieren a la individualización de las partes u otras características más o menos secundarias.
 - i) Respecto de la **parte dispositiva** el instrumento hace plena fe respecto de las partes, pero se puede producir prueba en contrario, por ejemplo, si en la escritura pública de compraventa se deja testimonio que el vendedor recibió el precio, esa declaración hace plena fe entre las partes, pero el vendedor podría probar que esa declaración no es exacta.
 - ii) Respecto de la **parte enunciativa**, en general **no produce efecto respecto de las partes**. Sin embargo, **producen fe cuando guardan relación con las dispositivas**; por ejemplo, si se contrata con una mujer y ella se declara mayor de edad y soltera, eso puede tener relación con lo dispositivo en función con la capacidad para celebrar el respectivo contrato, en consecuencia, esas declaraciones meramente enunciativas pueden producir plena fe, pero puede ser destruida por prueba en contrario. En este caso, será admisible la prueba testimonial, porque la limitación rige sólo en materia obligacional.

3.11.2 Valor probatorio del instrumento privado.

- a) Respecto de **terceros**, el instrumento privado no tiene valor probatorio *per se*, sin perjuicio de que en función de él pueda eventualmente poderse construir una presunción.
- b) Respecto de las **partes** hay que distinguir:
 - i) si el instrumento privado **ha sido reconocido o se le tiene por reconocido**, hace igual fe (plena prueba) que el instrumento público respecto de las partes.
 - ii) si el instrumento privado **no ha sido reconocido o tenido por reconocido**: no hace fe respecto de las partes y no tiene *per se* fuerza probatoria, sin perjuicio, de que se pudiese construir a partir de él una determinada presunción judicial.

Tema 4: Prueba Testimonial.

4.1 Concepto.

La prueba testimonial, como su nombre lo indica, **es la que proviene de testigos**. **Testigos** son terceros extraños al juicio que declaran sobre hechos que interesan a la causa.



4.2 Características de la prueba testimonial.

a) **Normalmente será prueba judicial**, en el sentido que se rinde durante el juicio; pero excepcionalmente puede ser prueba preconstituida, esto en dos circunstancias:

- i) cuando la prueba testimonial se obtiene como medida prejudicial probatoria.
- ii) en los casos de las llamadas “informaciones para perpetua memoria”, que son actuaciones de carácter no contencioso o voluntario reglamentados en el CPC en su libro IV, en virtud del cual se pretende dejar testimonio de ciertos hechos que vale la pena consignar y definitivamente recordar.

b) **Si el testigo es instrumental** (es decir, ha concurrido al otorgamiento de un instrumento), la prueba instrumental, en este caso, es preconstituida (el instrumento es anterior al juicio), en consecuencia, la prueba testimonial será también preconstituida.

c) La prueba testimonial, **puede ser prueba directa o indirecta**, de acuerdo a la clasificación que distinguía como prueba *directa* a aquella que se refiere derechamente al hecho que se trata de establecer, y prueba *indirecta* a aquella que se refiere a otro hecho distinto del que se trata de establecer, pero que lo supone.

d) La prueba testimonial **es siempre prueba personal**, es decir, emana del dicho de una persona.

e) La prueba testimonial **puede constituir plena prueba o no**, según las reglas de apreciación.

4.3 Admisibilidad o limitaciones a la prueba testimonial.

Esta **es una cuestión sustancial y no procesal**, que se encuentra regulada por el Código Civil en los artículos 1708, 1709, 1710 y 1711.

Las **razones** que ha señalado el legislador para poner limitaciones a la prueba testimonial son:

- i) **la mayor o menor capacidad de captación de los hechos**; para ser testigo han de tenerse las condiciones necesarias para haber captado el hecho sobre el cual se declara;
- ii) **posibles errores de memoria**;

iii) el legislador ha temido **que la prueba testimonial se fragüe**, o sea, que en definitiva se logre un acuerdo fraudulento entre la persona que pretende valerse de la prueba testimonial y los respectivos testigos.

La admisibilidad de la prueba testimonial **es una cuestión de fondo y no de forma**; en consecuencia, **el juez se pronunciará en la sentencia definitiva** si la prueba testimonial recibida es o no admisible, pero no puede poner límites al inicio de juicio y, desde luego, no puede rechazar una prueba testimonial arguyendo a su inadmisibilidad.

a) Artículo 1708 C.C.

“No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito.”

Aquí **no se trata de la prueba de “hechos”, sino que de “obligaciones”**.

Las obligaciones que deben consignarse por escrito son aquellas que requieren de la solemnidad de la **escrituración** (no escritura pública), así por ejemplo, no se puede probar por testigos la celebración de un contrato de promesa, como tampoco las obligaciones que debieron constar de escritura pública.

b) Artículo 1709:

“Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias.

No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma.

No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida.”

Lo que está prohibiendo el legislador es que con prueba testimonial se acredite un acto o contrato que contenga la entrega o promesa de entregar de una cosa que valga más de 2 UTM. en consecuencia, si un contrato no contiene la entrega o promesa de entregar de una cosa, aunque pueda implícitamente importar una gran cuantía, se puede probar por testigos.

El valor y límite está referido **al momento de la celebración del acto o contrato**, no al momento de la prueba; es decir, la cosa puede variar de valor durante el tiempo intermedio.

Esta limitación rige incluso si el demandante limita su pretensión a una cantidad inferior, por ejemplo: si el contrato contiene la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 UTM, y el demandante dice que el contrato se cumplió en la mitad, de manera que pretendo sólo cobrar la mitad, no se puede comprobar la existencia de este contrato con prueba testimonial (artículo 1710 inc. 1º C.C.). Por último, tampoco es admisible la demanda aunque se limite a menos del valor fijado cuando se pretende que se está cobrando sólo el saldo de una cantidad mayor (inc. 2º artículo 1710 C.C.).

Respecto de esta limitación es muy importante tener en vista lo establecido en el inc. 2º del artículo 1709, en cuanto a que si el contrato debió constar por escrito no es admisible la prueba testimonial en cuanto se pretenda adicionar o alterar de modo alguno lo que se expresa en el acto o contrato; tampoco

es admisible la testimonial si se pretende con ella probar lo que se dijo antes del contrato o al tiempo de su otorgamiento, aún cuando cualquiera de estas adiciones o alteraciones individualmente consideradas tenga un valor inferior a las 2 UTM.

4.4 Excepciones a las limitaciones a la prueba testimonial.

Estas excepciones a las limitaciones a la prueba testimonial se refieren sólo a los casos en que la escrituración es *ad probationem*, no cuando la escrituración es *ad solemnitatem*; dicho de otra manera, cuando la escrituración se requiere *ad solemnitatem*, no es posible nunca probar el acto o contrato por prueba testimonial, no hay excepciones a este principio, pero si hay excepciones al principio cuando la escrituración se requiere *ad probationem*.

Estas excepciones son genéricas o específicas. Son **excepciones genéricas** aquellas que se refieren a situaciones que se pueden producir respecto de cualquier acto o contrato; y son **excepciones específicas** las que se pueden referir sólo a determinados actos o contratos.

a) Excepciones Genéricas (artículo 1711 C.C.)

a.1) Cuando hay principio de prueba por escrito (inc. 1º y 2º artículo 1711 C.C.): el acto o contrato no consta por escrito, sin embargo hay un escrito emanado de la respectiva parte que hace verosímil la existencia de tal acto o contrato, y en tal evento si existe esta prueba podrá acreditarse el acto o contrato mismo en virtud de prueba testimonial.

El documento que debe emanar de la parte contraria, puede ser un instrumento público o un instrumento privado, pero si se trata de un instrumento privado, este debe estar reconocido o haberse tenido por reconocido.

El inc. 2º artículo 1711 da un ejemplo para ilustrar el concepto del inc. 1º, pero el legislador desdibujó el concepto dando un ejemplo oscuro e ininteligible.

a.2) Cuando la escrituración fue imposible (artículo 1711 inc. 3º): que haya sido posible o imposible de obtener prueba escrita es una cuestión de hecho, que naturalmente en cada caso particular deberá calificarse y eventualmente probarse.

La doctrina reiteradamente ha señalado que esta imposibilidad puede ser de carácter físico o de carácter moral. Imposibilidad de carácter **físico** significa que dadas las circunstancias en que nació el respectivo acto o contrato, no pudo escriturarse en ese instante (por ejemplo la urgencia); la imposibilidad de carácter **moral** surge cuando por las relaciones que unen a las partes contratantes, no se hace razonable exigir la correspondiente escrituración.

b) Excepciones Específicas. Son excepciones contenidas en relación con actos y contratos determinados, que no obstante haber tenido que constar por escrito por su cuantía, pueden probarse por prueba testimonial.

b.1) Artículos 128 y 129 C. Co.: estos artículos son 2 normas diferentes que apuntan en el mismo sentido:

Artículo 128 C. Co.: “La prueba de los testigos es admisible en negocios mercantiles cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la ley exija escritura pública.”

Artículo 129 C.Co.: “Los juzgados de comercio podrán, atendidas las circunstancias de la causa, admitir prueba testimonial aún cuando altere o adiciones el contenido de escritura pública.”

Estas normas apuntan al hecho que los actos o contratos de carácter mercantil, cuando ellos debieron celebrarse por escrito *ad probationem*, sin embargo pueden acreditarse por prueba testimonial; a contrario *sensu*, cuando los actos o contratos mercantiles debieron celebrarse por escrito *ad solemnitatem* no pueden acreditarse por prueba de testigos. El artículo 129 establece que sin embargo, respecto de escrituras públicas, los juzgados pueden admitir prueba testimonial cuando adicione o altere el contenido de dicha escritura; esto porque en el mundo mercantil rige el principio de la confianza, que debe presidir las relaciones de los comerciantes.

Una cosa muy distinta ocurre en el mundo civil, donde lo normal es que actos o contratos de cierta trascendencia no se celebren a cada instante, sino que son relativamente escasos, por lo que se exige su escrituración.

c) Disposiciones particulares del Código Civil:

c.1) Artículo 2237: se refiere a lo que se denomina “depósito necesario”; el depósito es un contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa, donde hay 2 partes: un depositante y un depositario, y este último debe recibir del depositante las cosas del depósito, y se obliga a entregarlas en cierto momento. Dentro del depósito existe el depósito necesario, que es el que se produce en ciertas circunstancias de urgencia donde el depositante no es libre de elegir al depositario, por ejemplo en caso de incendio; en este caso es aceptable toda especie de prueba.

c.2) Artículo 2241: es una situación que se produce entre el posadero y el huésped, en donde las especies que introduce quien se aloja en una posada se entienden regidas por las reglas del depósito común, en consecuencia ese depósito se puede probar por prueba testimonial cualquiera que sea la cuantía de las cosas entregadas.

c.3) Artículo 2248: la norma del artículo 2241, es también aplicable a los administradores de fondas, cafés, casas de billar y otros establecimientos semejantes.

4.5 Iniciativa de la prueba testimonial.

Como regla muy general, la iniciativa de la prueba testimonial corresponde exclusivamente a las partes (en materia civil), sin embargo esta regla se encuentra morigerada por 2 disposiciones, que son los arts. 159 Nº 5 CPC (que se refiere a las medidas para mejor resolver) y 207 inc. 2º CPC (que se refiere a las medidas para mejor resolver en segunda instancia).

El artículo 159 Nº 5 dispone que el juez, citada ya las partes o para oír sentencia y dentro del plazo que tiene para dictar la sentencia, puede decretar como medida para mejor resolver la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que expliquen o aclaren sus dichos.

En materia laboral existe también una medida para mejor resolver similar a esta, pero mucho más amplia, porque el juez laboral puede citar a testigos que hayan sido presentados pero que no hayan declarado.

El artículo 207 inc. 2º permite como medida para mejor resolver disponer la recepción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba testimonial rendida en autos, siempre que tales hechos no haya sido posible rendirlos en primera instancia, y se estimen como estrictamente necesarios para la acertada resolución del asunto.

En esta situación excepcional, el tribunal fija los hechos sobre los cuales debe recaer la prueba, y abre un término probatorio especial de prueba hasta por 8 días, debiendo las partes presentar la lista de testigos dentro de segundo día. Esta es una excepción muy calificada y restrictiva, puesto que se refiere a hechos que no hayan sido objeto de prueba.

4.6 Oportunidad de la prueba testimonial.

En este caso nos estamos refiriendo en general a la oportunidad de la prueba testimonial durante el juicio o como medida para mejor resolver, y no a la prueba testimonial que pudiese emanar de una información para perpetua memoria, o sea, estamos hablando de la prueba testimonial en función de la actividad jurisdiccional en un determinado proceso o causa.

La regla general es que la prueba testimonial sólo puede rendirse durante el término probatorio, o dicho de otra manera, el término probatorio es fatal para los efectos de rendir la prueba testimonial; y cuando hablamos de término probatorio, en este caso estamos hablando de término probatorio ordinario, extraordinario o especial. Sin embargo esta regla tiene como calificada excepción el artículo 207 que permite en circunstancias excepcionales rendir prueba testimonial en segunda instancia; y también debemos citar como excepción al artículo 286 que permite como medida prejudicial probatoria producir prueba testimonial en ciertas y determinadas circunstancias.

4.7 Los testigos.

4.7.1 Concepto de testigo

Testigo es un tercero extraño al juicio que depone sobre hechos de la causa; concepto que tiene dos elementos que deben examinarse:

- a) Se trata de un tercero extraño: esto tiene un doble significado: en primer lugar, no puede ser parte del respectivo juicio, y en segundo lugar no debe tener compromiso o interés en la causa, lo que precisamente constituye causal de inhabilidad. El concepto de **interés** ha sido entendido como interés económico – patrimonial.
- b) Depone sobre hechos de la causa: esto tiene importancia porque significa que el deponente debe referirse a elementos o circunstancias de carácter objetivo, y no puede referirse a opiniones o subjetivismos del respectivo deponente; naturalmente, no siempre es sencillo trazar una clara línea divisoria entre ambos conceptos.

4.7.2 Clasificación de los testigos

- a) Según la percepción de los hechos:

- a.1) **PRESENCIALES:** es aquel que declara respecto de hechos que ha captado con sus sentidos, o sea, es testigo presencial tanto el que vio el hecho, como el que lo oyó; es decir, hay un fenómeno de percepción directa del hecho, una relación sensorial directa entre el hecho y el testigo que lo capta.
- a.2) **DE OÍDAS:** es el que sabe del hecho por el relato de terceros, o sea, el no captó el hecho directamente con sus sentidos, sino que sabe del hecho por relato de tercero.
- a.3) **INSTRUMENTAL:** es aquel que concurre al otorgamiento de un cierto acto o contrato, cuando la ley exige o permite esta intervención. Por ejemplo, es testigo instrumental el testigo de un testamento.

b) Según su número y concordancia:

- b.1) **CONTESTES O MÚLTIPLES:** son testigos contestes cuando concurren 2 o más testigos que coinciden en el hechos y en sus circunstancias especiales; la declaración de estos es enteramente congruente, compatible.
- b.2) **SINGULARES:** el testigo singular es siempre uno solo, que declara sobre el hecho y sus circunstancias, pero no hay otro que coincida con él en la descripción que realiza.

La diferencia entre los testigos contestes y el testigo singular, tiene una particular trascendencia respecto de la fuerza probatoria de los testimonios.

c) Hábiles e inhábiles.

- c.1) **HÁBILES:** son hábiles todos aquellos respecto de los cuales no concurre una causal de inhabilidad.
- c.2) **INHÁBILES:** son aquellos respectos de los cuales si concurre una causal de inhabilidad, la que están señaladas taxativamente por el legislador.

4.7.3 Habilidad o inhabilidad de los testigos.

La regla general es la habilidad del testigo, y por tanto se requiere de norma expresa para que el testigo caiga en situación de inhabilidad.

Es importante tener presente que en el C.P.P. hay normas distintas de las del CPC

Genéricamente vistas, las causales de inhabilidad son:

- a) Por falta de capacidad del testigo para percibir el hecho sobre el cual declara;
- b) Por falta de probidad, y esto porque el testigo eso debe ser un hombre probo, que dice la verdad, que en definitiva es un tercero que no tiene interés en el respectivo conflicto;
- c) Por falta de imparcialidad, o sea, porque de alguna manera tenga interés en la respectiva causa, y en consecuencia no sea este tercero extraño que es precisa garantía en cuanto a las afirmaciones que hace en sus declaraciones.

Estas inhabilidades se clasifican a su vez en inhabilidades absolutas (artículo 357 CPC) e inhabilidades relativas (artículo 358 CPC). la **inhabilidad absoluta** es aquella que impide que el testigo sea hábil para cualquier tipo de causa civil; en cambio la **inhabilidad relativa** se refiere sólo a su falta de idoneidad para declarar en una o varias causas determinadas, y dice relación con las partes en conflicto o con el conflicto mismo.

a) Inhabilidades absolutas (artículo 357)

1. “Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse sus declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente.”

No obstante algunas discusiones que se han suscitado en torno al tema, el discernimiento significa una capacidad intelectual determinada que permita al testigo percibir o captar los hechos con la necesaria claridad. Este concepto, en un sentido ligeramente diverso, juega también en materia penal y en materia procesal penal, ya que la responsabilidad penal está graduada en función de la capacidad.

El discernimiento es calificado por el propio juez civil de la causa, a diferencia de lo que ocurre en materia penal donde el juez de menores es el llamado a determinar si el menor tiene el suficiente discernimiento.

2. “Los que se hallen en interdicción por causa de demencia.”

La interdicción deriva de una resolución judicial en virtud de la cual la persona es declarada interdicta, y las causales son dos: la demencia y la prodigalidad (es la situación en la que se encuentra el disipador).

Estas dos primeras causales, miran a la posibilidad de poder captar el respectivo hecho, así tanto el menor de catorce años como el demente no están en la posibilidad de captar el respectivo hecho.

3. “Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa.”

Aquí nuevamente estamos frente a una causal que mira a la capacidad de poder captar el hecho, y se refiere a 2 momentos:

- a) se puede estar incapacitado para captar el hecho al momento que se está verificando,
- b) se puede estar incapacitado al momento de declarar.

4. “Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos.”

La expresión “del sentido” significa que falta la vista, el tacto, el olfato, el oído, el gusto necesario para captar el hecho. Nuevamente estamos frente a la causal de falta de capacidad para captar el hecho.

5. “Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente”

Esta causal mira también a la falta de posibilidad de captar el hecho, y no sólo a la incapacidad de comunicación, ya que el sordomudo puede comunicarse; y esto porque el sordomudo que no puede darse a entender por escrito es considerado por nuestra ley civil como absolutamente incapaz.

6. “Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente.”

Esto mira a la probidad del testigo. No es necesario que este cohecho sea declarado criminalmente, basta que en el procedimiento civil respectivo, al momento de las tachas, se acredite el cohecho respectivo.

7. “Los vagos sin ocupación u oficio conocido.”

Hay un problema de fe y probidad.

8. “Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito.”

Los que han sido condenados por algún delito, en principio no son testigos inhábiles, sino que sólo lo serán cuando en concepto del tribunal, dicha condena los convierta en indignos de fe; o sea, no por la sola condena se produce la inhabilidad, sino que hay una calificación del tribunal.

9. “Los que hagan profesión de testificar en juicio.”

También mira hacia la probidad, y los “jureros” naturalmente que son inhábiles para declarar.

b) Inhabilidades relativas (artículo 358)

1. “El cónyuge y los parientes (legítimos) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos.”

La existencia de un vínculo de parentesco cercano, hace pensar en una falta de imparcialidad, lo que naturalmente inhabilita al testigo para declarar.

2. “Los ascendientes, descendientes y hermanos (ilegítimos), cuando hay reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de la parte que solicite la declaración.”

En este caso se esgrime el mismo argumento que en el numeral anterior.

3. “Los pupilos por sus guardadores y viceversa.”

En este caso estamos frente a la institución de las tutelas y las curatelas, donde el pupilo está sujeto a tutela y/o curatela, y los guardadores son los tutores o curadores en su caso.

4. “Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa.”

Aquí la norma se refiere al criado (el que presta servicios de carácter doméstico) y al dependiente, y el artículo da la idea que este último también realiza ciertos servicios similares al criado doméstico, porque la norma agrega “aunque no viva en su casa” es decir, en este caso se hace alusión a servicios de carácter personalísimos en función de las necesidades de la persona.

5. “Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio.”

En este caso la norma se refiere a las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, y no a las personas que prestan esporádicamente servicios profesionales, ya que estas no son dependientes, sino que hay una relación de paridad absoluta.

6. “Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto.”

El interés directo o indirecto se refiere a un interés de carácter patrimonial o pecuniario. Es importante destacar que aún cuando existe interés, es de calificación del juez, porque si este no acarrea la falta de imparcialidad no obsta a que sea admisible la declaración del testigo.

7. “Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren.”

La amistad o enemistad debe reflejarse en hechos graves, por lo tanto es importante empezar el interrogatorio acreditando los hechos que puedan significar una amistad íntima.

Cuando se trata de inhabilidades relativas ellas son renunciables, y hay naturalmente varias formas de expresar la renuncia: la más simple será no hacer valer la causal, también es forma de renuncia cuando la parte en cuyo beneficio está establecida la causal, incorpora al testigo en su propia lista (inc. final artículo 358 CPC).

4.7.4 Forma de hacer valer la inhabilidad.

El artículo 373 señala como regla muy general, que la inhabilidad debe invocarse antes que el testigo empiece a declarar sobre el fondo. Como normalmente el testigo comparece para declarar, la inhabilidad se hace valer en la misma audiencia en la cual el testigo comparece, previo un posible interrogatorio sobre tachas.

Sin embargo es posible, a título excepcional, que el testigo declare por oficio y en tal evento si hay que tener cuidado, porque la causal de tacha debe alegarse antes que el oficio respectivo sea acompañado o adjuntado a los autos.

El artículo 372 es una excepción, y permite que se examinen como testigos a personas que no figuran en la nómina respectiva, y al efecto quien los presenta fuera y después de la nómina debe jurar que no tuvo conocimiento de ellos al momento de confeccionarla. Es facultativo para el tribunal aceptar o no esta declaración de los testigos fuera de la nómina.

Es admisible respecto de estos testigos fuera de la nómina, que la tacha se formule después de que ellos hayan declarado y esto lo pueden hacer dentro de los tres días siguientes a esa declaración (artículo 373 inc. 1º, en relación con el artículo 372 inc. 2º).

Cuando se formula tacha, de acuerdo a los numerales de los arts. 357 y 358, debe precisamente indicarse cuál es la causal de tacha que se invoca y especificar los hechos constitutivos de dicha causal (inc. 2º artículo 373).

Para fundar la tacha se recurre al propio testimonio del testigo, y en consecuencia cuando comparece el testigo se puede en ese instante empezar a interrogarlo sobre posibles causales de tacha, y el dicho del testigo es antecedente suficiente para que la tacha en definitiva pudiese prosperar.

Artículo 373. *Solamente podrán oponerse tachas a los testigos antes de que presten su declaración. En el caso del inciso final del artículo anterior, podrán también oponerse dentro de los tres días subsiguientes al examen de los testigos.*

Sólo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358, y con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas.

4.7.5 Efectos de la tacha.

La regla general es que tachado que sea el testigo, dicha circunstancia no obsta a su interrogatorio y la tacha es en definitiva resuelta en la sentencia definitiva.

Es cierto que la tacha es un incidente, pero excepcionalmente este incidente es resuelto en la sentencia definitiva, no porque se aparte del conflicto, sino porque la ley expresamente señala que así sea, lo que guarda lógica con el sistema de ponderación de la prueba, porque prospere o no una tacha tendrá importancia substancial en como se pondera la prueba en su conjunto.

Sin embargo, cuando se trata de inhabilidades absolutas y el testigo notoriamente está dentro de ella, el tribunal aún de oficio y con mayor razón a petición de parte, puede repeler la declaración, no admitirla (artículo 375).

La parte que presenta al testigo tiene los siguientes derechos frente a la tacha deducida :

- a) defiende la habilidad del testigo, se opone a la tacha y naturalmente corre los riesgos de la resulta de la respectiva solución;
- b) retira al testigo y reemplaza al que estaba en la nomina.

Es importante, porque la ley limita el número de testigos por cada uno de los hechos de la causa, en consecuencia si se recurre al dicho de un testigo con alta probabilidad de que la tacha a su respecto prospere, se está quemando la posibilidad de presentar al mismo hecho a otro testigo hábil, y en consecuencia la ley da la alternativa de que frente a las tachas se puede perseverar o bien se retira al testigo (artículo 374).

4.7.6 Tramitación, prueba y fallo de la tacha.

Como regla general la tacha no obsta a la declaración del testigo y será en la sentencia definitiva donde se pronunciara el tribunal acogiéndola o desestimándola (artículo 379). El incidente sobre tacha se tramita de la siguiente forma:

1. Comparece el testigo y se le juramenta, se le empieza interrogar por la parte contraria de causales constitutivas de tachas; termina este interrogatorio formulando la tacha respectiva. La parte puede no interrogarlo y formular derechamente la tacha si esta aparece de manifiesto o en otros antecedentes que la acreditan.
2. Frente la tacha deducida, la parte que presenta al testigo puede también contrainterrogarlo sobre lo mismo que declaró respecto de la tacha y terminado, que sea, éste solicitará del tribunal que rechace la tacha deducida. También puede derechamente solicitar el rechazo de la tacha.
3. La tacha se prueba y se contraprueba por los dichos del mismo testigo (arts. 365 y 366).

Artículo 365. *Los testigos serán interrogados personalmente por el juez, y si el tribunal es colegiado, por uno de sus ministros a presencia de las partes y de sus abogados, si concurren al acto.*

Las preguntas versarán sobre los datos necesarios para establecer si existen causas que inhabiliten al testigo para declarar y sobre los puntos de prueba que se hayan fijado. Podrá también el tribunal exigir que los testigos rectifiquen, esclarezcan o precisen las aseveraciones hechas.

Artículo 366. *Cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las interrogaciones que estime conducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a los testigos, y a fin de que éstos rectifiquen, esclarezcan o precisen los hechos sobre los cuales se invoca su testimonio.*

En caso de desacuerdo entre las partes sobre la conducencia de las preguntas resolverá el tribunal y su fallo será apelable sólo en lo devolutivo.

La primera fuente o vertiente para acreditar la inhabilidad del testigo son los dichos del propio testigo que han sido presentados; sin perjuicio de esto, es admisible también toda otra clase de prueba para acreditar la inhabilidad del testigo, y al efecto puede haber término especial de prueba respecto de tachas, si el término probatorio ordinario no es suficiente (arts. 376 a 379).

Cuando el tribunal lo estima necesario, puede recibir a prueba las tachas y si el término probatorio ordinario no es suficiente ampliará el período probatorio hasta diez días, pudiendo incluso ese término probatorio ampliarse a su vez cuando es necesario rendir prueba fuera del lugar del juicio (artículo 376).

Artículo 376. *Cuando el tribunal lo estime necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba, la cual se rendirá dentro del término concedido para la cuestión principal.*

Pero si éste está vencido o lo que de él reste no sea suficiente, se ampliará para el solo efecto de rendir la prueba de tachas hasta completar diez días, pudiendo además solicitarse el aumento extraordinario que concede el artículo 329 en los casos a que él se refiere.

Para acreditar las tachas, son aplicables todos los medios de prueba posibles e imaginables, incluso la prueba testimonial, o sea puede haber testigos para acreditar la tacha de testigos (artículo 377).

Artículo 377. *Son aplicables a la prueba de tachas las disposiciones que reglamentan la prueba de la cuestión principal.*

Sin embargo para que esto no sea inacabable, el legislador establece una limitación: no se puede acreditar con testigos las tachas que pudiesen afectar a los testigos que declararon sobre tachas (artículo 378).

Artículo 378. *No se admitirá prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas deducidas. Lo cual no obsta para que el tribunal acepte otros medios probatorios, sin abrir término especial, y tome en cuenta las incapacidades que contra los mismos testigos aparezcan en el proceso.*

Las resoluciones que ordenan recibir prueba sobre las tachas opuestas son inapelables.

Artículo 379 (368). *Las resoluciones que ordenan recibir prueba sobre las tachas opuestas son inapelables.*

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la legalidad de las tachas y su comprobación serán apreciadas y resueltas en la sentencia definitiva.

4.7.7 Obligaciones del testigo.

Aquí estamos frente al fenómeno de obligaciones procesales, no se trata de cargas procesales. Esto es un requerimiento de conducta no establecido en beneficio del requerido, sino de la parte misma que ha presentado al testigo. Tan claro es que son obligaciones, que pueden ser compulsivamente cumplidas y su insatisfacción acarrea o puede acarrear graves consecuencias al obligado. Las obligaciones de testigo son:

1. CONCURRIR (artículo 359): Toda persona cualquiera sea su estado o profesión, está obligado a declarar y concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto; o sea, declarar como testigo en causa civil no es un acto voluntario, sino que la persona puede ser compelida. Como contrapartida a esta obligación, si se exige la comparecencia de un testigo a sabiendas que es inútil su declaración, puede el tribunal imponer a la parte una multa por esta conducta. Esta obligación de concurrir a la audiencia que el tribunal a fijado tiene excepciones que están señaladas en el artículo 361.

Artículo 359. *Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a declarar y a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto.*

Cuando se exija la comparecencia de un testigo a sabiendas de que es inútil su declaración, podrá imponer el tribunal a la parte que la haya exigido una multa de un décimo a medio sueldo vital.

Artículo 361. *Podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal:*

1° El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, los Subsecretarios; los Intendentes Regionales, los Gobernadores y los Alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes superiores de Servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos Tribunales, los Jueces Letrados; el Fiscal Nacional y los fiscales regionales; los Oficiales Generales en servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales Jefes; el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capitulares; y los Párrocos, dentro del territorio de la Parroquia a su cargo;

2° DEROGADO;

3° Los religiosos, incluso los novicios;

4° Las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave molestia; y

5° Los que por enfermedad u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallen en la imposibilidad de hacerlo.

Para este efecto, dentro del tercer día hábil siguiente a su notificación, las personas mencionadas propondrán al tribunal el lugar y la fecha, comprendida dentro del término probatorio, de realización de la audiencia respectiva. El juez los fijará sin más trámite si el interesado así no lo hiciere ni comunicare su renuncia al derecho que le confiere este artículo.

Con todo, los miembros y fiscales judiciales de las Cortes y los jueces letrados que ejerzan sus funciones en el asiento de éstas, no declararán sin previo permiso de la Corte Suprema, tratándose de algún miembro o fiscal judicial de este tribunal, o de la respectiva Corte de Apelaciones en los demás casos. Este permiso se concederá siempre que no parezca que sólo se trata de establecer, respecto del juez o fiscal judicial presentado como testigo, una causa de recusación.

Con respecto a las personas que gozan de inmunidad diplomática, esto guarda estrecha relación con las Convenciones de Viena.

Dignidades y agentes diplomáticos declaran mediante oficios e informes, expresando en este que declaran bajo la fe del juramento; con todo los agentes diplomáticos juraran y prestaran su declaración si voluntariamente lo quieren hacer, no pueden ser compelidos, salvo que sean diplomáticos chilenos al servicios de gobiernos del extranjero. Respecto de dignidades o autoridades, hay una regla importante en el sentido que los miembros y fiscales de las cortes y los jueces letrados no pueden declarar sin previa autorización de la Corte Suprema; sólo lo harán cuando el tribunal los autorice por estimar que no se esta creando a su respecto una causal de recusación. Las autoridades y dignidades están exentos de la obligación de concurrir, pero no de declarar, y estas declaran mediante el expediente burocrático y hacen bajo la fe del juramento. Por último pueden no concurrir pero en tal evento el examen se realiza por el propio tribunal constituyéndose el tribunal en se respectiva morada (artículo 362)

2. DECLARAR (artículo 359): Esta obligación de declarar tiene importantes excepciones consignadas en los tres primeros numerales del artículo 360.

Estas obligaciones de declarar y comparecer son autónomas y distintas, o sea, hay personas que pueden estar exentas de la obligación de concurrir, pero pueden declarar, y hay personas que deben concurrir y están exentas de la obligación de declarar.

Artículo 360: “No serán obligados a declarar:

1. Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas, sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio;

Aquí está uno de los reflejos que contiene nuestra legislación al amparo del secreto profesional y de la confesión. Pareciera que hubiese una enumeración taxativa, así quien no está expresamente contemplado en esta enumeración, aunque sea profesional no estaría sujeto las obligaciones de guardar

el secreto; esto de alguna manera se encuentra corregido por leyes especiales que han ampliado el ámbito del secreto a otras situaciones. El secreto para excusarse a declarar es siempre una situación excepcional y requiere de norma expresa sobre el particular.

El secreto no es sólo un derecho, es un deber y quien lo quebranta en ciertas y determinadas situaciones está sujeto a sanciones penales, específicamente en el caso de los abogados.

2. Las personas expresadas en los números 1°, 2° y 3° del artículo 358; y

El artículo 358 indica cuales son las personas inhábiles como testigos. El legislador se está poniendo en la situación que la parte contraria presenta como testigo a un pariente cercano, como las causales de inhabilidad se resuelven en la sentencia, estas personas más cercanas tendrían teóricamente la obligación de declarar, pero el legislador comprendiendo el íntimo vínculo lo exime de la obligación de declarar.

3. Los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del testigo o de las personas mencionadas en el número anterior, o que importen un delito de que pueda ser criminalmente responsable el declarante o cualquiera de las personas referidas.”

Guarda íntima relación con la quinta enmienda de la legislación norteamericana que tiene como función evitar la auto incriminación, en el sentido que nadie esta obligado a autoincriminarse; entendiéndose por esto no tan sólo un testimonio que se haga personalmente, sino también a personas íntimamente vinculadas a él. Se recoge este principio aquí en Chile también respecto de causas civiles, en el sentido que el testigo no está obligado a declarar sobre hechos que puedan afectar su honor o el honor de las personas íntimamente ligadas a él, o que importen la comisión de un delito porque puede ser criminalmente responsable el declarante mismo o aquellas personas vinculadas a él.

3. DECIR LA VERDAD: La obligación de decir la verdad no está explícitamente señalada en el CPC, pero se deduce por la sanción al falso testimonio, según el artículo 209 C.P., que lo tipifica y sanciona en materia penal, también aplicable en materia civil, y es más drástico dependiendo si fue a favor o en contra del acusado.

La circunstancia de no coincidir la declaración con la verdad en el relato de los testigos no importa falso testimonio. Para tipificarse, debe haber dolo en el comportamiento del testigo, siendo una situación extrema, de última *ratio*.

4.8 Forma de producir la prueba testimonial

Este procedimiento se establece para el juicio ordinario de mayor cuantía, siendo más simple para los otros procedimientos.

Se debe presentar la lista de testigos y la minuta con los puntos que serán objeto de la prueba, según el artículo 320, desde la primera notificación de la interlocutoria de prueba hasta el quinto día de la última notificación de la misma, cuando no se haya pedido reposición; si se pidió reposición, entonces la lista se presenta dentro de los cinco días siguientes a la notificación por el estado de la resolución que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición.

La **lista de testigos** es una nómina de testigos, cuyas declaraciones se piensa hacer valer (artículo 320). Debe existir individualidad de los sujetos, teniendo presente que a la época de la dictación de la norma no se exigía el número de la cédula de identidad, por no existir esta. Toda la individualización alude a que la parte contraria conozca a los testigos, para poder ejercer el derecho a tacharlos.

Como regla general sólo pueden declarar los testigos inscritos en la nómina; excepcionalmente se pueden aceptar otros testigos bajo juramento de la parte que los presenta de no haber tenido conocimiento de su existencia.

Sólo pueden declarar seis testigos por cada hecho, mas para la conformación de la lista se puede presentar el número que se estime conveniente.

La **minuta de los puntos de prueba** constituye las preguntas que se proponen a los testigos, siendo conveniente redactarlas en forma asertiva. Conviene que en la minuta se agrupen los puntos por hecho, cada hecho se vaya desglosando en distintas preguntas. La minuta es una nómina estándar para todos los testigos.

En la práctica conviene señalar a cada testigo sus preguntas según los hechos, por la limitación del número de testigos.

Si no se presenta la lista, por regla general se renuncia a la prueba testimonial. Sólo podrá haberla si, con posterioridad, la parte declara bajo juramento el haber desconocido la existencia de dichos testigos. También es muy excepcional la norma de la prueba testimonial en segunda instancia (artículo 372 inc. 2°).

Si no se señalan los puntos en la minuta, se renuncia a este derecho y los testigos se entiende que deben declarar sobre los hechos consignados en los autos de prueba.

En la prueba testimonial debe intervenir el tribunal que conoce de la causa, sin perjuicio de las causales de término probatorio especial de prueba por falta del tribunal. Es el receptor quien debe intervenir en la prueba testimonial en materia civil, anotando las pruebas que se van rindiendo, en acta escrita de las declaraciones (artículo 390 C.O.T.).

El tribunal que recibe la prueba, si es unipersonal, es el propio juez, y si es colegiado, uno de sus integrantes. También deben concurrir los respectivos abogados (artículo 365 inc. 1°).

Si debe rendirse prueba testimonial fuera del lugar del tribunal, la prueba se realizará ante tribunal exhortado, sea en Chile o en el extranjero (artículo 371 incs. 1° y 2° y el artículo 73).

4.8.1 Fijación de las audiencias.

Deben fijarse las audiencias para recibir la prueba testimonial, la que se fijará, normalmente, dentro de los dos, tres o cuatro últimos días del término probatorio. El tribunal lo puede fijar de oficio, lo que ocurre muchas veces; pero si no lo fija el tribunal de oficio, la parte, al presentar la minuta debe solicitar una determinada audiencia.

El testigo puede ser citado a comparecer, con objeto de compelerlo. La citación la realiza el receptor, y el testigo es notificado por cédula.

Si el testigo no comparece, por imposibilidad para concurrir, se puede pedir un nuevo término para rendir prueba, según el artículo 380. También existen ciertas y eventuales responsabilidades para el testigo.

4.8.2 Examen del testigo.

Se juramenta al testigo, según el artículo 363, remitiéndose al artículo 62. Si el testigo no quiere jurar, formalmente estaríamos frente a un testigo rebelde. En la práctica, se presentan todos los testigos frente al receptor, se les solicita juramento, todos responden sí, y luego se procede a escuchar a uno de ellos.

Según el artículo 364, se debe interrogar a los testigos separada y sucesivamente, para evitar la comunicación entre ellos. En las primeras audiencias, los testigos del demandante, y durante las siguientes audiencias, los del demandado. El testigo que declara debe retirarse, con autorización del juez, o bien quedarse en la sala de audiencias.

Presentado el testigo, se le interroga sobre posibles causales de inhabilidad; si de estas preguntas, la parte contraria llega a la conclusión de que el testigo es inhábil, se le debe tachar. Planteada la tacha, la parte que presenta al testigo puede interrogar al testigo sobre las tachas formuladas. Si el testigo es tachado, la parte que lo presenta puede:

- a) sustituirlo por otro, o
- b) defender la habilidad de su testigo, incidente que se resuelve en la sentencia definitiva.

La formulación de las tachas no impide que el testigo declare sobre el fondo, salvo que la inhabilidad sea absoluta.

Al testigo se le formulan las preguntas de la minuta, y se le plantea el porqué de su respuesta. Si se omiten las preguntas en la minuta, se le interroga sobre los hechos consignados en el auto de prueba, pudiéndosele realizar repreguntas (son preguntas del abogado que lo presenta, para que esclarezca o amplíe sus dichos).

Terminado el período de repreguntas, puede realizarse el contrainterrogatorio, que versa sobre los puntos dudosos, o para esclarecer la posible falta de veracidad del testigo.

Frente a cada pregunta que se le formule al testigo, pueden oponerse a ellas, planteándose un incidente que el tribunal lo resuelve inmediatamente. La resolución la firma el juez y el ministro de fe autorizante, en este caso el receptor y no el secretario. Si contra esta resolución se deduce apelación, ésta se concede en el solo efecto devolutivo.

De todo esto se debe dejar acta, en los términos más claros posibles, siendo conveniente que la lea el testigo para realizar las rectificaciones en forma inmediata (artículo 366).

Los testigos deben responder en términos claros y precisos, no pudiendo llevar sus respuestas por escrito (artículo 367).

Toda prueba testimonial es un solo acto, que no puede interrumpirse (artículo 368). Debe declararse en una sola audiencia (artículo 369 inc. 2°).

Si el testigo no habla español, se debe recurrir a un intérprete en los términos del artículo 382, en relación con el artículo 63.

De todo debe levantarse acta, según el artículo 370, debiendo ser escriturada. El ministro de fe autorizante en este caso es el receptor; y si no va la firma de éste en el acta, la actuación es nula (artículo 61).

4.9 Valor probatorio de la prueba testimonial (artículo 384)

4.9.1 Testigo de oídas.

- a) Si capta el hecho de un **tercero**: base de presunción judicial;
- b) Si capta lo que dijo una de las **partes**: puede ser eficaz en cuanto explique o esclarezca el hecho; teniendo como limitación el artículo 1709 inc. 2° C.C., en materia obligacional, en el sentido que no es admisible la prueba testimonial cuando el acto debió constar por escrito.

4.9.2 Testigos Presenciales.

a) Contradictorios: es el caso que se presenta cuando existe contradicción entre los testigos de una y otra parte. En este caso juegan cuatro reglas:

- a.1) Si se trata de testigos de distintas condiciones, se prefieren a los de mejor condición, cualquiera que sea el número; los testigos se pesan, no se cuentan (artículo 384 N°3);
- a.2) Si son testigos de iguales condiciones (igual fama, igualmente veraces y respetables), se prefiere el número, y se tendrá por cierto lo que diga el mayor número de testigos; se cuentan (artículo 384 N°4);
- a.3) Si son testigos de igual condición e igual número, racionalmente el juez no se puede inclinar, y así se tiene por no probado el hecho; se eliminan (artículo 384 N°5);
- a.4) Si los testigos de una parte son contradictorios entre sí, se tienen, para los efectos del cómputo, como testigos de la parte contraria (artículo 384 N° 6);

b) No contradictorios. En este caso entran a jugar 2 reglas:

- b.1) Si se trata de un solo testigo, su declaración vale como presunción judicial (artículo 384 N°1);
- b.2) Si los testigos son múltiples, pueden constituir plena prueba siempre que no haya otra plena prueba no testimonial en contrario (artículo 384 N°2).

Artículo 384. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes:

1. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado en conformidad al artículo 426;
2. La de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, podrá constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario;
3. Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos, o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones con otras pruebas del proceso;
4. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número;
5. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no probado el hecho; y

6. Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes.

4.9.3 Menores de 14 años

a) **Con discernimiento:** declaran sin previo juramento, y su declaración sirve de base de una presunción judicial (artículo 357 N° 1);

b) **Sin discernimiento:** su declaración carece de valor.

La resolución que declara a los menores de 14 años con o sin discernimiento se resuelve en la sentencia.

Tema 5: Prueba Confesional.

Es la confesión que hace alguna de las partes de la verdad de un hecho que produce consecuencias jurídicas en su contra.

5.1 Requisitos de la prueba confesional.

- a) La confesión debe hacerla la parte;
- b) Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones de Derecho o simples apreciaciones; y
- c) Que los hechos confesados produzcan efectos jurídicos contra la parte confesante.

5.2 Oportunidades de la prueba confesional.

La confesión es, por regla general, un medio probatorio; sin embargo, también puede ser una medida prejudicial probatoria, en los casos excepcionales en que ello procede, según el artículo 284; o puede ser una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, para llegar a ser título ejecutivo del cual se carece, según el artículo 435; también puede ser una medida para mejor resolver en los términos del artículo 159 N° 2, caso en que los tribunales pueden excepcionalmente ordenar la absolución de posiciones.

5.3 Requisitos de eficacia de la prueba confesional.

a) La prueba confesional debe versar sobre **hechos pertinentes al juicio**, lo que se desprende claramente del artículo 385 CPC; lo que significa que debe tratarse de cuestiones de hecho relacionadas o vinculadas al respectivo juicio.

Los hechos sobre los que puede versar la confesión, pueden ser tanto hechos personales, como hechos no personales. Se entiende por hechos personales, aquellos en los cuales le confesante ha tenido directa participación; y se entiende por hechos no personales, aquellos vinculados al juicio pero en los cuales el confesante no ha tenido directa participación.

Esta distinción entre hechos personales y hechos no personales, tiene una determinada consecuencia jurídica, porque respecto de los hechos personales no se admite prueba en contrario, en cambio cuando la confesión se ha referido a hechos no personales, si se admite prueba en contrario. En ambos casos la

confesión produce plena prueba, pero respecto de una se admite prueba en contrario y respecto de otra no se admite prueba en tal sentido.

b) La confesión debe emanar de quien tenga **capacidad para obligarse**; esto es muy importante, porque la confesión es, en el fondo, un acto de disposición, y en consecuencia quien confiesa debe tener capacidad de ejercicio, y si no tiene esta capacidad, su confesión no producirá efectos jurídicos.

Esta exigencia de capacidad, emana precisamente del carácter dispositivo de la confesión. Esto tiene también mucha importancia cuando la confesión es prestada por mandatario o representante, porque también en este caso si la confesión es provocada, el representante debe estar expresamente premunido de la facultad de absolver posiciones. Si la confesión es espontánea, aunque el mandatario o representante no esté premunido de los poderes suficientes, produce plenos efectos jurídicos. Esto se vincula con lo establecido en el artículo 7 CPC, donde se señala la facultad de absolver posiciones; y aquí no dice el código la “facultad de confesar”, o sea, en este artículo el código se refiere únicamente a la confesión provocada.

c) En principio existen disposiciones o principios que **restan eficacia a la confesión**. Esto es muy importante, porque la confesión es expresión de acto de disposición, y en consecuencia frente a ciertas y determinadas situaciones el legislador ha estimado que los derechos del conflicto no son libremente disponibles, y en este caso, por aplicación de los principios procesales, no es admisible la confesión.

Sin embargo, es importante tener presente que normas expresas en nuestra legislación que prohíben o restan eficacia probatoria a la confesión, y esto ocurre no tan sólo porque los derechos no sean libremente disponibles, sino también ocurre en protección de los intereses de terceros, que podrían verse afectados si a la confesión se le otorga eficacia jurídica.

Estas normas expresas son:

i) **Artículo 1713 C.C.**, en relación con el artículo 1701 inc. 1º: el artículo 1713, no obstante reconocer a la confesión, en principio, el carácter de plena prueba, expresamente exceptúa la situación del artículo 1701 inc. 1º, en el sentido que por la vía de la confesión no se puede acreditar la existencia de un acto o contrato cuya solemnidad era el instrumento público.

ii) **Artículo 157:** en el juicio de separación de bienes por el mal estado de los negocios del marido, la confesión de éste no hace prueba, precisamente en homenaje y resguardo a posibles terceros perjudicados.

La jurisprudencia ha entendido que en este caso la confesión no es prueba suficiente, no es admisible como prueba para acreditar el respectivo hecho, porque hay intereses superiores envueltos en el conflicto, y por tanto no se trata de cuestiones libremente disponibles. En los juicios de nulidad del matrimonio, pasa exactamente lo mismo, los hechos en los cuales se funda la nulidad del matrimonio no pueden ser probados por la confesión del marido o de la mujer.

La jurisprudencia se agarró del artículo 157 para poder llegar a esta conclusión, y así dijo que si la confesión no es suficiente para lograr lo menos, como es la separación de bienes, tampoco puede ser suficiente para lograr lo más, que es la nulidad del matrimonio.

iii) **Artículo 1739 inc. 2º:** se refiere a los regímenes patrimoniales derivados del matrimonio, en cuanto al haber de la sociedad conyugal, el que importa muy fundamentalmente a terceros acreedores, porque para estos hay una completa confusión entre el patrimonio del marido y el patrimonio de la sociedad conyugal, en el sentido que las deudas contraídas por el marido, responde éste no tan sólo con sus bienes propios, sino también con los bienes de la sociedad conyugal.

En un momento determinado podría debatirse o discutirse si un bien es de la sociedad conyugal o es un bien propio de los respectivos cónyuges, discusión que puede tener graves efectos para el acreedor que pretende pagarse su respectiva acreencia; y en consecuencia, también en este caso el legislador ha señalado que en esta discusión la confesión de los cónyuges no produce prueba. En este caso esta norma está establecida en beneficio de terceros de buena fe.

iv) **Artículo 2485 C.C.:** se refiere a la prelación de créditos, en relación con los créditos de una de las clases preferidas. Nuevamente esta norma establece que la confesión del marido, del padre o de la madre de familia, o del tutor o curador, no hará prueba por sí sola contra los acreedores. En este caso estas personas tienen créditos preferentes, pero para acreditar la existencia de estos, no es suficiente la confesión.

v) **Artículo 1133 C.C.:** se ha citado también este artículo dentro de las normas expresas que restan eficacia a la confesión, pero con ciertas reservas. Este artículo dispone que cuando el testador reconoce en su testamento una deuda, este reconocimiento suyo no hace prueba en su contra ni hace prueba a favor del presunto acreedor, sino que se tendrá sólo como una asignación gratuita establecida en su beneficio.

Esto es enteramente lógico, porque si se le diera valor a este reconocimiento, se favorecería a una persona que no pagaría impuesto de herencia, persona a la que se le pagaría como a un acreedor hereditario más. Pero al reconocérsele eficacia sólo como asignación a título gratuito, deberá pagar impuesto y como asignación gratuita estará limitada, de alguna manera, en beneficio de los legitimarios.

d) **La confesión**, como acto jurídico de gran importancia que es, debe estar **exenta de vicios**, o sea, el consentimiento debe claramente expresarse y no ser objeto de fuerza, dolo o error (libre y espontánea). Este principio, es aplicación de las normas generales del derecho civil, pero respecto del error hay una mención expresa en el CPC, que permite revocar la confesión cuando ella es consecuencia de error, y se pretende efectivamente acreditar ese error.

5.4 Clasificaciones de la confesión.

5.4.1 En cuanto al lugar donde se presta:

a) **JUDICIAL:** Es la que se presta en el juicio respectivo, ya sea como medio probatorio propiamente tal, ya sea como medida prejudicial probatoria, ya sea como medida para mejor resolver.

b) **EXTRAJUDICIAL:** Es la que se presta fuera del juicio en el cual se invoca. *En consecuencia, la confesión prestada en otro juicio diverso, es confesión extrajudicial, porque se está prestando fuera del juicio en el cual se invoca; esto es muy importante, ya que esta confesión prestada en juicio diverso puede tener mayor eficacia que otro tipo de confesiones extrajudiciales.

5.4.2 En cuanto a su origen o forma de producirse:

a) ESPONTÁNEA: Es aquella que presta la parte o su mandatario o representante aunque no tenga poder suficiente, en los escritos, presentaciones o comparecencias, en donde lo que dice importa reconocimiento de un hecho que produce consecuencias jurídicas en contra del que hace estas presentaciones; es una confesión, con todo lo que ello significa.

b) PROVOCADA: Es aquella que se produce en virtud del mecanismo denominado **absolución de posiciones**.

La confesión espontánea, sólo está regulada en cuanto a sus efectos por el C.C. y el CPC; en cambio, el CPC se refiere al mecanismo de la confesión provocada o absolución posiciones.

5.4.3 En cuanto a su contenido:

a) PURA Y SIMPLE: cuando derechamente se reconoce el hecho sin agregar ninguna nueva circunstancia o sin agregar un nuevo hecho.

b) CALIFICADA: Es aquella que importa el reconocimiento de un hecho, pero agregando circunstancias que eventualmente lo modifican.

c) COMPLEJA: Es el reconocimiento de un hecho, al cual se agrega(n) otro(s) hecho(s).

Es muy importante hacer la distinción entre la agregación de circunstancias y la agregación de hechos nuevos, porque dice relación fundamental en cuanto al criterio de clasificación (divisible o indivisible).

5.4.4 En cuanto a su divisibilidad:

a) DIVISIBLE

b) INDIVISIBLE

Como regla general, la confesión es indivisible, y en consecuencia debe tomarse como un todo, tanto en lo desfavorable para el confesante como en lo favorable para él. Sin embargo, es eventualmente divisible, y en tal caso es necesario remitirse a la clasificación anterior, que distingue entre confesión pura y simple, confesión calificada y confesión compleja.

Respecto de la confesión pura y simple, no se plantea el tema de la división. Respecto de la confesión calificada, esta nunca es divisible, o sea, cuando se agregan nuevas circunstancias la confesión misma es indivisible. Sólo es eventualmente divisible la confesión compleja, cuando se agregan hechos nuevos y se trata de hechos totalmente desligados con el hecho confesado o bien se trata de hechos que se acredita que son falsos.

5.4.5 En cuanto a su iniciativa:

a) DE PARTE: esta es la regla general.

b) DE OFICIO: como medida para mejor resolver. (Artículo 159 N°2 CPC).

5.4.6 En cuanto a su finalidad:

a) MEDIO DE PRUEBA: Esta es la regla general, ya sea que la confesión sea espontánea o provocada, ya sea como medida prejudicial probatorio o propiamente en el juicio.

b) MEDIDA PREJUDICIAL PROBATORIA: Es el caso del artículo 284, que se refiere a la declaración jurada sobre capacidad o representación.

c) GESTIÓN PREPARATORIA DE LA VÍA EJECUTIVA: La confesión como gestión preparatoria de la vía ejecutiva será regulada conforme a los arts. 434 N°5 y 435 CPC

5.5 Confesión judicial provocada.

La confesión judicial provocada o absolucón de posiciones, está particularmente regulada en el CPC en los arts. 385 a 402.

5.5.1 Órgano competente para recibir la confesión provocada

Cuando la confesión provocada se produce en el lugar donde se lleva el juicio, es órgano competente para recibirla el tribunal que conoce del juicio, o bien un ministro de fe a quien el tribunal le cometa o encargue recibirla. Sin embargo, si la parte exige que sea directamente el tribunal el que la reciba, así debe necesariamente procederse.

Cuando se trata de tribunales colegiados, se aplica la misma regla: puede ser el tribunal o un ministro de fe el que reciba la confesión, con la misma excepción en el sentido que la parte puede exigir que el tribunal sea el que directamente intervenga. Pero además, tratándose de tribunales colegiados, estos pueden acometer la diligencia a uno de sus integrantes.

Si la confesión provocada se presta fuera del lugar del juicio, hay que distinguir si se presta en Chile o en el extranjero:

a) Si se presta en Chile: en este caso es aplicable el artículo 388 inc. 3º, y en tal evento se prestará la confesión o ante el tribunal exhortado o ante el ministro de fe a quien encomiende la diligencia el tribunal exhortado. Rige también en este caso la excepción, en el sentido que si lo exige la parte, será el propio tribunal el que deberá tomarla.

b) Si se presta fuera de la República: en tal evento surge la alternativa que se tome ante el tribunal exhortado, es decir, es perfectamente posible que los tribunales chilenos, por la vía del exhorto internacional, encarguen a un tribunal extranjero la correspondiente diligencia (inc. 3º artículo 388). Pero la norma tiene una calificada modalidad: de acuerdo a lo establecido en el artículo 397 inc. 2º, la absolucón de posiciones también puede realizarse ante el agente diplomático o consular chileno en el respectivo lugar.

5.5.2 Oportunidad en que se puede solicitar.

La absolucón de posiciones se puede solicitar como prejudicial probatoria (cuando haya fundamentos al temor de que la persona se ausente en breve plazo) o como diligencia probatoria propiamente tal.

El artículo 385 establece que en primera instancia se puede pedir a partir de la contestación de la demanda (no antes), y hasta el vencimiento del término probatorio.

Si la demanda se tiene por contestada en rebeldía, se puede también pedir la absolucón de posiciones, porque la rebeldía es contestación negativa tácita.

En relación con la expresión “hasta el vencimiento del término probatorio”, aunque el asunto es opinable y controvertible, podemos decir que cuando la ley habla de término probatorio sin otro calificativo, se refiere al término probatorio ordinario.

En cambio, en segunda instancia existe mayor latitud, y se puede pedir durante toda la segunda instancia hasta la vista de la causa (artículo 385).

5.5.3 Veces que se puede solicitar.

En primera instancia se puede solicitar hasta dos veces y en segunda instancia sólo una vez. Sin embargo, si se alegan hechos nuevos, se puede solicitar una vez más en primera instancia y una vez más en segunda instancia (artículo 385, inc, 2º). Todo esto sin perjuicio que también se pueda exigir como medida para mejor resolver (artículo 159 N°2 CPC).

5.5.4 Iniciativa.

La iniciativa de la confesión provocada por la vía de la absolución de posiciones, puede estar entregada al juez de la causa, a título excepcional como medida para mejor resolver; pero lo normal es que la iniciativa la tenga la parte contraria, o sea, la parte en el respectivo litigio puede exigir de su contenedor la respectiva absolución de posiciones (artículo 385 inc. 1º).

5.5.5 Personas que deben prestar la confesión.

De acuerdo con la mecánica del CPC, debe prestar la confesión el litigante mismo, siempre que sea capaz, aunque tenga mandatario facultado para absolver posiciones.

Se puede exigir la comparecencia de la parte contraria en persona, siempre que sea capaz, aunque tenga mandatario constituido para absolver posiciones. Dicho de otra manera, la circunstancia de tener mandatario constituido para absolver posiciones, no libera a la parte misma de su obligación de comparecer personalmente, cuando así ha sido requerido.

Esta situación naturalmente, es plenamente aplicable cuando el litigante a quien se pide la absolución de posiciones es una persona natural y plenamente capaz; pero si el litigante a quien se le pide la confesión es una persona jurídica, puede comparecer la persona jurídica por el representante que ella elija, y no se puede exigir que sea específicamente una determinada persona la que absuelva posiciones.

Esta es una diferencia substancial con la prueba de testigos, porque en este caso no se puede pedir que cierta persona determinada concurra al tribunal.

Además del litigante mismo, puede ser obligado a absolver posiciones su mandatario, aunque no tenga poder suficiente para absolver posiciones, pero respecto de hechos personales suyos (artículo 396).

Cuando se cita a absolver posiciones, debe notificarse esa citación por cédula, porque se está ordenando la comparecencia personal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 CPC en relación con el artículo 397 inc. 1º.

5.5.6 Personas exentas de la obligación de concurrir.

Esto está señalado en el artículo 389 que enumera a las personas que no tienen obligación de concurrir, cosa totalmente distinta a la no obligación de declarar. Respecto de la obligación de declarar, en general el litigante debe declarar, salvo casos excepcionalísimos donde es posible guardar secreto o reserva.

Sobre el particular, hay tres numerales en el artículo 389: las personas que son o han sido dignidades o autoridades; las personas incapacitadas para concurrir; y las mujeres en caso que el tribunal estime prudente eximir las de esta asistencia.

Estas personas que están exentas de la obligación de concurrir, declaran constituyéndose el tribunal en su respectiva morada, o bien comisionando al efecto a su secretario. A los tribunales colegiados se aplica la misma regla, con la diferencia que puede encargarse la diligencia o a uno de sus ministros o a su secretario (inc. antepenúltimo y penúltimo artículo 389).

En ciertas leyes especiales se han establecido excepciones a la obligación de concurrir, y también excepciones a la obligación de declarar; en algunas leyes orgánicas de servicios públicos, por ejemplo, expresamente se señala que el director general del servicio público respectivo, no está obligado a concurrir, o no está obligado a absolver posiciones.

5.5.7 Tramitación de la absolución de posiciones.

La absolución de posiciones es todo un procedimiento complejo, que tiene naturalmente un determinado desarrollo. La absolución de posiciones se inicia con la petición que **se cite a la parte contraria** o al procurador en su caso, a absolver posiciones; y junto con la petición se acompaña el **pliego de posiciones**, que debe ir en sobre cerrado, solicitándose la custodia del sobre hasta el momento en que se vaya a proceder a la diligencia.

Frente a esta solicitud, el tribunal debe proveer “como se pide, con citación”, ya que todas las diligencias de prueba deben accederse con citación de la parte contraria, o sea, otorgándole un plazo de 3 días fatales para que se oponga a la respectiva diligencia.

La citación, como trámite esencial para la práctica de esta diligencia probatoria, aparece recogida en las disposiciones pertinentes, que se refieren al recurso de casación, específicamente los arts. 795 N°5 y 800 N° 5 CPC

Dentro de éste término de citación, **la parte contraria podrá oponerse a la diligencia**, por ejemplo, diciendo que se han agotado las oportunidades para pedirla o que se está pidiendo extemporáneamente o alegando que la parte, por una disposición legal, está exenta de la obligación de comparecer. El **tribunal resolverá**, ya sea manteniendo la diligencia o denegándola.

Lo normal es cuando el tribunal accede a practicar la diligencia con citación, fija de inmediato la audiencia para realizar la diligencia; y lo normal también es que no la fije un día determinado, sino que la fije dentro de tercero, de quinto, de octavo o de décimo día contados desde se practique la respectiva notificación (la que debe practicarse por cédula).

Fijado el día, la parte puede notificar por cédula al absolvente para que comparezca, o notificar al apoderado de la parte para que éste se obligue a hacer la comparecencia (artículo 397 inc. 1º).

Mientras la confesión no sea prestada, se mantendrán las preguntas en reserva, y para esto el sobre estará en custodia de la secretaría. La absolución, se realizará ante el receptor, que es actuario y encargado de autorizar las resoluciones que se dicten.

El artículo 386 CPC, se refiere a la redacción de las preguntas en el pliego de posiciones, señalando que estas deben ser planteadas en forma clara y precisa; el legislador da además, la posibilidad de plantearlas en forma asertiva o interrogativa:

- **Preguntas asertivas:** llevan en sí una afirmación, y frente a esta, se responde “sí” o “no”, pudiéndose agregar ciertos hechos.
- **Preguntas interrogativas:** envuelven una interrogación, y debe contestarse diciendo “sí, es cierto” o “no es cierto”, agregándose hechos o circunstancias.

La ley no exige que las preguntas sean redactadas todas en forma idéntica, por lo que pueden alternarse.

5.5.8 Posibles conductas del absolvente.

a) Conducta Rebelde: Si el citado no comparece, el receptor debe certificar esta no comparecencia; y se le volverá a citar bajo los apercibimientos correspondientes (artículo 393 CPC).

Si por segunda vez no comparece, o si compareciendo a la primera o a la segunda citación, no responde o da respuestas evasivas, se aplican los artículos 394 inc. 1º y 400 CPC

Y es aquí donde entra a jugar la manera en como se redactó el pliego de posiciones; así, si las preguntas son asertivas, se le dará por confeso, y si son interrogativas, permiten que se le apliquen multas o arrestos hasta por 30 días.

Es necesario tener presente el artículo 400, que se refiere a la **confesión tácita o presunta**, señalando que esta producirá los mismos efectos que la confesión expresa.

Si bien es cierto que las preguntas formuladas asertivamente son más eficaces, la finalidad de las preguntas interrogativas está en que las primeras son de respuestas muy escuetas, a diferencia de estas.

b) Conducta Obediente: Si el citado comparece, se le toma juramento de la misma manera que al resto de los comparecientes (el artículo 390 se remite al artículo 363).

Técnicamente hablando, quien miente bajo juramento deliberadamente, comete delito de perjurio; sin embargo, la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales ha dicho que aún cuando se mienta deliberadamente en una absolución de posiciones, no se comete perjurio.

Juramentado que sea el absolvente, se abre el pliego, y la declaración debe darse inmediatamente, de palabra y en términos claros y precisos. Si el absolvente es sordomudo, podrá escribir su confesión delante del tribunal (artículo 391 inc. 1º).

El inc. 2º del mismo artículo, reconoce la posibilidad de invocar el olvido por parte del confesante; el que puede calificarse como real, verosímil, notoriamente aceptable, o como expresión de evasividad.

El inciso final permite que el absolvente añada nuevos hechos y circunstancias a su confesión; lo que tiene importancia, porque la confesión no es divisible para quien confiesa.

El artículo 394 inc. 3º, permite en determinados momentos, a quien lo solicite, el tiempo razonable para consultar sus documentos antes de responder. En este caso, el tribunal deberá acceder o la parte contraria consentir en ello, si hay fundamento plausible para la petición.

Es necesario levantar acta de todo lo obrado en esta diligencia, la que deberá ser escueta, pero precisa, conservando las palabras del confesante (artículo 395 en relación con el artículo 370).

Quien propone posiciones, tiene derecho a presenciarlas y pedir al tribunal que el absolvente aclare, explique o amplíe sus respuestas, también puede, antes de terminar la diligencia, hacer que ciertas preguntas se repitan si hay puntos oscuros o dudosos; teniendo al efecto 2 momentos para ejercer su derecho: cuando se responde a la pregunta, puede pedir que se aclare la respuesta, o antes del término de la diligencia puede pedir la repetición de preguntas (artículo 392).

5.6 Valor probatorio de la confesión.

Si se trata de **confesión extrajudicial**, es necesario distinguir: si es escrita, puede constituir base de una presunción judicial; si es meramente verbal, sólo es admisible en los mismos casos en que es admisible en la prueba testimonial (tiene el mismo valor probatorio que la prueba de testigos).

En consecuencia, es aplicable el artículo 398 inc. 1º y e. Artículo 383 inc. 2º, en el sentido que la confesión extrajudicial en cuanto diga lo que oyó manifestar a una de las partes, es base de una presunción, en la medida que la prueba testimonial sea admisible. Si la confesión es extrajudicial, pero en presencia de la otra parte o ante el juez incompetente pero con jurisdicción, o en otro juicio distinto, entre terceros, la confesión puede constituir presunción grave (artículo 398).

La confesión extrajudicial que se presente en otro juicio que se lleva entre las mismas partes, puede dársele el mérito de plena prueba (artículo 398).

El valor probatorio de la **confesión judicial**, es idéntico sea esta expresa (explícita) o tácita (bajo el apercibimiento). En este caso es necesario distinguir entre **hechos personales** del confesante (vivencias de la persona misma del confesante; hay una participación directa) y **hechos no personales** (el confesante no ha tenido una participación directa).

El artículo 399 inc. 1º CPC en relación con el artículo 1713 C.C., señala que la confesión judicial sobre hechos personales, sea que se preste directamente por la parte, su apoderado con poder suficiente o representante legal, produce plena prueba y no admite prueba en contrario. Con todo, de acuerdo al artículo 1713 C.C., no produce plena prueba la confesión judicial cuando se trata de probar un acto o contrato que debió contar por instrumento público como solemnidad.

Si los hechos son no personales, producen plena prueba en contra del confesante, ya sea que la confesión la preste la parte misma, o su apoderado con poder suficiente o su representante legal; pero la diferencia está en que respecto de estos hechos se admite prueba en contrario (artículo 402, en una interpretación a *contrario sensu*).

El que se permita o no probar en contra de los hechos personales o los no personales, es distinto de la posibilidad que tiene el confesante de renovar su confesión. La única causal que admite el legislador para que el confesante se retracte de los hechos confesados, es invocar error de hecho, siendo el confesante el que debe probar este error; en este caso, el tribunal puede abrir un término especial de

prueba para acreditar este error de hecho. El error de hecho puede ser de hechos personales como de hechos no personales (artículo 402 inc. final).

5.7 Divisibilidad de la confesión.

En principio, la confesión no es divisible en perjuicio del confesante; la confesión debe ser tomada como un todo. Sin embargo, la confesión es eventualmente divisible, y en virtud de esta eventual divisibilidad, la confesión se clasifica en: pura y simple, calificada y compleja.

La confesión pura y simple, no es divisible. También es indivisible la confesión calificada; la única divisible es la confesión compleja, bajo 2 circunstancias:

- Que los hechos agregados se encuentren desligados de los hechos confesados.
- Que al hecho confesado se le agregue un nuevo hecho y se acredite que ese nuevo hecho es falso.

El artículo 1698 C.C. enumera no taxativamente los medios de prueba, en los que se comprende el **juramento deferido**, institución suprimida por los arts. 4 y 5 de la ley N° 7760 de 1944. Consistía que cuando el litigante no tenía pruebas en su beneficio, podía exigir este medio, para que jurará sobre ciertos hechos, con la consecuencia de que lo que declaraba bajo juramento se tenía por cierto (prueba a favor de la contraparte); pero cayó en desuso, porque fue absorbido por la absolución de posiciones.

Tema 6: Inspección Personal del Tribunal.

6.1 Concepto.

Es el examen que realiza el tribunal por sí mismo de hechos o circunstancias materiales relevantes para la resolución de la litis.

La regla general, es que el propio tribunal de la causa, sea quien realice esta diligencia; si se trata de un tribunal colegiado, puede constituirse el tribunal en pleno, o cometer la actuación a alguno de sus ministros. El tribunal de la causa puede salir de su territorio jurisdiccional para realizar la inspección; también puede cometerla a otro tribunal, por vía del exhorto nacional o internacional.

6.2 Iniciativa de la inspección.

Respecto de la iniciativa de la inspección personal de tribunal, hay que distinguir si la inspección personal es diligencia necesaria, medida para mejor resolver o diligencia probatoria propiamente tal.

a) Inspección personal del tribunal como diligencia necesaria: se encuentra en ciertos juicios, y específicamente en los interdictos posesorios, como en el caso de la denuncia de obra ruinosa, donde este trámite es parte del procedimiento respectivo (arts. 571 a 577).

b) Inspección personal del tribunal como medida para mejor resolver: en este caso, puede ser decretada de oficio por el tribunal (artículo 159 N° 3 CPC).

c) Inspección personal del tribunal como diligencia probatoria propiamente tal: puede ser solicitada por la parte como medida prejudicial probatoria o como medio de prueba (arts. 281, 288 CPC).

Es importante tener presente, que respecto de ese medio de prueba el tribunal siempre realiza la calificación correspondiente, para determinar si la diligencia es útil o no.

6.3 Requisitos de procedencia.

Para que proceda la inspección personal del tribunal, se requiere que:

- se trate de hechos o circunstancias materiales que sean controvertidas, y
- es necesario que el tribunal la estime necesaria.

El legislador fue lógico, y razonablemente señala que la parte que solicita la inspección debe depositar, en manos del secretario del tribunal, la suma necesaria para los gastos, y si se decreta de oficio ambos pagan (artículo 406 CPC).

6.4 Tribunal que practica la diligencia.

- a) Si el objeto de la inspección está dentro del territorio jurisdiccional, la hace el propio tribunal; y si el tribunal es colegiado, hace la inspección todo el tribunal o un ministro de este.
- b) Si está fuera del territorio, puede ir el mismo juez o un juez exhortado (403 inc. 2º CPC).

6.5 Oportunidad para solicitar la diligencia

La oportunidad para solicitar la inspección personal a petición de parte, se da sólo en primera instancia, en cualquier estado de la causa, hasta el vencimiento del término probatorio (ordinario).

6.6 Forma de llevar a cabo la diligencia.

Pedida la diligencia, si el tribunal la estima necesaria, accederá y proveerá “como se pide, con citación”, señalará el día y hora para efectuarla, pudiendo las partes concurrir a la diligencia, por sí o por medio de sus abogados (artículo 403).

El tribunal se constituye en el lugar de la inspección y se levanta acta, expresando los hechos materiales o circunstancias que se observen, los que no pueden interpretarse como opinión anticipada. Las partes pueden pedir que se consignen en el acto hechos o circunstancias que estimen pertinentes y útiles (407 CPC).

Esta diligencia puede combinarse con la de informe de peritos, y realizarse conjuntamente. Los peritos deben concurrir al lugar en el día y hora prefijados (404 CPC).

El tribunal realiza la diligencia con las partes y peritos, o bien por sí mismo, y si es colegiado por alguno de sus ministros.

De esta diligencia que realiza el tribunal (juez o jueces con su secretario), se levanta acta que debe ser firmada por el juez, las partes concurrentes y el secretario, ya que es un requisito de validez la firma del ministro de fe interviniente.

6.7 Valor probatorio.

En este caso, se está en el camino de la certeza física, los hechos son directamente observados por el tribunal, con la particular atención para constatarlos; por ello, se le otorga a esta diligencia el máximo valor probatorio: producen plena prueba los hechos materiales que el tribunal establezca en el acta (408 CPC).

La práctica judicial ha hecho que el tribunal pueda ordenar la inspección respecto de otro expediente que se ve en otro tribunal o ante sí mismo; observa el expediente y deja constancia de esto en autos.

Artículo 408: “La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación”.

Tema 7: Informe de Peritos.

7.1 Concepto.

Peritos, son terceros extraños al juicio e imparciales, que informan al tribunal sobre hechos que para su acertada percepción se requiere del conocimiento de una ciencia o arte.

Los peritos deben ser terceros extraños al juicio, por tanto, no puede ser perito el propio tribunal, como tampoco las partes. Además, este tercero debe ser imparcial, imparcialidad que está resguardada por dos instituciones ya que a los peritos les son aplicables las tachas de los testigos e igualmente les afectan las causales de implicancia y recusación de los jueces.

Para efectos penales, las Cortes de Apelaciones forman listas de peritos, y la designación de los tribunales, debe recaer en una persona que se encuentre en esta nómina. En materia civil se es libre para designar los peritos, sin embargo, frente a la falta de acuerdo de las partes, se suele recurrir a estas nóminas.

7.2 Paralelo entre peritos y testigos.

SEMEJANZAS	DIFERENCIAS
Son terceros respecto del juicio	El testigo tiene la obligación de concurrir y declarar; el perito sólo está obligado a informar si ha aceptado el cargo; en materia civil, el perito es libre de aceptar o rechazar la nominación
Son extraños e imparciales	El testigo no requiere conocimientos especializados de una ciencia o arte, a diferencia del perito El testigo se informa de los hechos antes del juicio, en tanto que el perito se informa ya iniciado el juicio. El testigo jura decir la verdad, el perito jura fidelidad y rapidez. El testigo es una actuación gratuita, sólo se le reembolsan los gastos en que haya incurrido, en tanto que la labor pericial es una actuación profesional remunerada.

Las reglas de designación de peritos se encuentran en los arts. 409 y ss. La importancia de las normas sobre designación de peritos, arranca de que estas normas no tan sólo son aplicables a la designación de peritos, sino que también lo son a la designación de árbitros y a la designación de partidores.

7.3 Procedencia de la prueba pericial.

Respecto de la procedencia de la prueba pericial, debemos señalar que ella puede ser: necesaria u obligatoria (arts. 409 y 410 CPC) o facultativa.

El informe de peritos es necesario u obligatorio cuando la ley expresamente así lo dispone, ya sea que se valga propiamente de la expresión “informe de peritos” o que indique que se requieren opiniones especializadas o periciales.

El artículo 410 es precisamente un ejemplo de mandato legal, donde debe oírse informe de perito. Así, cuando la ley ordena que se resuelva un asunto en juicio práctico o previo informe de perito, se estará cumpliendo este requisito oyendo informe de perito según las reglas establecidas en el párrafo 1, del título XI, del libro segundo.

En la antigua legislación española que rigió en nuestro país, existía lo que se llamaba los “juicios prácticos”, que eran juicios donde se debatían cuestiones de carácter especializado; como una remisión a esta realidad, el artículo 410 habla de los “juicios prácticos”.

El informe de peritos es obligatorio, por mandato legal, en el caso de las querellas posesorias especiales, especialmente la querella de obra nueva y la querella de obra ruinosa. En estos casos, el informe pericial es trámite incorporado en el juicio.

La regla general es que la prueba pericial sea eventual o facultativa, y sobre el particular debemos remitirnos al artículo 411 CPC que señala 2 numerales donde la prueba pericial es eventual facultativa, lo que se desprende claramente del encabezado del artículo.

Artículo 411: “Podrá también oírse el informe de peritos:

1° Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte; y”.

Esta es típicamente la procedencia más clara, pero eventual, de la prueba pericial; o sea, cuando se requiera para la debida apreciación de ciertos hechos, conocimientos especializados de alguna ciencia o arte, es altamente conveniente que sobre el particular se oiga informe de peritos.

2° Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.

Se trata de dilucidar puntos o cuestiones de derecho extranjero, eventualmente aplicables a un conflicto cuyo conocimiento está entregado a un juez local.

Respecto de este numeral, es necesario hacer algunos alcances importantes:

- En este caso, la prueba pericial es eventual y no necesaria, porque de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Privado, recogido específicamente en el Código de Bustamante, si el juez conoce el derecho extranjero derechamente lo aplica, sin necesidad del informe de peritos.

- La procedencia del informe de peritos, en este caso, hay que concordarla con las normas pertinentes del Código de Bustamante, y esto porque el C.D.I.P. contempla otras formas de acreditar la existencia, sentido y alcance de la legislación extranjera, las que no son contrarias al CPC; porque si así fuera, estas últimas se preferirían en virtud de la reserva con la cual se adhirió Chile a este código, dando preeminencia a la legislación chilena presente y futura.

En relación con esta materia debemos tener presente una importante advertencia adicional: el Código de Bustamante es un tratado multilateral, en consecuencia sólo obliga a aquellos países vinculados al tratado por su aprobación y posterior ratificación; por lo tanto, este mecanismo de acreditación de la legislación extranjera, es sólo posible entre los países que se encuentran vinculados a este tratado.

7.4 Iniciativa de la prueba pericial.

La iniciativa de la prueba pericial puede ser de oficio o a petición de parte. La prueba pericial puede ser de **oficio**, ordenada como medida para mejor resolver, de acuerdo al mecanismo indicado en el artículo 159 N° 4 CPC, pero con una importante modalidad que es importante destacar ya que en general la resolución que dicta la medida para mejor resolver es inapelable, sin embargo la medida para mejor resolver que ordena informe de peritos si es apelable.

En la posibilidad de ordenar el informe pericial de oficio, el legislador dio un paso adelante, porque como regla general las medidas probatorias que ordena el tribunal sólo las puede ordenar como medidas para mejor resolver en determinada oportunidad y de acuerdo con un cierto rito; sin embargo el informe pericial también se puede ordenar de oficio por el tribunal en una oportunidad distinta y durante el juicio, como se desprende del artículo 412. Esta norma dice que el reconocimiento de perito podrá decretarse de oficio en cualquier estado del juicio, o sea, no tan sólo se puede decretar de oficio como medida para mejor resolver, sino que se puede decretar en cualquier estado de juicio, y esto porque el mismo artículo señaló una oportunidad extraordinariamente estrecha para pedir como medida probatoria el informe de peritos, y esta oportunidad es durante el término probatorio.

Así, el informe de peritos a **petición de parte** sólo se puede hacer valer durante el término probatorio, no antes ni después; lo que constituye una excepción a las reglas generales, porque de acuerdo a estas, las medidas probatorias se pueden pedir desde el inicio del juicio hasta el término del probatorio.

O sea, frente a la estrechez de la oportunidad para solicitar el informe de peritos por las partes, como remedio el legislador contempla la posibilidad que, en general, durante el juicio se pueda decretar de oficio.

El inc. 2º del artículo 412, señala que decretado el informe de peritos, que en general es una diligencia que demanda bastante tiempo, no se suspenderá por ello el procedimiento.

7.5 Requisitos para desempeñarse como perito.

En general, podemos decir que los requisitos para desempeñarse como perito son imparcialidad y competencia, o sea, ser efectivamente un tercero extraño, en el sentido de no tener vinculaciones con

las partes ni tampoco con el conflicto mismo, y que se acredite la idoneidad necesaria para emitir el dictamen que se le solicita, en cuanto a la competencia.

Los que se van a desempeñar como peritos están sometidos a una doble fiscalización en cuanto a su **imparcialidad**, porque, en primer lugar, a su respecto son aplicables las reglas de inhabilidad de los testigos, o sea, quien es inhábil como testigo, absoluta o relativamente, es también inhábil como perito; y en segundo lugar, porque por expreso mandato del artículo 113 inc. 2º CPC, a los peritos les son precisamente aplicables las causales de impugnación y recusación establecidas para los jueces; y como les son aplicables estas causales, les es también aplicable el procedimiento para hacer efectivas las impugnaciones y recusaciones, por lo que es necesaria consignación previa, antes de plantear la correspondiente inhabilidad.

La **competencia** o **idoneidad**, se prueba con la exhibición del título profesional expedido por las autoridades competentes, que acredite el conocimiento de la ciencia o arte que se trata de invocar. Pero, hay ciertas ciencias o artes que no van vinculadas a un título profesional; en cuyo caso se debe designar a una persona que tenga fama o prestigio en la práctica respectiva, es el caso, por ejemplo, de los peritos calígrafos (artículo 413 Nº 2).

Por otra parte esta misma disposición señala que si en el territorio del tribunal no hay 2 o más personas con el título respectivo, puede desempeñar el cargo otra persona que no tenga dicho título.

7.6 Forma del nombramiento.

En primer lugar encontramos la resolución que ordena proceder a la prueba pericial, resolución que puede ser dictada a petición de parte (que es lo más frecuente) o de oficio. Ordenada la prueba pericial, esta se ordenará con citación, y al mismo tiempo el tribunal fijará una audiencia para que las partes comparezcan; esta audiencia tiene gran importancia, porque tiene por objeto fijar:

- el número de peritos,
- la calidad o aptitud de los peritos,
- los puntos o materias que van hacer objeto de la diligencia, y
- el nombre del respectivo perito.

La resolución que cita a las partes a comparendo para estos efectos, se notifica por cédula (artículo 48 CPC).

Si todas las partes concurren, el tribunal intenta que haya acuerdo respecto de estas 4 cuestiones; si alguna de las partes no concurre o efectivamente no se produce acuerdo, es el tribunal el que resuelve. Dicho de otra manera, el desacuerdo puede ser expreso o tácito, y será expreso cuando efectivamente las partes, todas ellas concurrentes, no llegan o no convienen en todos o algunos de los puntos para los que se las ha citado; y hay desacuerdo tácito cuando alguna parte deja de concurrir; y en caso de desacuerdo (expreso o tácito) es el tribunal el que resuelve (artículo 415).

Hay aquí, sin embargo, una importante limitación, ya que si las partes concurren efectivamente y proponen nombres y no se produce acuerdo respecto de los nombres que proponen, el tribunal no

puede designar a los 2 primeros nombres propuestos por cada una de las partes (si son dos las partes y cada una ha propuesto a dos personas, quedan inhabilitadas cuatro personas).

La diligencia misma de designación es inapelable, porque es una diligencia probatoria, salvo en el caso que se adopte como medida para mejor resolver; sin embargo, son apelables las menciones, calidades o aptitudes que pueda el juez atribuirle al respectivo perito, y las materias sobre las cuales pueda, en definitiva, dictaminar. O sea, sí hay apelación respecto del número de peritos, de las materias o de las aptitudes, apelación que es admisible en el sólo efecto devolutivo, y la apelación deducida no obsta a que el proceso continúe, hasta la designación inclusive (artículo 414 inc. final, en concordancia con el artículo 326 que se refiere a la inapelabilidad de las diligencias probatorias).

El artículo 416 señala que cuando nombramiento se haga por el tribunal, lo hará de entre los peritos que figuren en las listas a que se refiere el artículo 416 bis, y la designación se pondrá en conocimiento de las partes (por el estado diario) para que dentro de tercero día deduzcan oposición. Vencido este plazo sin que se formule oposición, se entenderá aceptado el nombramiento (ver artículo 416 bis que se refiere a la lista de peritos).

Cuando se deduce la oposición, se deben indicar los hechos que constituyen la inhabilidad y específicamente la disposición legal que contempla dicha inhabilidad o los hechos que se están señalando.

Es importante tener presente también, que el asumir la calidad de perito importa una grave responsabilidad, que incluso se puede convertir en responsabilidad penal (artículo 227 Nº 3 C.P., que establece como causal de prevaricación la conducta del perito designado).

El **juramento** es trámite esencial en los peritos y árbitros; y en el caso de los primeros se ha considerado que es equivalente al juramento instalatorio de los jueces, de manera que sólo adquieren su jurisdicción en virtud del juramento.

El juramento, es un juramento de fidelidad, no de verdad como en el caso del testigo, puesto que el perito emite una opinión que puede o no ser aceptada (artículo 417).

En materia civil, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, el perito es libre de aceptar o no el cargo; o sea, la **designación** del perito no es una carga, sino que es una designación que conlleva, en el fondo, un contrato de prestación de servicios, y como tal necesita la aceptación del respectivo perito.

Lo normal es que al perito se le **notifique** por receptor, o lo notifique el propio secretario si el perito concurre al tribunal, y en tal evento el ministro de fe juramenta al perito y deja constancia de su aceptación y juramento en el respectivo expediente.

Es perfectamente posible que el perito se de un tiempo para decidir si acepta o no el cargo, y si lo acepta se deja testimonio de esto en actas.

Tratándose de los árbitros, el árbitro otorga una escritura pública donde deja testimonio de que ha sido requerido como árbitro y que acepta el cargo, y ante el funcionario competente presta el juramento de rigor (artículo 417 inc. 1º).

Aceptado que sea el cargo, debe el perito realizar una diligencia muy importante que se ha denominado el **reconocimiento**, que es el examen que realiza el perito respecto de los objetos materiales que van a ser el objeto del estudio respectivo (artículo 417 inc. 3 y artículo 418).

Hay dos normas que particularmente deben destacarse, las cuales son:

a) Artículo 417 inc. 3º: señala que el perito debe citar a las partes para realizar el reconocimiento respectivo; en consecuencia, el perito deberá comunicarles a las partes cuando, donde y a qué hora va a realizar el reconocimiento.

La norma no señala cómo debe notificarse, y se ha señalado que bastaría una simple comunicación privada, pero también se ha señalado que como se trata de una actuación dentro del proceso, debe hacerse en forma solemne, y al efecto el perito debe hacer una presentación al tribunal señalando el día, hora y lugar en que va a realizar la diligencia y pedir al tribunal que lo notifique a las partes.

Basta notificar por el estado diario la resolución del tribunal que, accediendo a la petición del perito, fija día, hora y lugar del reconocimiento, porque en este caso, la comparecencia de las partes es facultativa, y sólo debe notificarse por cédula cuando se ordena la comparecencia de las partes.

b) Artículo 418: el reconocimiento, como regla general, en caso de haber 2 o más peritos, debe realizarse de consuno por todos ellos, salvo que el tribunal los autorice para actuar por separado.

Artículo 419. En el acto de reconocimiento, si la partes concurren por sí o debidamente representadas, podrán realizar las observaciones que estimen pertinentes respecto del objeto reconocido, y terminado el reconocimiento debe levantarse acta que deje testimonio de haberse realizado esta diligencia, de cuáles son los hechos o circunstancias constatados y de las observaciones que realicen las partes.

Terminado que sea el reconocimiento, viene la **deliberación de los peritos**, en donde naturalmente no participan las partes.

La diligencia pericial, en muchas oportunidades, es una diligencia compleja, y según la naturaleza del objeto y de la materia del peritaje, será más o menos complejo; en consecuencia, significa o puede significar un retardo serio para la causa, y de esta manera el artículo 420 señala la posibilidad que el tribunal fije un plazo para que los peritos evacuen su encargo, y en caso que no cumplan los puede apremiar con multas o prescindir de su informe o decretar un nuevo peritaje, según el caso.

En caso de pluralidad de peritos, se prefiere que se emita su informe en forma conjunta, pero la ley también permite que lo evacuen en forma separada (artículo 423).

La ley civil, no señala cuales son las partes del informe de perito, pero por aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal la práctica ha señalado cuales son estas partes:

- el reconocimiento, o sea, la descripción del objeto materia de la diligencia;
- la descripción de las operaciones o análisis realizadas por el perito; y
- las conclusiones, donde se consigan las opiniones del perito respecto de los puntos específicos que se han sometido a su dictamen.

El valor probatorio de cada una de estas partes del informe pericial es distinto, porque en materia penal tiene valor probatorio mayor el reconocimiento y la descripción de las operaciones, y valor probatorio disminuido lo que son propiamente las conclusiones.

En caso de pluralidad de peritos puede haber, naturalmente, discordia entre ellos, y los arts. 421 y 422 se refieren a esta situación. Cuando se produce discordia (diferencia de opiniones en cuanto a la conclusión) puede el tribunal designar un nuevo perito, el que se une a los anteriores y emite su opinión. Si la discordia se mantiene (en el sentido que el nuevo perito tiene una tercera opinión), el tribunal es libre de apreciar cada una de estas opiniones.

7.7 Gastos, honorarios y sanciones (artículo 411 inc. 2º y 3º)

La regla general, es que los gastos y honorarios de la diligencia pericial sean de cargo de la parte que los ha solicitado; si el tribunal lo ordena de oficio, lo normal es que sea pagado por ambas partes por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

Para hacer frente a los gastos de honorarios, incluyendo en este concepto incluso lo que significa para la otra parte el desplazarse, el tribunal fija un monto a ser consignado en la cuenta corriente del tribunal; muchas veces este monto es insinuado por el perito.

Lo muy importante es que la resolución que fija el monto de la consignación, debe ser notificada por cédula a quien debe realizarla, y si la parte correspondiente no hace la correspondiente consignación dentro de los 10 días siguientes a la notificación, se le tendrá por desistida de la prueba pericial sin más trámite.

El artículo 424 es una regla procedimental, en el sentido que todo lo que diga relación con la designación del perito y el desempeño de sus funciones deberá tramitarse por cuerda separada.

Artículo 411 incs. 2º y 3º: Los gastos y honorarios que en estos casos se originen por la diligencia misma o por la comparecencia de la otra parte al lugar donde debe practicarse, serán de cargo del que la haya solicitado; salvo que el tribunal estime necesaria la medida para el esclarecimiento de la cuestión, y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre pago de costas. El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que previamente se consigne una cantidad prudencial para responder a los gastos y honorarios referidos.

La resolución por la cual se fije el monto de la consignación será notificada por cédula al que solicitó el informe de peritos. Si dicha parte deja transcurrir diez días, contados desde la fecha de la notificación, sin efectuar la consignación, se la tendrá por desistida de la diligencia pericial solicitada, sin más trámite.”

7.8 Valor probatorio.

El artículo 425 señala que los tribunales aprecian la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas generales de la sana crítica. Esta es una norma muy importante y excepcional en materia procesal civil, porque en materia procesal civil rige el principio de la prueba legal morigerada, o sea, se aplican las normas legales pero siempre dándole mayor o menor latitud al juez; pero en este caso concreto el legislador se apartó de este criterio.

Se ha entendido por la jurisprudencia que sana crítica es igual a decir apreciación de la prueba en conciencia, lo que significa el examen razonado de las respectivas probanzas, y las razones por las cuales se inclina por una u otra. En consecuencia, en este caso el juez debe fundamentar su decisión, en el sentido de reconocerle o no valor probatorio.

El artículo 354 se refiere al cotejo de letras, que es una diligencia de carácter pericial; como el legislador ha sido particularmente receloso respecto del cotejo de letras, le resta valor probatorio y no lo trata como informe pericial en general, y así a este no se le puede dar valor de plena prueba sino sólo de base para una presunción judicial.

Tema 8: Prueba de Presunciones.

8.1 Concepto.



Tanto el C.C. como el CPC señalan dentro de los medios de prueba a las presunciones, pero estas tienen ciertas y determinadas características que hacen difícil el aceptar encajarlas propiamente como medio de prueba, porque las presunciones no resultan de la actividad de las partes, o mejor dicho, la actividad de las partes sólo puede contribuir a la construcción de una presunción, toda vez que las presunciones nacen de una construcción que realiza o el propio juez (en cuyo evento estamos frente a una presunción judicial) o una construcción que realiza el legislador (en cuyo evento estamos o frente a una presunción legal o frente a una presunción de derecho).

Frente a esta realidad, se ha dicho que la presunción no es en esencia medio probatorio, sino que es una forma de raciocinio que puede llevar, en definitiva, al tribunal a la respectiva convicción.

Es importante destacar, la estructura lógica de una presunción, y así si se empieza a desagregar el fenómeno de la presunción, se verá que está compuesta por 3 elementos diferentes:

- el hecho indicador o indicio,
- las reglas de la lógica o la experiencia, y

- la conclusión.

El hecho indicador o indicio es aquel que se acredita pero que no es el hecho que se trata de establecer, pero a partir de él se puede afirmar la existencia del hecho que se trata de establecer; o sea, este tiene que llegar al proceso por prueba directa (podrá ser prueba testimonial, prueba documental, confesional, etc.), pero no puede ser nunca acreditado por prueba de presunciones, porque al legislador le repugna la cadena de presunciones, porque el camino a la certeza es más falible donde el raciocinio juega un papel particularmente importante.

Este hecho indicador o indicio, se enfrenta a las reglas de la lógica y de la experiencia, reglas que no están dadas por el legislador, sino que están dadas efectivamente por la lógica, por el correcto raciocinio. El camino, desde el punto de vista intelectual, para llegar a las reglas de la lógica y de la experiencia es el de la inducción, o sea, de un conjunto muy amplio de fenómenos se extraen reglas o leyes que se deben enfrentar a las reglas de la lógica y de la experiencia, y de este enfrentamiento puede resultar que se llegue como conclusión a afirmar un hecho que se quería establecer y que a su vez es distinto de hecho indicador.

Así, en virtud de un ejercicio intelectual del primer orden, se salta con la inteligencia para afirmar este hecho nuevo, y este salto se debe primeramente al indicio y en segundo lugar a las reglas de la lógica y de la experiencia; este camino se recorre por la vía de la deducción. O sea, se está frente a una presunción que tiene 3 elementos perfectamente distintos: el hecho indicador o indicio, las reglas de la lógica y de la experiencia, a las que se llega por la vía de la inducción, y el hecho que se afirma, nuevo y distinto del indicio, al que se llega por la vía de la deducción.

Este camino lógico es igual en el caso de la presunción judicial que en el caso de la presunción legal o de derecho; pero en materia legal el legislador, por asimilación, llama presunciones a fenómenos que no son tales, sino que son ficciones, así por ejemplo encontramos el caso del artículo 8 C.C.

Tratándose de presunciones judiciales, el juez debe explicitarla en su sentencia, en tanto que tratándose de presunciones legales, esta es implícita, y el legislador sólo señala el hecho indicador y la conclusión, pero no el raciocinio.

Ejemplo de Presunción Legal: el hijo concebido dentro del matrimonio, se presume que tiene como padre al marido.

En este caso, los hechos indicadores o indicios son: la existencia del matrimonio y el período de la concepción. Con estos dos elementos, que no son naturalmente quien es el padre, se llega a concluir quien es el padre.

Las reglas de la lógica y de la experiencia que aplica el legislador para llegar a afirmar que el padre es el marido, es el principio de fidelidad del matrimonio.

Ejemplo de Presunción Judicial: se investiga un robo con homicidio; el hecho mismo, el delito, no cae bajo la observación directa, y hay una persona que tiene los objetos robados, el arma con la cual se pudo

efectivamente cometer el homicidio y que sus vestimentas están manchadas con sangre que proviene de la víctima.

En este caso, los hechos indicadores o indicios son: los objetos robados en poder del sospechoso; el arma ocupada en poder del sospechoso y las vestimentas manchadas, usadas por el sospechoso.

Las reglas de la lógica y de la experiencia que aplica el legislador son: que los objetos robados, por lo menos en un inicio, están en manos del autor; que nadie se pone ropa manchada con sangre que sea de un tercero y que lo normal es que quien usó el arma aún la conserve en su poder.

Frente a estos hechos indicadores, se aplican las normas de la lógica, y se concluye que esta persona, a la que no se vio cometer el hecho, es quien efectivamente cometió el robo con homicidio.

La prueba de presunciones es en sí misma, precisamente por su estructura lógica y compleja, una prueba falible, o sea, es muy posible que efectivamente en la prueba de presunciones se cometa un error. Este error puede ser ya en la constatación de el o los hechos indicadores, ya en cuanto a formular las reglas de la lógica y experiencia, o bien, ya en cuanto a deducir el hecho nuevo.

En la estructura de la presunción estamos ya sea en la certeza físico-lógica, si es el juzgador quien directamente ha observado el o los hechos indicadores, o en la certeza físico-histórico-lógica, si los hechos indicadores son consecuencia de testimonios de terceros.

Esta complejidad de la estructura hace que el legislador sea receloso frente a las presunciones, y sea exigente para que efectivamente esta compleja estructura pueda, en definitiva, permitir afirmar un hecho hasta ese instante desconocido.

El **artículo 1712 C.C.**, dice que las presunciones son legales o judiciales; las legales se reglan por el artículo 47, y las que deduce el juez deberán ser:

- a) Graves:** lo que significa que con fuerza, con peso propio, sin forzar los distintos elementos permita efectivamente afirmar el hecho conocido. Si quisiéramos buscar el antónimo de una presunción grave, diríamos una simple sospecha, o como decían los antiguos un barrunto.
- b) Precisas:** en este caso, se está poniendo hincapié en la conclusión, en el sentido que ésta, debe ser única y excluyente de cualquier otra. No es presunción aquella donde el hecho presumido no es único, sino que son varios los posibles hechos presumidos que puedan entrar entre sí en contradicciones.
- c) Concordantes:** aquí hay implícito un doble requerimiento: que las presunciones sean 2 o más, y que todas ellas apunten hacia una misma conclusión. Esto tiene importancia, porque se vincula con el efecto acumulativo de la certeza, que consiste en que si varias pruebas concuerdan, y cada una de ellas, individualmente miradas, sólo importa un juicio de probabilidad, en virtud de su concordancia, este juicio de probabilidad se convierte efectivamente en certeza.

El legislador del Código Civil, establece tres calificativos para que la presunción sea entendida como tal, y son el que sea grave, precisa y concordantes. El legislador del Código de Procedimiento Penal, es aun más exigente y en su artículo 488 señala un conjunto de requerimientos para que efectivamente la presunción legal pueda ser invocada como tal.

Además de esta exigencia tan importante del artículo 1712, hay que observar el artículo 47, que se refiere a la presunción, pero curiosamente no se refiere al concepto de presunción sino a la operación o acto de presumir. El artículo señala: **“se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas”**. Esta breve oración del legislador tiene mucha importancia y cabe destacar:

1. El hecho al cual se llega a afirmar en virtud de la presunción, se denomina **hecho presumido**, o sea, hecho afirmado como consecuencia de una presunción.
2. Este hecho presumido **es consecuencia de una deducción**, y esta arranca del enfrentamiento de los hechos indicadores e indicio con las reglas de la lógica y experiencia.
3. El hecho presumido **se deduce de ciertos antecedentes y circunstancias conocidas**, lo que significa que los antecedentes y circunstancias son consecuencia de prueba directa y no pueden ser resultado de una presunción anterior.

Estas normas tan particularmente exigentes del Código Civil en cuanto a las presunciones judiciales, han sido morigeradas por el Código de Procedimiento Civil, y sobre el particular debemos remitirnos al artículo 426. Este artículo, si bien en su inciso primero hace una alusión sin reservas al artículo 1712, agrega en su inciso segundo que una sola presunción puede constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficiente para formar su convencimiento. De esta manera, la exigencia del Código Civil de que las presunciones fuesen concordantes (y en consecuencia que fuesen dos o más), está modificada por el artículo 426 CPC, ya que permite que una sola presunción, o una presunción única, puedan constituirse en plena prueba cuando ella tiene la gravedad y precisión suficiente.

Esta norma tan permisiva del Código de Procedimiento Civil, no se encuentra en el Código de Procedimiento Penal, donde todavía se sigue exigiendo que las presunciones sean múltiples, es decir, más de dos.

8.2 Clasificación de las presunciones.

a) PRESUNCION LEGAL: Es la que construye el legislador, en el sentido que si ciertos antecedentes se establecen como tales, el legislador señala un hecho presumido distinto; así por ejemplo, si está establecida la fecha de la concepción, y está establecido el hecho del matrimonio, el legislador presume que el padre de la criatura es el marido; a partir del hecho del nacimiento se presume que la concepción antecedió al nacimiento en no menos de 180 días ni más de 300.

Las presunciones legales, se subclasifican en:

a.1) Presunciones simplemente legales: son aquellas en que hay que acreditar por prueba directa el o los hechos indicadores, el hecho presumido se tiene por cierto, pero se admite prueba en contrario; así por ejemplo, la presunción de paternidad permite acreditar que, no obstante estar establecida por el legislador, efectivamente no es el marido el padre de la criatura. En consecuencia, en esta clase de presunciones hay acreditar el o los hechos indicadores, las normas de la lógica y experiencia se encuentran implícitas (el legislador no las enuncia expresamente) y el hecho presumido se tiene por cierto, pero se admite prueba en contrario.

Se ha dicho, en consecuencia, que las presunciones simplemente legales son en el fondo reglas de inversión de la carga o peso de la prueba, porque quien está favorecido por una presunción legal no necesita probar, la presunción legal trabaja en su beneficio, pero la parte desfavorecida por la presunción simplemente legal, puede probar en contrario y en consecuencia puede acreditar que el hecho presumido no es efectivamente cierto. De esta manera, tratándose de presunciones simplemente legales, dos son las formas de atacar su mérito:

- i) controvertir el o los hechos indicadores, o
- ii) controvertir el hecho presumido.

a.2) Presunciones de Derecho: el hecho presumido o conclusión no admite prueba en contrario, se tiene por cierto, por efectivo, por el sólo mérito o fuerza de la respectiva presunción de derecho; por ejemplo, la época de la concepción.

En consecuencia tratándose de presunciones de derecho se puede controvertir el o los hechos indicadores, pero no el hecho presumido o la conclusión, de esta forma la presunción de derecho no es regla de inversión de la carga de la prueba.

En general, las presunciones simplemente legales son más o menos abundantes en nuestro sistema, en cambio las presunciones de derecho son relativamente escasas; además, por mandato de la Constitución Política del Estado, las presunciones de derecho están erradicadas en materia penal.

b) PRESUNCION JUDICIAL: La presunción judicial, es aquella que construye el juez. Estas tienen una serie de limitaciones, explícitas e implícitas:

- i) No se puede afirmar la existencia de un acto o contrato solemne por la vía de las presunciones judiciales, o sea, por vía de la presunción no se puede acreditar que efectivamente se celebró un acto o contrato solemne, cuya solemnidad es el instrumento público; y esto porque el artículo 1701 C.C. dice que para acreditar el acto o contrato solemne, cuya solemnidad es el instrumento público, sólo se puede valer de dicho instrumento público.
- ii) Cuando el hecho indicador está probado por prueba testimonial, se ha dicho, en general, que se puede probar por presunciones la existencia de un acto o contrato que debió constar por escrito *ad probationem*.

El legislador usa dos términos refiriéndose a esta prueba, que envuelven graves equívocos; refiriéndose a otros medios de prueba, habla de que pueden constituir “base de una presunción”, y al referirse a otros

medios de prueba dice que pueden constituir "una presunción". Así por ejemplo, cuando habla del testimonio del menor de 14 años con suficiente discernimiento, dice que puede constituir base de una presunción, y cuando habla de una confesión extrajudicial, en ciertos casos, esta puede constituir una presunción.

Se ha llegado a afirmar, que cuando el legislador habla de "base de una presunción", quiere decir que esa probanza puede tenerse como un hecho indicador, para construir sobre ella una presunción. Y cuando dice que otro medio de prueba constituye "presunción", quiere decir que ese medio de prueba puede tenerse como valor de ese hecho presumido.

Así, se legisla la creación de un valor probatorio de medio prueba que puede asimilarse al hecho indicador o al hecho presumido.

Tema 9: Otros Medios de Prueba.

Nuestro legislador en cuanto a los medios de prueba, sigue la doctrina clásica de enumeración taxativa, pero con un criterio genérico; sin perjuicio de las leyes especiales que admiten otros medios de prueba específicos. Por otra parte, la jurisprudencia acepta otros medios de prueba especiales.

Encontramos entre estos medios de prueba no regulados sistemáticamente:

9.1 Certificado de un ministro de fe que atestigua la veracidad de un hecho por orden del tribunal. (Artículo 427 inc. 1º CPC)

Respecto de este hecho, se presume verdadero, salvo prueba en contrario.

Es importante recalcar que no es la certificación pura y simple, sino que es la de un ministro de fe por orden del tribunal.

9.2 Sentencia civil en un juicio entre las mismas partes (artículo 427 inc. 2º CPC):

Los hechos que establecen en una sentencia civil, se presumen que son verdaderos si se invocan en otro juicio civil, entre las mismas partes. Pero esta fuerza probatoria, emanada de dicha sentencia civil, admite prueba en contrario.

Al aceptar prueba en contrario, el valor probatorio disminuye, y esto se produce porque en materia civil se va tras la verdad formal, y hay un criterio de verdad suficiente y por lo tanto existe una probabilidad de que esos hechos no sean realmente efectivos.

9.3 Valor probatorio de la sentencia penal (arts. 178, 179, 180 CPC):

Existe una diferencia substancial e importante, y es que en la sentencia penal los hechos establecidos en ella tienen un gran valor probatorio en los juicios civiles posteriores, e incluso aunque no sean las mismas partes, esto porque en materia penal se persigue la verdad material, y, por tanto, los hechos corresponden a una exhaustiva investigación.

El artículo 178 establece la regla general, en el sentido que la **sentencia condenatoria** en materia penal, produce plena prueba con respecto a los hechos que establece, esto se justifica porque la sentencia condenatoria requiere certeza y convicción, en tanto que la sentencia absolutoria puede ser consecuencia de dudas del juzgador.

Artículo 178. *En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo.*

Sin embargo, el legislador siendo consecuente, permite que ciertas sentencias **absolutorias o sobreseimientos**, también produzcan efectos en materia civil. Así el artículo 179 da valor probatorio a sentencias absolutorias y sobreseimientos en materia civil.

El sobreseimiento definitivo es una resolución que una vez firme y ejecutoriada, pone término al procedimiento penal en relación con ciertos hechos o sujetos inculcados; y respecto de estos, produce los mismos efectos que la sentencia absolutoria.

El artículo 179 establece ciertos requisitos para que las sentencias absolutorias o las que ordenen el sobreseimiento definitivo, produzcan un efecto reflejo en materia civil:

1. No existencia del delito o cuasidelito en materia del procedimiento, o sea, no existe el tipo penal respectivo. No se comprende en este caso, cuando proviene de circunstancias que eximan de la responsabilidad, sino que se refiere a la inconcurrencia de características de carácter objetivo y subjetivo de la ley penal.
2. No existencia de relación alguna entre el hecho y la persona acusada, ni como autor, cómplice ni encubridor. Esto, sin perjuicio de la responsabilidad civil que emane del hecho.
3. No existencia en autos, de indicio alguno en contra del acusado; en este caso sólo puede hacerse valer el efecto reflejo respecto de personas que hayan sido parte en el proceso penal.

Señala además el inciso final del artículo 179 que quien es administrador de bienes ajenos, como tutor, curador, albacea, etc., tiene un alto grado de responsabilidad, sean bienes públicos o privados; reflejo de esta responsabilidad es que si en relación a estas personas se dicta sentencia absolutoria o sobreseimiento, en ningún caso dicha sentencia produce efecto en materia civil; y siempre existe la posibilidad de accionar civilmente contra ellos.

El artículo 180 es una norma aclaratoria, que precisa que significa el efecto reflejo probatorio en materia civil: en los casos en que la sentencia penal produce efecto reflejo probatorio en materia civil, no es lícito en el juicio civil discutir los hechos sentados en la sentencia penal, ya sea en su parte resolutive o en sus consideraciones.

9.4 Información para perpetua memoria.

Como último caso está el artículo 914, disposición que se refiere a la **información para perpetua memoria**, cuestión regulada en materia de juicios voluntarios o no contenciosos. En ciertos casos es necesario dejar fehaciente testimonio de la existencia de un hecho; cuando un hecho no perjudica a personas

determinadas, los tribunales permiten que se abra un procedimiento para dejar testimonio cabal de ese hecho, se abre probanza y se dicta sentencia para probar este hecho.

Lo que se establece en esta sentencia, tiene posteriormente valor de presunción legal, se tiene por cierto el hecho, salvo prueba en contrario.

Tema 10: Apreciación Comparativa de los Medios de Prueba.



Esta situación se encuentra contemplada en el artículo 428, donde se parte de la hipótesis de que hay probanzas contradictorias; en este caso hay dos situaciones: que en la colisión, la ley resuelva el conflicto; pero, en general, el legislador no resuelve el eventual conflicto, se lo deja entregado al juez, para que lo resuelva conforme lo que el crea más cercano a la verdad (sana crítica).

Aquí hay una labor de ponderación del juez, que se realiza en la parte considerativa de la sentencia.

Unidad 6: Los Incidentes.

Tema 1: Generalidades.

1.1 Concepto.

El concepto de incidente emana del artículo 82 que señala que es *“toda cuestión accesoria a un juicio, que requiere de un pronunciamiento especial con audiencia de las partes”*.

La redacción de este artículo merece una crítica por cuanto no define incidente, sino que se refiere a una regulación procedimental, además, porque dice *con audiencia de las partes*, dando a entender que es elemento necesario la audiencia de las partes, pero hay ciertos y determinados casos en que el tribunal puede resolver los incidentes de plano, sin dar traslado a la contraparte.

En consecuencia, para nosotros incidente ***es toda cuestión accesoria al juicio que requiere pronunciamiento especial por parte del tribunal.***

1.2 Características.

Son características de los incidentes:

a) Accesoriedad. La cuestión que se plantea por la vía del incidente es distinta de la cuestión principal, pero de alguna manera depende de ella.

b) Conexión. Significa que el incidente que se promueve necesariamente debe tener una conexión con la cuestión principal.

c) Pronunciamiento especial: El incidente requiere de un pronunciamiento especial por parte del tribunal, el que normalmente será resuelto por una sentencia interlocutoria de primera clase o un auto, dependiendo si establecen o no derechos permanentes a favor de las partes. Sin embargo, ciertos incidentes sin perder el carácter de tal, son resueltos en la sentencia definitiva, por ejemplo, el pronunciamiento sobre las tachas a los testigos; en esta parte la sentencia no es definitiva, sino que un auto o una interlocutoria según corresponda.

1.3 Clasificaciones de los incidentes.

a) En cuanto a su regulación en el Código de Procedimiento Civil.

a.1) Generales. Son aquellos que no están particularmente regulados por el legislador, y que en consecuencia se sujetan, en cuanto a su tramitación, a las directrices comunes, por ejemplo, la impugnación de un documento.

a.2) Especiales. Son los que el legislador en particular ha normado, fijando su oportunidad, requisitos, etc., por ejemplo, el abandono del procedimiento, el privilegio de pobreza o el desistimiento de la demanda.

b) Atendiendo a si paralizan o no la cuestión principal (artículo 87).

b.1) Incidentes de previo y especial pronunciamiento. Son aquellos que tienen tal importancia y gravitación para la marcha de la cuestión principal, que traen como consecuencia su suspensión hasta que sea resuelto. Congruente con lo anterior estos incidentes se tramitan en el cuaderno principal.

b.2) Incidentes sin tal carácter. Los incidentes que no son de previo y especial pronunciamiento no tienen este efecto paralizante respecto de la cuestión principal, tramitándose en cuaderno separado sin entorpecer la marcha del proceso.

c) En cuanto a su origen.

c.1) Anteriores al inicio del juicio. Son aquellos que tienen lugar antes del inicio del respectivo juicio, el ejemplo característico son las medidas prejudiciales.

c.2) Coetáneos al juicio. Son aquellos que tienen lugar durante la tramitación del juicio y son la regla general.

c.3) Posteriores a la sentencia. Son aquellos que tienen lugar una vez dictada la sentencia definitiva, el caso especialísimo es el cumplimiento incidental del fallo.

1.4 Reglas preclusivas o limitaciones de los incidentes.

El legislador ha mirado con particular recelo a los incidentes porque constituyen una fuente de distracción para la marcha de la cuestión principal, como consecuencia de esta visión ha establecido una serie de reglas preclusivas, en el sentido que si no se cumplen el incidente debe ser rechazado de plano. Estos resguardos son:

a) Hecho anterior o simultáneo al inicio del juicio (artículo 84 incisos 2º y 3º). Si los hechos y circunstancias que pudiesen motivar el incidente, son anteriores al nacimiento del juicio o coetáneos a dicho nacimiento, deben promoverse con anterioridad a otra gestión principal, en caso contrario, deberán rechazarse de oficio por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso o sea una cuestión esencial para la marcha del juicio.

b) Hecho ocurrido durante el juicio (artículo 85). Si el hecho que da lugar al incidente tiene lugar durante el juicio, la parte debe promoverlo tan pronto como el hecho llegue a su conocimiento. Si realiza cualquier actuación que no sea promover el incidente, y posteriormente lo hace, el incidente deberá ser rechazado de plano, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso o sea una cuestión esencial para la marcha del juicio.

c) Artículo 86. Este principio preclusivo tiene aplicación cuando varios incidentes tienen una causa coetánea, en tal evento todos deben promoverse simultáneamente, y si así no se hace, sólo se tramitarán aquellos que hayan sido promovidos y los que no lo hayan sido deberán rechazarse de plano, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso o sea una cuestión esencial para la marcha del juicio.

En este caso, el legislador no exige que se promuevan en un mismo escrito, pero deben promoverse simultáneamente, esto es, en el mismo momento.

d) Artículo 88. Contiene también una expresión del recelo del legislador frente a los incidentes y la necesidad que efectivamente no se produzca retardo en el juicio por promoverlos. Este artículo establece que si una parte ha perdido dos incidentes, en la resolución que rechace el segundo debe fijarse, de oficio por el tribunal, una previa consignación para promover nuevos incidentes, suma que varía de 1 a 10 UTM y que irá a beneficio fiscal, a título de multa, si el nuevo incidente es rechazado. Sin se promueve un nuevo incidente sin consignar el tribunal lo tendrá por no interpuesto, perdiéndose el derecho de provocarlo a posteriori.

Si la parte no está obligada a efectuar el depósito previo en razón de gozar de privilegio de pobreza e interpone nuevos incidentes y éstos son rechazados; el juez, en la misma resolución que rechace el nuevo incidente, podrá imponer personalmente al abogado o al mandatario judicial que lo hubiere promovido, por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de 1 a 10 UTM, si estima que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso.

Además, sin hacerse la distinción entre incidentes de previo y especial pronunciamiento e incidentes que no lo son, los nuevos incidentes deben necesariamente tramitarse en cuaderno separado, para no entorpecer la marcha del juicio.

1.5 Tramitación de los incidentes.

La tramitación de los incidentes se encuentra regulada en los artículos 89, 90 y 91 C.P.C.

La regla general es que promovido que sea un incidente, se de traslado a la otra parte por un plazo de tres días fatales. Sin embargo, el tribunal puede resolverlo de plano, esto es sin necesidad de traslado y sin prueba, si los hechos en que se funda constan en el proceso o son de pública notoriedad, lo que el tribunal debe consignar en su resolución.

El artículo 90 regula la situación de que haya que recibir el incidente a prueba, en tal caso se abre un término probatorio tanto para el incidente mismo, como para la prueba de las tachas a los testigos que hayan declarado en el incidente. Este término probatorio es de ocho días.

Es importante tener presente dos circunstancias en relación con la resolución que recibe el incidente a prueba, de acuerdo a lo previsto por el artículo 323:

a) En los incidentes la resolución señala puntos de prueba, a diferencia de lo que ocurre en el juicio ordinario donde se fijan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. De esta diferencia nace una importante consecuencia, ya que junto con la lista de testigos, que se presenta dentro de segundo día, no es necesario acompañar minuta de puntos de prueba.

b) La resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado diario.

El legislador se pone en la situación que sea necesario un término extraordinario para rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. En este caso el plazo el tribunal, por motivos fundados, puede ampliar el término, por una sola vez, por un número de días que sumados al término probatorio no exceda de treinta días.

Las resoluciones que se refieran a estas materias son inapelables (artículo 90).

Por su parte, el artículo 91 se refiere a la necesidad de pronto fallo del incidente: vencido el término de prueba, fallará el tribunal inmediatamente o no más allá de tercero día.



Tema 2: desistimiento de la demanda.

2.1 Concepto.

Es muy importante detenerse en lo preceptuado en el artículo 148, donde hay una clara distinción entre desistimiento y retiro de la demanda.

El **retiro de la demanda** es un acto material que consiste pura y simplemente en retirar la demanda del tribunal al cual ha llegado, dejando testimonio de ese retiro por razones de orden, aunque la ley no lo exige, en el libro de ingresos. Ese retiro necesariamente debe ocurrir antes que la demanda sea notificada. El retiro de la demanda no produce ningún efecto jurídico, manteniéndose incólumes todos los derechos y expectativas de los respectivos actores.

En cambio, el **desistimiento de la demanda** tiene lugar cuando la demanda ya se encuentra notificada, y es un acto solemne en virtud del cual el demandante declara hacer dejación de la respectiva pretensión.

Este acto de hacer dejación de la respectiva pretensión, debe ser un acto puro y simple, no puede estar sujeto a ninguna modalidad (condición, plazo, modo, etc.), y además, aunque la ley no lo dice, puede ser total o parcial, refiriéndose a todas y cada una de las pretensiones que se han hecho valer, o bien sólo a algunas.

Cuando el desistimiento de la demanda es aceptado con resolución simple, trae una importantísima consecuencia jurídica: que irrevocablemente se entienden extinguidas las respectivas pretensiones, de manera que si el demandante desistido intentara renovarlas en otro procedimiento, debería el demandado oponer una excepción de cosa juzgada para enervar esta pretensión.

El desistimiento seguido de la resolución que lo acepta, es un equivalente jurisdiccional; porque no hay propiamente pronunciamiento jurisdiccional respecto de la pretensión, sino que hay un mecanismo donde una voluntad de no perseverar en una demanda, seguido de la aceptación del respectivo tribunal produce los efectos como si sobre el asunto se hubiese dictado sentencia firme y ejecutoriada.

La resolución que acepta el desistimiento no se pronuncia sobre el fondo, pero tiene la virtud de extinguir irrevocablemente las acciones del actor.

2.2 Oportunidad.

El artículo 148 señala precisamente que el desistimiento de la demanda podrá realizarse en cualquier estado del juicio, o sea, sólo se exige que exista juicio pendiente, y existe juicio pendiente hasta la ejecutoria de la sentencia definitiva.

Es interesante también respecto de la oportunidad recordar la norma que señala que la citación para oír sentencia cierra irrevocablemente el término probatorio, tanto en primera como en segunda instancia, y en consecuencia no son admisibles ni escritos, pruebas, ni presentaciones de ninguna clase, salvo las excepciones legales. Dentro de las excepciones legales contempladas es las disposiciones que se refieren específicamente a la citación para oír sentencia, no se encuentra la posibilidad de desistimiento, sin embargo, como esta norma es de carácter especial y permite realizarlo en cualquier estado del juicio, se ha entendido que el desistimiento de la demanda incluso puede sobrevenir durante el período de citación para oír sentencia. Esto es lógico, ya que inspira siempre en el derecho procesal el principio de la economía, y si de esta manera el juez puede ahorrarse el esfuerzo de dictar sentencia definitiva por la vía del desistimiento reconociendo el efecto dispositivo del instituto, naturalmente que es admisible.

El desistimiento de la demanda se tramita como incidente, o sea, presentado el desistimiento por el demandante se da traslado de esta presentación al demandado, el que puede adoptar dos conductas:

- a) Lo acepta pura y simplemente: en este caso el tribunal necesariamente debe tener al demandante por desistido y dictar la resolución respectiva.
- b) Se opone al desistimiento o lo acepta condicionalmente: en este caso el tribunal deberá pronunciarse aceptando o rechazando el desistimiento, y los efectos sólo se producirán al partir del momento que quede firme y ejecutoriada la resolución que aceptó el desistimiento.

El demandado podrá oponerse al desistimiento, por ejemplo, cuando un juicio ha llegado ya a finísimas expresiones y ha sido visto el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema y esta a punto de dictar sentencia, y ha sido constantemente favorable para el demandado; imaginemos también que el demandado ha sido condenado a pagar las costas, en consecuencia el demandado tiene la expectativa de las costas. Si hay desistimiento de la demanda, las costas no son las costas del juicio sino que sólo las costas del incidente, en consecuencia puede perder esta importante expectativa. Otro ejemplo donde no ha estado inmerso el interés económico, es cuando la voluntad del demandado es que la justicia a través de una sentencia firme que efectivamente reconociera la legitimidad de su posición; por eso el legislador contempla la oposición del desistimiento o de la aceptación condicional (artículo 149).

2.3 Efectos del desistimiento

Sea que la resolución se dicte como consecuencia de haberse aceptado pura y simplemente el desistimiento, o sea que la resolución se dicte rechazando la oposición del demandado, una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acepta el desistimiento, extinguirá las acciones a que se refiere con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio al que se pone término (artículo 150).

Si en el juicio respectivo a sobrevenido reconvencción y el demandante se desiste de la demanda, y por resolución firme y ejecutoriada es aceptado su desistimiento, subsiste la reconvencción y se sigue tramitando el juicio sólo respecto de la acción reconvenzional, porque la reconvencción tiene vida propia, es un juicio que se inserta, para los efectos procedimentales, en un procedimiento ya iniciado, pero que tiene toda las características de una controversia con ribetes absolutamente individuales.

En cuanto al desistimiento de la reconvencción, este se entiende perfecto por el solo hecho de plantearse, o sea, el tribunal en principio no se pronuncia sobre el desistimiento de la reconvencción y frente a un desistimiento de la reconvencción el tribunal pura y simplemente provee “tégase presente”, resolución que debe notificarse por el estado diario; pero notificada que sea esta resolución, el demandante puede oponer oposición al desistimiento de esta reconvencción, oposición que se debe deducir dentro de tercero día y que, en este caso, se tramita incidentalmente, y deberá sobrevenir una resolución que acepta el desistimiento de la reconvencción o que lo rechaza; así, los efectos extintivos derivaran en este caso de la resolución que aceptó el desistimiento de la reconvencción una vez firme y ejecutoriada.

Tema 3: Abandono del Procedimiento.

Hasta 1988 el instituto se denominaba “abandono de la instancia”, y efectivamente era impropia la nomenclatura porque no es que se hubiese abandonado sólo el grado jurisdiccional correspondiente, sino que se tenía por abandonado todo el procedimiento.

Este instituto se asocia estrechamente al principio del impulso procesal, o sea a la carga que tienen todas las partes litigantes de realizar las actuaciones necesarias para que efectivamente el proceso siga su marcha; y hoy día el C.P.C., de alguna manera innovando sobre el particular, mira con malos ojos los acuerdos preclusivos de las partes y los limita en el tiempo y en las oportunidades; por esta razón, también ha ido perfeccionando el instituto del abandono del procedimiento y ha ido acortando substancialmente los plazos.

Así el plazo de abandono del procedimiento en un principio del C.P.C. era de 3 años, posteriormente se acorto el plazo a un año y ahora el legislador acorto el plazo a seis meses.

El abandono del procedimiento tiene mucho que ver con la prescripción, ya que ambos institutos comparten dos elementos: la inactividad y el transcurso del tiempo.

Esta similitud o paralelo entre abandono del procedimiento y prescripción, a hecho que se entienda que las normas para contar los plazos de prescripción contenidos en la ley de efecto retroactivo de la leyes son aplicables también para contar los plazos del abandono del procedimiento. Esto es muy útil e importante, porque los plazos para abandono del procedimiento se han acortado y en consecuencia quien alegue abandono, que debe ser siempre el demandado, debe elegir entre el plazo más largo y otro más corto, y si se elige el plazo más corto, este plazo se cuenta sólo desde la vigencia de la nueva ley que fijo el plazo más corto (artículo 25, L.E.R.L)

3.1 Oportunidad

Se entiende abandonado un procedimiento, cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en se prosecución durante 6 meses. Para que se produzca el fenómeno del abandono, este abandono debe referirse a todas las partes, la inactividad debe ser de todos los que están comprendidos en la respectiva relaciona procesal, sean partes principales propiamente tales o terceros.

La fecha de inicio del plazo de los seis meses se cuenta de la fecha de la resolución última recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Se cuenta desde la fecha de la resolución, no desde su notificación, y aunque la resolución no haya sido notificada para estos efectos y sólo para estos, tiene eficacia; siendo esta una calificada excepción a la regla general. Sin embargo hay un elemento calificadorio muy particular, esta resolución debe recaer en una gestión útil para dar curso progresivo a los autos; o sea, 2 son los requisitos de la gestión que se provee: que la gestión sea útil, es decir, efectivamente funcional; y además que sea útil para dar curso progresivo a los autos.

Esta gestión útil puede venir de una de las partes, lo que será lo normal, pero también podría ser que la gestión útil proviniera del respectivo tribunal, y en ese evento también la resolución que se dicta tiene este efecto interruptivo; o sea, toda gestión que se dicte, aún cuando no se encuentra notificada, y que se dicte frente a una solicitud de gestión útil, tiene el efecto de ir interrumpiendo este eventual plazo de prescripción.

Este plazo es de 6 meses y no de 180 días, en consecuencia, es un plazo que no se interrumpe durante los días feriados, ni tampoco se interrumpe durante el feriado de vacaciones judicial. Corre en feriados y festivos legales y judiciales.

El abandono **sólo lo puede pedir el demandado**; el hecho que sea sólo el demandado el que lo puede hacer valer durante todo el juicio hasta que se dicte sentencia firme o ejecutoriada, esta consagrado en el inciso 1º artículo 153.

Hay una situación excepcionalísima en el juicio ejecutivo, en el inciso 2º artículo 153, inciso que es introducido por una modificación de hace nueve años. Este abandono especial del procedimiento

aplicable al juicio ejecutivo, es sin perjuicio que también en el juicio ejecutivo se aplique el abandono general, o sea, en el juicio ejecutivo puede haber abandono general o puede haber la aplicación del instituto del abandono particular. Esto fue necesario introducirlo, porque nace de la necesidad de no dejar al deudor respecto del cual se ha iniciado una ejecución, eternamente vinculado, porque en el juicio ejecutivo (antes de este instituto) si se rechazaban las excepciones del deudor o este no oponía excepciones, se entendía que se había interrumpido la prescripción por la demanda, y en consecuencia el acreedor en cualquier momento, cualquiera que fueran los años que hubieran pasado, podía caer encima de su deudor y hacer efectiva la deuda en los nuevos bienes que hubiese adquirido; existía una situación de perpetua servidumbre.

El legislador estableció, para sanar esta situación, que si el ejecutado fue condenado o no opuso excepciones, el ejecutante puede seguir persiguiendo sus bienes, pero si cesa en esta persecución de sus bienes por más de 3 años, se entiende abandonado el procedimiento; y como ocurre esto, por un efecto reflejo, puede haber prescrito la obligación y por esta vía liberar al deudor.

Es necesario tener presente la diferencia que existe entre el abandono general y el abandono particular, en cuanto a que este último puede ser otorgado después de la dictación de la sentencia definitiva.

Será oportuno para hacer efectivo el abandono, hasta que ya se haya dictado sentencia firme o ejecutoriada, o sea incluso si hay sentencia de segunda instancia y el asunto está radicado ante la Corte Suprema, si se produce ante este tribunal la inactividad, puede normalmente declararse también el abandono.

El abandono del procedimiento es consecuencia del incumplimiento de la carga del impulso procesal; en consecuencia si las partes respectivas no están cargadas y éste se ha desplazado al tribunal, aún cuando ocurra la inactividad por el transcurso del plazo, no es posible pedir el abandono. Así, cada vez que hay liberación de la carga del impulso deja de transcurrir el plazo respectivo.

3.2 Forma de alegarlo.

Podrá alegarse el abandono por vía de acción o de excepción, y se tramitará como incidente. Aquí encontramos dos posibles situaciones:

- a) Llega el día en que se cumplió el sexto mes, el demandado llega al día siguiente y pide que se declare el abandono del procedimiento; esta pretensión suya se está haciendo valer por vía de acción, o sea, él es el que toma la iniciativa de pedir el abandono del procedimiento.
- b) Llega el sexto mes y al día siguiente el demandante presenta un escrito y pide 15 diligencias, esta actividad posterior del demandante no le impide al demandado pedir el abandono, porque puede oponer una excepción; esto se produce cuando cumplida las condiciones del abandono el demandante intenta renovar la actividad, entonces en cualquier momento posterior puede el demandado pedir el abandono.

Renovando un procedimiento que ya se había abandonado, el demandado puede instar a la declaración de su abandono. Sin embargo hay un elemento de carácter preclusivo que está contenido en el artículo 155: si el demandante renovó el procedimiento después del sexto mes y el demandado compareció realizando cualquier gestión no encaminada a pedir el abandono del procedimiento, esta gestión hace precluir su posibilidad de solicitarlo.

3.3 Efectos.

Esta materia es muy importante, porque el abandono del procedimiento tiene efectos directos procesales y efectos reflejos substanciales. El C.P.C. sólo se refiere a los efectos directos procesales pero vinculándolos al C.C., podemos entender los efectos reflejos o substanciales.

El **efecto procesal directo** está contemplado en el artículo 156. En primer lugar, este artículo 156 señala que el abandono del procedimiento no extingue las acciones y excepciones de las partes, o sea, la regla general es que abandonado que sea un procedimiento pueden renovarse las mismas acciones y excepciones en otro procedimiento, porque el abandono no extingue las acciones y excepciones de las partes, pero lo que si se extingue es todo lo actuado en el respectivo procedimiento y se extingue el derecho de continuarlo. (Inciso 1º artículo 156).

Sin embargo, aún cuando lo actuado en el juicio deja de tener eficacia, hay una calificada excepción en el inciso 2º artículo 156, que señala que subsistirán sin embargo con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos. Esto significa que durante el procedimiento pueden haberse realizado actos y contratos de carácter procesal, pero también con efectos substanciales, y estos actos y contratos que tengan efectos substanciales conservaran su valor no obstante el abandono del procedimiento; así por ejemplo, el avenimiento parcial al que se ha llegado, conservará su total valor no obstante el abandono del procedimiento.

El abandono del procedimiento no trae como consecuencia retrotraer todo lo realizado en el procedimiento abandonado, sino que solo que este procedimiento abandonado ha perdido eficacia.

El **efecto reflejo** tiene enorme importancia, y en virtud del artículo 155 no se extinguen las acciones y excepciones, sin embargo, refleja y substancialmente pueden extinguirse por la vía de la prescripción, y esto por aplicación de los artículos 2518 en relación con el artículo 2503 Nº 2 C.C. Este artículo dice que si produjo la notificación legal de la demanda y en consecuencia se produjo la interrupción civil, se entenderá que nunca se produjo dicha interrupción si se declara el abandono del procedimiento; el principio general es que la prescripción se interrumpe civilmente por la notificación de la demanda, pero si en ese procedimiento donde se notificó legalmente la demanda se declara el abandono de dicho procedimiento, se declara que nunca se produjo la interrupción y en consecuencia el plazo siguió transcurriendo desde su mismo inicio.

El artículo 157 señala excepciones en relación con ciertos y determinados procedimientos donde no se puede declarar el abandono; por ejemplo en el juicio de quiebra (aquellos regulados por la ley de quiebras, que pueden ser tanto de quiebras propiamente tales o de convenios), los de división o liquidación de herencia, etc. Esto por una razón de carácter práctica, ya que estos procedimientos son de muy largo desarrollo, ya que las partes buscan momentos más favorables para ellas.

Tema 4: Incidente de Costas (artículos 138 a 147)

Las costas, son una carga pecuniaria que deben soportar las partes, y la regla general es que durante el curso del respectivo juicio, las costas sean soportadas por la respectiva parte que incurrió en ella. Hay también ciertas costas que son comunes, como los honorarios de un perito designado como medida para mejor resolver, y en tal evento las partes durante el juicio pagaran a este perito por mitades.

Sin embargo, no obstante que estos desembolsos iniciales gravan a la parte que incurrió en ellos, el legislador contempla un mecanismo para resarcirse de todos esos desembolsos, y que en el fondo significan que la parte que incurrió en el desembolso puede ser restituida o reembolsada por la parte contraria si efectivamente ha sido condenada en costas; o sea, la obligación de reembolsar costas no deriva necesariamente de todo el juicio, sino que deriva de la condena que se imponga al responsable.

Hay una cuestión que tienen una importancia de carácter substancial, porque la condenación en costas guarda relación con la prestación de servicios profesionales y guarda relación con otro instituto de carácter substancial que se denomina la *litis expensas*.

El tema de las costas, cuando a mediado condenación en costas, vincula a las partes litigantes entre si, en el sentido que una debe reembolsarle a la otra las costas en que incurrió, pero no vincula ni a los representantes de las partes con la parte contraria, ni regula las relaciones de la respectiva parte con sus abogados y mandatarios. Esto significa que el abogado o mandatario de una parte a cuya favor se declaró el derecho a ser reembolsado, no tiene acción directa en contra de la parte contraria; y por otra parte, que los compromisos que haya contraído la parte con sus respectivos abogados o mandatarios no son incluidos ni determinados por las costas que se exigen en el respectivo juicio.

Si un abogado o apoderado de la parte recibe costas, se entiende que las recibe para su mandante, que es el beneficiario de dicha condenación (artículo 139 inciso final).

La condenación en costas puede producirse respecto del juicio todo, puede producirse también, en ciertos y determinados recursos procesales, en contra de quien lo ha interpuesto y no ha obtenido en ellos; incluso, tratándose de ciertos recursos procesales la condenación en costas es necesaria para el pernicioso, como ocurre en el caso del recurso de casación.

Las costas pueden ser impuestas para el incidentista, cuando no obtiene el incidente que promueve, y precisamente hay una disposición en este sentido.

Es importante también destacar que respecto de las costas hay una disposición trascendente, que es la que distingue entre costas procesales y costas personales (artículo 139 C.P.C.):

a) Costas Procesales: son las causadas por los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, que prestan los servicios correspondientes. Estas costas se determinan de acuerdo a los aranceles judiciales que fija al efecto el poder judicial. También constituyen costas procesales todo otro tipo de desembolso que pudiera haber ocurrido, como por ejemplo el pago por la confección de exhortos, copias, etc.

b) Costas Personales: son aquellas que se causan por los servicios de carácter personal que se prestan a las partes; y estos son los que prestan los abogados o procuradores. Pero también se entienden comprendidos otros honorarios, como los de los peritos que haya pagado la parte respectiva.

Esta distinción entre costas procesales y costas personales, tiene importancia por el hecho que el monto de ellas se fija por diferentes métodos; así, tratándose de costas procesales son determinadas por el secretario del respectivo tribunal, en tanto que tratándose de costas personales, estas son determinadas por el propio tribunal, o sea, es el juez de la causa el que las fija (artículo 140 inciso 2º).

En relación con este mismo temas, debemos señalar que los defensores públicos, en ciertos y determinados casos, pueden asumir la representación de las personas a quien la ley les encomienda velar por sus intereses, y en tal evento ellos merecen honorarios por su actuación; y en caso que hayan honorarios, también se consideran estos como costas personales (artículo 139 C.P.C. en relación con el artículo 367 C.O.T.).

El artículo 138 señala que la condenación en costas conlleva, a petición de parte, a la respectiva tasación de costas. Por su parte, el artículo 140 dispone que sólo se consideran las costas útiles. Practicada la tasación de las costas procesales y personales, hay un término de citación de 3 días, para que las partes litigantes puedan impugnar la tasación (artículo 141).

Producida la objeción, el tribunal o resuelve de plano o le da tramitación incidental, y será, en consecuencia, una sentencia interlocutoria la que se pronuncie sobre la impugnación correspondiente (artículo 142).

La tasación de costas, es una resolución que vincula a las partes litigantes entre sí, pero no vincula a las personas que hayan prestados sus servicios a las partes litigantes, como sus respectivos abogados y procuradores, los que tienen como fuente de remuneración el contrato respectivo o, a falta de este, una sentencia judicial que fije los honorarios en un procedimiento especial (juicio de fijación de honorarios).

La regla general es que quien ha sido vencido en un juicio o en un incidente, debe ser condenado al pago de las costas. Sin embargo, no obstante haber sido totalmente vencido en el juicio, la parte puede ser eximida del pago de las costas cuando se estime que ha tenido motivo plausible para litigar, o sea, que no ha sido un litigante temerario, sino que ha habido un principio, a primera vista, que justifica el haber pedido la intervención de la justicia (artículo 144).

Esto también es aplicable, como principio general, a los incidentes, de manera que si se promueve un incidente, también el tribunal puede eximir del pago de las costas si ha sido plausible la promoción de dicho incidente.

Con todo, esta disposición hay que relacionarla con el artículo 147, el que señala que si el incidente es de carácter dilatorio, calificación que el tribunal hará, precisa y necesariamente debe sobrevenir condenación en costas para el articulista.

El **artículo 145** es una disposición que se refiere a todas las costas (procesales y personales) del recurso de apelación, permitiendo que el tribunal exima de su pago.

El **artículo 146** se refiere claramente al pago de costas en los recursos procesales, y señala que si quien ha conocido del recurso procesal es un tribunal colegiado, y ha habido algún voto disidente en beneficio del recurrente, éste no podrá ser condenado en costas. Y esto es lógico, porque significa que el recurrente tenía motivo plausible para recurrir, y en consecuencia no merece sanción.

Sin embargo esta norma tiene calificadas excepciones, como es el caso del recurso de casación, donde cuando son estos rechazados, debe necesariamente sobrevenir condenación en costas, no obstante la existencia de voto disidente; y también tratándose del recurso de protección se puede imponer condenación en costas no obstante la existencia de voto disidente.

La disposición del artículo 28 antes de su modificación en 1985 y 1993, establecía una responsabilidad solidaria entre las partes y su procurador, respecto del pago de las costas; esta solidaridad, de alguna manera, era incompatible con el principio del derecho a la asistencia jurídica, por eso se modificó la norma, señalando el nuevo artículo 28 que se responde solidariamente sólo de las costas procesales.

En otros ordenamientos jurídicos, se permite que el juez de la causa, frente a ciertas y determinadas acciones, pueda de oficio o a petición de parte, exigir un depósito o caución previa. En nuestro ordenamiento, esta norma no existe, y quizás sería interesante de establecer, precisamente para evitar aventuras procesales y acciones temerarias, que se sabe no tendrán ningún resultado.

Tema 5: Litis Expensas.

El artículo 136 C.C., regula las ***litis expensas***, dentro del título que regula las obligaciones recíprocas de los cónyuges, quienes se deben auxilio entre sí, para ejercer debidamente sus respectivos juicios.

Esta norma contiene el principio que, cuando el matrimonio se rige por las normas de la sociedad conyugal, el marido debe auxiliar a la mujer para la litis, en cualquier juicio del marido en contra de la mujer o de la mujer en contra del marido.

Es la jurisprudencia la que ha sido más clara en este aspecto, y no así la ley.

Las *litis expensas* son una previsión o perspectiva de lo que podrían ser las costas de la causa, de suerte que el tribunal que fija las *litis expensas*, sigue los mismos que los que se observan cuando se trata de tasar costas.

Puede ocurrir, naturalmente, que las costas sean superiores o inferiores a la *litis expensas*, pero de todas maneras estas costas deben guardar relación general con lo que pueden ser las costas definitivas.

Tema 6: Acumulación de Autos (artículos 92 y ss.)

La institución de la acumulación de autos, es clara manifestación del principio de la economía procesal; y tiene por objeto que dos o más causas que inicialmente se tramitan en forma separada, lleguen a constituir una unidad y sean resueltas por una sola sentencia.

La acumulación de autos, es una institución que tiene diversas manifestaciones o expresiones, y en ciertos y determinados casos, la acumulación de autos debe necesariamente decretarse, en tanto que en otros casos la acumulación de autos es facultativa, y en general sólo puede ser ordenada a petición de parte.

En materia civil, específicamente en materia mercantil, tiene importancia la institución respecto de las quiebras, ya que declarada una quiebra e iniciado el juicio de quiebras, a este proceso, en general, se acumulan todos los juicios en que es parte el fallido y que dicen relación con sus bienes. Esta es una situación regulada por la Ley de Quiebras (artículo 93).

El artículo 92 sienta la norma de carácter general en cuanto a la regulación de la acumulación de autos, en el sentido que procede la acumulación en todos los casos en que varios procesos que se tramitan por separado, deben constituir uno solo y terminar por una sola sentencia. Sin embargo esta norma de carácter general se ha concretado o especificado en 3 situaciones señaladas en los numerales del artículo 92; pero es necesario tener presente que el Nº 3 vuelve a remitirse a la regla general, de manera que en el fondo las situaciones específicas de acumulación de autos que contempla el C.P.C., están en los Nº 1 y 2 del artículo 92.

Artículo 92 Nº 1 primera parte: Cuando la acción o acciones entabladas en un juicio sean iguales a las que se hayan deducido en otro...

Los elementos que determinan la naturaleza o esencia de la acción, son: persona del accionante, el objeto pedido y la causa de pedir. Para los efectos de la aplicación de esta norma, y por comparación entre el Nº 1 y el Nº 2, deben observarse sólo 2 de estos elementos: la cosa pedida y la causa de pedir, no la persona del accionante; así, basta que exista identidad entre la cosa pedida y la causa de pedir en un juicio con la cosa pedida y la causa de pedir en otro juicio, para que proceda la acumulación. O sea,

identidad en la cosa pedida e identidad en la causa de pedir determinan, cumpliéndose los demás requisitos legales, acumulación aunque las partes sean distintas.

La **cosa pedida**, es el beneficio jurídico que se reclama, y la **causa de pedir**, es el antecedente jurídico que sirve de sustento a la respectiva pretensión.

En este caso no se requiere la concurrencia de los 3 elementos, porque cuando hay identidad en los 3 y ambos juicios se están tramitando, surge la institución de la *litis pendencia*; en consecuencia, si esta institución es propia y autónoma, es diferente de la *litis pendencia*, por tanto sólo requiere de la concurrencia de dichos 2 elementos.

Es necesario tener presente que lo importante no es el nombre genérico de la acción, sino que la acción específica de que se trate; así estas acciones específicamente (no en forma genérica) deben ser idénticas.

Artículo 92 Nº 1 segunda parte "...o cuando unas y otras emanen directa e inmediatamente de unos mismos hechos;"

Procede también la acumulación de autos cuando los juicios separados proviene directa e inmediatamente de unos mismos hechos. En este caso la cosa pedida y la causa de pedir pueden ser distintas, pero procede la acumulación porque todos los juicios proviene directa e inmediatamente de los mismos hechos.

La ley exige que la relación causal sea directa e inmediata, es decir, debe haber una relación causal estrechísima entre los hechos y los juicios de que se trata, aunque sean diferentes acciones.

Artículo 92 Nº 2: "Cuando las personas y el objeto o materia de los juicios sean idénticos, aunque las acciones sean distintas; y"

Aquí nuevamente hay una coincidencia de dos elementos: persona y cosa pedida. Encontramos como ejemplo de este caso cuando se pide la restitución de un inmueble en calidad de usufructuario, y se pide restitución del mismo en calidad de arrendatario.

Este caso es de rara ocurrencia, porque ambas acciones son incompatibles, y la lógica es que se intentará en una sola demandada en forma subsidiaria.

Artículo 92 Nº 3: "En general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en otro."

Este numeral hace una remisión implícita al inciso primero, o sea, cuando una sentencia que se dicte en un juicio deba producir cosa juzgada en otro juicio.

El **artículo 94** señala que, como regla general, la acumulación de autos debe decretarse a petición de parte, y para este efecto se estima legítimo contradictor, o sea habilitado para pedirla, quien haya sido aceptado como parte en cualesquiera de los procesos que se tratan de acumular, sea como parte principal o sea como tercero. Sin embargo, a título excepcional y constituyendo esto una situación

particular frente al principio de la pasividad, cuando dos o más juicios se encuentran ante un mismo tribunal, y se dan los requisitos legales correspondientes, el tribunal puede de oficio ordenar la acumulación.

El **artículo 95** señala los requisitos de carácter procedimental para que sea posible acceder a la acumulación:

- los juicios deben estar sometidos a un mismo procedimiento; y
- la substanciación de todos ellos debe encontrarse en instancias análogas.

El término “instancias análogas”, ha dado lugar a discusiones en relación con que significa, y al respecto hay 2 vertientes de interpretación:

a) que el término instancia significa grado jurisdiccional, y en consecuencia se refiere a que ambos juicios estén en primera instancia, o que ambos estén en segunda instancia, o que ambos juicios estén a nivel de casación;

b) que el término instancia no está tomado en su sentido propio de grado jurisdiccional, sino en su sentido de etapa en el respectivo juicio.

Es curioso que el legislador haya usado el término “instancias análogas”, y no la expresión “en la misma instancia”; y se ha interpretado esta expresión en el sentido que, cuando se habla de instancias análogas, son instancias que tienen el carácter de comunes, y como ejemplo de instancias comunes se da la primera instancia con la única instancia.

En virtud del artículo 96, para determinar ante quien se produce la acumulación es necesario distinguir si todos los juicios se llevan ante el mismo tribunal, caso en que es éste tribunal el que conoce de las causas acumuladas, y si los procesos se siguen ante distintos tribunales. En este último caso, es necesario hacer una nueva distinción:

a) si se trata de tribunales de diferente jerarquía: la acumulación se produce ante el tribunal de mayor jerarquía. No es de frecuente ocurrencia.

b) si se trata de tribunales de igual jerarquía: el juicio más moderno se acumula al juicio más antiguo.

Este ensamble que es la acumulación, es un ensamble de carácter material, o sea, los juicios se cosen uno con el otro formando un solo cuerpo, y se folian correlativamente. Como los juicios pueden estar en distintos momentos, se logra que se produzca esta unidad, deteniéndose el que está más avanzado, hasta que el otro juicio que está menos avanzado llegue a la misma etapa, y ahí siguen en conjunto, como un solo todo, esperando una misma sentencia (artículo 97).

El artículo 97 confirma la interpretación en el sentido que instancias análogas no se refiere a etapas procesales similares, sino que se refiere a grados jurisdiccionales similares.

El artículo 98 señala la oportunidad en que puede pedirse la acumulación de autos, y esta oportunidad es hasta antes de que se dicte la sentencia de término, es decir, hasta antes de la dictación de la sentencia

que falla la última instancia. Y esta acumulación de autos se pide ante el tribunal que deberá conocer de las causas acumuladas.

El artículo 99 señala la tramitación de la acumulación de autos, y dispone que pedida la acumulación, se concederá traslado por 3 días fatales, para que las otras partes expongan lo conveniente sobre ella. Transcurrido este plazo, haya o no respuesta, el tribunal ordena traer a la vista todos los procesos cuya acumulación se solicita, remitiendo los respectivos oficios si fuera necesario; y en virtud de tenerlos todos a la vista, ponderará si se dan los requisitos sustanciales y procedimentales.

La resolución que accede o deniega la acumulación, es apelable en el sólo efecto devolutivo (artículo 100).

Tema 7: Cuestiones de Competencia (artículos 101 y ss.)

Las cuestiones de competencia son las que provocan las partes en torno a la posible competencia o incompetencia del respectivo tribunal; está bien pueden no provocar contiendas de competencia, y no provocan contiendas de competencia cuando todos los tribunales involucrados coinciden en la resolución que se dicta; en cambio, la cuestión de competencia se convertirá en contienda de competencia, cuando los tribunales envueltos no coincidan o disientan de su respectiva competencia, y si se produce esta situación, debe ser resuelta por otro tribunal distinto de los involucrados.

Las cuestiones de competencia pueden provocarse por dos vías: por la vía de la declinatoria y por la vía de la inhibitoria. Se provoca la cuestión de competencia por la vía de la declinatoria, cuando se concurre ante el juez que está conociendo del asunto para que declare su incompetencia; y se procede por la vía de la inhibitoria, cuando hay un determinado juez que está conociendo de un asunto y se estima que ese juez no es el competente, y se concurre ante el juez que se estima competente para que se declare competente e inhiba al juez que está conociendo del asunto, para que no siga conociendo de este (artículo 102).

El incidente de cuestiones de competencia, se refiere fundamentalmente al procedimiento por vía inhibitoria, y esto porque el tema de la declinatoria está comprendido en cada uno de los procedimientos, donde se examina cual es la oportunidad procesal para reclamar de la incompetencia del tribunal.

El artículo 101 C.P.C. señala un fenómeno preclusivo, en el sentido que recurriendo a la vía de la inhibitoria o de la declinatoria, inmediatamente precluye la posibilidad de la otra; o sea, no se puede abandonar una para intentar la otra, ni tampoco se puede intentar las 2 vías simultáneamente.

7.1 Tramitación de la vía inhibitoria.

El juez ante el cual se plantea la inhibitoria, con los antecedentes que se le suministran por quien reclama la inhibitoria, derechamente resuelve, dando o no lugar a ella; no se plantea aquí una cuestión incidental (artículo 103).

Cuando el tribunal accede, comunica a quien está conociendo del asunto, para que se inhíba de seguir conociendo de él (artículo 104).

El tribunal que recibe la comunicación de inhibición, da traslado a la parte que litiga ante él, y con lo que ésta expone o en su rebeldía, resolverá ya sea accediendo a la inhibición que se le plantea o negando lugar a ella; es decir, la tramitación de la inhibición, se realiza incidentalmente (artículo 105).

Si el tribunal requerido accede a la inhibición, ejecutoriada que sea esta resolución, mandara los antecedentes al tribunal. Si deniega la inhibición planteada por el otro tribunal, se produce una contienda de competencia; frente a esta circunstancia, con citación de las partes, se remiten los antecedentes al tribunal que deba conocer de la respectiva contienda, de acuerdo a las reglas de competencia consignadas en el C.O.T. (artículo 106).

En relación con la apelabilidad de la resolución, el artículo 107 señala que son sólo apelables la resolución del tribunal requerido que niega la inhibitoria o ante el tribunal a quien se dirige la inhibitoria y queda lugar a ella; las demás resoluciones no lo son. La apelación, como regla general, se llevará ante el tribunal que debe conocer de la contienda de competencia, pero cuando los tribunales dependan de diversos superiores pero de igual jerarquía, conocerá de la apelación el superior del tribunal que dictó la resolución apelada (artículo 108).

El artículo 109 regula la tramitación ante el superior jerárquico llamado a resolver la respectiva apelación y eventualmente la contienda. Para pronunciar la resolución, se debe citar a las partes litigantes, y eventualmente se debe oír al Ministerio Público, si los tribunales ejercen distinta jurisdicción.

El tribunal que resolvió la apelación respectiva o la contienda en su caso, remitirá los antecedentes a quien corresponda para que inicie o continúe el conocimiento del asunto (artículo 110).

7.2 Tramitación de la vía declinatoria.

El artículo 111, es la única norma que se refiere a la tramitación de la declinatoria, la que se tramitará como incidente; pero esta regla debe entenderse como supletoria, o sea, si en el procedimiento respectivo existen reglas procedimentales que fijen una manera de tramitar la cuestión, a ello hay que sujetarse, y sólo subsidiariamente se puede tramitar esto incidentalmente.

El artículo 112, se refiere al efecto suspensivo que tiene el incidente, o sea, planteada la cuestión de competencia, la regla general es que se suspende la causa principal; con todo, puede el tribunal que está conociendo librar las providencias de carácter urgente.

En relación con la apelación de la resolución que desecha la declinatoria de jurisdicción, se estará a la regla del respectivo procedimiento; y subsidiariamente se aplicará la norma del artículo 112, que establece que se concederá sólo en el efecto devolutivo.

Cuando el tribunal que fue requerido de inhibición, la desecha, sigue tramitando la causa, sin perjuicio que esa tramitación ulterior podrá quedar sin efecto, si en definitiva los superiores jerárquicos correspondientes modifican la resolución (inciso final artículo 112).

Tema 8: Implicancias y Recusaciones (artículos 113 y ss.)

Las implicancias y recusaciones, se encuentran reguladas en el C.O.T., y tiene por objeto que los jueces, los funcionarios del orden judicial y, eventualmente, los peritos, no entren a desempeñarse en un determinado asunto, porque se estima que a su respecto no concurre la debida imparcialidad.

Las implicancias importan un grado mucho más cercano, en tanto que las recusaciones significan un compromiso de menor entidad; y precisamente por estas circunstancias tienen un tratamiento diferente, en el sentido que las implicancias son de orden público, y las causales de recusación miran sólo al interés privado del litigante; las implicancias son irrenunciables y las recusaciones no lo son; las implicancias deben declararse de oficio y las recusaciones debe dejarse constancia de ella, pero no deben declararse propiamente tal.

Implicancias y recusaciones, miradas en su conjunto constituyen las denominadas **causales subjetivas de incompetencia**, en el sentido que la incompetencia no alcanza propiamente al órgano jurisdiccional, sino que alcanza a la persona que lo sirve (juez, auxiliar de la administración de justicia, o perito).

En relación con la normativa del C.P.C., es importante destacar:

a) tratándose de implicancias o recusaciones, siempre debe hacerse una consignación previa en la cuenta corriente del tribunal, por los montos que en cada caso se señalan, en función de la jerarquía del funcionario cuya implicancia o recusación se reclama (artículo 118);

b) estas disposiciones contemplan el **“bastandeo de la causal”**, lo que significa que cuando se trata de causales de implicancia y recusación hay un pronunciamiento propio del tribunal ante el cual se plantea, señalando o no bastante la causal; y se entiende que la causal es bastante cuando se invoca causal legal

específica, y se invocan los hechos encausados dentro de dicha causa legal más la consignación correspondiente (artículo 119).

Si el tribunal estima que no se ha cumplido con estos requisitos, resuelve de plano la implicancia o recusación planteada; y entrará al conocimiento propio de ella cuando se declare bastante. Así, hay una especie de fiscalización preliminar, para evitar el abuso respecto de esta institución.

En estas disposiciones se contempla una situación preclusiva de carácter especial, en el sentido que si durante la tramitación del incidente, la parte que lo promovió deja de realizar gestión útil durante **10 días**, se entiende abandonada la causal, y en consecuencia deberá ser desechada (artículo 123).

Dentro de esta normativa se encuentra la **recusación amistosa**, que consiste en que la parte que estima que un determinado juez o funcionario se encuentra de situación de recusación, no acude ante el tribunal que debiera conocer de la causal, sino que acude previamente ante el propio funcionario y le plantea amistosamente la causal; y sólo si esta recusación amistosa es desechada, se podrá ocurrir ante el tribunal que deba conocer de ella, conforme a las reglas generales (artículo 124).

El artículo 113 señala que, tratándose de peritos, se aplican a su respecto todas las causales de implicancia y recusación, en cuanto les sean aplicables, como las causales de tachas de los testigos.

En virtud de la recusación, la causa queda sin tribunal, y como se puede recusar sin expresión de causa a los abogados integrantes de Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, esta era una forma oblicua para suspender la causa; por lo que el legislador señaló, en el inciso final de este artículo, que cada vez que exista una causal de recusación, el presidente de la respectiva Corte procederá a formar sala.

Antes de cualquier gestión en cuanto al fondo, debe plantearse la causal de implicancia o recusación, siempre que sea conocida; o bien, antes que entre a funcionar la respectiva persona, según lo señalado en el artículo 114.

Hay nuevamente un mecanismo de preclusión respecto de la alegación de la recusación, en el sentido que si la causa de recusación es posterior o no ha llegado a conocimiento de la parte, deberá promoverse tan pronto como se tenga noticia de ella, y si no se justifica esta circunstancia, la recusación será desechada. Este sistema no rige respecto de la alegación de la implicancia, pero quien retarda maliciosamente la alegación de una implicancia podrá ser objeto de una multa.

La implicancia de un juez de un tribunal unipersonal, debe ser planteada ante él mismo. La recusación de un juez de un tribunal unipersonal, y las implicancias y recusaciones de miembros de tribunales colegiados, se deben hacer valer ante el tribunal que la ley señala (artículos 115 y 116).

La implicancia y recusación de los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, se plantea ante el propio juez de la causa (artículo 117).

Cuando la causal ha sido declarada bastante, y es necesario rendir prueba, se tramita incidentalmente el asunto y por cuerda separada.

Si se ha producido positivamente el bastandeo, queda inhabilitado el funcionario para seguir interviniendo. Cuando se produce la inhabilitación parcial del funcionario, se sigue tramitando la causa hasta la citación para oír sentencia, pero se suspende la dictación de la sentencia, hasta que no se resuelva efectivamente el incidente de implicancia o recusación (artículos 120 y 121).

El artículo 122 señala que si la implicancia o recusación es desechada, se condenará en las costas al que la haya reclamada, y se le impondrá una multa.

Cuando media una causal de recusación, el juez que está conociendo del asunto deja testimonio en el expediente de que concurre a su respecto dicha causal; y se notifica a las partes del testimonio que se ha dejado en el expediente. La parte en cuyo beneficio la ley entiende que está establecida la recusación, tiene un plazo de 5 días para hacerla valer, y si no lo hace se entiende renunciada, y en consecuencia el juez podrá seguir actuando en el respectivo asunto.

El artículo 126 establece que la regla general es que sean inapelables las resoluciones que se pronuncien sobre las implicancias o recusaciones, salvo situaciones excepcionales.

Las implicancias o recusaciones, no son necesariamente un incidente en el respectivo juicio, sino que pueden plantearse respecto de una serie de juicios, entre las mismas partes, donde también se produzca la misma situación (artículo 127).

Finalmente, el artículo 128 dispone que las implicancias o recusaciones y la sentencia que los resuelve, produzcan el efecto de la cosa juzgada.

Tema 9: Privilegio de Pobreza (Título XVII C.O.T., artículos 129 y ss. C.P.C.)

El privilegio de pobreza es una institución que está dentro de las facultades conservadoras de los tribunales, en el sentido que por esta vía se contribuye al acceso a la justicia a personas privadas de los recursos económicos necesarios.

El privilegio de pobreza es una institución que se refleja en definitiva en la resolución que lo declara o lo desecha, y esta resolución es un auto, porque no establece derechos permanentes a favor de las partes, toda vez que cambiando las circunstancias, puede cambiar la resolución.

Respecto de la persona a quien se concede el privilegio de pobreza, queda exenta de la obligación de pagar por los servicios judiciales que se le presten; además está exenta de las consignaciones judiciales, y

deben ser servidas gratuitamente por los abogados o procuradores de turno, o eventualmente por las respectivas corporaciones.

Por una norma especial, al **reo preso** se le presume pobre, y en consecuencia por la sola circunstancia de estar en prisión preventiva goza, por el ministerio de la ley, de privilegio de pobreza (artículo 135).

Para obtener el privilegio de pobreza, no se requiere ser pobre de solemnidad, sino que se requiere estar en una situación económica tal, que no sea posible soportar razonablemente los costos del respectivo juicio (artículo 131).

Tema 10: Incidente de Nulidad Procesal.

10.1 Generalidades.

Las normas de procedimiento fijan ritualidades a las que deben ajustarse los actos procesales, de manera tal que si no cumplen con los requisitos es posible decir a su respecto de nulidad procesal.

La nulidad procesal pueda ser declarada por distintas vías, específicamente recursos procesales, como la casación en la forma, o bien, a través de los incidentes, como una cuestión accesoria en el mismo juicio, por lo cual se le aplican las normas preclusivas ya señaladas. Cuando se reclama como incidente sólo puede hacerse en el juicio en que se trata, no es lícito y debe ser rechazada de plano, cualquier demanda donde autónomamente se pretenda plantear una nulidad procesal.

En cuanto a sus efectos, la nulidad procesal tiene un **efecto extensivo o progresivo**, por cuanto el proceso es una concatenación de actos procesales que se van sucediendo en el tiempo, de suerte tal que cuando un acto procesal se declara nulo, lo normal es que esta declaración de nulidad acarree el mismo efecto respecto de los actos procesales siguientes. Mayor es el efecto cuando se trata de la nulidad procesal por falta de emplazamiento, teniendo un efecto reflejo civil muy importante, que se recoge en la prescripción tanto adquisitiva como extintiva: la prescripción se interrumpe con la notificación legal de demanda, y si se anula el emplazamiento no hay, en consecuencia, notificación legal y no se produce el efecto interruptivo de la prescripción.

10.2 Nulidad procesal por fuerza mayor.

Esta nulidad se encuentra regulada en el artículo 79 a propósito de las rebeldías (Título VIII del Libro I).

Artículo 79. *Podrá un litigante pedir la rescisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor.*

Este derecho sólo podrá reclamarse dentro de tres días, contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio.

Del análisis de la norma transcrita llama la atención que el legislador use el término “rescisión”, porque en el C.C. rescisión es sinónimo de nulidad relativa, por lo tanto, aquí hay una impropiedad, ya que simplemente se trata de nulidad.

La disposición se basa en el principio de la fuerza mayor, en relación con el aforismo que dice “a lo imposible nadie está obligado”, de esta manera si al litigante le ha sido imposible realizar actos procesales por fuerza mayor, puede pedir que se anule todo lo obrado en su rebeldía. En el inciso 2º hay una cortapisa, en el sentido que la alegación respectiva se puede formular sólo dentro de los tres días desde que cesó el impedimento.

En cuanto a sus efectos, declarada la nulidad por fuerza mayor, se anulan sólo los actos procesales ejecutados durante la rebeldía y los que son su necesaria consecuencia.

10.3 Nulidad procesal por falta de emplazamiento.

El artículo 80 se refiere a la nulidad falta de emplazamiento por defectos en la forma de notificar la demanda.

El presupuesto para que opere es que el litigante se encuentre rebelde y además que pruebe que por un hecho que no le sea imputable, no le ha recibido las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte substancial.

La remisión a los artículos 40 y 44 se refieren a la notificación personal y a la sustitutiva de la personal, respectivamente. Llama la atención la referencia al artículo 40, porque cuando se trata de este tipo de notificación, las copias le son entregadas directamente al notificado, ergo la referencia debe entenderse a la segunda hipótesis, esto es que el contenido de las copias no son exactas en lo sustancial.

Esta disposición también está acompañada de una norma preclusiva contenida en el inciso 2º, ya que este derecho sólo se puede reclamar dentro de quinto día contado desde que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio, no es un saber más o menos difuso, sino que efectivamente tiene que acreditarse que tuvo conciencia del juicio en su contra.

Artículo 80. *Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo acreditar que, por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte substancial.*

Este derecho no podrá reclamarse sino dentro de cinco días, contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio

En cuanto a sus efectos, declarada la nulidad por falta de emplazamiento, se anula todo el juicio hasta la notificación de la demanda. En todo caso, una vez reclamada la nulidad debe estarse a lo dispuesto en el artículo 55 inciso 2° (notificación tácita especial).

Finalmente el artículo 81 contempla una norma procedimental respecto de los artículos 79 y 80, en el sentido que ambos incidentes no son de previo y especial pronunciamiento, sino que debe tramitarse en cuaderno separado.

10.4 Incidente de nulidad procesal en otros actos procesales.

Esta nulidad puede acarrear, incluso, la nulidad de todo lo obrado, cuando se trata de actos procesales que miran a los presupuestos procesales de validez o existencia como la incompetencia absoluta, la falta de jurisdicción o la incapacidad de las partes.

El artículo 83 inciso 1º señala que la nulidad pueda ser declarada de oficio o a petición de parte, y esto es muy importante porque establece una calificada excepción al principio de la pasividad de los tribunales.

Además, tiene lugar en los casos en que la ley expresamente lo disponga y en aquellos en que exista un vicio que irrogue a una de las partes un perjuicio que sólo se pueda reparar con la declaración de nulidad. Esto es importante porque si es posible por otra vía reparar las consecuencias de dicha nulidad procesal, debe siempre preferirse la otra vía. La nulidad procesal es remedio *in extremis*, es la *ultima ratio*.

El inciso 2º artículo 83, contiene algunas normas de carácter preclusivo de gran importancia en virtud de la cual la parte afectada debe alegar la nulidad dentro de quinto día contado desde que aparezca o se acredite que tuvo conocimiento del vicio, la calificada excepción a esta norma es que será oído el incidentista si lo que se reclama es la incompetencia absoluta del tribunal. La falta de jurisdicción no está expresamente enumerada, pero también en ese caso el incidentista será oído porque la falta de jurisdicción acarrea, consecuentemente, la incompetencia absoluta.

La segunda parte de este inciso, contiene otra norma preclusiva, en el sentido que la parte que ha ocasionado el vicio o concurrido a su ejecución o lo ha aceptado tácitamente, no podrá demandar de nulidad, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Esto tiene como importante consecuencia que la nulidad procesal sólo la puede reclamar la **parte agraviada**, lo que implica:

- a) Que la omisión o defecto directamente lo afecte, o dicho otra manera, que la corrección del acto procesal hubiere estado en su beneficio.
- b) Que el acto procesal específico que se trata de anular, también le produzca perjuicio.

El inciso final limita el efecto extensivo o progresivo de la nulidad procesal, señalando que la nulidad de un acto procesal no significa la nulidad de todo lo obrado, sino que sólo la nulidad de los actos

procesales que son consecuencia del acto anulado, para estos efectos el tribunal, al declarar la nulidad procesal, debe precisamente señalar cuáles son los actos procesales consecuenciales que quedan nulos. Por su parte, el inciso final del artículo 84 guarda estrecha relación con el artículo 83, ya que reconoce expresamente al juez la posibilidad de corregir de oficio los errores que observe en la tramitación de los juicios, para evitar la nulidad procesal, sin embargo, no podrá subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado fuera del plazo legal.

La ineficacia de los actos procesales no tan sólo deriva de la nulidad, sino que también puede tener otras causales como la inoponibilidad. Un acto procesal, desde el punto de vista formal, puede ser válido, pero respecto de ciertas y determinadas personas, puede ser inoponible.

El legislador del C.P.C., no reguló la inoponibilidad procesal, pero hay disposiciones aisladas que se refieren a la materia, por ejemplo, cuando se solicita el cumplimiento incidental del fallo a un tercero, éste puede oponer la excepción de no empecerle la sentencia que se trata de ejecutar.

Unidad 7: Juicio Sumario.

Se encuentra regulado en los artículos 680 y ss. C.P.C., Título XI, Del libro III, denominado “Del Procedimiento Sumario”.

Tema 1: Características generales.

a) El procedimiento sumario puede ser tanto declarativo como de condena, es más ambas pretensiones pueden hacerse valer en un mismo procedimiento sumario, incluso siendo incompatibles, pues en ese caso se hacen valer una en subsidio de la otra.

b) Es un procedimiento especialmente concentrado, pues se han simplificado trámites, otros se han suprimido y también se han reducido plazos. Otra norma relevante en este punto es la oportunidad y forma de plantear los incidentes, ya que éstos deben promoverse y tramitarse en la audiencia de contestación y conciliación y son resueltos en la sentencia definitiva (artículo 690).

c) Es un procedimiento verbal, pero se aplica el principio de la protocolización en cuya virtud se deja testimonio escrito en el acta que para tales efectos se levanta. Este principio de la protocolización se encuentra recogido en el artículo 682 C.P.C.

Artículo 682: “El procedimiento sumario será verbal; pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulen.”

El legislador habla de “minutas escritas”. Minuta es un término que se usa con bastante frecuencia en el lenguaje jurídico y significa testimonio escrito particularmente breve. Sin embargo, en la práctica se ha entendido que la exigencia de presentar minutas escritas se puede entender cumplida por la presentación de formales escritos y, en consecuencia, en los comparendos donde se acompañan estos escritos la parte respectiva solicita que el escrito se entienda incorporado al acta del comparendo. Pero reiteramos que la intención del legislador era que se tratase de presentaciones particularmente breves y no tan formales como los escritos judiciales.

d) En estricto análisis el juicio sumario puede ser tanto un juicio ordinario como un juicio especial. Puede ser **ordinario** porque hay una causal genérica que permite su aplicación contemplada en el artículo 680 inciso 1º, cuando la acción deducida requiera de una tramitación rápida para ser eficaz. Sin embargo, no hay una norma de carácter general que señale cuáles son estas situaciones, quedando entregado al tribunal el calificar si se dan o no las circunstancias del caso para aplicar el procedimiento sumario.

Artículo 680: “El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

En otro sentido, el procedimiento sumario es un **procedimiento especial**, porque en la casuística del artículo 680 hay una serie de situaciones concretas a las cuales específicamente alude el legislador. Es más, este procedimiento se encuentra regulado en el Libro III del C.P.C. que precisamente se llama “De los Juicios Especiales”.

Tema 2: Sustitución del procedimiento.

Cuando el juicio sumario tiene aplicación por la causal genérica prevista en el inciso 1° del artículo 680 procede una novedosa institución llamada la “sustitución del procedimiento”, en tal sentido puede convertirse un procedimiento inicialmente comenzado como sumario, en un procedimiento ordinario o viceversa.

A esta situación se refiere el artículo 681 que dispone:

Artículo 681. En los casos del inciso 1° del artículo anterior, iniciado el procedimiento sumario podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello.

Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo al procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo.

La solicitud en que se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente.

La ley no señala una oportunidad específica para pedir la conversión del procedimiento, de manera que se podría sostener que se puede solicitar en cualquier momento durante su desarrollo, pero mientras tenga alguna utilidad para las partes.

Concedida la sustitución no se anula lo actuado en el otro procedimiento, en consecuencia, lo que se ha actuado válidamente durante el procedimiento sumario respectivo subsiste y la sustitución será aplicable respecto de las etapas siguientes.

La tramitación de la solicitud se rige de acuerdo a los incidentes. Creemos que tiene el carácter de previo y especial pronunciamiento, en primer lugar, porque el legislador no dice que se tramitará en cuaderno separado, y en segundo, porque podría ser inútil el planteamiento respectivo en la medida que no se impide el avance del procedimiento sumario y la situación puede convertirse en casi irreversible.

Es muy interesante este instituto ya que se puede convertir el procedimiento sumario en ordinario, pero también a la inversa, es decir, procedimiento ordinario en sumario y a esto puede instar tanto el

demandante como incluso el demandado (artículo 681 inciso 2°). Lo anterior implica que el concepto de urgencia en torno al requerimiento de que la acción deducida sea eficaz es un concepto esencialmente dinámico y pueden, en consecuencia, modificarse las condiciones y un procedimiento iniciado bien como ordinario, por dicha modificación de circunstancias, va a ser necesaria su sustitución por un procedimiento sumario.

Tema 3: Causales específicas de aplicación del procedimiento sumario.

Artículo 680 inciso 2°. Deberá aplicarse, además, a los siguientes casos:

1° A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o en otra forma análoga;"

Este numeral se remite a cualquier texto legal que diga que en una situación concreta debe procederse sumariamente, o como también se suele emplear en forma combinada, breve y sumariamente, o bien usando otra expresión análoga que indique precisamente la urgencia o concentración del respectivo procedimiento.

2° A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar;

Las servidumbres pueden ser naturales, legales o convencionales. Las servidumbres convencionales, como su nombre lo indica, se constituyen en virtud de una convención donde un predio se convierte en predio sirviente y el otro se convierte en predio dominante, conviniéndose las prestaciones que corresponden. La constitución de una servidumbre convencional es solemne y debe constar en escritura pública.

Este numeral se refiere sólo a las servidumbres naturales y legales, donde todo lo que diga relación con servidumbres naturales (como la de escurrimiento) o servidumbres legales (como la de luz o de vista), debe tramitarse conforme al procedimiento del juicio sumario, sea su constitución, subsistencia, modificación, prestaciones mutuas, etc.

3° A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697;

El cobro de honorarios deriva de un contrato que se denomina "prestación de servicios", que es perfectamente distinto y separable del contrato de trabajo. La persona que recibe debe pagar al prestador un *honorario*, y es su cobro el que se tramita de acuerdo a las normas del juicio sumario.

Basándose en el tenor de la disposición algunos autores han sostenido que el procedimiento sumario sólo se aplica al cobro de honorarios ya determinados. Sin embargo, una interpretación más razonable es que no tan sólo el cobro del honorario mismo es el que se puede plantear por la vía del juicio sumario, sino que también la fijación de su cuantía. A esta conclusión se llega no sólo por la interpretación lógica de la norma, sino por la remisión que ella hace al artículo 697. De esta manera la fijación y cobro, en esta interpretación puede hacerse por la vía del juicio sumario.

Artículo 697. Cuando el honorario proceda de servicios profesionales prestados en juicio, el acreedor podrá, a su arbitrio, perseguir su estimación y pago con arreglo al procedimiento sumario, o bien interponiendo su reclamación ante el tribunal que haya conocido en la primera instancia del juicio.

En este último caso la petición será substanciada y resuelta en la forma prescrita para los incidentes.

Cuando los honorarios se han causado en juicio, al acreedor le surge una alternativa: cobrar los honorarios conforme al procedimiento del juicio sumario o bien, como un incidente en juicio donde los servicios se prestaron. Esta disposición es aplicable no sólo a los abogados, sino a cualquiera que haya prestado los respectivos servicios en el juicio, por ejemplo, un perito, un procurador, un tasador, etc.

4° A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus representados;

Esta hipótesis contempla dos materias perfectamente distintas que son:

- a) los juicios sobre remoción de guardadores y,
- b) los juicios que se susciten entre los representantes legales y sus representados.

Los guardadores, pueden ser de dos categorías: los tutores y los curadores; ya sea que se trate de tutores o de curadores, si se trata de la remoción del respectivo guardador, el procedimiento aplicable es el sumario. Es importante señalar que no se trata de juicios indemnizatorios, es decir, no se trata de determinar las prestaciones que uno le debe al otro, sino sólo de la remoción de los tutores y los curadores.

La segunda parte de esta misma disposición se refiere a los juicios entre los representantes legales y sus representados, no aplicándose en consecuencia a los representantes judiciales o convencionales.

6° A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario;

El depósito es un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la cosa, donde surgen derechos y obligaciones recíprocas entre depositante y depositario. El **depósito necesario**, se da cuando las posibilidades de elección por parte del depositante, son limitadísimas o nulas.

El comodato precario es la entrega de una cosa, a título gratuito, que queda en poder del comodatario, y que la conserva por mera tolerancia o complacencia de su respectivo propietario. Esta situación se da principalmente en el mundo de los inmuebles, donde el propietario tolera la ocupación de un bien raíz de su propiedad. Es de la esencia del comodato precario, y así lo ha señalado la jurisprudencia, que no haya título de ocupación, sino que se produzca por mera tolerancia o complacencia del propietario, de manera tal que si el comodatario puede exhibir algún título, no puede prosperar una acción semejante.

7° A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil;

Hay un lapso que media entre el momento en que se cumple la prescripción de la acción ejecutiva y aquel en que se cumple el plazo de prescripción de la acción ordinaria, este tiempo medio es por regla general de dos años. En efecto, la prescripción de la acción ejecutiva es de tres años y la prescripción de

la acción ordinaria de cinco años, entonces la acción va a subsistir por dos años como ordinaria, así cuando el acreedor pretenda su cobro debe recurrir a las normas del juicio sumario.

8° A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696;

El legislador se pone en la situación de la existencia de dos procedimientos sucesivos: un juicio declarativo para que se declare la obligación de rendir una cuenta, y posteriormente, el juicio de cuentas propiamente tal.

Muchas pueden ser las vinculaciones jurídicas que colocan a una persona en la necesidad de rendir cuenta frente a otra (por ejemplo, en el caso del mandatario o del agente oficioso), ya sea por disposición legal o vinculación contractual.



Frente a la obligación de rendir cuenta, encontramos **dos posibilidades**:

a) que quien tiene la obligación de rendir cuenta, paralelamente reconozca esa obligación, y en consecuencia, tenga la disposición de rendirla;

b) que quien tiene la obligación de rendir cuenta, o mejor dicho, que la persona respecto de la cual se pretende existe la obligación de que rinda cuenta, controvierta esta pretensión.

Cuando se controvierte si existe o no la obligación de rendir cuenta, es necesario entablar un procedimiento declarativo para que la sentencia definitiva reconozca la existencia o no existencia de dicha obligación de rendir cuenta. Este procedimiento declarativo se debe plantear por la vía del juicio sumario, donde la sentencia simplemente dirá: “el demandado debe rendir cuenta” o “el demandado no debe rendir cuenta”.

Si la sentencia declara que no debe rendir cuenta, termina definitivamente toda posible repercusión. Pero si la sentencia declara la obligación de rendir la cuenta, se puede producir propiamente el juicio de cuentas; aunque bien puede no ocurrir si el demandado rinde cuenta y ésta es aprobada por el actor. Entonces, el juicio de cuentas tendrá lugar cuando el demandado no rinde cuentas, o rindiéndola, ésta no es aprobada por el demandante.

En el juicio de cuentas propiamente tal hay una discusión doctrinaria y jurisprudencial en el sentido de ante quién se plantea el juicio. Esta discusión arranca de una norma del C.O.T. que señala que las cuestiones sobre cuentas son materias de arbitraje forzoso. Algunos han sostenido que debe recurrirse ante el juez en lo civil y sólo si se produce oposición a la cuenta rendida ante el juez civil, se provoca el escalón siguiente (juez árbitro). Otros por su parte sostienen que toda la cuestión se sigue ante el juez árbitro.

9° A los juicios en que se ejercite el derecho que concede el artículo 945 del Código Civil para hacer cegar un pozo.

De esta norma, que ya no existe en el C.C. porque fue derogada y trasladada al Código de Aguas, sirvió para que la doctrina sostuviera que en nuestro país se recoge el principio del “abuso del derecho”. La norma señalaba que era lícito y legítimo cavar un pozo para obtener agua, en los lugares donde se podía

hacer, pero si con esa labor se secaban napas de otra persona que ya tenía pozos establecidos, el derecho era abusivamente ejercitado, ergo el afectado podía reclamar solicitando cegar el pozo.

Este procedimiento sumario, hoy en día está supeditado a las normas específicas del Código de Aguas, el que señala cuáles son las maneras de reclamar los derechos que dicho cuerpo legal establece. Actualmente la referencia al artículo 945 del C.C. debe entender al artículo 65 del Código de Aguas.

10° A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada.

El artículo 59 del Código Procesal Penal señala que las acciones civiles son de dos tipos: restitutoria e indemnizatoria. La primera debe interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal. La acción segunda, puede interponerse en sede penal o sólo en sede civil, dependiendo de quién y contra quién se ejerza la acción.

Pues bien, si hay sentencia condenatoria firme o ejecutoriada las eventuales consecuencias civiles del delito pueden ser perseguidas mediante el juicio sumario, sea que el demandante sea la víctima o un tercero, en contra del autor del delito o un tercero civilmente responsable.

Tema 4: Tramitación.

4.1 Demanda.

Respecto de la demanda, hay un criterio universal tanto doctrinario como jurisprudencial en el sentido de que ésta debe ser necesariamente escrita, argumento que se ve reforzado si se compara el artículo 683 con el artículo 704 inciso 2° que se refiere al juicio de mínima cuantía, donde se contempla la alternativa de que la demanda puede ser escrita u oral, en cambio, en las normas del juicio sumario no se advierte esa alternativa. Asimismo, si hay varios tribunales competentes que son asiento de Corte, sería imposible distribuir una demanda verbal.

La demanda debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 254 C.P.C, como también los comunes a todo escrito y eventualmente, con la presuma.

Interpuesta la demanda, el tribunal analiza que cumpla con los requisitos del artículo 254, pudiendo no darle curso si contiene los primeros tres numerales (artículo 256). Si se encuentra en orden, el tribunal cita a audiencia para el quinto día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo el aumento que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 259 (artículo 683 inciso 1°).

Entonces, la providencia frente a la demanda es “vengan las partes a comparendo dentro de quinto día”; y esta providencia, partiendo del supuesto que es la primera que se dicta en el juicio (lo que es la regla general), deberá notificarse personalmente o en una forma substitutiva de la personal. Podría ocurrir que no fuera la primera providencia y que otra anterior se hubiese notificado personalmente, como por

ejemplo si se hubiesen concedido medidas prejudiciales precautorias, en ese caso la mencionada resolución debería, por lo menos, notificarse por cédula, en obediencia a lo dispuesto en el artículo 48 que ordena notificar por cédula aquellas resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes.

4.2 Objeto del comparendo.

Este comparendo tiene por finalidad que el demandado **conteste la demanda**. No es una audiencia de contestación y prueba como ocurre con otros procedimientos concentrados, por ejemplo, en los juicios de arriendo.

Como se señaló anteriormente, el artículo 682 establece que este procedimiento es verbal, pero las partes pueden acompañar minutas, por tanto, es perfectamente posible que el demandado en el comparendo conteste verbalmente la demanda, debiendo el actuario transcribir en el acta dicha contestación. Pero como el mismo artículo 682 permite acompañar minuta escrita, lo normal será que el demandado acompañe minuta de contestación y solicite en el comparendo que dicha minuta se tenga como parte integrante del mismo.

En la audiencia de estilo, además de la contestación, deben promoverse todos los incidentes que crea oportuno plantear el demandado, así por ejemplo, si el demandado estima que es del caso oponer excepciones dilatorias debe hacerlo antes de la contestación.

Artículo 690. Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el curso de ésta. La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida y sobre los incidentes, o sólo sobre éstos cuando sean previos o incompatibles con aquélla.

En los hechos se ha desdibujado la voluntad del legislador, y en la práctica los tribunales frente a excepciones dilatorias o al planteamiento de incidentes, normalmente dan traslado por tres días y suspenden el comparendo.

En cuanto al fallo de los incidentes, éstos se reservan para la dictación de la sentencia definitiva, o sea, la sentencia definitiva no tan sólo resolverá la cuestión controvertida sino que también fallará los incidentes que se promovieron. Sin embargo, la ley se plantea la posibilidad que alguno de los incidentes promovidos sea incompatible con la sentencia que se pudiese dictar, y en tal evento solo se resolverá el incidente y no habrá pronunciamiento sobre el fondo (artículo 690).

Es necesario plantearse si en el juicio sumario procede o no la reconvencción, partiendo del supuesto que se cumplan las exigencias para reconvenir. La cuestión es discutida, pero se acepta la procedencia de la reconvencción cuando efectivamente concurren los requisitos de ésta, porque la reconvencción es uno de

los institutos más importantes en función de la economía procesal, y si este procedimiento mira y está establecido en función de este valor, sería irracional, contradictorio no permitirlo. Claro está, que en caso de reconvención habrá que adecuar la tramitación en función de esta realidad, a partir de las prácticas y costumbres del tribunal.



Al comparendo de contestación, en algunos y determinados casos, debe ser emplazado el defensor público, y esto debe ocurrir cuando conforme a la ley el defensor público deba ser oído. Sobre el particular, hay que concordar el artículo 366 N° 1 C.O.T. con el artículo 680 N°4 C.P.C., en el sentido que el defensor público debe ser oído en los juicios entre los representantes legales y sus representados. También el tribunal puede convocar o emplazar al defensor público en el caso del artículo 683 inciso 2º, pero en el caso anterior es una exigencia, es decir, el tribunal debe emplazar al defensor público.

Si el demandado comparece y contesta la demanda, al tribunal se le presenta la siguiente alternativa: recibe la causa a prueba o cita a las partes a oír sentencia. Sin embargo, aquí vemos una cierta dicotomía entre estas disposiciones y las actuales normas sobre conciliación, porque de acuerdo a las modificaciones introducidas a las normas sobre conciliación, ésta es aplicable a todos los procedimientos, salvo aquellos que están específicamente excluidos entre los cuales no se encuentra el juicio sumario. En consecuencia, se debería llegar a la conclusión que las normas sobre conciliación son enteramente aplicables al juicio sumario.

De acuerdo con lo anterior, una vez contestada la demanda el tribunal debe llamar a las partes a conciliación. Si ésta no se produce el tribunal debe recibir la causa a prueba o citar a las partes para oír sentencia. No recibirá la causa a prueba cuando las partes lo hayan solicitado expresamente, o bien cuando no haya hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

4.3 Rebeldía del demandado.

El legislador se coloca en una segunda posibilidad y es que el demandado se encuentre en rebeldía, o sea, el demandado no concurre al comparendo; en este caso surge para el demandante un derecho que de ser acogido tiene graves consecuencias para aquél:

Artículo 684: “En rebeldía del demandado, se recibirá a prueba la causa, o, si el actor lo solicita con fundamento plausible, se accederá provisionalmente a lo pedido en la demanda.

En este segundo caso, podrá el demandado formular oposición dentro del término de cinco días, contados desde su notificación; y una vez formulada, se citará a nueva audiencia, procediéndose como se dispone en el artículo anterior, pero sin que se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado con esta calidad, ni se altere la condición jurídica de las partes.”

Si se produce la situación de rebeldía, el tribunal normalmente deberá recibir la causa a prueba, porque la rebeldía es defensa negativa tácita y en consecuencia el tribunal debe estimar que hay controversia sobre los hechos y necesariamente debe recibir la causa a prueba. Pero puede no recibir la causa a prueba de inmediato, sino que a solicitud del demandante y siempre que éste invoque fundamento plausible, puede acceder provisionalmente a la demanda.

Normalmente el pronunciamiento respecto de la pretensión se produce sólo en la sentencia definitiva que, precisamente por su calidad de tal, resuelve el asunto controvertido. Sin embargo, existe una tendencia creciente, que ya tímidamente fue recogida en nuestro C.P.C., de acceder provisionalmente a la demanda, sin perjuicio de lo que en definitiva pudiese resolverse; una demostración en este sentido es esta norma, y otra demostración es la llamada denuncia de obra ruinosa, donde efectivamente y aún antes de la sentencia definitiva, accediendo provisoriamente se puede ordenar la demolición o la adopción de los resguardos del caso para evitar la ruina.

Es necesario distinguir claramente entre lo que es acceder provisionalmente a la demanda y las medidas cautelares o resguardos procesales que significan paralizar la respectiva situación. En nuestra legislación, son muy abundantes los ejemplos de medidas cautelares o bien resoluciones judiciales procesales que tienen este efecto paralizante, por ejemplo, la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos y la orden de no innovar, respectivamente. El acceder provisionalmente a la demanda no tiene un efecto paralizante, sino que tiene un efecto innovativo, en el sentido que se modifica una situación de hecho antes que haya un pronunciamiento sobre la pretensión misma.

Si el tribunal accede provisionalmente a la demanda, surge para el demandado un derecho de oposición que está contemplado en el artículo 684, el cual debe ser ejercitado dentro de quinto día contado desde que se notifique la resolución que accede provisionalmente a la demanda. Es importante destacar que esta resolución que accede provisionalmente a la demanda, como la ley no indica la forma especial de notificación, debe notificarse por el estado diario y a partir de ese acto se cuenta dicho plazo.

Si se deduce oposición, el tribunal cita a un nuevo comparendo, y en éste puede producirse la contestación, que se tuvo por evacuada en rebeldía. Esta nueva audiencia de contestación, no tiene la virtud de suspender el cumplimiento provisional de lo decretado, ni tampoco altera la posición jurídica de las partes.

4.4 Prueba.

Si no se deduce oposición ni se accede provisionalmente a la demanda, el artículo 685 señala que el tribunal recibirá la causa a prueba o citará a las partes para oír sentencia, según estime conveniente.

Respecto de la prueba, la disposición que la regula es extraordinariamente escueta, señalando:

Artículo 686: *“La prueba, cuando haya lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la forma establecidas para los incidentes.”*

El auto de prueba en el juicio sumario, al igual que en los incidentes, fija puntos de prueba, lo que tiene importancia para efectos de la prueba testimonial en el sentido que no es necesario acompañar minuta de puntos.

La resolución que recibe la causa a prueba debe notificarse por cédula, no obstante la referencia a la prueba de los incidentes, y a esta conclusión se llega si se examina lo establecido en el artículo 323, que señala que la resolución que recibe un incidente a prueba se notifica por el estado diario, con lo cual se ve claramente la voluntad del legislador de limitar esta forma de notificación sólo respecto de los incidentes. Además, al notificarse por cédula se está aplicando la regla general del artículo 48 C.P.C.

4.4.1 Recursos contra el auto de prueba.

La reponibilidad del auto de prueba, es un tema que se ha discutido tanto en los incidentes como, por extensión, en el juicio sumario. Se produce esta discusión, porque hay una dicotomía en el sentido que la lista de testigo, por aplicación de las normas de los incidentes, debe presentarse dentro de segundo día, y la reposición se debe presentar dentro de tercero día; entonces se dice que es evidente que no cabe la reposición, porque si se aceptase, en el fondo sólo se estaría ampliando, por un resquicio, el plazo para presentar la lista de testigos. Sin embargo, no obstante que esta interpretación tiene cierto asidero, en general los tribunales en su práctica han aceptado la posibilidad de reposición.

4.4.2 Término probatorio.

Respecto del término probatorio debemos entenderlo en relación con el artículo 90, que se refiere al término probatorio en los incidentes, en consecuencia, el término probatorio ordinario tiene una duración de ocho días, pudiendo aumentarse con un término probatorio extraordinario para rendir prueba fuera del lugar del juicio, por motivos fundados, por una sola vez por los días que determine el tribunal, que en ningún caso pueden exceder de 30 días contados desde que se recibió el incidente a prueba. Las resoluciones en esta materia son inapelables.

4.4.3 Citación para oír sentencia.

Terminado que sea el término probatorio, procede la citación para oír sentencia, la que de acuerdo al artículo 688 debe ser dictada dentro del plazo de diez días. Además la misma norma establece que las demás resoluciones deben dictarse dentro de segundo día.

El artículo 689 contempla una institución que se llama la “**audiencia de parientes**”; el término pariente se encuentra definido en el artículo 42 del C.C. donde se señala que se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge y los consanguíneos.

Esta audiencia de parientes corresponde a una visión decimonónica que recogió el Código de Napoleón, y que correspondía a ciertas costumbres francesas de la época, que se denominaba el “consejo de familia”, o sea, cuando un miembro de la familia se encontraba en una situación determinada, se producía una concurrencia de los parientes más cercanos y tomaban ciertas decisiones con fuerza vinculante.

En nuestra legislación este instituto es de escasa aplicación y el artículo 689 señala que cuando haya que oírse a los parientes, se les cita a la primera audiencia o a otra posterior, debiéndose notificarles personalmente, aunque pueden concurrir sin notificación. El tribunal les pedirá informe sobre los hechos conducentes, y si no ha concurrido un pariente que el tribunal estime particularmente importante, se puede suspender la audiencia y ordenar que se le cite.



Es interesante notar que en la casuística del artículo 680 hay una situación específica donde por mandato del C.C. debe oírse a los parientes: en juicios sumarios que se refieren a remoción de guardadores (artículo 680 N°4).

Tema 5: Apelación en el procedimiento sumario.

Son apelables en ambos efectos, la sentencia definitiva y la resolución que convierte en sumario un procedimiento que se inició como ordinario. Esta misma norma contempla una excepción genérica, que dice que si bien son apelables en ambos efectos, se concederán en el solo efecto devolutivo si el tribunal llega a la conclusión que se puede eludir sus resultados concediéndola en ambos efectos.

Artículo 691. La sentencia definitiva y la resolución que dé lugar al procedimiento sumario en el caso del inciso 2° del artículo 681, serán apelables en ambos efectos, salvo que, concedida la apelación en esta forma, hayan de eludirse sus resultados.

Las demás resoluciones, incluso la que acceda provisionalmente a la demanda, sólo serán apelables en el efecto devolutivo.

La tramitación del recurso se ajustará en todo caso a las reglas establecidas para los incidentes.

Todas las demás resoluciones, e incluso aquellas que acceden provisionalmente a la demanda, son apelables en el solo efecto devolutivo.

La tramitación del recurso se ajustará a las normas de los incidentes. Hasta antes de una reforma, la apelación de la sentencia definitiva contemplaba, como norma general, un escrito en segunda instancia que se denominaba la “expresión de agravio”, y un escrito de respuesta que se llamaba la “contestación o respuesta a la expresión de agravios”; esto está modificado, y ahora en segunda instancia no existen estos escritos, sino que las apelaciones en materia civil deben formularse con peticiones concretas.

En consecuencia, no hay mayor diferencia en la tramitación de la apelación de los incidentes versus las apelaciones normales, salvo que la primera normalmente se resuelve en cuenta.

Se ha producido una duda interpretativa respecto del artículo 691 cuando la apelación del juicio sumario se refiere a la sentencia definitiva, porque algunos dicen que se aplican las reglas de los incidentes y por

lo tanto debe resolverse en cuenta. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado en sentido contrario, de modo de que cuando se trata de la sentencia definitiva en el juicio sumario, la resolución es “autos en relación” y no “dése cuenta”.

En el juicio sumario se le otorga una especial competencia al tribunal de alzada, sus facultades son más amplias que la competencia normal (artículo 692).

Tratándose del recurso de apelación, el tribunal de alzada podrá fallar y pronunciarse sobre las cuestiones ventiladas y resueltas en primera instancia, puede también excepcionalmente pronunciarse sobre cuestiones no resueltas en primera instancia, pero que no fueron resueltas por ser incompatibles. Este principio se produce, porque el principio de la doble instancia significa que el tribunal revisa lo resuelto anteriormente, para que no sea un tribunal de primera instancia. Si el tribunal de primera instancia no resuelve una cuestión que debió conocer, el fallo es vicioso y puede llegar a anularse por la vía de la casación en la forma, por falta de decisión del asunto controvertido; aún cuando, a título muy excepcional, el tribunal de segunda instancia puede ordenar que se complete el fallo.

En homenaje a la brevedad y para que no se produzca la nulidad del fallo de primera instancia y por la demora que significaría devolverlo a primera instancia para que lo completen, en el juicio sumario hay una regla excepcional, que permite que el tribunal de segunda instancia puede pronunciarse sobre toda cuestión ventilada, aunque no haya sido resuelta, sin que importe si no fue resuelta por incompatible o por error.

En consecuencia, **en este caso y tratándose del juicio sumario, el tribunal de alzada pasa a fallar respecto de cuestiones ventiladas y no resueltas como tribunal de única instancia, lo que la ley expresamente permite.**

Unidad 8: Juicio Ejecutivo de Mayor Cuantía.

Este juicio especial es de aplicación general. No existe el juicio ejecutivo de menor cuantía, de manera tal que se tramitan bajo este procedimiento los asuntos de mayor y de menor cuantía. Si hay contemplado por el legislador el juicio ejecutivo de mínima cuantía.

La razón de ser del juicio ejecutivo es que, cuando una persona pretende el pago de una obligación, el tribunal normalmente estará en situación de duda respecto de la existencia, monto y exigibilidad de la obligación porque normalmente, frente a la pretensión de pago del acreedor, surgirá la contrapretensión del deudor de no deber aquella cantidad, de deber una cantidad inferior o de que la obligación no es exigible.

Cuando el tribunal está en situación de duda respecto de la existencia de la obligación, del monto de la obligación o de la exigibilidad de la misma, será necesario un procedimiento declarativo, de más o menos lato desarrollo, en el cual en la sentencia definitiva se declare efectivamente la existencia o inexistencia de la obligación, monto y pronunciamiento respecto de su exigibilidad.

Si los antecedentes que apareja el acreedor, llevan al tribunal en un examen *prima facie*, que la obligación efectivamente existe, que su monto está determinado y que esta obligación es exigible, y todos estos antecedentes constan de un título ejecutivo, se puede iniciar el denominado procedimiento ejecutivo; o sea, dicho de otra manera, el procedimiento ejecutivo arranca de la convicción promovida al tribunal, en virtud de un antecedente que es de especial rigor, denominado título ejecutivo, que determina que la obligación existe, cual es el monto y que efectivamente es exigible.

En consecuencia, la génesis misma del juicio ejecutivo indudablemente se vincula con los principios de la prueba, porque en el fondo el título ejecutivo produce *prima facie* en el tribunal aquel grado de convicción necesaria, en torno a estos tres aspectos que son: existencia, monto y exigibilidad de la obligación.

Tema 1: Características del juicio ejecutivo.

1.1 El procedimiento ejecutivo es rápido y concentrado. Si uno compara la estructura del juicio ordinario de mayor cuantía con el procedimiento ejecutivo, va a ver que en este último hay una serie de simplificaciones en cuanto a los trámites y también el acortamiento de los plazos procesales, lo que naturalmente acarrea mayor rapidez y eficacia de este procedimiento.

1.2 Iniciado que sea el juicio ejecutivo se decreta, necesariamente y desde luego, respecto del deudor una medida específica, que es una medida de carácter

cautelar y que se denomina el embargo. Esto es aplicable en el juicio ejecutivo por obligación de dar, donde se produce este fenómeno del embargo, pero no respecto del juicio ejecutivo por obligación de hacer o de no hacer, que también contiene el requerimiento sobre el deudor, pero que no se traduce en un embargo.

El embargo es una institución de gran importancia y jerarquía, y que tiene una serie de consecuencias, tanto dentro del proceso como extraprocesales.

El embargo es una medida de carácter cautelar, o sea tiene por objeto asegurar el resultado, es decir, que cuando efectivamente se ordene el pago de la obligación haya bienes suficientes para responder a dicha orden.

Lo que es determinante en cuanto a su diferenciación con las demás medidas cautelares, es que estas, como regla muy general, son eventuales en el sentido que el tribunal las puede ordenar o no de acuerdo a las circunstancias; en tanto que la medida cautelar de embargo procede necesariamente cuando el tribunal estima que se enfrenta a un título ejecutivo y se reúnen ciertas y determinadas condiciones de certeza.

El embargo no importa ni gravamen, ni mucho menos, pérdida del dominio respecto del bien, o sea, el bien no obstante su embargo continua en el patrimonio del deudor y además no altera sus situación, ni se entiende que el embargo sea forma de prenda, de hipoteca o de cualquier otra preferencia; dicho de otra manera, el embargo no constituye al acreedor en cuyo beneficio se traba, en acreedor preferente, su calidad de acreedor preferente o valista, derivará de circunstancias substanciales, pero no del hecho que haya o no embargo.

El embargo trae como consecuencia, como regla muy general, que el deudor pierde la administración del bien embargado, y la administración de este bien, con toda la responsabilidad que esto trae, pasa al depositario. Esta es una institución que tiene similitudes con la medida prejudicial precautoria, pero que tiene características muy propias y distintas. Este depositario, puede ser provisional o definitivo.

En virtud del embargo, también se entiende que los bienes objetos del embargo quedan adscritos al cumplimiento de la obligación, o sea, se ve que este conjunto de bienes embargados queda ligado al cumplimiento de la obligación; y efectivamente cuando sobreviene la necesidad de hacer el pago, es precisamente sobre los bienes embargados que se desencadena todo un procedimiento de realización de los bienes.

En virtud del embargo, los bienes son sustraídos del comercio humano. Aplicando el art. 1464 C.C., hay objeto ilícito en la enajenación de bienes embargados, a menos que el juez que ordenó el embargo lo autorice.

Son cosas distintas la enajenación de un bien y el título translativo de un bien; en nuestro derecho, para que se produzca la transferencia de dominio se requiere título y modo de adquirir, y aquí está el énfasis en cuanto a que el objeto ilícito se refiere a la transferencia, o sea, al modo de adquirir.

La pregunta que cabe, es sí al título translativo del bien embargado le alcanza o no este efecto de nulidad por objeto ilícito. En este caso, el efecto se proyecta al título translativo de dominio, cuando este título es una compraventa o una permuta.

La sanción de nulidad como sanción que es, es de derecho estricto y en consecuencia será nula la compraventa por mandato expreso de la ley, será nula la permuta por remisión, pero no los otros títulos translativos, sin perjuicio que la transferencia no se pueda realizar (Profesor).

El embargo, para que produzca efectos respecto de terceros, debe cumplir ciertas medidas de publicidad, y particularmente cuando se trata de bienes raíces, y en general, bienes sujetos al sistema de inscripción. Los registros conservatorios respectivos, específicamente el Conservador de Bienes Raíces, dentro de sus tres libros matrices, lleva uno que se llama “Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar”, y entre ellas se encuentra el embargo; por lo tanto, para que la medida sea oponible en relación con terceros, debe inscribirse en el registro respectivo.

1.3 Posibilidades particularmente restringidas de defensa para el ejecutado. El legislador naturalmente determinó que, si ya se ha iniciado juicio ejecutivo, frente a los antecedentes que *prima facie* producen este grado de convicción necesaria respecto de la existencia, monto y exigibilidad de la obligación, mira con recelo al deudor que todavía se rehúsa a pagar la obligación.

El legislador lo mira con particular desconfianza y esta se traduce en que:

- a) El contradictorio paritario se quiebra en beneficio del acreedor, así en el posible período de discusión, los escritos fundamentales del acreedor son dos (la demanda y el escrito que responde frente a las excepciones), en tanto que la posibilidades de defensa del deudor es solo el escrito de excepciones.
- b) En el escrito de excepciones del deudor, éste debe oponerlas todas, y en tal sentido el legislador, para este efecto procesal de oponerlas todas, no distingue entre excepciones dilatorias, perentorias, mixtas o anómalas.
- c) Haciendo excepción a la regla general, el deudor en su escrito de excepciones debe anunciar los medios probatorios de los cuales se valdrá, y si no hace este anuncio, se entiende que renuncia a la prueba.
- d) Si el deudor no opone excepciones en tiempo y forma, se omite la sentencia definitiva y el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva, para el efecto de la realización de los bienes embargados.
- e) Las apelaciones que hace el deudor, siempre se conceden en el solo efecto devolutivo.

Así, el deudor está claramente en una situación de desventaja frente a su acreedor, precisamente por la fuerza de convicción del título que ha aparejado el acreedor.

Tema 2: Estructura del juicio ejecutivo.

La estructura del juicio ejecutivo es muy distinta a la del juicio ordinario de mayor cuantía, y en general a la de los procedimientos declarativos.

El juicio ejecutivo, necesariamente, debe tramitarse en dos cuadernos, y es posible que surjan otros cuadernos. Los dos cuadernos necesarios del juicio ejecutivo son:

2.1 Cuaderno principal o ejecutivo: Se puede producir la discusión sobre la existencia, monto y exigibilidad de la obligación en caso que el deudor haya opuesto excepciones de fondo y forma.

Este terminará con la sentencia ejecutoriada que se pronuncie sobre estos extremos; sentencia que podrá ser de primera y única instancia, o de segunda instancia, o sentencia de casación. En este cuaderno se produce la fase de discusión y descripción.

El cuaderno principal normalmente se inicia con la demanda ejecutiva, a la cual se apareja el respectivo título, y si efectivamente se prueba que el título es ejecutivo, que la obligación es líquida y actualmente exigible y que la acción ejecutiva no se encuentra prescrita, el tribunal proveerá la demanda ejecutiva con una palabra de explosiva consecuencia: “despáchese”, gatillándose el inicio del cuaderno de apremio.

Es posible también que este cuaderno se inicie anteladamente con gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, porque tratándose de títulos ejecutivos es posible distinguir entre títulos ejecutivos perfectos y título ejecutivos imperfectos, y este último se puede convertir en perfecto en virtud de una gestión previa, que se denomina “gestión preparatoria de la vía ejecutiva”. Esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es el antecedente del cuaderno principal o ejecutivo; si efectivamente se perfecciona el título, este cuaderno ejecutivo se produce o forma a partir de esta gestión preparatoria, en el mismo ramo o cuerda.

2.2 Cuaderno de apremio: Este se inicia con el mandamiento; tratándose de una obligación de dar, el mandamiento se denomina “mandamiento de ejecución y embargo”, y tratándose de una obligación de hacer o no hacer, el mandamiento tiene características propias, pero la regla general es que nos encontremos frente a una obligación de dar.

La actuación de fojas uno del cuaderno de apremio contiene la orden de requerir al deudor de pago, y si no paga en el acto del requerimiento, de inmediato procede la orden del embargo de sus bienes en cantidad suficiente para hacer completo pago de la respectiva obligación.

Como un recuerdo de carácter histórico, pero que en Chile se aplicó hasta el siglo XIX, recordemos que las medidas de apremio respecto del deudor abarcaba también a la persona de este, y en la vieja

legislación (antes de las leyes marianas) si el deudor no pagaba en el acto era reducido a prisión. Hoy día, sólo el deudor responde por su patrimonio en virtud del principio de prenda general.

Este cuaderno de apremio nace con el mandamiento de ejecución y embargo, sigue naturalmente con el embargo con todas las cuestiones que puedan suscitarse en torno a este, como son la ampliación, la rendición, la sustitución del embargo y con todo aquello que tenga que ver con la administración del embargo; y en su momento, este cuaderno de apremio contempla todo lo que se vincule a la realización de los bienes para el debido pago de la respectiva obligación.

La regla general es que la realización de los bienes embargados, salvo situaciones muy excepcionales, sólo se inicia cuando no se han opuesto excepciones o bien cuando estas excepciones han sido desechadas por sentencia de primera instancia, que en el juicio ejecutivo causa ejecutoria; hasta ese instante no se inicia propiamente la realización de los bienes embargados.

Además de estos dos cuadernos, pueden surgir en este juicio ejecutivo, lo que es de frecuente ocurrencia, los llamados cuadernos de tercería, que recogen la intervención de terceros que de alguna manera se vinculan al juicio ejecutivo por tener un determinado interés comprometido. Estas posibles tercerías del juicio ejecutivo, que se traducen en los respectivos cuadernos son cuatro:

- tercería de dominio;
- tercería de prelación;
- tercería de pago;
- tercería de posesión.

Estas tercerías tienen reglas procedimentales especiales, se tramitan todas ellas en cuaderno separado, pero su regulación en cuanto al procedimiento es distinta. La tercería de dominio se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, prescindiendo solo de los escritos de réplica y dúplica, en tanto que las otras tres se tramitan conforme las reglas de los incidentes.

El tercerista de dominio pretende en general, salvo situaciones muy particulares y excepcionales, dominio sobre el bien o los bienes embargados o alguno de ellos. Esto se basa en el principio elemental, de que el derecho de prenda general recae sólo sobre los bienes del deudor, pero no sobre los bienes de terceros; de manera que si inadvertidamente o de mala fe, se han embargado bienes de dominio de un tercero, este tercero puede reclamar esta circunstancia y solicitar el aislamiento del daño diciendo que el bien es de su dominio y no del deudor. Como la discusión sobre la propiedad o dominio de un bien es una cuestión difícil y complicada, se tramita esta tercería de acuerdo a las normas del juicio ordinario de mayor cuantía, de lato conocimiento, salvo los escritos de réplica y dúplica.

El tercerista de prelación, invoca el título preferente en relación con el ejecutante; el tercerista de prelación, ya sea porque su preferencia deriva del bien embargado, ya sea porque su preferencia deriva de una situación general respecto del todo el patrimonio del deudor, dice “yo primero”, o sea, “usted

esta embargando bienes para pagarse y usted es un acreedor valista o acreedor de preferencia menor a la mía, yo me pago primero”.

El tercerista de pago no pretende una situación preferida, sino que frente a la circunstancia de que no hay otros bienes del deudor fuera de los embargados y el también es el acreedor, pretende pagarse a prorrata, en la misma forma o proporción, que el embargante o ejecutante; en consecuencia el tercerista de pago dice “yo también”.

La tercería de posesión, es una institución que nació por la vía jurisprudencial frente al hecho que la tercería de dominio era particularmente exigente, y la jurisprudencia empezó a ver ciertas y determinadas situaciones en donde era de manifiesta injusticia exigirle a quien se le habían embargado bienes que estaban en su posesión, que intentara acreditar el dominio de dichos bienes, cuando la posesión era evidentemente muy fácil de acreditar. Esta realidad jurisprudencial fue posteriormente recogida legislativamente, y hoy día la tercería de posesión se encuentra expresamente regulada por el Código de Procedimiento Civil.

En el juicio ejecutivo se pueden producir muchos otros cuadernos fuera de estos específicos, porque a su respecto también son aplicables la reglas generales de tramitación de incidentes, y en consecuencia todos los incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento y que por mandato legal deban tramitarse en cuaderno separado, producen también los cuadernos separados correspondientes; de manera que en la vida real, un juicio ejecutivo puede convertirse en un verdadero racimo con dos cuadernos necesarios, dos o tres tercerías más, y un número indeterminado de incidentes.

Tema 3: Normas aplicables al juicio ejecutivo.

El título primero, que es el más extenso, se refiere al juicio ejecutivo de mayor o menor cuantía por obligación de dar, y el título segundo se refiere al juicio ejecutivo por obligación de hacer y por obligación de no hacer. Además, se regula el juicio ejecutivo por las reglas comunes a todo procedimiento del C.P.C., las cuales en su art. 3 se remiten al juicio ordinario de mayor cuantía, y así también pasa a ser norma supletoria del juicio ejecutivo.

En definitiva, en el orden de prelación, son normas que regulan al juicio ejecutivo:

- las reglas propias contenidas en el Título I y II del Libro III del C.P.C.;
- las reglas comunes a todo procedimiento;
- las reglas de juicio ordinario de mayor cuantía, como normativa de carácter supletorio.

Tema 4: Clasificación de los juicios ejecutivos.

4.1 Según la naturaleza de la obligación cuyo pago se persigue:

a) Juicio ejecutivo por obligación de dar: Se entiende que cuando hablamos de obligación de dar, nos referimos tanto a la obligación propiamente de dar como a la de entregar, o sea, lo normal será que la entrega sea título translativo de dominio, es decir, forma de tradición, pero también se puede perseguir ejecutivamente una obligación de entregar que no sea traslativa de dominio.

La obligación de dar o entregar, se puede referir a una cantidad de dinero, que será la situación más frecuente; pero puede también referirse a una especie o cuerpo cierto, o tener como objeto una cantidad de un género determinado. Dicho de otra manera, en el juicio ejecutivo por obligación de dar se puede pretender que se pague una cantidad de dinero, o que se entregue la especie o cuerpo cierto debida, y por último, también se puede perseguir una cantidad de un género determinado.

b) Juicio ejecutivo por obligación de hacer: Esta obligación puede tener dos objetivos perfectamente distintos: la obligación de suscribir un instrumento, o la obligación de realizar una obra material. Según sea la naturaleza de la obra, será el procedimiento respectivo para su cumplimiento.

c) Juicio ejecutivo por obligación de no hacer: Se puede perseguir ejecutivamente una obligación de no hacer, y esto ocurre cuando el deudor se ha obligado a una determinada abstención, y no obstante esta obligación suya, realiza la obra prohibida, quebrantando su obligación. En tal evento, y concurriendo ciertas y determinadas circunstancias, la obligación de no hacer se enmarca en la destrucción de la obra, con cargo al patrimonio del deudor que quebranta la obligación.

Tratándose de estos distintos tipos de juicio ejecutivo, ya sea obligación de dar, hacer, o no hacer, en todos ellos puede ser muy similar el cuaderno ejecutivo, porque ahí se discutirá la existencia o la inexistencia de la obligación; pero lo que cambiará fundamentalmente, según el tipo de obligación es el cuaderno de apremio, que tiene características propias desde el inicio mismo del juicio, porque el cuaderno de apremio según la naturaleza de la obligación perseguida será distinto.

4.2 Atendiendo a la cuantía.

a) Juicio ejecutivo mayor y menor cuantía

b) Juicio ejecutivo mínima cuantía.

Se trata conjuntamente el juicio ejecutivo de mayor y menor cuantía porque tienen igual procedimiento; no hay un juicio ejecutivo de menor cuantía, pero si hay un juicio ejecutivo de mínima cuantía, que está regulado en los arts. 703 y ss. C.P.C.

4.3 Atendiendo a su regulación.

a) juicios ejecutivos comunes: Este juicio es el que, de acuerdo con su naturaleza, se encuentra regulado en el C.P.C.

b) Juicios ejecutivos especiales: Existen juicios ejecutivos especiales, en donde los tramites son fundamentalmente más concentrados, las posibilidades de defensa del deudor también suelen ser bastante más reducidas y los procedimientos de apremio y realización son normalmente explosivamente rápidos. Ejemplos de estos juicios ejecutivos especiales son:

- Juicios de Cobro de Impuestos, en donde el ejecutante es el Fisco y se tramitan por un tribunal especial, que es el tribunal de la Tesorería General o Regional de la República.
- Juicio Hipotecario Especial, está establecido para ciertas y determinadas obligaciones hipotecarias que se contraen con los bancos u otras instituciones financieras.
- Juicio de Liquidación de la Prenda Industrial.
- Juicio de Realización de Acciones dadas en Prenda a favor de los Bancos.

Todos estos juicios ejecutivos especiales, se regulan primero por la normativa propia y subsidiariamente se van regulando por el juicio ejecutivo del C.P.C. que corresponda, por las reglas comunes a todo procedimiento, y por último, por el juicio ordinario de mayor cuantía.

Unidad 9: Juicio Ejecutivo por Obligación de Dar.



Se encuentra regulado en el **Título I del libro III del C.P.C.**

La obligación de dar, puede ser propiamente dar en cuanto signifique transferencia de dominio, como puede ser simplemente de entregar.

Este juicio es la matriz de todos los juicios ejecutivos, y los demás son variaciones más o menos profundas respecto del juicio ejecutivo por obligación de dar.

Tema 1: Presupuestos

Este juicio requiere cuatro presupuestos indispensables, los cuales deben concurrir copulativamente:

a) Que el acreedor se encuentre premunido de un título ejecutivo:

El título ejecutivo es un instrumento o una actuación a la cual la ley le otorga *prima facie* el mérito de acreditar indubitadamente la existencia de una obligación.

De este concepto arranca una primera e importantísima consecuencia, que la calificación de título ejecutivo emana sólo y exclusivamente de la ley, o sea, no hay otros títulos ejecutivos que los que el legislador expresa y taxativamente indica. Ni la voluntad de las partes, ni la sentencia judicial, ni ninguna otra fuente es creadora de títulos ejecutivos.

El título ejecutivo puede ser un instrumento o una actuación; lo normal es que sea un instrumento que emane del pretendido deudor, como por ejemplo, una letra aceptada por el deudor, una escritura pública suscrita por el deudor, un pagare, un cheque girado por el deudor; pero también el título ejecutivo puede ser una actuación, como por ejemplo, la sentencia firme o ejecutoriada que declara la existencia de una obligación.

El mérito o virtud del título ejecutivo es que con su simple examen, *prima facie*, a primera vista aparezca indubitada la existencia de una obligación. Esto significa una fuerza de convicción de tal envergadura, que efectivamente el tribunal al examinarlo concluya que la obligación existe. Es por esta razón que el concepto de título ejecutivo, se vincula con aquel de prueba legal, porque efectivamente esta fuerza de convicción arranca del mérito probatorio que de él emana respecto de la obligación que se persigue.

b) Que la obligación que se persiga sea líquida:

Para este efecto el legislador ha señalado cuando se entiende que una obligación es líquida. Es, por ejemplo, líquida la obligación respecto de una especie o cuerpo cierto determinado, la cantidad de un género determinado, y con mayor razón es líquida una cantidad de dinero debida.

Se entiende que una obligación es líquida cuando es liquidable, en virtud de simples operaciones aritméticas con el solo mérito de los datos que proporcione el título.

c) Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita:

El legislador distingue claramente entre acción ordinaria y acción ejecutiva, fijando plazos distintos para cada una; dicho de otra manera, en general los plazos de prescripción de la acción ejecutiva son sustancialmente menores que los plazos de prescripción de la acción ordinaria, y así por ejemplo una obligación en un momento determinado podrá ser perseguida por la vía ejecutiva, si la acción ejecutiva no está prescrita, y podrá ser perseguida también por la vía ordinaria si la acción ejecutiva está prescrita, pero aún no ha prescrito la vía ordinaria.

La prescripción de la acción ejecutiva debe declararla de oficio el tribunal, si efectivamente constata que el plazo de prescripción se ha completado, y su declaración aparece nítida por la circunstancia de negar despachar mandamiento de ejecución de embargo, o sea, si efectivamente el tribunal estima que la acción ejecutiva se encuentra prescrita, debe negar despachar mandamiento de ejecución y embargo.

d) Que la obligación sea actualmente exigible:

Lo que significa que no esté diferido su cumplimiento en virtud de una modalidad; las modalidades son varias, y las más corrientes son la condición y el plazo. Así, si hay una condición que difiere el cumplimiento de una obligación o hay un plazo pendiente, la obligación no será actualmente exigible, salvo naturalmente que se alegue el cumplimiento de la condición o haber esta fallado o, en ciertas y determinadas ocasiones, la caducidad del plazo.

Tema 2: Títulos ejecutivos

La única fuente del título ejecutivo es la ley; la sentencia no puede convertir en título ejecutivo lo que la ley no ha incluido en su enumeración.

Puede surgir la interrogante si frente a un título ejecutivo el acreedor puede renunciar a la vía ejecutiva; aunque la cuestión es dudosa y opinable, se puede pensar que es lícito que el acreedor renuncie al título ejecutivo, y en consecuencia opte por discutir la cuestión en un procedimiento lato.

Esta posición se ve reforzada por la existencia en el juicio ejecutivo de la institución que se denomina la reserva de acciones, ya que precisamente la reserva de acciones, en ciertas y determinadas situaciones, es el abandono de la vía ejecutiva para reservarse la vía ordinaria; por lo tanto, si esto es lícito ya iniciado el procedimiento, con mayor razón es lícito realizar esta renuncia anteladamente (Profesor).

2.1 Clasificación de los títulos ejecutivos.

1º Título ejecutivo perfecto o completo: es aquel que sin ninguna tramitación o actuación a su respecto tiene la calidad de tal; por ejemplo, la copia autorizada de una escritura pública, o una sentencia firme o ejecutoriada.

2º Título ejecutivo imperfecto o incompleto: son aquellos que requieren de un tramitación u actuación previa para adquirir precisamente el carácter de título ejecutivo; por ejemplo, un documento privado del

cual consta una obligación, o una letra de cambio que no ha sido autorizada ante notario, o un pagaré que no ha sido autorizado ante notario.

Esta tramitación o actuación no necesariamente es una tramitación o actuación jurisdiccional, lo normal es que así sea, pero hay otras actuaciones o tramitaciones no jurisdiccionales que convierten al título ejecutivo imperfecto en título ejecutivo perfecto.

Cuando se trata de un título ejecutivo imperfecto y se requiere una tramitación jurisdiccional para que dicho título se convierta en perfecto, se dice de “gestión preparatoria de la vía ejecutiva”, que es una gestión jurisdiccional y contenciosa; de acuerdo con las normas de la competencia, el tribunal que conoció de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es también el tribunal competente para conocer de la demanda ejecutiva. Cuando hay gestión preparatoria de la vía ejecutiva, el cuaderno ejecutivo nace con la gestión preparatoria y se continúa después de la gestión preparatoria con la acción ejecutiva propiamente tal.

Los títulos ejecutivos de que trata el C.P.C., se encuentran enumerados taxativamente, salvo una referencia de carácter genérico, en el art. 434 C.P.C. Este art. 434, de alguna manera subraya el carácter de enumeración taxativa que realiza, especialmente en su inciso primero en la frase “alguno de los siguientes títulos”.

Tema 3: Análisis del artículo 434.

Artículo 434: ***El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos:***

1° Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria;

Es particularmente importante destacar que el carácter de título ejecutivo lo puede adquirir tanto la sentencia definitiva como la sentencia interlocutoria, pero no tienen este carácter los autos o los decretos.

La sentencia definitiva o interlocutoria de que se trata, debe declarar la existencia de una obligación, y precisamente por esta declaración se convertirá en título ejecutivo.

Es importante destacar que esta norma le da sólo el carácter de título ejecutivo a la sentencia definitiva o interlocutoria firme. Cuando se habla de sentencia firme, es igual que decir sentencia ejecutoriada, y en este caso nos estamos remitiendo al art. 174 C.P.C., que señala cuando una sentencia se entiende firme o ejecutoriada.

El art. 174 establece que hay que hacer como primera distinción, si caben o no recursos; si no caben recursos, la sentencia se entiende firme o ejecutoriada cuando se encuentra notificada a ambas partes. Si caben recursos hay que hacer una nueva distinción: si no se interpusieron en tiempo y forma, la

sentencia se encuentra firme o ejecutoriada desde que se cumplieron los plazos para interponerlos; pero si los recursos se interpusieron en tiempo y forma, la sentencia se entiende firme desde que fallados o extinguidos los recursos vuelven los autos al tribunal de primera instancia y se estampa el “cúmplase”, y se notifica esta cúmplase a las partes.

Dentro del C.P.C., en la sistemática general, hay una distinción fundamental, que es aquella que distingue entre sentencia firme o ejecutoriada y aquella sentencia que causa ejecutoria. La sentencia firme o ejecutoriada tiene el carácter de inimpugnable e inmodificable; en cambio la sentencia que causa ejecutoria es aquella que no obstante la existencia de recursos procesales pendientes puede ser cumplida, esto ocurre cuando respecto de aquella sentencia se ha otorgado el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, o bien cuando respecto de aquella sentencia se ha interpuesto recursos de casación y este recurso no suspende el cumplimiento del fallo.

Es muy importante destacar que la sentencia que causa ejecutoria no cabe dentro de la sistemática de este N°1 del art. 434 C.P.C., pero la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime han sostenido que la sentencia que causa ejecutoria cabe dentro del N° 7 de este artículo, que se refiere a todos los otros títulos a los que la ley les reconoce el carácter de ejecutivo, ósea, hay una remisión a la norma legal que precisamente reconozca el carácter ejecutivo de cualquier otro título.

Es importante señalar, que la circunstancia que se entienda que la sentencia firme o ejecutoriada constituya título ejecutivo, habilita al acreedor para iniciar la acción ejecutiva respectiva, y en tal evento obtendrá copia autorizada de la sentencia aparejada del correspondiente certificado de ejecutoria, y podrá de esta manera autónomamente iniciar un procedimiento ejecutivo invocando como título la sentencia. Pero el ganancioso tiene un camino mucho más expedito, rápido, breve, que es “el cumplimiento incidental del fallo”; este procedimiento es en el fondo, un procedimiento ejecutivo especial particularmente concentrado, que está regulado por los arts. 233 y ss. C.P.C., y que técnicamente es un incidente que se tramita con posterioridad a la ejecutoria o causa de ejecutoria de la respectiva sentencia.

Que el acreedor opte por el juicio ejecutivo autónomo y no por el cumplimiento incidental, se debe a una razón histórica, hoy día ligeramente modificada; de acuerdo a la normativa antes vigente, el procedimiento incidental sólo se podía pedir dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, entonces bien podía ocurrir que el plazo hubiese transcurrido y en consecuencia al acreedor sólo le quedara la vía del juicio ejecutivo correspondiente.

Es importante tener presente dos reglas de competencia, que son las que están en los arts. 232 y 114 C.O.T.; en virtud de estas dos reglas, cuando el acreedor premunido de una sentencia firme o ejecutoriada inicia un juicio ejecutivo autónomo, tiene dos posibles tribunales competentes a su elección: el tribunal que dictó la sentencia en primera o en única instancia, o el tribunal que corresponda

de acuerdo a las reglas generales. En este caso hay claramente una situación de competencia preventiva, esto es, la existencia de dos o más tribunales competentes a elección del acreedor.

El cumplimiento de sentencias firme o ejecutoriada, o eventualmente cumplimiento de sentencias que causan ejecutoria, acepta una referencia a situaciones especiales:

a) El Fisco, por mandato expreso de la ley, no es sujeto posible de ejecución, o sea, respecto al Fisco si se dicta una sentencia condenatoria no es posible iniciar en su contra juicio ejecutivo, ni tampoco cumplimiento incidental del fallo. La sentencia que condena al Fisco a una determinada prestación, se cumple mediante la dictación del correspondiente decreto supremo por el Ministerio de Hacienda, y si el ministro de Hacienda no lo dicta se pone en situación de ilegalidad e inconstitucionalidad y rebeldía, con todas las consecuencias políticas que esto pueda acarrear. Esta característica respecto del Fisco, se ha ido expandiendo respecto de otras instituciones, y así encontramos algunas leyes orgánicas que no permiten el juicio ejecutivo en contra de la respectiva institución.

b) El cumplimiento de sentencias dictadas por árbitros (situación que se encuentra regulada en los art. 635 en relación con el art. 643 C.P.C.): la regla general es que para la ejecución de un sentencia arbitral, se puede acudir al mismo árbitro que la dictó con tal que su plazo no se encuentre vencido; sin embargo, si el cumplimiento de la sentencia exige un procedimiento de apremio u otras medidas compulsivas, o si afecta a terceros que no sean parte del compromiso, se debe concurrir a la justicia ordinaria. Esta norma es aplicable ya sea que se recurra al cumplimiento incidental del fallo o que se recurra a procedimiento autónomo.

2° Copia autorizada de escritura pública;

Respecto a la copia autorizada de escritura pública, hay que remitirse a los arts. 1699 C.C. y 403 C.O.T., que nos dan el concepto de escritura pública.

La escritura pública es una especie dentro del género de instrumento público y es la otorgada ante el competente notario e incorporada a su protocolo o registro.

El art. 434 N° 2 otorga el carácter de título ejecutivo a la copia autorizada de la escritura pública, no le otorga este carácter a la matriz porque la matriz debe perdurar dentro del protocolo, y en consecuencia nunca saldrá de este protocolo.

La escritura pública puede otorgarse ante notario, notario extranjero, o cónsul chileno; el C.P.C. no distingue, basta que sea copia autorizada de escritura pública.

Respecto de quien autoriza la copia respectiva, la regla general es que sea el notario u otro funcionario interviniente; excepcionalmente se pueden autorizar también, por el archivero judicial y por el archivero nacional.

Antes de una modificación al C.P.C. de 1982, se distinguía entre primeras y segundas copias; las primeras se entregaban a las partes contratantes que fueran acreedoras de obligaciones, y sólo estas constituían título ejecutivo, en tanto que las segundas se otorgaban a cualquier interesado.

3º Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizado por un ministro de fe o por dos testigos de actuación;

En este caso estamos frente a las obligaciones que pueden emanar de un acto de autocomposición provocado o espontáneo. Lo normal es que el acta de avenimiento se haga valer en acta autorizada; la simple conciliación extrajudicial (acta de avenimiento), no constituye título ejecutivo, sino que tiene que haberse otorgado ante tribunal competente.

Esta última disposición puede interpretarse en 2 sentidos:

- a) una interpretación restringida, siendo tribunal competente aquel que conocía del juicio que se aviene y respecto de las materias avenidas; y
- b) una interpretación amplia, siendo competente, cualquiera que sea la materia del avenimiento, en la medida que esa materia pudiera haber caído en su ámbito de conocimiento (Profesor).

La autorización puede ser dada por:

- a) un ministro de fe, que será lo normal, en aplicación del art. 61 C.P.C.; o dos testigos de actuación; en este caso, lo normal es que se presente frente a tribunales arbitrales, y en relación con árbitros arbitradores que no actúan con ministro de fe, pero también puede tratarse de un acta ante un tribunal ordinario.

4º Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario;"

Los tres primeros números de este artículo, se refieren a instrumentos públicos, aquí en cambio, estamos frente a instrumentos privados, que no tienen en sí mismo, *prima facie*, valor indubitable; y por esto es que el legislador tuvo que ocuparse en forma minuciosa de cuando el instrumento privado es título ejecutivo perfecto o cuando puede adquirir este carácter.

Los instrumentos privados que pueden ser títulos ejecutivos perfectos sin necesidad de preparación son: las letras, pagarés y cheques.

Los instrumentos privados propiamente tales, son cualquier tipo de instrumento firmado por el pretendido deudor, que da testimonio de una obligación, y que no sea ni letra, ni cheque, ni pagaré. Estos, no son nunca título ejecutivo perfecto, se requiere siempre en relación con ellos una gestión preparatoria, aunque este instrumento privado se encuentre autorizado ante notario.

La letra de cambio, el pagaré y el cheque, se engloban bajo una denominación común: título de crédito. El cheque, no es propiamente título de crédito, pero se regula subsidiariamente a sus normas propias, por las normas de la letra de cambio, y es por esto que el legislador los trata conjuntamente.

A. Instrumento privado propiamente tal.

Es un escrito otorgado sin solemnidades, pero firmado por el pretendido deudor, y que da testimonio de una obligación.

La exigencia de la firma está en los arts. 435 y 436, que convierten al instrumento privado en título ejecutivo cuando media reconocimiento expreso o tácito de la firma. Se tiene por preparado el título ejecutivo, y se convierte en perfecto, cuando se cita a presencia judicial a la persona que se pretende firmó el escrito. Al efecto, el tribunal fija una audiencia, y al demandado se le notifica personalmente o por el art. 44. El día de la audiencia, se le hace comparecer ante el tribunal, y el juez personalmente le pregunta si es suya la firma del instrumento (gestión bajo juramento).

Las posibles conductas del notificado son:

- a) No concurre a la audiencia. En este caso se le tiene por reconocida la firma; esta es una citación única. El tribunal dictará una resolución teniendo por reconocida la firma.
- b) Comparece y reconoce como suya la firma. Se tiene por preparada la vía ejecutiva y por perfeccionado el instrumento, aunque niegue la obligación. En este caso no se requiere resolución judicial.
- c) Comparece y da respuestas evasivas. También en este caso el tribunal lo tiene por confeso, se tiene por suya la firma y preparada la vía ejecutiva. Aquí nuevamente es necesaria la resolución judicial.
- d) Si comparece y niega la firma. La gestión preparatoria fracasa irreversiblemente, y al pretendido acreedor sólo le queda la vía del juicio declarativo que corresponda.

Esta es una gestión pura y simple y de muy expedito desarrollo; el acreedor puede estar presente en el acto, pero no tiene derecho a contrainterrogar ni realizar gestión alguna respecto del pretendido deudor.

B. Letra de cambio, pagaré y cheques.

B.1) LETRA DE CAMBIO.

En la letra de cambio intervienen tres personas necesariamente, pudiendo intervenir otras. Estas tres personas son: el girador o librador; el girado o librado, que cuando acepta el encargo se convierte en aceptante, y el beneficiario. Pero también pueden intervenir otras personas:

i) **El avalista:** es quien se constituye en codeudor solidario de la obligación de pagar. No están limitados en el número.

ii) **Los endosantes:** el primer posible endosante es el propio beneficiario, que puede hacer circular este instrumento de crédito entregándoselo a un tercero; y este tercero puede hacerlo circular con un endoso. Así, puede tener número ilimitado de endosos, agregándose, en caso necesario, un volante para poder seguir haciendo endosos.

Por expreso mandato de la ley, todos los intervinientes son solidariamente responsables frente a su tenedor: cada uno de los endosantes (beneficiario), el girador y el aceptante. De este documento nace un sinnúmero de acciones de cobro para hacer efectivo el pago de una deuda.

Cuando llega su vencimiento y el librado no paga, el tenedor del documento puede requerir su protesto; actuación esta que debe realizarse por un notario público o por un oficial del registro civil en las comunas en que no haya notario.

La gestión de protesto, consiste en que el notario, o en subsidio el oficial del registro civil, va con la letra donde el aceptante y lo requiere para que pague. Si no lo encuentra, deja testimonio de que lo buscó, y requiere de pago al tesorero municipal en su ausencia y levanta acta de protesto. Así es posible distinguir dos clases de protesto: personal y no personal.

Respecto de qué ocurre con la letra de cambio cuando ha sido protestada, hay que distinguir en relación de quien se trate:

a) El aceptante: La letra de cambio adquiere carácter de título ejecutivo perfecto respecto del aceptante:

- i) Se le protesta personalmente y en el acto de protesto no opone tacha de falsedad a su firma.
- ii) Se le notifica judicialmente el protesto de la letra, en una gestión judicial preparatoria de la vía ejecutiva, y no opone tacha de falsedad dentro de tercero día.
- iii) Si su firma ha sido autorizada ante notario, y al efecto el notario pone un atestado en la letra misma en el que autoriza la firma; en este caso es título ejecutivo sin necesidad de protesto.

Si sobreviene tacha de falsedad:

- i) Si el protesto es personal y en el acto del protesto el aceptante tacha de falsa la firma, fracasa irreversiblemente la gestión y la letra no se convertirá en título ejecutivo. Pero en virtud de una modificación relativamente reciente, esta conducta es sancionada penalmente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 110 de la ley sobre letras y pagares.
- ii) Si se notifica judicialmente el protesto se convierte en título ejecutivo si no se opone tacha de falsedad dentro de tercero día. Ahora, en virtud de lo establecido en el art. 111 de la ley sobre letras y pagares, se puede probar incidentalmente la autenticidad de la firma, y en consecuencia fallado que sea ese

incidente declarando la autenticidad de la firma la letra se convierte también en título ejecutivo perfecto.

Este art. 111 se refiere en general al N° 4 inciso 1º del artículo 434, y en una lectura rápida podría entenderse que también es posible probar incidentalmente la autenticidad de la firma cuando el protesto es personal y se tacha de falso; pero la verdad es que no es posible, porque si la norma dice que esta tacha de falsedad provocará un incidente, tiene que haber procedimiento judicial previo para que de pie a la existencia de éste, y el proceso judicial previo será la gestión preparatoria para la vía ejecutiva por notificación de protesto, lo que solo procede con el protesto no personal.

En relación a los otros obligados de la letra de cambio (avalista, endosante, girador): Respecto de ellos no cabe el protesto personal, porque ésta, que es una gestión notarial, sólo dice relación con el aceptante, en consecuencia nunca hay protesto personal respecto de los otros obligados.

La letra de cambio adquiere fuerza ejecutiva respecto de los otros obligados mediante la gestión preparatoria de notificación del protesto de letra, o sea, a los otros obligados se les notifica judicialmente que se protestó la letra respecto del aceptante. Producida que sea la notificación, el notificado tienen también un plazo de tres días para oponer tacha de falsedad; si opone tacha de falsedad a su firma, y la firma resulta autentica, incurre en responsabilidad penal de acuerdo a lo establecido en el art. 110 de la ley sobre letras y pagares, y también en este caso se puede incidentalmente acreditar la autenticidad de la firma, con lo cual, firme que sea esa resolución, la letra adquiere también mérito ejecutivo.

Respecto de los otros obligados, si su firma se encuentra autorizada ante notario, la letra es título ejecutivo perfecto en relación con el, sin necesidad de protesto. De esta manera, la autorización notarial se refiere firma a firma, y es perfectamente posible que respecto de una letra de cambio exista autorización notarial de la firma del aceptante y un endosante o de un avalista o de otro endosante, o sea pueden resultar situaciones diversas de una misma letra de cambio.

B.2) PAGARÉ.

El pagaré también es un título de crédito, pero en el pagaré idealmente sólo interviene una persona en un acto jurídico, y esa persona se denomina suscriptor.

El pagaré tiene una determinada fórmula, tiene ciertos y determinados requisitos de constitución, como fecha de expedición, cantidad debida y época o día en que debe realizarse el pago.

El pagaré puede tener un sinnúmero de otras menciones, por ejemplo, interese pactados, distintas cuotas, reajustabilidad de la obligación, cláusula de aceleración, entre otras.

El acreedor no requiere concurrir al pagaré, sino que él se queda con el pagaré. Respecto del pagaré pueden también concurrir otras personas, que son los avales y los endosantes; y al igual que en la letra de cambio, todos los concurrentes al pagaré son solidariamente responsables.

El pagaré, al igual que la letra de cambio, puede ser protestado cuando a su vencimiento el suscriptor no paga, y el protesto (que también es una gestión de carácter notarial, y que excepcionalmente realiza el oficial del registro civil), se realiza respecto del suscriptor y puede ser: personal o no personal.

El pagaré es título ejecutivo perfecto respecto del suscriptor en las mismas situaciones que es título ejecutivo perfecto la letra de cambio respecto del aceptante. También respecto del pagaré que se ha opuesto tacha de falsedad dentro de tercero día, es posible acreditar la autenticidad de la firma, y en consecuencia convertirse en título ejecutivo perfecto.

Respecto de los demás obligados por el pagaré, se aplican nuevamente las mismas reglas de la letra en relación con los otros obligados, o sea, notificación de protesto, posible tacha de falsedad, responsabilidad penal, posible incidente o sino autorización notarial.

B.3) CHEQUE

El cheque es una orden de pago emitida por un girador respecto de un banco, que es el girado o librado.

El antecedente del cheque es el contrato de cuenta corriente, que se celebra entre una persona natural o jurídica y un determinado banco donde al cliente, después de las intervenciones correspondientes, se le hace firmar el contrato de cuenta corriente con sus respectivas obligaciones; se le entrega un libretto de cheques y el girador, o sea, el cliente puede entonces girar en pago contra fondos depositados en la respectiva cuenta corriente, o contra fondos que el banco le autorice mediante la figura del sobregiro.

Además del girador en el cheque, está el beneficiario que es la persona en favor de quien se gira el cheque.

Respecto de los cheques pueden intervenir otras personas también, como el endosante, ya que el cheque, al igual que la letra y el pagaré, puede circular y en consecuencia se le va poniendo un endoso en cada una de las sucesivas entregas. Los endosantes son solidariamente responsables de la obligación del pago.

Cuando un cheque no se paga por el banco librado, el propio banco librado tiene que protestar el cheque en una actuación interna del banco, y el acta de protesto del cheque se estampa al dorso del cheque o en un volante que especialmente se le pega. La única causa por la cual se puede protestar un cheque es por negativa de pago. De esta manera, la gestión de protesto de un cheque nunca puede ser personal

respecto del girador, sino que necesariamente, como es un acto interno del banco, el girador estará siempre ausente del protesto.

Del cheque se pueden derivar responsabilidades civiles y también penales, en un delito que será denominado giro doloso de cheques.

El cheque también se puede convertir en título ejecutivo, cuando:

- a) Se notifica judicialmente el protesto, y el girador dentro del plazo de tercero día no opone tacha de falsedad.
- b) Su firma ha sido autorizada ante notario.

Respecto de los demás posibles obligados, el cheque también se convierte en título ejecutivo perfecto en las dos mismas circunstancias, o sea, cuando se notifica judicialmente el protesto al otro obligado y no opone tacha de falsedad dentro de tercero día, o cuando su firma se encuentra autorizada ante notario .

Si se opone tacha de falsedad a la firma, es posible probar incidentalmente la autenticidad de la firma, y esta interpretación arranca del art. 11 de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, que hace subsidiariamente aplicables al cheque las mismas normas de la letra de cambio, y respecto de esta, frente a la tacha de falsedad puede incidentalmente probarse su autenticidad (Profesor).

Es importante tener presente, que la indebida tacha de falsedad respecto de un cheque acarrea responsabilidad penal, pero no en virtud de las normas respecto de las letras y pagarés, sino que en virtud de la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.

Cuando se trata de letras y pagarés, la respectiva gestión preparatoria de notificación del protesto, siguiendo la regla general, se notifica personalmente; pero tratándose del cheque, el art. 41 de la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques permite la notificación sustitutiva de la personal sin necesidad de ninguna gestión previa, y en consecuencia se entiende preparada la vía ejecutiva a partir de esa forma de notificación (que en el fondo es una notificación por cédula) si no se opone tacha de falsedad dentro de tercero día.

También es título ejecutivo el cheque cuando la firma del girador o de cualquiera de los otros obligados se encuentra autorizada ante notario.

Hay ciertas y determinadas cuestiones que se han suscitado, doctrinaria y jurisprudencialmente, respecto de este numerando cuarto del art. 434:

- a) Si se está frente a un instrumento privado propiamente tal, cuya preparación para la vía ejecutiva es por reconocimiento de la firma, y la persona que firmó ha muerto, no se podrá preparar la vía ejecutiva por reconocimiento de firma citando a sus herederos, porque el reconocimiento o desconocimiento es

un acto personalísimo, porque el legislador parte del supuesto que el mejor juez para determinar la autenticidad de la firma es la persona a quien se atribuye, y en consecuencia como acto personalísimo que es no pueden ser citados los herederos.

Esta solución también es extrapolable a otras situaciones, y así por ejemplo no se puede citar al mandatario para que reconozca la firma que se le atribuye a su mandante, ni se puede citar al representante legal o curador con la misma finalidad.

b) Respecto de los demás instrumentos (letra, pagaré y cheque), también se puede preparar la vía ejecutiva, por la gestión de reconocimiento de firma, y se le aplica la misma normativa.

Respecto de un pagaré, cheque o letra cuya acción ejecutiva está prescrita, no se puede preparar la vía ejecutiva por vía del reconocimiento, reviviendo así la acción ejecutiva, porque la gestión preparatoria no revive una acción ejecutiva prescrita, en consecuencia por esta vía no se puede lograr mejorar un título que ya ha perdido su vigor (Profesor).

5º Confesión judicial.

Debería agregarse en este numeral “de una obligación”, pero el legislador habla sólo de confesión judicial.

En este caso no se refiere a la confesión provocada o espontánea en juicio, porque esa es medio de prueba; sino que a la que se refiere el legislador en este numerando, es la confesión judicial como vía preparatoria o gestión preparatoria del juicio ejecutivo.

Para preparar el título ejecutivo, se pide que el pretendido deudor sea llamado a presencia judicial, y ante el juez reconozca la obligación; al efecto se fija día y hora, y se le notifica al pretendido deudor en la forma personal o sustitutiva de la personal. Las posibles conductas del citado son:

a) No comparece: se le da por confeso de la deuda. En este caso puede haber mediado entorpecimiento.

b) Comparece y reconoce la deuda: también en este caso el título ejecutivo queda perfecto y no es necesario dictar la correspondiente resolución, basta el simple reconocimiento de la deuda.

c) Reconoce la deuda, pero alega circunstancias que la modifican: la fuente del título ejecutivo es el reconocimiento puro y simple; si el reconocimiento es complejo o calificado, no es divisible y por tanto, fracasa la gestión preparatoria.

d) Comparece y da respuestas evasivas: el tribunal calificará, en este caso, esta evasividad, y si estima que confiesa la deuda, se dicta la resolución judicial correspondiente.

e) Comparece y no reconoce la deuda: fracasa la gestión.

Se ha planteado si es posible la comparecencia escrita por el citado; la cuestión es dudosa, pero si se aceptase habría que exigir que se hiciese bajo juramento, y en este caso no podría haber mendacidad.

Es compatible exigir el reconocimiento de firma y el reconocimiento de la deuda. No hay inconveniente en citar al representante legal, al mandatario, al curador, ya que esta no es una actuación personalísima.



6º Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio; y"

Debe haber una ley especial que autorice a las instituciones a emitir estos títulos, como consecuencia de una obligación que ha contraído esta institución.

La institución emite el título y los cupones, que son arrancados de un libro llamado "libro talonario"; así en el documento hay 3 elementos: está el talón, el título y pueden surgir cupones, en la medida que la obligación pueda dividirse en cuotas de igual valor.

El acreedor que tiene el título y quiera cobrar ejecutivamente la obligación, debe realizar una gestión preparatoria de confrontación, que tiene por objeto constatar la coincidencia entre el título y los cupones, y entre el título y el talón. Si esta confrontación se realiza, y se constata esta identidad, queda preparada la vía ejecutiva, aún cuando el representante legal de la institución deudora tache de falso el título.

7º Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.

Este numerando se refiere a cualquier otro título al que la ley le reconozca la calidad de tal. Y se subraya que la única fuente posible de títulos ejecutivos es la ley.

Son ejemplos de títulos a los que la ley les da fuerza ejecutoria:

- el contrato de prenda agraria, si la firma está autorizada;
- los boletines de tesorería;
- las multas impuestas por las Superintendencias.

Tema 4: Obligación líquida

El legislador no da un concepto de obligación líquida, sino que pone algunos ejemplos de esta naturaleza, de los que se desprende lo que se debe entender por ella. Y obligación líquida es aquella que esta, *prima facie*, indubitadamente establecida en cuanto a su naturaleza y monto.

El legislador hace una enumeración, en el art. 438, sobre lo que puede recaer la ejecución, desprendiéndose de este artículo, que el objeto de la ejecución debe ser una obligación líquida.

Artículo 438 “La ejecución puede recaer:

1° “Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor;”

Si la especie o cuerpo cierto ha perecido, no hay obligación líquida, y en este caso se deberá una indemnización. Si el deudor la enajenó, como regla general no hay obligación líquida, pero si habrá, si se trata de una obligación real y el cuerpo cierto es una caución.

2° “Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su evaluación por un perito que nombrará el tribunal, y”

Si la especie o cuerpo cierto no existe en poder del deudor, debe cumplirse por equivalencia, pagando el valor de la cosa. No hay propiamente obligación líquida, pero si puede llegarse a la liquidación de la obligación, la que se obtiene mediante la evaluación de la especie o cuerpo cierto por peritos, como gestión preparatoria de la vía ejecutiva.

Gestión, que es una actividad no contradictoria, sino que el juez directamente designa a los peritos para que realicen la evaluación.

Las partes pueden controvertir esta evaluación hecha por los peritos, porque la obligación es en dinero, pero en momentos distintos:

- a) el acreedor en cuanto ésta se ponga en su conocimiento, y deberá objetarla dentro de tercero día (art. 414);
- b) el deudor puede reclamar en esta misma oportunidad, pero tiene además una segunda oportunidad, ya que puede oponer como excepción a la ejecución el exceso de evaluación (art. 464 N° 8).

3° “Sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado cuya evaluación pueda hacerse en la forma que establece el número anterior.

Se entenderá cantidad líquida, no sólo la que actualmente tenga esta calidad sino también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con sólo los datos que el mismo título ejecutivo suministre.

El acreedor expresará en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución.

Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresan en otras disposiciones de este código.”

Esta es la regla general, es decir, que la ejecución recaiga sobre la cantidad líquida de dinero o en un género determinado, cuya evaluación sea posible según el N° 2. Puede tratarse también de una

obligación liquidable, obligación que con simples operaciones aritméticas, con sólo datos que contenga la obligación, pueda entenderse como líquida.

Cuando se trata de una cantidad líquida de dinero, el título debe proporcionar dicha cantidad líquida, o por lo menos, los datos necesarios para su simple liquidación, mediante simples y rápidas operaciones aritméticas.

Esta disposición suscitó dudas y jurisprudencia en contrario, sobre la situación en que el título propiamente tal no tenía los elementos necesarios para liquidar la obligación; al efecto se dictó una ley interpretativa, la que señala que se considerarán líquidas las obligaciones en dinero, si se han pactado intereses y reajustabilidad, y se ha determinado en el título la forma de su cálculo (referencia a fuentes indubitables).

Las obligaciones en moneda extranjera, no son técnicamente obligaciones en dinero, porque el dinero es la moneda de uso corriente y con poder liberatorio en Chile. No es lo mismo obligación en moneda extranjera que obligación en dinero con reajuste en moneda extranjera; y cuando se demanda alguno de estos conceptos, el ejecutante debe acompañar el certificado de paridad bancaria.

Esta distinción, tiene importancia porque cuando termina el período de ejecución, en un caso el tribunal ordenará convertir el dinero en moneda extranjera, y en el otro caso se deberá el dinero con el reajuste en moneda extranjera.

Las obligaciones de un género determinado, también el legislador la entiende inicialmente no líquida, y en este caso hay que proceder a la evaluación por peritos, al igual que en el caso de la especie o cuerpo cierto que no está en poder del deudor. Y en este caso también, esta evaluación podrá ser impugnada por una y otra parte.

Fuera de éstas, no hay otras obligaciones líquidas, tratándose de obligaciones de dar (si hay otras obligaciones líquidas tratándose de obligaciones de hacer y de no hacer).

El art. 439 se refiere a la situación en que se persigue una obligación que es parte líquida y parte ilíquida, en este caso, prescribe la ley, el acreedor podrá iniciar juicio ejecutivo por la parte líquida, quedando reservada la acción por la vía ordinaria por la parte ilíquida.

4.1 Obligación actualmente exigible.

Es aquella cuyo cumplimiento no está supeditado a una condición, o a un plazo, o a un modo; lo que no significa que la obligación deba ser necesariamente pura y simple, ya que es posible que la obligación haya estado supeditada a una modalidad, y esta se haya cumplido a favor del acreedor.

La cláusula de aceleración, es una estipulación que se contienen en el título respectivo, en virtud de las cuales el acreedor puede cobrar anticipadamente la obligación; cuando opera esta cláusula, se entiende que el plazo se ha extinguido y la obligación se hace actualmente exigible.

Tema 5: Acción ejecutiva no prescrita.



Observación

El art. 442 C.P.C. y el art. 2515 C.C., distinguen entre la prescripción de la acción ejecutiva y la prescripción de la acción ordinaria. Estos artículos señalan que la acción ejecutiva prescribe en 3 años contados desde su exigibilidad, y la acción ordinaria en 5 años.

El art. 2515 señala que la acción ordinaria, como regla general, prescribe a los 5 años, de suerte que, hay un lapso en que se encuentra prescrita la acción ejecutiva pero vigente la acción ordinaria, y este lapso es de 2 años. Durante este lapso, se puede cobrar la obligación por la vía ordinaria, pero el legislador señala una situación privilegiada, en el sentido que por este termino de supervivencia de 2 años, se puede ejecutar la acción en juicio sumario (artículo 680 N° 7).

Cuando se completa el plazo de prescripción de la acción ordinaria, se entiende también que prescribe la obligación, porque aquí acción y obligación, entran de alguna manera a coincidir; pero prescrita que sea la acción ordinaria, subsiste sin embargo la obligación como obligación natural.

Por expreso mandato de la ley, la prescripción de la acción ejecutiva, el tribunal debe declararla de oficio, implícitamente cuando se niega a despachar el mandamiento de ejecución y embargo por prescripción (art. 442).

Esta regla, tiene una calificada excepción en la segunda parte del art. 442 "... salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434."

En este caso, la acción ejecutiva prescribió, pero puede haber ocurrido un evento que haga posible la ejecución, evento que debe constar en título ejecutivo.

Sólo se puede hacer la comprobación de la subsistencia de la acción ejecutiva, acreditando el hecho, en virtud de un instrumento o actuación que tenga la característica del título ejecutivo; o sea, el hecho que se debe demostrar que ha ocurrido, y que tiene como virtud hacer subsistir la acción ejecutiva, debe acreditarse sólo exhibiendo como antecedente, instrumento o actuación, uno de los cualesquiera de los enumerados en el art. 434.

Aplicando la anterior norma en concreto, podemos decir que, por ejemplo, respecto de la prescripción de la acción ejecutiva se ha producido su interrupción natural. En el ejemplo, cuando se llevaban 2 años y 6 meses, se produce la interrupción natural de la prescripción, mediante el reconocimiento de la obligación por el deudor; y se pretende ejecutar la obligación después de transcurridos los 3 años, pero antes de transcurridos los 3 años contados desde la interrupción. El juez va a aceptar la acción ejecutiva, si es que la interrupción natural se acredita mediante un instrumento o actuación que en sí mismo pueda

ser calificado como título ejecutivo, como es la copia autorizada de una escritura pública, o la confesión judicial como vía preparatoria, donde se reconoció la obligación.

Frente a esta disposición se ha planteado la interrogante sobre la acción ejecutiva que, a título excepcional, prescribe en un año (como es la acción ejecutiva de las letras, pagarés y cheques), en el sentido si el tribunal debe y puede de oficio declarar su prescripción; sobre el particular, hay 2 interpretaciones: una interpretación literalista, se ha dicho que tratándose de una norma de carácter excepcional, hay que interpretarla restrictivamente, y en consecuencia no puede declararse de oficio por el tribunal ; y una interpretación teleológica, que lleva a la conclusión contraria.

Estrechamente vinculada con esta materia, encontramos la cláusula de aceleración, que es la circunstancia que se produce cuando en el título se contempla un determinado hecho o circunstancia, que de producirse trae como consecuencia la exigibilidad inmediata de la obligación, no obstante el plazo inicialmente convenido.

En virtud de la aceleración, se produce la exigibilidad completa de la obligación, y para los efectos de la prescripción de la acción ejecutiva, cabe plantearse desde donde se cuenta como fecha de exigibilidad. La lógica del sistema legal habría hecho pensar que para estos efectos se contaba la fecha de la aceleración, porque esta no sólo está establecida en beneficio del acreedor, sino también en beneficio del deudor en función de la prescripción; sin embargo la jurisprudencia, muy reiteradamente ha estimado que, cuando hay cláusula de aceleración, la exigibilidad para los efectos de la prescripción se cuenta desde los plazos primitivamente convenidos.

Tema 6: Cuaderno principal o ejecutivo.

El juicio ejecutivo cuenta necesariamente con 2 cuadernos, que se denominan el cuaderno principal o ejecutivo, y el cuaderno de apremio; puede contar con otros cuadernos, que son los cuadernos de tercera, como la tramitación separada de los incidentes.

La existencia del cuaderno principal o ejecutivo y la del cuaderno de apremio, aparece recogida en el art. 458, que se refiere a ambos cuadernos y a la necesidad de su tramitación separada. Esta norma además señala que en el cuaderno principal o ejecutivo, se recogerá la fecha en que se practique el embargo y la fecha en que se practique la ampliación del embargo; y subraya el hecho de que estos dos cuadernos tienen vidas separadas (paralelas), en consecuencia, lo que ocurra en uno no puede importar retardo en el otro, sin embargo hay ciertas influencias recíprocas dadas ciertas circunstancias.

El cuaderno principal o ejecutivo puede nacer de 2 maneras:

a) Derechamente como cuaderno principal o ejecutivo, cuando efectivamente se puede aparejar un título ejecutivo perfecto, y nace con la demanda ejecutiva;

b) Puede nacer también, y en estricto rigor convertirse en principal o ejecutivo, después de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva exitosa, o sea, obteniéndose título ejecutivo perfecto. En este caso, la demanda ejecutiva se cose materialmente, y se provee a continuación de la gestión preparatoria; y sólo se produce un cambio de carátula, en el sentido que ya el objeto del respectivo juicio no es la preparación del juicio ejecutivo, sino el juicio ejecutivo mismo, pero no hay cambio de rol. Esto aparece, en cierta manera, del art. 178 C.O.T., que señala que cuando se ha producido distribución respecto de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, no se requiere distribución de la demanda ejecutiva.

6.1 Demanda ejecutiva.

Es la primera actuación procesal dentro del cuaderno ejecutiva, salvo que haya actuaciones preparatorias previas. Esta demanda ejecutiva debe cumplir también con los requisitos del art. 254, o sea, los requisitos de la demanda del juicio ordinario de mayor cuantía; en virtud de que las normas del juicio ordinario de mayor cuantía, son supletorias a las normas del juicio ejecutivo. Además de estos requisitos generales, en la demanda ejecutiva debe necesariamente aparejarse el título que se invoca como ejecutivo, siendo esta una diferencia substancial con la demanda del juicio ordinario, donde es facultativo para el demandante acompañar o no instrumentos (art. 441).

En la demanda ejecutiva se pide:

- Que se tenga por deducida demanda ejecutiva en contra del deudor.
- Que a su respecto se despache mandamiento de ejecución y embargo, por la cantidad
- Que se consigna en la demanda, más intereses y costas.
- Que si fuese necesario se dicte sentencia definitiva, ordenando que continúe la ejecución hasta el entero pago de la obligación, con sus interese y costas.

Además, de estos requisitos generales de la demanda ordinaria, y específicos de aparejar el título y contener estas menciones, la demanda ejecutiva puede tener también las siguientes otras menciones:

- En un otrosí, puede indicar los bienes que propone para ser embargados (art. 443 inciso penúltimo).
- Puede designar depositario provisional (art. 443 Nº 3).
- Puede solicitar que, para los efectos de la traba de embargo, se requiera desde luego el auxilio de la fuerza pública. Normalmente los tribunales no acceden desde luego al auxilio de la fuerza pública, sino que acceden sólo cuando ha habido oposición a la traba de embargos; pero, si en concepto del tribunal hay fundado temor que el mandamiento sea desobedecido en cuanto a la traba y lo ha solicitado el acreedor, puede desde luego ordenar dicho auxilio (art. 443 inciso final).

El tribunal, derechamente, sin audiencia del deudor, aún cuando este haya estado presente, por ejemplo, en la gestión preparatoria, decide ordenar el inicio del juicio ejecutivo o denegar su inicio.

Cuando ordena el inicio del juicio ejecutivo, sólo dice “despáchese”, con lo que de inmediato nace el cuaderno de apremio, que nace con el mandamiento de ejecución y embargo.

El futuro ejecutado puede haber estado presente en la gestión preparatoria previa, o frente a la noticia que se va a iniciar un juicio ejecutivo en su contra, puede realizar observaciones ante el tribunal; en este caso, todas las gestiones que realice el futuro ejecutado, no embarazarán en manera alguna el procedimiento ejecutivo, y sólo podrán ser estimadas por el tribunal como datos ilustrativos para apreciar la procedencia de la acción (art. 441 inciso 2º).

6.1.1 Naturaleza jurídica de la resolución que provee la demanda ejecutiva

Esto tiene mucha importancia, porque de la naturaleza jurídica de la resolución, dependerán los recursos procesales que se puedan intentar en su contra.

La resolución es una sentencia interlocutoria de segunda clase, porque resuelve acerca de una cuestión, que va a servir de base para la dictación de la sentencia definitiva; e incluso, puede ser, junto con el mandamiento, substitutiva de la sentencia definitiva.

En relación con los recursos que se pueden intentar en su contra, es necesario distinguir si el mandamiento es denegado o si es ordenado:

1. Si el mandamiento es denegado, el agraviado es el demandante, y puede intentar los siguientes recursos procesales:

- a) no puede intentar reposición, porque como regla muy general, no cabe la reposición respecto de sentencias interlocutorias;
- b) puede intentar apelación (art. 441 inciso final), y en este caso la apelación tiene algunas características particulares: se concede en el solo efecto devolutivo, y no es necesario emplazar, por la apelación, al ejecutado (es una apelación con apelante, pero sin apelado);
- c) si la Corte de Apelaciones respectiva confirma el fallo, este fallo no es susceptible de recurso de casación en el fondo, porque la resolución no pone término al juicio, sino que impide su iniciación.

2. Si el ejecutado ha tenido noticias del inicio del juicio ejecutivo, ya sea por haber intervenido eventualmente en la gestión preparatoria o por cualquier otra forma, puede intentar hacer algunas alegaciones antes que el tribunal provea en torno al despáchese, pero estas alegaciones, establece la ley, no podrán entorpecer en forma alguna el curso del procedimiento. Respecto a la resolución que ordena el despáchese, encontramos las siguientes situaciones:

- a) no cabe el recurso de reposición en su contra, por ser la resolución una interlocutoria de segunda clase;
- b) aunque la jurisprudencia es más o menos vacilante, en general, se ha indicado que tampoco cabe a su respecto el recuso de apelación, porque la apelación sería una forma de entorpecer el procedimiento aún cuando ella se concediera con el solo efecto devolutivo, y precisamente la ley señala que no se admitirán actuaciones que pudieran importar entorpecimiento en el curso del juicio;

c) respecto al recurso de casación en el fondo, claramente éste tampoco procede, porque en la medida que no es apelable, no habrá sentencia de la Corte de Apelaciones que casar.

Junto y paralelamente con esta resolución de despáchese y el mismo día, el tribunal dicta el llamado mandamiento de ejecución y embargo, que es una resolución separada y que tiene la misma fecha que el despáchese, y que se ha entendido como la consecuencia de esta orden que se da a sí mismo el tribunal, en el sentido de efectivamente despachar el mandamiento.

Este mandamiento de ejecución y embargo es la foja número 1 del cuaderno de apremio; y así surge en virtud del despáchese el cuaderno principal o ejecutivo, que habrá nacido con la demanda, pero que se consolida propiamente como ejecutivo a partir del despáchese, y por otra parte habrá nacido el cuaderno de apremio cuya primera actuación es esta resolución que se denomina el mandamiento de ejecución y embargo.

A esta materia se refiere muy específicamente el art. 443 C.P.C., que señala precisamente los requisitos y menciones de este mandamiento de ejecución y embargo; en las que hay que distinguir menciones necesarias y menciones eventuales. Son menciones necesarias las que debe contener el mandamiento, y son menciones eventuales las que en ciertas y determinadas circunstancias puede contener el mandamiento.

6.1.2 Menciones necesarias del mandamiento.

1° La orden de requerir de pago al deudor:

Es una actuación solemne, debe ser hecha por la persona (ministro de fe) y en la forma que la ley señala.

El requerimiento lo debe realizar un receptor judicial, que es ministro de fe, y cuando el requerimiento se realiza conjuntamente con la notificación personal de la demanda, el requerimiento se realiza bis a bis, frente al deudor, y el receptor le dice “lo requiero de pago por tal obligación”, y si en el acto de requerimiento el deudor no paga, el receptor de inmediato debe proceder al embargo de los bienes respectivos.

De acuerdo a esta visión, hay una determinada secuencia: primero el requerimiento, y si frente a este el deudor no paga, prosigue inmediatamente el embargo; esto significa que la medida cautelar de embargo requiere siempre de previo requerimiento. Así si se va iniciar un juicio ejecutivo y se teme que el deudor vaya a ocultar o enajenar sus bienes, es perfectamente posible e incluso recomendable que se obtengan medidas prejudiciales precautorias, porque en el juicio ejecutivo estas son perfectamente posibles por la aplicación subsidiaria de las normas del juicio ordinario.

Si en vez de notificar personalmente al deudor, se le notifica por el art. 44 C.P.C., o sea, por la notificación sustitutiva de la personal, habiendo acreditado que efectivamente el deudor se encuentra en el lugar del juicio y que el lugar donde se notificó era efectivamente su morada o domicilio, el

requerimiento se realiza de acuerdo a un mecanismo que se ha denominado “cédula de espera”, que consiste en que el receptor notifica por el art. 44, dejando copia, y señalándole que para los efectos del requerimiento lo espera en un lugar, día y hora determinada. El receptor concurre a dicho lugar y se encuentra esperando que el deudor concorra para los efectos de requerirlo; si el deudor no llega se le tiene por requerido.

La notificación y el requerimiento, coinciden en el tiempo sólo cuando la notificación es personal; no coinciden en el tiempo cuando la notificación es la del art. 44 o en otra forma de notificación. Esto también tiene importancia, porque el plazo para oponer excepciones se cuenta desde el requerimiento y no desde la notificación de la demanda.

Podría ocurrir que al deudor se le hubiese notificado previamente en forma personal o sustitutiva de la personal, durante la gestión preparatoria del juicio ejecutivo; cuando al deudor se le notifica personalmente con antelación a la iniciación del juicio, tiene que cumplir una carga procesal, que es fijar domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal dentro del segundo día, y si no cumple con esta carga se le notifica la demanda y se le tiene por realizado el requerimiento, por la simple notificación por el estado diario. Si efectivamente ha fijado domicilio dentro de ese plazo, se le realiza la notificación de la demanda por cédula, y en este caso también se requiere cédula de espera para el requerimiento.

Esta última conclusión no es del todo clara porque no se desprende con nitidez de la norma, pero si el requerimiento es tan esencial como trámite en el juicio ejecutivo, naturalmente la notificación por cédula de la demanda tiene que conllevar necesariamente la cédula de espera para requerimiento, haciendo aplicación de la misma normativa para la notificación sustitutiva de la personal. Todo esto aparece, no con la claridad que sería ideal, en el numerando primero del art. 443 C.P.C.

El inciso 2° del numerando primero del art. 443 establece que “cuando el deudor haya sido notificado personalmente o con arreglo al art. 44 para otra gestión anterior al requerimiento, se procederá a éste y a los demás trámites del juicio, en conformidad a lo establecido en los art. 48 a 53”; esta remisión no es equivocada, pero sí hay que analizarla porque dificulta la interpretación.

El art. 48 se refiere a la notificación por cédula, en tanto que los arts. 50 y siguientes se refieren a la notificación por el estado diario; por lo tanto, hay una remisión tanto a la notificación por cédula como a la por el estado diario. Debe entenderse esta remisión haciendo primero aplicación del art. 49, que dice que para los efectos de la notificación por cédula la parte debe fijar el domicilio (aquí la ley establece que debe fijarse el domicilio dentro del segundo día), y si no se cumple con esta carga se notifica por el estado diario.

En conclusión, las alternativas son:

- Notificación personal y requerimiento bis a bis;
- Notificación por el art. 44 C.P.C. y cédula de espera;
- Si antes fue notificado personalmente o por el art. 44, hay que distinguir:

* Si designó domicilio dentro del segundo día: se le notifica por cédula y también hay cédula de espera;

* Si no designó domicilio dentro del segundo día: se entiende notificado y requerido por el estado diario.

El requerimiento de pago, como lo dice el art. 443 inciso1, debe hacerse personalmente al deudor, ergo el mandatario judicial que el deudor hubiese constituido, por ejemplo en la gestión preparatoria o en una actuación posterior, no es persona hábil para ser requerido de pago. Si el deudor es una persona jurídica o es una persona inhábil, hay que requerir, naturalmente, a quien corresponda su representación.

2° La orden de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas, si no paga en el acto:

Deben embargarse los bienes en una cantidad suficiente, es decir, hay una evaluación previa que realiza el ministro de fe para, efectivamente, trabar la medida sobre bienes que sean suficientes para el pago íntegro de la obligación, sus intereses y costas.

Si el requerimiento se realiza en un lugar distinto de donde están los bienes del deudor, inmediatamente después, el ministro de fe se desplazará al lugar donde efectivamente se encuentren sus bienes y trabará el embargo correspondiente.

En consecuencia, el requerimiento no es necesariamente un acto simultáneo al embargo, sino que el embargo es un acto subsecuente al requerimiento.

3° La designación de un depositario provisional:

En relación a esta mención, hay que concordar tres disposiciones: el art. 443 Nº 3, el art. 450 inciso 1° y el art. 444 inciso final.

El depositario es figura esencial para el embargo, porque el embargo es la entrega real o simbólica de los bienes al depositario. No hay embargo sin depositario, y además por regla muy general, el depositario adquiere la administración de los bienes embargados.

El depositario puede tener una doble característica: depositario provisional o depositario definitivo. Será iniciativa de las partes que el depositario provisional pueda eventualmente ser constituido como un depositario definitivo.

Como regla general, el depositario provisional lo propone el propio demandante en su demanda, y el tribunal lo acepta y lo designa como tal. Si el ejecutante no propone depositario provisional, el tribunal puede designarlo de oficio con la restricción, que no puede ser funcionario del mismo juzgado y está limitado el número de veces que puede ser depositario una misma persona.

También está reconocida la facultad que el demandante pida que no se designe depositario, en cuyo evento juega una ficción en el sentido que el depositario es el propio deudor.

Cuando se trata de embargar el menaje de una casa, el depositario necesariamente es el deudor, y al efecto debe levantarse un inventario valorizado de los bienes, tarea encomendada por la ley al receptor que practica la diligencia.

En el art. 444 inciso final, hay una remisión al Código Penal: hay una figura en nuestro Derecho Penal que se denomina el “depositario alzado”, o sea, el depositario que incumple el deber de custodia que se le ha impuesto dado su calidad de tal.

6.1.3 Menciones eventuales del mandamiento.

1° La designación de bienes para la traba del embargo (art.443 inciso 7):

La ley permite que el demandante señale bienes para la traba del embargo, o si el embargo recae sobre una especie o cuerpo cierto. En ambos casos el mandamiento contendrá la designación de los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo.

2° El uso de la fuerza pública para realizar el embargo (art. 443 inciso final):

La fuerza pública sólo se puede ordenar si hay fundado temor en el sentido que el mandamiento sea desobedecido.

6.2 Posibles conductas del deudor requerido.

Estas posibles conductas son tres:

1° El deudor paga: Es una conducta excepcional, ya que si se ha llegado en definitiva a la ejecución, es porque estamos frente a un deudor sumamente renuente a pagar.

Si el deudor paga, y si aún si paga antes del requerimiento, serán de su cargo las costas de la causa, como lo señala el art. 446 C.P.C.

2° El deudor ejecutado no hace nada: Si el deudor no hace nada, transcurren los plazos fatales que tiene para oponer excepciones, y se pierde irrevocablemente para él la oportunidad de ejercerlos; porque en el juicio ejecutivo no hay excepciones anómalas que puedan oponerse a *posteriori*, todas las excepciones deben oponerse en una sola y única oportunidad.

Si el deudor no se defiende no es necesario dictar sentencia definitiva, y el mandamiento de ejecución y embargo se convierte en título suficiente para seguir adelante la ejecución hasta el entero pago de la obligación respectiva, sus intereses y costas; o sea, se produce una situación de ejecución en el sentido que el mandamiento sustituye en cuanto a sus efectos a la sentencia definitiva.

3° Se defiende: Si el deudor se defiende oponiéndose a la ejecución, debe hacer valer una o alguna o todas las excepciones enumeradas en el art. 464 C.P.C.

Todas estas excepciones deben oponerse en un solo escrito, que es el escrito de excepciones.

La ley, en cuanto a su tramitación no distingue entre excepciones dilatorias, perentorias, anómalas; todas las excepciones son tratadas en su conjunto, salvo la excepción de incompetencia del tribunal, donde existe un pequeño matiz. Esta identidad en la tramitación no significa que tengan consecuencias jurídicas similares; la distinción entre excepciones dilatorias y perentorias, no tiene importancia procedimental, pero si puede tener importancia substancial, porque eventualmente si se trata de una excepción técnicamente dilatoria podrá ser posible reiniciar la ejecución.

El deudor que opone excepciones debe indicar en su escrito cuales son los medios de prueba de que se valdrá, y se ha entendido que este requerimiento se cumple con la simple enumeración, y en el caso de testigos no es necesario acompañar la lista de ellos.

El término para oponer excepciones es fatal, y se cuenta desde el requerimiento, no desde la notificación de la demanda.

Para determinar cuándo el deudor debe oponer las excepciones, hay que distinguir entre las distintas situaciones posibles (art. 459 C.P.C.):

- a) El deudor es requerido en el lugar de asiento del tribunal: en este caso tiene el plazo fatal de 4 días para oponer excepciones, contados desde el requerimiento.
- b) El deudor es requerido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, pero fuera de la comuna donde este tiene su asiento: en este caso tiene el plazo de 8 días para oponer excepciones, contados desde el requerimiento y no desde la notificación.
- c) Si la notificación se realiza fuera del territorio jurisdiccional, o sea la notificación y el requerimiento se han realizado por exhorto (art.460 y 461 C.P.C.). Hay que distinguir:
 - i) exhorto nacional: el deudor tiene la alternativa de oponer la excepción ante el tribunal exhortado o ante el tribunal exhortante. Si las opone ante el tribunal exhortado, se aplica la misma regla ya vista, o sea, si es requerido en la misma comuna el plazo es de 4 días, y si es requerido fuera de la comuna, pero dentro del territorio del tribunal, el plazo es de 8 días. Si el ejecutado decide oponer sus excepciones ante el tribunal exhortante, tiene el plazo de 8 días más el termino de emplazamiento según la tabla.
 - ii) exhorto internacional: el plazo es solo el término de emplazamiento, sin un plazo base. No se pueden oponer las excepciones ante el tribunal exhortado.

El término para oponer excepciones es un término individual, no es un término común, a diferencia de lo que ocurre en el juicio ordinario de mayor cuantía, porque el requerimiento es un acto del acreedor al deudor; y se cuenta desde cada uno de los requerimientos.

El art. 462 señala la obligación de quien es ministro de fe y practica el requerimiento, de hacerle presente al ejecutado cuántos son los días que tiene para oponer excepciones. La omisión de esta

obligación del ministro de fe, no acarrea la invalidación de la respectiva diligencia; sin embargo, lo hace responsable de los perjuicios del juicio.

El art. 463 señala que los términos para oponer excepciones, son un término fatal, disposición que hoy es redundante.

6.3 Excepciones a la demanda ejecutiva.

El estudio de las excepciones a la demanda ejecutiva, se basa fundamentalmente en el art. 464 C.P.C. Como aparece del encabezamiento de esta norma, las excepciones están taxativamente numeradas; sin embargo, la excepción del N° 7 es de carácter genérico, de manera que muchas son las situaciones posibles que se pueden enmarcar dentro este numeral.

Desde el punto de vista procedimental, no es necesario distinguir entre excepciones dilatorias, excepciones perentorias, excepciones anómalas y excepciones mixtas; caben todas dentro de la misma enumeración, y tienen todas, salvo la excepción de incompetencia del tribunal, la misma tramitación; esto no significa que del punto de vista substancial tengan el mismo tratamiento.

Es importante también destacar, que las excepciones no necesariamente deben referirse a la totalidad de la obligación, sino que puede referirse a parte de la obligación (art. 464 inciso final).

Las excepciones del art. 464, de los números 1 a 5, son las mismas que las excepciones dilatorias (art. 303); pero no hay una excepción de carácter genérico como la del N° 6 del art. 303.

Art. 464: “La oposición del ejecutado sólo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes:

1º La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda;

Esta excepción se refiere, tanto a la incompetencia absoluta como a la incompetencia relativa. En el caso de falta de jurisdicción, también es aplicable esta excepción, porque la falta de jurisdicción acarrea consecuentemente incompetencia.

Esta situación, se encuentra regulada en el art. 465 CPC. Si se deduce la excepción de incompetencia, ésta puede resolverse por el tribunal desde luego, o bien reservársela para la sentencia definitiva; la norma no es absolutamente clara, pero podemos entender que la expresión “desde luego” no obsta a dar traslado a la contraparte, y una vez que se evacue el traslado puede el tribunal resolver sobre esta excepción (Profesor).

No obsta a la posibilidad de oponer la excepción de incompetencia, el hecho que el ejecutado haya intervenido en las gestiones preparatorias previas, o sea, su intervención en dichas gestiones, no hace precluir la posibilidad de oponer esta excepción.

2º La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca en su nombre;”

3º La litis pendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvencción;”

La *litis pendencia* requiere que el juicio en que se invoque, haya sido promovido por el acreedor, ya sea por la vía principal, o ya sea por la vía reconvenzional; dicho de otra manera, si la *litis pendencia* se basa en un juicio anterior, pero este fue desencadenado por el ejecutado, no será oído si opone esta excepción, en homenaje a la buena fe.

4º La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254;”

Sólo se puede oponer esta excepción, por la falta de los requisitos genéricos, y no los requisitos específicos de la demanda ejecutiva.

5º El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza;”

6º La falsedad del título;

Aquí se alega que el título es falso, o sea, no ha sido otorgado en la forma que aparenta haberlo sido, ha habido cualquier forma de falsedad. En la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, en ciertos y determinados casos, el pretendido deudor puede oponer tacha de falsedad; y se puede oponer la tacha de falsedad como excepción a la demanda, se haya o no opuesto esta tacha en la gestión preparatoria, porque la ley reconoce varias posibilidades para alegar de esta situación.

7º La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado;”

Aquí el legislador, se remite a todos los posibles títulos ejecutivos, y se refiere también a todo el conjunto de requisitos que rodea a cada uno de los títulos ejecutivos; no hace una remisión explícita, pero en la medida que se refiere a la falta de requisitos del título, naturalmente que engloba a todos ellos.

Por ejemplo, si un pagaré no tiene fecha de extensión, hay aquí una falta de requisito para que el pagaré tenga fuerza ejecutiva; o si la letra de cambio no ha sido firmada por el girador, no existe propiamente tal como letra.

Se ha discutido si la falta de liquidez de la obligación o si la falta de exigibilidad de la obligación, cabe o no dentro de este número; y se ha concluido que, precisamente, este numerando séptimo permite invocar ambas circunstancias para oponerse a la ejecución. Y esto por una razón de texto, porque la falta de liquidez o de exigibilidad de la obligación, no está contemplada en otra posible excepción, de

manera que sería una grave inconsecuencia del legislador que no se pudiera invocar esta circunstancia en este numerando.

También se ha debatido, si cabe la excepción del art. 1552 C.C. conocida como “la mora purga la mora”. La jurisprudencia acepta esta excepción de falta de exigibilidad de la obligación, por el incumplimiento del ejecutante de sus obligaciones para con el ejecutado, cuando ella emana claramente del respectivo título.

8º El exceso de avalúo en los casos de los incisos 2.º y 3.º del artículo 438;

El Nº 2 del art. 438, se refiere a una obligación de especie o cuerpo cierto que no existe en poder del deudor; en tal evento, la especie o cuerpo cierto se avalúa por el procedimiento de peritos, y así la obligación de especie o cuerpo cierto se convierte en una obligación de dinero. Lo mismo ocurre con la cantidad del género debido, sin distinguir si se encuentra o no en manos del deudor; situación a la que se refiere el art. 438 Nº 3.

La gestión de evaluación que se realiza como actividad preparatoria, o la eventual impugnación que surja en esta gestión, no obsta a que posteriormente el ejecutado invoque a su respecto el exceso de evaluación; porque si efectivamente se ha avaluado en exceso la especie, el resulta deudor por equivalencia de una cantidad superior de la que efectivamente adeuda.

9º El pago de la deuda.

El pago es la prestación de lo debido. Cuando se habla de pago de la obligación, es importante tener presente que, desde el punto de vista jurídico, el pago es una convención, o sea, normalmente surge del acuerdo entre acreedor y deudor; aunque es una convención, es posible pagar en contra de la voluntad del deudor a través del mecanismo denominado “pago por consignación”.

Cuando se refiere a pago de la obligación, se refiere a cualquier forma de pago, y también puede tratarse de un pago parcial, que en ciertos y determinados casos extingue parcialmente la obligación.

10º La remisión de la misma;

La remisión de la deuda significa, la formal manifestación del acreedor en el sentido que hace dejación de la obligación, que condona la obligación. Quien condona una obligación, equivale a quien dona una determinada cantidad de dinero, y en consecuencia la condonación de una obligación está sometida a los mismos requisitos que la donación.

11º La concesión de esperas o la prórroga del plazo;

12º La novación.

Es la sustitución de una obligación por otra, que en consecuencia se extingue. Para que exista novación debe haber ánimo de novar claramente expresado.

13º La compensación.

En este caso, parte la ley del supuesto que ejecutante y ejecutado son recíprocamente acreedores y deudores; para que la compensación se produzca, ambas obligaciones deben ser líquidas y actualmente exigibles, y de acuerdo con la orgánica del legislador, las obligaciones se extinguen hasta la concurrencia de la menor.

14º La nulidad de la obligación.

Esto tiene cierta importancia, porque la nulidad de la obligación puede derivar de dos conjuntos de circunstancias: una que puede ser la nulidad del título, que como tal acarree la nulidad de la obligación; también la nulidad de la obligación, puede referirse al acto o contrato mismo.

15º La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el título XIX, libro IV del código civil.

La remisión al C.C., debe entenderse hecha a las obligaciones de especie o cuerpo cierto, y efectivamente la pérdida de la cosa debida, en ciertas ocasiones, extingue la obligación.

16º La transacción.

Es un contrato, en virtud del cual extrajudicialmente se pone término a un litigio pendiente o se precave un litigio eventual, mediante concesiones recíprocas.

17º La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva.

La prescripción de la acción ejecutiva es distinta a la prescripción de la acción ordinaria, ya que la primera prescribe, como regla general teórica, en 3 años, en tanto que la acción ordinaria prescribe, como regla general, en 5 años.

En este número, se contempla tanto la prescripción de la acción ejecutiva, como la prescripción de la acción ordinaria; ya que se entiende que la deuda está prescrita si a su respecto se ha extinguido la acción ordinaria, sin perjuicio de que la obligación subsista como obligación natural.

18º La cosa juzgada.

Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella sólo.

6.3.1 Requisitos del escrito de excepciones.

Este escrito de excepciones se homologa o se compara con el escrito de contestación a la demanda, y en consecuencia este escrito debe cumplir con los requisitos genéricos del art. 309 C.P.C. Pero, además de estos requisitos genéricos, el art. 464 señala que:

- a) todas las excepciones deben oponerse en un mismo escrito, sin distinción de cuál sea su respectiva categoría;
- b) deben expresarse con claridad y precisión los hechos en que se fundan las excepciones;

c) deben expresarse los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarla. Se ha entendido que, para este efecto, basta que el demandado haga una simple mención a los medios de prueba.

6.4 Tramitación posterior.

Del escrito de excepciones, se concede traslado al ejecutante por cuatro días fatales (art. 466 inciso 1º), para que el ejecutante oponga lo que estime oportuno respecto de sus derechos. Esta oportunidad de traslado al ejecutante le da la ocasión de señalar cuáles son las razones que esgrime, para que en definitiva, las excepciones no sean acogidas.

Vencido este plazo, ya sea que el ejecutante oponga lo que estime oportuno o en su rebeldía, se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas; siendo este juicio de admisibilidad un juicio de procedimiento y no de mérito.

El tribunal declarará admisibles las excepciones si:

- se trata de aquellas excepciones taxativamente numeradas;
- han sido opuestas en tiempo; y
- si están claramente expuestos los hechos en que se funda la respectiva excepción.

Si falta cualquiera de estos extremos, el tribunal declarará inadmisibles las excepciones.

Si el tribunal estima que las excepciones son inadmisibles, dicta sentencia desde luego, declarando en la sentencia dicha inadmisibilidad; lo curioso aquí, es que esta inadmisibilidad se declara en la sentencia, sin que haya habido previamente citación para oír sentencia. Igual situación se produce, si el tribunal estima que no hay hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, y en tal evento, también, sin necesidad de citar para oír sentencia, dictará sentencia de inmediato.

Si el tribunal estima que las excepciones son admisibles, y que hay hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, declarará primero admisibles las excepciones, y segundo recibirá la causa a prueba, dictando una resolución del todo similar al llamado “auto de prueba” que recibe la causa a prueba y fija los puntos de prueba; o sea, aquí debemos entender nuevamente una remisión al art. 318 C.P.C. (art. 466 inciso 2º y 3º). Aquí hay una diferencia con el juicio ordinario, porque en él la resolución que recibe la causa a prueba fija los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, en tanto que aquí se fijan los puntos de prueba, con lo cual podría interpretarse que cuando se acompaña la lista de testigos, no es necesario acompañar minuta de puntos de prueba, en la medida en que la resolución en sí misma los contiene.

La recepción de la causa a prueba está regulada en los arts. 466, 468 y 469. El art. 468 señala el término probatorio, y aquí se aplica íntegramente, en cuanto al inicio del término probatorio, las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía; o sea, en primer lugar, la resolución que recibe la causa a prueba en el juicio ejecutivo se notifica por cédula, salvo cuando procede notificarla por el estado diario; en segundo lugar, se aplican iguales normas del juicio ordinario en cuanto a la posibilidad de pedir reposición apelando en subsidio; y en tercer lugar, se aplican también las normas del juicio ordinario en el sentido de que el término probatorio entra a correr a partir del momento en que se notifica por el estado diario la última resolución que se pronuncia sobre las reposiciones interpuestas.

Respecto del término probatorio hay algunas situaciones especiales:

- el término probatorio es de 10 días.
- este término probatorio se puede ampliar a 10 días más, sólo a petición del ejecutante, y la ampliación debe solicitarse antes de su extinción. Este término probatorio de 10 o 20 días a petición de parte, se considera como término probatorio ordinario;
- la regla general, es que no se conceda término probatorio extraordinario, salvo que se pida de común acuerdo entre el ejecutante y el ejecutado;
- no hay norma especial respecto de los términos probatorios especiales, y en consecuencia en esta materia son íntegramente aplicables las normas del juicio ordinario (art.468).

Vencido que sea el término probatorio, se concede un plazo de 6 días para observar la prueba rendida, y aquí también hay algunas diferencias con el juicio ordinario, porque en éste el plazo para observar la prueba es de 10 días. Transcurrido que sea este plazo, se presenten o no observaciones a la prueba, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, trámite que se incorporó al juicio ejecutivo en una reciente reforma (art. 469).

Transcurrido este plazo y producida la citación para oír sentencia, el tribunal deberá pronunciar sentencia dentro del término de 10 días, según indica el art. 470.

6.5 Sentencia definitiva.

La sentencia en el juicio ejecutivo se clasifican en sentencias absolutorias y sentencia condenatoria; estas a su vez se subclasifica en sentencia condenatoria de pago y sentencia condenatoria de remate.

1. Sentencia absolutoria: es aquella que por acoger una o más de las excepciones opuestas, declara que no procede la ejecución, y ordena, en consecuencia, el levantamiento del embargo que se hubiese trabado.

2. Sentencia condenatoria: puede ser totalmente condenatoria o parcialmente condenatoria; y será totalmente condenatoria cuando ordena seguir la ejecución por el total de la obligación demandada,

más sus intereses y costas, y será parcialmente condenatoria si sólo ordena seguir adelante la ejecución por parte de la obligación demandada.

Esta sentencia, sea total o parcialmente condenatoria, según la naturaleza de los bienes embargados se subclasifica en:

a) Sentencia condenatoria de pago: tendrá este carácter si el bien embargado es la especie o cuerpo cierto debido o el bien embargado es dinero, ya que en este caso no se requiere realización del bien embargado, para satisfacer al ejecutante.

b) Sentencia condenatoria de remate: será sentencia de remate si los bienes embargados no son dinero, o la especie o cuerpo cierto debido, sino que otro tipo de bienes; porque en este caso se requiere la realización de los bienes embargados, de modo que éstos se traduzcan en un pago en dinero que sea girado o entregado al acreedor.

De esta manera, la sentencia de pago se cumple mediante un procedimiento particularmente simple, ya sea por la entrega de la especie o cuerpo cierto debida o por el giro del dinero correspondiente, en tanto que la sentencia de remate se cumplirá en una forma más o menos compleja según sea la naturaleza de los bienes embargados.

Esta clasificación de sentencia absolutoria y condenatoria tiene gran importancia respecto de los siguientes aspectos:

1. En cuanto al pago de las costas (art. 471):

- a) Si la sentencia es condenatoria, y es totalmente condenatoria, las costas necesariamente deben imponérsele al ejecutado;
- b) Si la sentencia es absolutoria, las costas deben imponérsele al ejecutante;
- c) Si la sentencia es parcialmente condenatoria, las costas se distribuyen proporcionalmente, pero el tribunal por motivo fundado puede imponerle las costas totales al ejecutado.

2. En cuanto a la apelación:

- a) Si la sentencia es absolutoria, es apelable en ambos efectos; esto es importante para el ejecutante porque al concederse en ambos efectos, la orden de alzar los embargos que está contenida en la sentencia no se cumple mientras no se confirme por la Corte de Apelaciones;
- b) Si la sentencia es total o parcialmente condenatoria, es apelable por el ejecutado pero sólo en el efecto devolutivo. La sentencia parcialmente condenatoria es apelable por el ejecutante porque lo agravia; la ley no ha señalado como se concede esta aplicación y si se aplican las reglas generales se llegaría a la conclusión de que esa apelación se concede en ambos efectos;
- c) Si la sentencia es total o parcialmente condenatoria y es de remate, se procede a la realización de los bienes embargados no obstante la apelación pendiente;

d) Si la sentencia es condenatoria y de pago de dineros embargados, la regla general es que no se procede al pago pendiente la apelación, salvo que el ejecutante caucione las resultas del recurso (art. 475 C.P.C.);

e) Si la sentencia condenatoria es de pago de la especie o cuerpo cierto debido, no se procede nunca a la ejecución de ésta, si la sentencia no se encuentra ejecutoriada (arts. 475 y 512).

Tratándose de una sentencia condenatoria de segunda instancia, el recurso de casación en la forma y en el fondo no suspende nunca la ejecución del fallo, según lo señala el art. 773.

Si el ejecutado no se opone a la ejecución, se omite la sentencia definitiva y bastará el mandamiento de ejecución y embargo para seguir adelante la ejecución hasta el entero pago de la obligación. Hay una ficción, en el sentido de asimilar el mandamiento a la sentencia definitiva.

6.6 Efectos de la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo.

La regla general, está recogida en el art. 478 y también en el art. 477, interpretado a *contrario sensu*. La regla general es que, la sentencia definitiva que se dicta en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada formal y substancial, o sea, en principio no se puede volver a debatir el asunto en juicio ejecutivo, ni en otro juicio diverso.

Este principio de la cosa juzgada formal y de la cosa juzgada substancial, tiene, sin embargo, dos conjuntos de excepciones:

- la posibilidad de renovar la acción ejecutiva (art. 477);
- la posibilidad de deducir a posteriori la acción ordinaria (arts. 467 y 478).

En relación con qué ocurre con la prescripción que se ha interrumpido en virtud de la respectiva demanda ejecutiva, si efectivamente es posible su renovación, hay que hacer una distinción respecto de estas dos situaciones: si la acción ejecutiva puede ser renovada como acción ejecutiva, lo que significa que la primera acción ejecutiva fue rechazada, y se inicia una segunda acción ejecutiva con la esperanza de que esta prospere. En este caso se renueva la acción ejecutiva del acreedor porque el demandado obtuvo sentencia absolutoria (art. 2503 N° 3 C.C.), por lo que se entiende que la notificación de la primitiva acción no interrumpió la prescripción.

Se produce el mismo fenómeno en el caso que se intente renovar la acción por la vía ordinaria a iniciativa del acreedor, porque efectivamente hay respecto del deudor absolución. Pero si es el deudor el que pide que se renueve la acción, el juicio ejecutivo si tiene la virtud de interrumpir la prescripción.

6.6.1 Renovación de la acción ejecutiva.

La posibilidad de renovación de la acción ejecutiva que ha sido desestimada, está indicada en el art. 477 C.P.C., que dice que no obstante haber mediado sentencia absolutoria, por alguna de las razones que

señala, es posible renovar por el acreedor la misma acción ejecutiva; de esta manera la sentencia absolutoria anterior no produce cosa juzgada, porque se puede replantear la posibilidad de discusión.

Es posible la renovación de la acción ejecutiva en los siguientes casos:

- **Incompetencia del Tribunal:** si el acreedor se equivocó y demandó ejecutivamente donde no correspondía, y fue aceptada la excepción de incompetencia, no por esto va a perder su posibilidad de usar una vía rápida para obtener el pago de la obligación. O sea, que haya prosperado una excepción de carácter sustancialmente dilatorio, no impide que posteriormente se renueve la acción ejecutiva.
- **Incapacidad:** si efectivamente el acreedor no se apersonó como correspondía, no por esto va a perder la expectativa de elegir la vía ejecutiva para hacer efectiva su acreencia.
- **Ineptitud del Libelo:** una razón de carácter meramente formal, no puede perder el acreedor definitivamente sus expectativas.
- **Falta de Oportunidad en la Ejecución:** aquí puede tratarse de una situación enmarcable dentro de una excepción dilatoria propiamente tal, pero puede tratarse de una situación distinta, por ejemplo, un plazo pendiente o una condición pendiente.

Así el art. 477 permite, en general, renovar la acción ejecutiva cuando se ha acogido una excepción que en su substancia es dilatoria; pero permite también renovar la acción ejecutiva, cuando el rechazo de la ejecución deriva de la circunstancia de ser inoportuna la ejecución.

6.6.2 Reserva de acciones y excepciones.

Este segundo conjunto de excepciones, se refiere tanto a la posibilidad de replantear por parte del acreedor, como por parte del deudor la pretensión o contrapretensión en juicio ordinario. Este replanteo de la respectiva pretensión o contrapretensión, necesariamente debe hacerse por la vía del juicio ordinario.

a) Ejercicio de este derecho por parte del demandante o ejecutante: El ejecutante tiene dos oportunidades para impetrar el derecho de renovar su pretensión por la vía ordinaria, las que están reguladas en el art. 467 CPC y en el art. 478 CPC:

i) Artículo 467 CPC: Del escrito de excepciones, se le da traslado por cuatro días a la parte ejecutante, en esta oportunidad tiene la primera opción de solicitar reserva; pero esta primera opción necesariamente se traduce en que se desiste de la demanda ejecutiva, impetrando en su beneficio la reserva, y en este caso, el tribunal necesariamente debe reconocerle u otorgarle la reserva. El desistimiento produce una situación muy particular, porque la regla general es que el desistimiento aceptado hace extinguir irrevocablemente la pretensión, en tanto que este desistimiento con reserva, deja subsistente la pretensión, para hacerse valer en el procedimiento ordinario.

Es importante destacar, que en este caso el ejecutante que se desiste, debe responder de los perjuicios que haya causado con su ejecución; o sea, las consecuencias dañosas para el ejecutado, derivadas del embargo o cualquier otra instancia, son de cargo del ejecutante que desiste. En caso de mediar este desistimiento con reserva, significa que el embargo queda *ipso facto* sin valor.

ii) Artículo 478 CPC: Esta segunda oportunidad debe ejercitarse antes de dictarse sentencia en el juicio ejecutivo. Con relación a este punto, aunque la redacción de la disposición es oscura, podemos entender que antes de la dictación de la sentencia de primera instancia o también antes de la dictación de la sentencia de segunda instancia (Profesor).

Esta norma existía antes de que se incorporara en el juicio ejecutivo el trámite de citación para oír sentencia; para compatibilizar esta norma del art. 478 CPC con este trámite, deberá entenderse que puede impetrarse este derecho antes de dictar sentencia, no obstante la citación para oír sentencia; tanto porque lo establece así literalmente la norma, cuanto porque este es un derecho de carácter procesal para el ejecutante y para el ejecutado, y debe interpretarse la norma en pro del ejercicio de este derecho.

Esta reserva que intenta el ejecutante, es una facultad del tribunal concedérsela a diferencia de la primera reserva, que opera de pleno derecho. Sin embargo, el tribunal debe concederla si la reserva se refiere no a la existencia misma de la obligación que ha sido objeto de la ejecución, así por ejemplo, se concederá siempre, si la reserva se hace sobre circunstancias que no hicieron oportuna la ejecución.

Cuando se concede la reserva, debe demandarse en juicio ordinario posterior, pero la ley señala al efecto un plazo con carácter de preclusivo, y a quien se le ha otorgado la reserva debe demandar ordinariamente en el plazo de 15 días desde que se notifique la sentencia definitiva que se dicte en la ejecución. Este plazo de 15 días se cuenta desde la sentencia de primera o de segunda instancia, dependiendo de la oportunidad en que se impetre el derecho.

b) Reserva de acciones por parte del ejecutado: El ejecutado tiene también dos oportunidades para impetrar en su beneficio la reserva; una que es individual suya, y la otra es la misma oportunidad que la ley le reconoce al ejecutante. A estas situaciones se refieren los arts. 473 y 474 del CPC.

i) Artículos 473 y 474 del CPC: En este caso concreto, el ejecutado realiza un acto de allanamiento, o sea, se somete a la pretensión del ejecutante en cuanto a que, efectivamente, en este procedimiento, se siga adelante hasta el entero pago de la obligación. Cuando el ejecutado realiza este acto de allanamiento, el tribunal debe dictar sentencia de inmediato, o sea, no es necesario en este caso, dar traslado al ejecutante; *pero en este acto el ejecutado opone excepciones, y la reserva que pide se le concede sólo respecto de las excepciones opuestas, de manera que en el juicio ordinario posterior no puede haber otras alegaciones o defensas, sino que precisamente se deben renovar las excepciones que hizo valer al oponerse a la ejecución.

La razón que debe necesariamente invocar el ejecutado para impetrar en su beneficio esta reserva, es que no tiene medios de prueba para acreditar las excepciones.

Esta primera oportunidad del ejecutado, necesariamente debe aceptarla el tribunal, y debe concederle la reserva correspondiente.

Junto con impetrar la reserva, el ejecutado puede pedir que no obstante la realización de los bienes embargados, no se proceda al pago al ejecutante, en tanto no caucione a satisfacción del tribunal, la eventual restitución en caso de prosperar la acción ordinaria.

Esta acción ordinaria, debe entablarla el ejecutado dentro del plazo de 15 días desde que se le notifica la sentencia definitiva de primera instancia.

ii) Artículo 478 CPC: La segunda oportunidad para el ejecutado es idéntica a la segunda oportunidad para el ejecutante, o sea, puede pedir su reserva antes que se dicte la sentencia definitiva, de primera o segunda instancia según el momento en que la impetre. Y el tribunal podrá o no concederle la reserva, pero deberá necesariamente conceder la reserva si las excepciones impetradas no miran a la existencia misma de la obligación, sino a su exigibilidad. En consecuencia, en este caso, es plenamente aplicable el art. 478 del CPC.

Tema 7: Cuaderno de apremio.

El cuaderno de apremio, nace simultáneamente con el cuaderno ejecutivo, frente a la resolución “despáchese”; en consecuencia, si el tribunal niega la ejecución, no hay “despáchese” y no nace el cuaderno de apremio; de esta manera, el “despáchese” es una orden que se da el tribunal a sí mismo, para iniciar paralelamente el cuaderno ejecutivo y el cuaderno de apremio.

Este cuaderno de apremio tiene como actuación de fojas 1, el “mandamiento de ejecución y embargo”, y en él se realizan todos los actos que digan relación con la administración de los bienes embargados y con la realización de los mismos; o sea, todo cuanto se derive del embargo, del depósito, de la reducción o ampliación del embargo, del desempeño del depositario, de las cuentas del depositario, y posteriormente de la realización de los bienes embargados, se tramita en el cuaderno de apremio.

El mandamiento es una actuación esencial en el juicio ejecutivo, y en caso de no haberse opuesto excepciones se omite la sentencia definitiva, y el mandamiento es instrumento suficiente para seguir adelante la ejecución hasta el entero pago de la obligación.

7.1 Embargo.

Es de la esencia del embargo, la existencia de un depositario, sea que se trate de un depositario provisional o de un depositario definitivo; en algunos casos el depositario es, necesariamente, el deudor, como cuando se trata de embargar los muebles de una casa, y por otro lado, cuando no se designa depositario se entiende que el deudor es el depositario.

Y esta obligación esencial de que exista depositario, radica en que el art. 450 inciso 1º CPC dice que el embargo es "... la entrega real o simbólica de los bienes al depositario...", o sea, hay un desplazamiento, real o simbólico, de los bienes, desde la esfera de custodia y administración del propietario a la esfera de protección y administración del depositario.

Si el depositario es el propio deudor, no hay un desplazamiento físico, pero si hay un desplazamiento jurídico, porque cambia el título de la tenencia (no se tiene la cosa como dueño, sino que como depositario) y el título de la administración (no se tiene la administración como dueño, sino que como depositario, y en consecuencia con la obligación y necesidad de rendir cuenta).

El art. 450 CPC, para evitar una serie de arbitrios que se habían cometido respecto de la forma de entabrar los embargos, ha sido extremadamente riguroso en cuanto a como debe proceder el ministro de fe para dar certeza a la respectiva diligencia y rodearla de la garantía que es indispensable (inciso 2º, 3º, 4º y 5º):

"El ministro de fe que practique el embargo deberá levantar un acta de la diligencia, la que señalará el lugar y hora en que éste se trabó, contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados e indicará si fue necesario o no el auxilio de la fuerza pública para efectuarlo y de haberlo sido, la identificación del o de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Asimismo, dejará constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado.

Tratándose del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y estado de conservación y todo otro antecedente o especificación necesarios para su debida singularización, tales como, marca, número de fábrica y de serie, colores y dimensiones aproximadas, según ello sea posible. En el embargo de bienes inmuebles, éstos se individualizarán por su ubicación y los datos de la respectiva inscripción de dominio.

El acta deberá ser suscrita por el ministro de fe que practicó la diligencia y por el depositario, acreedor o deudor que concurra al acto y que desee firmar.

Sin que ello afecte la validez del embargo, el ministro de fe deberá enviar carta certificada al ejecutado comunicándole el hecho del embargo, dentro de los dos días siguientes de la fecha de la diligencia o del día en que se reabran las oficinas de correo, si ésta se hubiere efectuado en domingo o festivo. El ministro de fe deberá dejar constancia en el proceso del cumplimiento de esta obligación, en los términos del artículo 46 CPC".

7.2 Depositario

Para efectos del embargo basta la designación de depositario provisional, y a esta situación se refiere el art. 443 Nº 3 del CPC. El depositario provisional puede ser:

- designado por el propio acreedor bajo su responsabilidad;
- a falta de esta designación, puede hacerlo el tribunal con ciertas y determinadas limitaciones;
- el acreedor puede solicitar que no se designe depositario, y se entiende que el depositario provisional es el propio deudor.

El depositario provisional desempeña su labor “entre tanto”, o sea, hasta que se designe depositario definitivo. Sin embargo, no es un trámite indispensable ni necesario la designación de depositario definitivo, ya que es perfectamente posible que los bienes queden en manos del depositario provisional hasta el momento de la realización.

El depositario definitivo, se nombrará de común acuerdo entre las partes en audiencia verbal que se fije, y si no se produce el acuerdo, el depositario definitivo lo designa el tribunal (art. 451 inciso 1 CPC).

La ley permite, a título excepcional, que se designe más de un depositario, y esto ocurre cuando los bienes se encuentran en distintos territorios jurisdiccionales, o se trata de bienes de distinta naturaleza. La pluralidad de depositarios puede referirse a los depositarios definitivos o a los provisionales (art. 451 inciso 2 CPC).

El depositario es un cargo que puede ser revocado por incompetente desempeño o porque el depositario puede renunciar a su ejecución. La ley señala que las partes serán oídas si quieren probar que el depositario no es responsable (art. 451 inciso 3 CPC).

El inciso final señala que en caso de dinero, alhajas, especies preciosas o efectos de comercio, el depósito se hará en un banco o Caja Nacional de Ahorro a la orden del juez de la causa, previa certificación en la causa. Esto tiene una importante modificación recogida en el art. 507 C.O.T. que señala que cuando se embarga dinero se debe depositar en la cuenta corriente del tribunal; se ha aceptado que el tribunal en vez de mantener estos dineros en la cuenta corriente, tome un depósito a plazo para evitar la desvalorización de los dineros embargados, pero técnica o estrictamente, el embargo de dinero debe traducirse en depósito en la cuenta corriente del tribunal.

El art. 452 CPC señala que lo normal y natural, es que el deudor sea quien entregue la especie al depositario, pero si se niega o no está presente, la efectuará el ministro de fe.

El art. 453 CPC se refiere al embargo de bienes raíces, que posee una regulación especial, a saber:

Art. 453 incisos CPC 1: *“Si el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros sino desde la fecha en que se inscriba en el respectivo registro conservatorio en donde estén situados los inmuebles”.*

Cuando el Código habla de “bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos”, está queriendo referirse al embargo de la propiedad plena, vale decir, del bien raíz todo, y respecto del derecho real, al usufructo, que es perfectamente embargable y enajenable; no así al derecho de uso y habitación que es personalísimo.

Para que el embargo sea oponible a terceros, éste debe ser inscrito en el registro respectivo del conservador. El embargo produce efectos respecto del deudor, cuando recae sobre un bien raíz, desde que se practica aún cuando no haya inscripción, lo que tiene importancia para efectos de la responsabilidad del deudor que si, a sabiendas de un embargo practicado aunque no inscrito, dispone de dicho bien, puede ser sancionado penalmente.

El registro respectivo es el de prohibiciones e interdicciones de enajenar que lleva el Conservador de Bienes Raíces del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble; y se encuentra practicada la inscripción desde la fecha del repertorio, o sea, desde el instante que se requiere al conservador respectivo para que practique la inscripción.

Si se decreta un embargo y el bien se enajena antes de la inscripción, naturalmente el acreedor nada puede hacer en el juicio mismo, sin perjuicio de poder perseguir por otras vías la restitución del bien al patrimonio del deudor.

Debe tenerse presente que el sistema de la propiedad inscrita ha ido ampliándose, ya que antiguamente sólo se inscribía la propiedad raíz y hoy día hay sistemas de la propiedad inscrita respecto de aguas, de marcas comerciales, de patentes e incluso respecto de vehículos motorizados. De acuerdo con las regulaciones respectivas, se ha entendido en general, que si el bien de que se trata está sujeto a un sistema de propiedad inscrita, el embargo es sólo oponible a terceros cuando se ha anotado en el registro respectivo, vale decir, se hace una interpretación extensiva de la norma (art. 453 inciso 1 CPC). Como toda actuación que se realiza ante el conservador, la inscripción precisa de un requirente, que en este caso es el ministro de fe que practicó la diligencia de embargo (art. 453 inciso 2 CPC).

El art. 454 CPC señala la situación que se produce cuando el embargo recae sobre un bien que está en poder de un tercero y que alega algún derecho sobre dicho bien, aún cuando no reclama el dominio, sino que algún derecho derivado de otro título que le permita seguir gozando o percibiendo los frutos del bien. El inciso 1 señala que el bien sigue en poder de este tercero hasta la enajenación, y el depositario podrá ejercer los mismos derechos que tenía el deudor. Es necesario precisar que cuando la ley habla de “hasta el momento de la enajenación” es porque la regla general es que, en virtud de la enajenación cesan los derechos de los terceros, pero bien pueden no cesar, en el sentido que puede seguir el tenedor gozando de la cosa embargada, en virtud de los derechos que sobre ella tiene (inciso 2).

El art. 455 en sus inciso 1 y 2 CPC, contienen disposiciones reglamentarias que se refieren a la comunicación del ministro de fe al tribunal de la práctica del embargo, y de la certificación del secretario y de la entrega a que se refiere el art. 453 CPC, respectivamente. El inciso final, es una disposición incorporada el año 1995 y que significa una protección a los deudores, en el sentido que el retiro de las especies para su realización, no se puede practicar sino después de transcurridos diez días desde la fecha del embargo.

A quien primero le corresponde designar los bienes para la traba del embargo, es al propio acreedor, que lo puede señalar en su demanda y, en tal evento, el mandamiento de ejecución y embargo contendrá el señalamiento de los bienes a embargar. Si así no lo hiciere, el acreedor puede concurrir a la diligencia del embargo y señalar en ese mismo momento y oportunidad los bienes, siempre que sean en cantidad suficiente.

Si el acreedor no ha designado bienes, se practicará el embargo en los bienes que presente el deudor siempre que sean suficientes para efectos de la acreencia.

Si no los designa ni el acreedor ni el deudor, es el ministro de fe el que elige, pero al efecto la ley le señala un orden de prelación, sobre que bien debe preferir y este orden es:

- dinero;
- otros bienes muebles (de más fácil realización que los bienes raíces);
- bienes raíces;
- salarios y pensiones, en la medida que ellos sean embargables.

Al hablar de bienes raíces, se comprende a los bienes raíces propiamente tales, a los derechos reales constituidos sobre ellos y a las cuotas de copropiedad.

7.3 Inembargabilidad.

Es regla excepcional, y como tal sólo tiene como fuente la ley, o sea, no hay otros bienes inembargables que los que la ley señala como tales.

La regla general es la embargabilidad, en virtud del principio conocido como el “derecho de prenda general del acreedor” que está recogido en el art. 2465 C.C., en el sentido que el acreedor tiene su expectativa de cumplimiento respecto de todos los bienes del deudor salvo los inembargables, vale decir, que todo el patrimonio del deudor queda adscrito al cumplimiento de sus obligaciones.

La inembargabilidad es un principio de orden público, en consecuencia es irrenunciable por parte del deudor. Cuando se produce el embargo sobre un bien inembargable, si el deudor no reclama, la situación se consolida y puede en consecuencia burlarse el principio de la inembargabilidad.

Las fuentes de la inembargabilidad son el art. 1618 C.C. y el art. 445 C.P.C. Sin perjuicio de que hay un conjunto de leyes especiales, que han creado ciertas y determinadas instituciones, que en razón de

intereses de carácter general declaran la inembargabilidad de los bienes de dichas instituciones, por ejemplo los bienes del fisco.

De estas dos normas debe preferirse la norma del C.P.C., porque es ley posterior y en consecuencia en todo lo que sea contradictorio rige esta última; y también en lo que no sea contradictorio debe regir esta norma, por haber un tipo de derogación orgánica. Sin embargo, los principios de inembargabilidad en una y otra norma son similares (Profesor).

Artículo 445 CPC “No son embargables:

1° Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades.

Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta el cincuenta por ciento de las prestaciones que reciba el alimentante en conformidad al inciso anterior;”

Lo que paga el Fisco no es embargable; sin embargo, lo será para responder de las pensiones alimenticias decretadas judicialmente hasta por el 50% de dicho monto.

2° Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo;”

Hay una remisión a los arts. 40 y 153 del Código del Trabajo, pero debe entenderse echa al artículo 57, que señala que son embargables las remuneraciones en toda aquella parte que exceda de 56 UF.

3° Las pensiones alimenticias forzosas;”

Las pensiones alimenticias forzosas son aquellas que se deben por ley, y son inembargables porque miran a la subsistencia del alimentante.

4° Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de los hijos que viven con él y a sus expensas;”

Se trata de ciertas y determinadas prestaciones que se reciben de una fundación o de la liberalidad de un tercero y que tienen el carácter de alimenticias. Tales prestaciones son inembargables en la parte que sean necesarias, pero en el exceso podrán ser embargadas.

5° Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile y en las condiciones que ella determine;”

Hay una remisión a la Ley Orgánica del Banco del Estado, y específicamente a los contratos de ahorro que hasta cierto monto son inembargables.

6° Las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo convenido en ellas, pague el asegurador.

Pero, en este último caso, será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza;"

El seguro puede referirse a cualquier riesgo, pero también es asegurable el riesgo de muerte, a través de una póliza de seguro de vida; esta norma sólo se refiere a la póliza de seguro de vida y no a otras pólizas. La norma dice que la póliza no es embargable y tampoco lo es la indemnización que se pague si concurre el siniestro, pero sí son embargables las primas que el asegurado pague a la compañía.

En el contrato de seguro de vida hay tres intervinientes que son:

- el asegurador que celebra el contrato,
- el asegurado que asume el riesgo, y
- el beneficiario que recibe la indemnización.

7° Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la construcción de dichas obras;"

Es una norma excepcional, y en consecuencia sólo aplicable a las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas.

Las obras públicas son aquellas que específicamente se califican, en virtud de leyes o reglamentos, como tales. Estas sumas son inembargables, porque miran como objetivo a que no se paralice la ejecución de las labores, ya que habría intereses colectivos envueltos. Sin embargo, no son inembargables las sumas que el empresario adeude por concepto de remuneraciones a sus trabajadores y de pago a sus proveedores.

8° El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a 50 UTM o que se trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones, a que se refiere el artículo 5º del DL 2552 de 1979; los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.

La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;"

La inembargabilidad del bien raíz que ocupa el deudor es muy restringida, porque se refiere a los bienes raíces que no tengan un avalúo superior a diez sueldos vitales mensuales. Esta norma establece también la inembargabilidad de ciertos muebles de la casa del deudor: muebles de dormitorio, de comedor y de cocina; dentro estos no se encuentran las colecciones especialmente valiosas.

Esta inembargabilidad de los bienes raíces no se aplica respecto de ciertas y determinadas deudas que tenga el deudor con el Fisco, cajas de previsión y demás organismos regidos por la Ley del Ministerio de la Vivienda.

9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 UTM y a elección del mismo deudor;”

10. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;”

Se refiere a objetos destinados a la docencia que realice el deudor, hasta cierto valor.

11. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;”

12. Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 UTM y a elección del mismo deudor;”

Se refiere a utensilios de trabajo, ya sean artesanales o agrícolas, hasta cierto valor.

13. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustibles que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes;”

14. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;”

Se vincula a una institución de poca aplicación práctica, pero que existe en nuestra normativa, que es la propiedad fiduciaria; donde hay un propietario fiduciario, un fideicomisario y una condición pendiente para que se produzca o no la consolidación de la propiedad. En relación con el propietario fiduciario, tampoco es embargable esta forma de propiedad.

15. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;”

Los derechos enteramente personales o llamados también personalísimos, no son embargables porque sólo están establecidos en beneficio de una determinada persona, y en consecuencia no están dentro del comercio. Como aparece claramente de la redacción, las dos situaciones que en la disposición se mencionan son meramente ejemplares, o sea el derecho de uso y habitación no es embargable por ser un derecho personalísimo, pero naturalmente hay otros posibles derechos personalísimos.

16. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran;”

Los bienes raíces donados o legados con expresión de inembargabilidad, son efectivamente inembargables siempre que se deje testimonio de su valor, y el valor sea aprobado judicialmente.

Esta norma es aplicable, tanto a los bienes raíces donados como a los bienes raíces legados, o sea, a los que son consecuencia de una donación entre vivos o que se adquieren por sucesión por causa de muerte por la vía del legado, siempre que se haga constar su valor respectivo.

Sin embargo es embargable el valor adicional que ellos eventualmente pudiesen adquirir. Establecer esta inembargabilidad es una manera de favorecer a una determinada persona.

17. Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.; pero podrá embargarse la renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior; y"

Los bienes de los servicios públicos que no se pueden paralizar sin causar grave daño son inembargables, pero son embargables las rentas líquidas que provengan de su explotación.

18. Los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar.

Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el número 1° de este artículo o de alguna parte de ellas."

El inciso 1º, reafirma el principio de que la inembargabilidad arranca de un mandato legal, en la medida que constituye una excepción al principio de prenda general del acreedor.

El inciso final, señala que las convenciones que se refieren a cesión de las rentas o pensiones a las cuales se refiere el numerando primero del art. 445 CPC son nulas.

7.4 Derechos sociales y su embargabilidad.

Sobre el particular hay que hacer una distinción entre instituciones que se relacionan con el derecho mercantil.

La gran diferencia, entre muchas otras, entre la sociedad y la comunidad, es que la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, en tanto que la comunidad no es una persona jurídica, sino que deriva del dominio del haber común o de ciertos y determinados bienes.

Respecto de la comunidad, no son embargables los bienes que se posean en común, pero si son embargables las cuotas que el respectivo comunero tenga en el bien de que se trata, se realiza dicha cuota y el que adquiere la cuota en el proceso de realización forzada, pasa a ser comunero con el otro en el bien. La calidad de comunero da, naturalmente, derecho para provocar la liquidación de la comunidad.

Respecto del derecho en sociedad, hay que hacer una distinción:

a) Sociedades de Capitales: Son principalmente las sociedades anónimas, pero también son sociedades de capital las sociedades encomanditas por acciones. Tratándose de sociedades de capital, son embargables las acciones de respectivo socio y así son embargables las acciones que tiene una persona en una sociedad anónima o que tiene la misma persona u otra en una sociedad encomandita por

acciones. Hay un procedimiento de realización de las acciones, pero hay que tener presente que este bien típicamente dentro del comercio puede ser objeto del embargo y de realización.

b) Sociedades de Personas: La característica de dichas sociedades es que los derechos sociales no son libremente cedibles, sino que los derechos sociales son sólo cedibles con el consentimiento de los demás socios, porque en las sociedades de personas, el contrato se celebra *intuito persona*, o sea, en función de quien es la persona con la cual efectivamente se está asociando.

El contrato de sociedad importa una voluntad de vínculo serio entre las personas que lo celebran, y este vínculo se traduce en lo que la doctrina ha denominado la "*afectio societatis*", o sea la voluntad efectiva de formar una sociedad. Dado este carácter de no cedibilidad de los derechos en una sociedad de personas, se ha estimado que estos derechos son irrealizables salvo consentimiento unánime de los demás socios; o sea, un embargo sobre ellos no traería consecuencia de poder realizarse los derechos, y de esta manera, se ha sostenido por algunos que, no es posible embargar los derechos en una sociedad de personas por que el embargo como objetivo mira a la realización.

El tema no es tan claro ni tan evidente, en primer lugar lo que es claramente embargable son las posibles utilidades que obtenga el socio y además son embargables el producto de la eventual liquidación de esa sociedad, y en ese sentido podríamos obtener que al hacer efectivo el embargo sobre los frutos o el embargo sobre los eventuales productos de la liquidación de la sociedad, es necesario embargar los derechos y en tal caso debemos distinguir ente el embargo y la realización.

La realización de los bienes embargados cuando, el embargo recae sobre derechos en una sociedad de personas, no puede efectuarse; el embargo sobre dichos bienes sociales tiene efecto cuando se trate de rentas que produzcan los derechos sociales o reparto en virtud de la liquidación de dicha sociedad; o sea, hay una situación que podríamos llamar intermedia que permite el embargo con ciertas y determinadas consecuencias entre las cuales no se encuentra la posibilidad de realizar el bien.

Si bien es cierto que el saldo de una cuenta corriente bancaria no es propiamente dinero, sino que es un crédito que tiene el cuenta correntista en contra del respectivo banco y que el banco debe pagar en dinero, se entiende que estos saldos son embargables; y en consecuencia, cuando se produce el embargo el banco respectivo debe poner los fondos correspondientes a disposición del tribunal depositándolos en la cuenta corriente de este último, de acuerdo con el mecanismos del art. 507 C.O.T. También son embargables los depósitos a plazo que tenga un cliente en una institución financiera. El depósito tampoco es dinero sino que un crédito en dinero, pero al vencimiento el banco o la institución financiera puede ser compelida a depositar su producido en la cuenta corriente del tribunal.

En relación al embargo, hay también una situación que se encuentra regulada en el art. 444 inciso 1º y 2º C.P.C. Se refiere a la posibilidad de embargar no bienes determinados, sino embargar una universalidad, como es una empresa o un establecimiento mercantil o industrial. Este es un derecho del acreedor, pero en ciertos y determinados casos podrá convenirle al acreedor señalar para embargar la empresa de la

actividad íntegra, porque naturalmente con ello podrá no provocar la paralización del establecimiento de que se trate, naturalmente en beneficio de sus expectativas de cobro.

En tal caso, también puede intentar embargar las utilidades de la respectiva empresa, y en ese caso el depositario no pasa a administrar el bien embargado, sino que cumple un papel de interventor judicial, en el sentido que debe vigilar la administración del establecimiento o empresa que se trate y exigir las cuentas correspondientes y dar las informaciones que corresponda al tribunal de la causa.

Esto tiene una cierta vinculación con una institución, ahora muy importante en la quiebra, que se llama la “continuidad del giro”. También en el caso de la ley de quiebras, es un tratamiento, en definitiva, de una determinada universalidad jurídica. El mismo criterio está aplicando el legislador del C.P.C. en este caso particular del embargo.

7.5 Efectos del embargo.

Respecto de los efectos del embargo, hay que señalar que estos son tanto de carácter civil como de carácter procesal.

El primer efecto, es que en virtud del embargo el bien se convierte en inenajenable y esto se desprende del art. 1464 N° 3 C.C. En consecuencia, dicha enajenación es nula de nulidad absoluta por objeto ilícito, sin embargo, y cuestión muy importante, esta norma tiene dos calificadas excepciones que permiten esta enajenación:

- a) Cuando el juez lo autoriza: el juez que debe autorizar la enajenación es el juez que decretó el embargo; en consecuencia, si este juez que decretó el embargo autoriza la enajenación del bien, estaremos en presencia de la situación de excepción y la enajenación será válida.
- b) Cuando el acreedor consienta en ello.

Es importante tener presente, que lo que aquí está prohibido es la enajenación, y esta se produce en virtud de la conjunción de dos elementos de carácter jurídico, que son el título y el modo de adquirir. De esta manera, como regla general, a consecuencia de que la enajenación se perfecciona por el modo de adquirir, el título en sí mismo es válido aun si se refiere a un bien embargado; o sea, la prohibición y el objeto ilícito está en la enajenación, no en el título.

Cuando la ley declara nula la enajenación, como regla muy general, no se refiere al título sino que se refiere al modo de adquirir, pero debemos entenderlo referido al título cuando el título es compraventa o permuta, por aplicación del art. 1810 C.C., pero no es extensible a otros títulos translativos de dominio.

En cuanto a las consecuencias civiles, en virtud del embargo el poseedor del respectivo bien no pierde el derecho a percibir sus frutos; sin embargo es también posible, pero solo en virtud de disposición especial, extender el embargo también a los frutos, pero sobre el particular tiene que haber petición y

resolución, o sea, por el simple embargo no se entiende que es este se extiende los frutos sino que sólo al bien.

La tercera cuestión de carácter civil importante es que el embargo no otorga ninguna clase de preferencia, o sea, el acreedor embargante conservar su calidad de acreedor en la categoría que le corresponde, no mejora su calidad de acreedor en virtud del embargo.

Desde el punto de vista procesal, el embargo tiene como consecuencia que el deudor pierde la administración del bien embargado que pasa al depositario, salvo la situación especialísima de la industria o de la empresa, donde el depositario no adquiere la administración, sino que solo el carácter de interventor judicial.

Esta situación también se produce si el depositario es el propio deudor o dueño del bien embargado, porque en ese caso el dueño no administra a título de dueño, sino que administra a título de depositario, con todas las obligaciones inherentes de esa calidad y la necesidad de rendir oportunamente cuenta.

7.6 Ampliación del embargo (art. 456)

El embargo es consecuencia del mandamiento de ejecución y embargo; en general, el criterio es que deben embargarse bienes suficientes, pero bien puede ocurrir que los bienes sean de difícil realización o que los bienes pierdan su valor con posterioridad al embargo, estas dos circunstancias permiten la ampliación del embargo.

La ampliación del embargo es una solicitud que plantea el acreedor, solicitando al tribunal que efectivamente lo amplíe, y como cuestión accesorio que es deberá sujetarse a la correspondiente tramitación incidental.

También es causa de pedir ampliación del embargo, la interposición de cualquier tercería que diga relación con el bien embargado.

Señala el inciso final de este artículo, que si al ampliación del embargo se ha producido después de la sentencia definitiva, la tramitación de estos nuevos bienes a los cuales se ha extendido el embargo, se puede efectuar sin necesidad de dictar nueva sentencia.

7.7 Sustitución del embargo (art. 457)

La sustitución del embargo es norma de aplicación general, salvo que el embargo haya recaído sobre la especie o cuerpo cierto debida, en cuyo caso no puede sustituirse. Tampoco cabe sustituir el embargo cuando este ha recaído sobre dinero, y así llegamos a la conclusión, que sólo es sustituible el embargo cuando ha recaído sobre bienes distintos al dinero, o distintos a la especie o cuerpo cierto debido.

La sustitución del embargo es, en el fondo, reemplazar el bien embargado, pero el único bien que tiene la virtud de poder reemplazar al bien embargado es el dinero, de manera que sólo se puede sustituir el embargo sobre determinados bienes reemplazando el embargo por dinero que, naturalmente, se entiende también embargado; o sea, al efecto se deposita en la cuenta corriente del tribunal una cantidad de dinero y se solicita la sustitución del embargo.

La cantidad de dinero que debe depositarse para que pueda producirse la sustitución, es la cantidad que sea equivalente al monto del crédito, sus intereses y sus costas.

Es muy importante señalar, que esta sustitución del embargo por dinero no es pago, o sea, el deudor puede seguir discutiendo la existencia de la obligación o la exigibilidad de la obligación, y el acreedor no puede pretender que con este dinero de la sustitución se le pague, el juicio continua a diferencia de lo que ocurre en la institución de la liberación del embargo.

7.8 Reembargo.

Reembargo significa el analizar la posibilidad de que determinado bien embargado produzca nuevamente otro embargo, o sea, por ejemplo, un deudor que no ha podido satisfacer a un acreedor, normalmente tampoco ha podido satisfacer a otro, y todos los acreedores individualmente intentan normalmente hacer efectiva su respectiva pretensión; si el deudor tiene una casa y un acreedor A embarga esa casa y otro acreedor B, sin saber la primera ejecución o sabiendo, embarga por segunda vez la misma casa.

Si es o no posible el reembolso, es una cuestión que se ha discutido largamente y en la que hay distintas posiciones y puntos de vista. Un primer planteamiento es que el reembolso es posible, porque si no se permite el reembolso se estaría desconociendo el derecho de prenda general del segundo acreedor, y en consecuencia éste estaría en una posición desmedrada, y de alguna manera la consecuencia directa es que el primer embargo sería una forma de preferencia, lo que es contrario al principio de igualdad fundamental de los acreedores. El segundo argumento es que si el reembolso no se permitiera, sería muy posible la colusión entre el deudor y su primer acreedor, con el objeto de dejarlo fuera del alcance de los demás acreedores.

Sin embargo, esta doctrina que acepta el reembolso ha sido controvertida, y se ha dicho que el segundo acreedor tiene derechos alternativos, y estos derechos son, por ejemplo, la tercería de pago o la tercería de prelación; si él efectivamente tiene alguna causa de preferencia y en consecuencia no necesita recurrir al reembolso, sino que puede intentar dichas tercerías en la misma ejecución.

Se ha dicho, aun más, que de acuerdo con lo establecido en el art. 528 inciso 1° C.P.C. es perfectamente posible que el segundo acreedor inicie una ejecución separada, y oficie para que esta primera ejecución

se reserve de la realización de los bienes el remanente o la parte proporcional, si ha de pagarse a prorrata.

Se recuerda también que el art. 528 inciso 2 CPC, sanciona al segundo acreedor que en virtud del reembolso sabiendo del primero, hace retirar los bienes embargados de manos del depositario, y lo sanciona como autor del delito de estafa, con lo cual se quiere decir que en caso de una segunda ejecución no cabe reembolso, sino que sólo la retención de la liquidación del remanente producto de la primera ejecución.

No obstante en la vida real se da el reembolso; es una verdad procesal constante, y cuando se produce hay una serie de dificultades respecto de la realización de los bienes embargados, y se ha entendido que para los efectos de la realización de éstos, todos los jueces embargantes tienen que dar su consentimiento, porque si no estaríamos en la situación de objeto ilícito.

7.9 Liberación el embargo (art. 490)

Antes de verificarse el remate, el deudor puede libentar sus bienes pagando la deuda y las costas. En este caso, el deudor paga la obligación y la paga siendo una obligación dineraria, haciendo la consignación respectiva en la cuenta corriente del tribunal, la que debe comprender la obligación misma, sus intereses y costas.

Este derecho que tiene el deudor de libentar sus bienes, no es aplicable si lo embargado es la especie o cuerpo cierto debido, porque ahí al acreedor sólo se le satisface mediante la entrega de dicho cuerpo cierto.

Esta liberación de los bienes de parte del deudor, significa ponerle término al juicio, porque por esta liberación el deudor reconoce la obligación y la paga. Esta es la gran diferencia que hay entre la liberación del embargo y la sustitución del embargo; en ambos casos hay una consignación en dinero en la cuenta corriente del tribunal, pero en la situación de la sustitución el deudor no reconoce la deuda sino que sigue o puede seguir discutiendo la existencia o monto, en tanto que en la liberación el deudor reconoce la deuda y pone fin al respectivo juicio ejecutivo por quedar debidamente satisfecho el acreedor.

La liberación de los bienes embargados sólo se puede realizar hasta antes del remate, ya efectuado que sea éste, este derecho se extingue.

7.10 Características de la administración que realiza el depositario (arts. 514 a 517)

Existe una administración ordinaria y una extraordinaria. El depositario es administrador de los bienes embargados, lo que está dentro de la administración ordinaria. Como regla general no tiene la capacidad de realizar los bienes embargados.

Derivado de su calidad de administrador, debe rendir cuenta de su administración, detallada y documentadamente, al igual que los tutores y curadores. Normalmente sucederá cuando expire su cargo, se le puede exigir rendiciones parciales.

El art. 514 CPC señala que presentada la cuenta, las partes tienen un término de 6 días para repararla, lo que se tramita como incidente.

El depositario tiene derecho a una remuneración, la cual tiene las mismas preferencias que las costas de la causa. Sin embargo, Hay situaciones excepcionales, en que el depositario no tiene derecho a una remuneración (art. 517 CPC):

- Cuando sólo es retencionista de pagar salarios o pensiones.
- Cuando se hace responsable de dolo o culpa grave, en su respectiva gestión

En relación a esta gestión del depositario, es interesante su papel cuando la ejecución recae en moneda extranjera. La moneda chilena debe convertirse en moneda extranjera, y para este efecto el art. 511 CPC da la posibilidad de que sea el propio depositario quien reciba la moneda chilena respectiva, y a través del sistema bancario de la plaza que corresponda la convierta en moneda extranjera; o bien el secretario del tribunal (art. 511 inciso 2 CPC).

Todas las cuestiones que se susciten con el depositario relativas, a la administración de bienes embargados o a la venta, en los casos en que el depositario los pueda realizar, se van resolviendo entre el ejecutante o el ejecutado, y el depositario en audiencias verbales, que tendrán lugar con los que asistan (art. 480 CPC).

7.11 Pago o realización de los bienes embargados.

La situación será distinta según se trate de pago de bienes embargados o realización de los mismos.

El pago de los bienes embargados se da sólo en dos situaciones:

- a) Cuando la obligación es de dinero y lo embargado es dinero, en tal evento no es necesario realizar el bien sino que sólo se procederá al pago respectivo.
- b) Cuando lo embargado es la especie o cuerpo cierto debida que se encontraba en poder del deudor, el pago se realiza entregando al acreedor dicha especie o cuerpo cierto.

7.11.1 Sentencia de pago.

En relación al pago, hay que tener en cuenta la clasificación entre sentencia de pago y sentencia de realización o remate. Será de pago, cuando el bien embargado sea dinero o la especie o cuerpo cierto debida. Será de remate, en todas las demás situaciones en que sea necesario un proceso de liquidación o realización de bienes para satisfacer las pretensiones del acreedor.

También hay que tener presente que si no se han opuesto excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo sustituye a la sentencia en cuanto a sus efectos (sea de pago o de remate) según sea la naturaleza de los bienes embargados.

a) Si la sentencia es de pago y lo embargado es dinero (que está depositado en la cuenta corriente del tribunal), por regla general, se procederá al pago desde que dicha sentencia se encuentre ejecutoriada. Excepcionalmente se podrá proceder al pago cuando lo embargado es dinero, aun si hay recursos pendientes, siempre que el ejecutante caucione a satisfacción del tribunal las resultas del recurso, lo que significa que de prosperar la apelación el ejecutante procederá a la restitución de los dineros recibidos. Si el bien embargado es dinero y **no se oponen excepciones**, transcurrido que sea el plazo para oponerlas, se puede de inmediato proceder al pago mediante el giro del respectivo cheque.

b) Si la sentencia es de pago y lo embargado es la especie o cuerpo cierto debida, no se puede proceder al pago, sino cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada. En este caso, el ejecutante no tiene la posibilidad de ofrecer caución para que la sentencia se cumpla entre tanto.

Si la ejecución recae sobre la especie o cuerpo cierto debida, y el ejecutado no opone excepciones, se puede proceder a la entrega transcurrida que sea el plazo para oponer excepciones.

7.11.2 Sentencia de realización de bienes o de remate

Se da cuando lo embargado no es dinero, ni es la especie o cuerpo cierto debida, sino que otra clase de bienes debiendo procederse a su realización.

Dentro del universo de bienes embargables, hay una enorme gama de bienes no todos sujetos al mismo método de realización. En consecuencia, para determinar cómo debe efectuarse la realización de los bienes embargados hay que distinguir situaciones en función de la calidad o naturaleza del respectivo bien:

- Bienes muebles sujetos a corrupción, próximo deterioro o difícil conservación.
- Efectos de comercio (acciones, bonos, opciones de acciones, etc.).
- Demás bienes muebles.
- Bienes que requieren previa tasación, y especialmente bienes inmuebles.

7.11.3 Bienes muebles sujetos a corrupción, próximo deterioro o dispendiosa conservación.

Art. 483 CPC. Venderá el depositario en la forma más conveniente, sin previa tasación, pero con autorización judicial, los bienes muebles sujetos a corrupción, o susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

En estos casos, aun antes de la dictación de la sentencia de remate, el depositario puede vender estos bienes, sin previa tasación, incluso en venta privada, requiriendo sólo autorización del respectivo tribunal.

Evidentemente, el depositario deberá rendir cuenta de su administración y de esta enajenación y estará sujeto a sanciones si se ha comportado de manera indebida.

Esta realización la efectúa el depositario sin esperar la sentencia, sino que a partir del embargo mismo dándose las condiciones objetivas que señala la disposición.

7.11.4 Valores mobiliarios o efectos de comercio.

Art. 484 CPC. Los efectos de comercio realizables en el acto, se venderán sin previa tasación, por un corredor nombrado en la forma que establece el artículo 414.

La realización se efectúa por un corredor, y al corredor que se refiere estas norma no es al mismo que se refiere el Código de Comercio, que también contempla el corretaje como posible actividad mercantil; al corredor que se refiere el C.P.C. es al corredor visualizado en la ley de mercado de capitales (Ley Nº 18.045).

La liquidación de estos bienes debe realizarse, sin previa tasación, por remate en bolsa, actividad regulada no tan sólo por disposiciones de la autoridad, sino que también por disposiciones de las respectivas bolsas de comercio.

El corredor en este caso, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y se le designa de la misma forma que a los peritos, así debemos entender la remisión al art. 414 CPC, de esta manera, el tribunal cita a una audiencia que se lleva a cabo con quienes asistan a ella, si hay acuerdo entre las partes se designará al corredor consensuado, de no ser así, será el propio tribunal quien lo designará.

Estos bienes no podrían ser realizables por el depositario antes de la dictación de la sentencia, por estar sujetos a pronta corrupción, porque la pronta corrupción se refiere a características intrínsecas del respectivo bien, no a circunstancias de mercado que puedan traer como consecuencia deterioro de su valor (Profesor).

7.11.5 Demás bienes muebles

Art. 482. *Los bienes muebles embargados se venderán en martillo, siempre que sea posible, sin necesidad de tasación. La venta se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda.*

Se venderán a través de martillero designado por el tribunal.

Lo interesante es que este martillero, cuando se realiza la venta emite una factura, y muchas veces cuando se trata de bienes sometidos a alguna forma de registro, como son los vehículos motorizados, la factura del martillero que se vincula a la ejecución es título suficiente para que el registro la acepte, y se entienda hecha la transferencia del ejecutado propietario del vehículo al nuevo dueño.

Respecto de esta situación existe una pequeña excepción: cuando se embarga ganado, existen reglas especiales, en el sentido que quien debe realizar la subasta es la feria respectiva.

7.11.6 Los bienes raíces y los demás bienes que requieran tasación (art. 485 CPC)

El legislador no hace una enumeración taxativa, pero indudablemente se refiere a los bienes inmuebles, porque la regulación posterior hace constante mención a los bienes inmuebles. Pero también se ha entendido que esta forma de realización alcanza a otros bienes, que propiamente no son bienes inmuebles, pero que son asimilables a bienes inmuebles; por ejemplo, cuando se trata de rematar derechos de agua (o de aprovechamiento).

Como no existe una enumeración taxativa, ha sido la creación jurisprudencial la que ha ido determinando en qué medida este sistema de previa tasación y realización es también aplicable a otras categorías de bienes.

Esta forma de realización, tiene dos características esenciales:

a) Su forma de realización es un trámite complejo, largo y solemne. Aquí el legislador claramente visualizó un tratamiento especial sobre los bienes raíces, porque todo lo relacionado con transferencia de bienes raíces es solemne y por ello toda liquidación de bienes raíces es solemne.

b) La subasta la realiza el propio juez de la causa, y muy excepcionalmente el juez del lugar donde se encuentre el respectivo bien (art. 485 CPC).

Esta tramitación de bienes embargados que para su realización requieren previa tasación, es particularmente compleja, y los trámites que deben cumplirse son los siguientes:

- Tasación;
- Bases del remate;
- Día y hora de la subasta;
- Redacción y publicación de avisos;
- Caución y remate mismo;
- Acta de remate;
- Escritura pública de remate;
- Consignación, liquidación y pago.

A. Tasación.

De acuerdo al art. 486 se tiene en principio como tasación la que figure en el rol de avalúo vigente para los efectos de “la contribución de haberes”, denominación arcaica que es el antecedente tributario de la actual contribución de bienes raíces (avalúo fiscal).

No obstante este avalúo fiscal al ejecutado (sólo a él) le cabe el derecho de impugnar este avalúo y solicitar que se realice uno nuevo.

Este nuevo avalúo debe realizarse por peritos designados de acuerdo a las reglas generales (acuerdo de las partes, el tribunal en subsidio).

Sin necesidad de citación, este comparendo de designación se realizará al segundo día de notificada que sea la sentencia, o sea, notificada que sea la sentencia de remate. Pero en la práctica esto no ocurre, porque la fijación del avalúo fiscal como base del remate es consecuencia de las bases del remate, que es una actuación autónoma, de manera que esta norma pasa a ser letra muerta.

Art. 486. *La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que se haga nueva tasación.*

En este caso la tasación se practicará por peritos nombrados en la forma que dispone el artículo 414, haciéndose el nombramiento en la audiencia del segundo día hábil después de notificada la sentencia sin necesidad de nueva notificación.

En el caso que la designación de peritos deba hacerla el tribunal, no podrá recaer en empleados o dependientes a cualquier título del mismo tribunal.

Puesta en conocimiento de las partes la tasación, tendrán el término de tres días para impugnarla.

De la impugnación de cada parte se dará traslado a la otra por igual término.

Evacuado el informe de peritos, se pone en conocimiento de las partes, quienes tienen un plazo de tres días para realizar las impugnaciones correspondientes, vencido el plazo hayan o no las partes expresado lo conveniente a su derecho, el tribunal podrá (art. 487 CPC):

- Aprobar la tasación, no obstante las impugnaciones.
- Ordenar se rectifique la tasación indicando los puntos específicos, por el mismo o por otro perito.
- Fijar el mismo tribunal, el justo precio.

Cualquiera sea el camino que el tribunal siga, estas resoluciones son inapelables. Y si se realiza la rectificación ordenada por el tribunal, esta rectificación se mantendrá como definitiva sin aceptarse nueva reclamación.

Aprobada que sea la tasación deberá fijarse día, hora y lugar para la subasta.

Se ha planteado si por la circunstancia de que el ejecutante acompañe un certificado de avalúo vigente y el ejecutado no lo impugne durante el término de citación, se entiende o no aprobada la tasación fiscal

para el remate. Se ha dicho por algunos, que sí. Para otros, esto no es así, porque en definitiva la tasación que se exige es consecuencia de las bases del remate.

B. Bases del remate.

Las bases del remate son una actuación de carácter procesal, ya que en función de dichas bases posteriormente se realizará la subasta, y además, son las condiciones del contrato de compraventa, en que el ejecutante será el vendedor y el subastador será el comprador.

En este contrato *sui generis* de compraventa, el ejecutado está representado legalmente por el juez para los efectos de prestar su consentimiento. Este contrato de compraventa no es un contrato de libre discusión, sino que es un contrato de adhesión por parte del subastador, ya que tiene la posibilidad sólo de decir compro o no compro, pero no tiene la posibilidad de modificar las condiciones del respectivo contrato de compraventa, ya fijadas por las bases del remate.

Las bases del remate, son propuestas por el ejecutante, y frente a ellas el ejecutado tendrá un derecho de impugnarlas, de esta impugnación resultarán en definitiva las bases del remate. Así, si son rechazadas las impugnaciones, las bases del remate nacerán de la proposición más la resolución que, total o parcialmente, acepta la impugnación.

B.1) Menciones de las bases del remate.

a) Individualizar de manera inequívoca el bien de que se trate. Si se trata de un bien raíz, la individualización comprenderá la precisa indicación de las inscripciones correspondientes.

b) Precio y las condiciones de pago, que generalmente será de contado; excepcionalmente, cuando así aparezca de manifiesto, será posible que se fije otra forma de pago y al fijarse otra forma de pago las bases del remate deberán contener:

- la época en que deban efectuarse los respectivos pagos;
- los intereses incorporados;
- los reajustes en su caso; y

c) Todas las otras menciones necesarias e indispensables, como por ejemplo, que las contribuciones atrasadas de bienes raíces sean de cargo del subastador, o cuándo se realizará la entrega material del respectivo bien.

B.2) Limitaciones a las bases de remate.

a) En general, el precio de la subasta debe pagarse al contado; salvo que las partes acuerden o que el tribunal por motivo fundado resuelva lo contrario;

b) Las posturas para la subasta deben ser por lo menos $\frac{2}{3}$ del avalúo respectivo; salvo se haya resuelto otra cosa al fijarse las bases del remate (art. 493 CPC);

c) Se debe fijar caución para participar en la subasta, la cual debe ser calificada por el tribunal y será equivalente al 10% de la tasación. De esta manera, todo posible postor debe rendir dicha caución, y esta

caución respecto del subastador subsistirá hasta la suscripción de la escritura definitiva de compraventa, o hasta el pago total del precio en su caso.

La forma como la caución debe constituirse, estará expresada en las bases del remate, y así por ejemplo, la caución podrá ser un vale vista a la orden de tribunal por dicho 10%, o un depósito equivalente por aquella cantidad, o la que el tribunal tenga a bien determinar al pronunciarse sobre las bases del remate.

El remate se realizará en un día y hora determinado, en el recinto del tribunal, y ahí los posibles interesados comparecen ante el secretario, cada uno de ellos van rindiendo su respectiva caución. Lo más conveniente, es que cuando se exija el vale vista a la orden del tribunal, el subastador saque un vale vista en su propio beneficio y lo endose a la orden del tribunal para responder como caución al remate.

Terminado que sea el remate, el adjudicatario debe mantener su caución en poder del tribunal, hasta el otorgamiento de la escritura definitiva del pago de la subasta en su caso. A los demás participantes inmediatamente se les devolverá su caución.

C. Día, hora y lugar para la subasta.

Aprobada la tasación se señalará día y hora para la subasta (art. 488).

Respecto del lugar, la regla general es que la subasta se realice en el recinto y por el propio tribunal que conoce de la causa. Excepcionalmente, este tribunal puede autorizar que la subasta se realice en el lugar donde el bien se encuentre.

Respecto del día de la subasta, debe fijarse en función de los avisos que deben publicarse, ya que la ley ordena un mínimo de avisos, y que entre el primer aviso y el día de la subasta medie un plazo mínimo; en consecuencia, de acuerdo a estos plazos y a la necesidad de publicar los avisos es que se fija efectivamente el día en que debe realizarse la subasta.

D. Redacción y publicación de avisos.

Art. 489. *El remate, con el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos publicados, a lo menos por cuatro veces, en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere. Los avisos podrán publicarse también en días inhábiles. El primero de los avisos deberá ser publicado con quince días de anticipación, como mínimo, sin descontar los inhábiles, a la fecha de la subasta.*

Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella o en la capital de la respectiva región, si fuere el caso, por el mismo tiempo y en la misma forma.

Los avisos serán redactados por el secretario y contendrán los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse (bases del remate).

Debe redactarlos el secretario del tribunal, y deben publicarse a lo menos cuatro veces en un diario de la comuna donde tenga su asiento el tribunal, o de la provincia, o subsidiariamente de la capital de la región.

Los avisos pueden publicarse en días inhábiles, y el primero de ellos debe anteceder en 15 días al del remate, sin descontar en estos 15 días, los días festivos (inciso 1º). Si el inmueble se encuentra en otro lugar distinto a aquel en que tenga su asiento el tribunal, el remate se anunciará además, en la misma forma y por el mismo tiempo, en el lugar donde se encuentre ubicado el inmueble, ya sea en el diario de la comuna o en el diario de la capital de la región (inciso 2º).

E. Caución y remate.

En las bases del remate se determina cómo debe rendirse la caución. No hay inconveniente en que las bases del remate señalen una alternativa, como por ejemplo, que la caución pueda ser en dinero o en un vale vista a la orden del tribunal. Si se suscita discusión entre los partícipes respecto de la caución, de plano resuelve el tribunal, aceptando la caución o rechazándola y, en consecuencia, no admitiendo a una determinada persona como posible subastador.

Inmediatamente de constituidas las cauciones se realiza el remate, se hace llamar por el oficial de sala, y pasan los postores, el juez individualiza el bien, nombra a los participantes y comienza la subasta hasta que en definitiva, quien ofrezca el mayor precio se adjudique el bien.

Es importante destacar, lo que es aceptado por la práctica y autorizado por la ley sustantiva, de que una persona acceda a la subasta pero que al momento de rematar remate por otro, en Derecho Civil es un mandato a nombre propio.

Realizada que sea la subasta, queda sólo el subastador en el recinto del tribunal, a los demás postores se les devolverá su caución. El tribunal, mantendrá la caución hasta la suscripción de la escritura definitiva de compraventa o hasta la consignación de la totalidad del precio. Inmediatamente después del remate debe suscribirse el acta de remate (art. 495 inciso 2º y 496 CPC).

F. Acta de remate.

El acta de remate es indispensable tratándose de bienes raíces, y así debe entenderse la remisión al art. 1801 C.C., que señala que tratándose de compraventa de bienes raíces la escritura pública es solemnidad. En este caso excepcional, el acta de remate vale como escritura pública, de manera que del contrato de compraventa se deja testimonio en el acta de remate, la que se extiende en el libro que al efecto debe llevar el secretario del tribunal.

El acta de remate, señalará que en el día determinado, de la hora determinada, en el juicio “tal”, se efectuó la subasta del bien “x”, que fue adjudicado a don N.N. en la cantidad de “tanto”.

El acta de remate será firmada por el juez de la causa, por el subastador, y por el secretario del tribunal y queda incorporada al libro especial que el secretario lleva al efecto.

Sin perjuicio del acta de remate, debe posteriormente otorgarse escritura de remate, o sea, la inscripción que debe realizarse en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del subastador, no se hace exhibiéndole copia autorizada del acta de remate, sino que debe exhibirse copia autorizada de la escritura de remate, la cual no es más que la manera de solemnizar una compraventa ya realizada.

Es interesante recordar el art. 496 CPC referido al acta de remate, que permite específicamente la intervención de un tercero, que señala el nombre de la persona en beneficio de la cual está subastando.

Como es una estipulación a favor de otro regulada por el C.C., y el C.P.C. el tercero sólo adquiere responsabilidad si ratifica lo actuado por ese mandatario que ha actuado a nombre suyo; si no existe ratificación subsiste la responsabilidad del subastador (art. 496 C.P.C.).

Si el subastador no suscribe la escritura de remate o no realiza el pago correspondiente, se hace efectiva la caución y la pierde (art. 494 inciso 2º CPC). Y de esta caución, se deducen las costas del remate, que naturalmente se entregarán al ejecutante que ha incurrido en los costos de publicación, y el remanente se divide:

- el 50% se entrega al ejecutante en abono de su crédito,
- el otro 50% va a la Junta de Servicios Judiciales.

En todo lo que dice relación con la subasta, el subastador puede incidentar, por ejemplo, al momento que se le quiere hacer efectiva la caución, y los incidentes que tramite serán resueltos por el tribunal. Y las apelaciones que deduzca el subastador, serán resueltas en el solo efecto devolutivo (inciso final art. 494 CPC).

G. Escritura pública de remate.

La escritura de remate debe extenderse dentro de tercero día. La redacción del art. 495 CPC es oscura, porque dice que la escritura de remate debe realizarse dentro de tercero día, pero no señala desde qué momento deben contarse estos tres días. Y si se fuera más exigente, se podría concluir que el tercero día se cuenta desde el día del remate, en que se otorga el acta de remate. Pero esto no es así, sino que el tercero día se cuenta desde que queda ejecutoriada o cause ejecutoria, la resolución del tribunal que ordena extender escritura de remate.

No obstante la forma en que se ha redactado la norma, se ha entendido que el plazo es no fatal, de manera que válidamente podrá suscribirse la escritura de remate aunque hayan transcurrido estos tres días.

Firma la escritura pública el subastador, y el juez en representación del ejecutado. La confección de la escritura es de cargo del subastador, pues es a él a quien le interesa que ésta quede perfecta

Las menciones que deben ir insertas en la escritura son:

- a) Inserción de los antecedentes que acrediten la válida relación procesal (emplazamiento).
- b) Las bases del remate, y la resolución ejecutoriada o que cause ejecutoria de las bases del remate.
- c) Inserción completa del acta de remate.
- d) Certificado de notificación de la sentencia de remate, o de la circunstancia de que no se opusieron excepciones.
- e) Certificado de publicación de avisos.
- f) Resolución que ordena extender escritura de remate, y certificado de ejecutoria de dicha resolución.
- g) Certificado de haberse consignado el precio.
- h) Individualización del bien y de sus respectivos deslindes e inscripciones.
- i) Si ha mediado purga de la hipoteca, debe también dejarse testimonio en la escritura de los trámites realizados en función de dicha purga, para los efectos que el Conservador de Bienes Raíces respectivo haga las cancelaciones de las inscripciones hipotecarias respectivas.
- j) Y en general todos aquellos antecedentes que sean indispensables o convenientes para demostrar que efectivamente se han cumplido a cabalidad los requerimientos respectivos.

Es importante tener presente que, aunque la ley no lo dice, la práctica ha aceptado que sea subastador el propio ejecutante; esta circunstancia debe constar en las bases del remate, caso en el que se dirá que, sin necesidad de caución, podrá ser subastador el ejecutante con cargo a su crédito. Por lo tanto, no es necesario un desembolso previo para la caución, ni para el pago de la subasta, produciéndose así una compensación.

Se debe revisar cuidadosamente la escritura de remate, y si efectivamente se encuentra conforme a los antecedentes la suscribe el juez en su propio despacho (no se va a la notaría para la suscripción). El subastador va, inmediatamente después, con su escritura al Conservador de Bienes Raíces, para solicitar la inscripción a su nombre, para todos los efectos de realizar la tradición.

G.1) Validez o nulidad del remate.

El remate, consecuencia de una ejecución forzada reviste una doble característica: actuación procesal dentro del juicio ejecutivo y contrato de compraventa, en que es vendedor el ejecutado representado por el juez, y es comprador el subastador, que puede ser un tercero o el propio ejecutante.

La validez o nulidad de este acto se encuentra regulada por dos conjuntos de disposiciones: como acto de carácter procesal y como contrato de compraventa.

Como acto procesal que es, puede ser impugnado por la vía de la nulidad procesal, pudiendo el acto ser ineficaz por inobservancia de las regulaciones que, en definitiva, norman el respectivo acto; por ejemplo, no se publicaron los avisos oportunamente, no se rindió la caución, no se firmó el acta de remate o no se firmó oportunamente la escritura de remate. La jurisprudencia ha creado una razón

adicional de preclusión, en el sentido que ningún incidente de nulidad procesal del remate, puede ser tramitado después que queda ejecutoriada la resolución que ordena extender escritura pública.

Pero el remate puede ser impugnado, en cualquier momento posterior, por la vía de la nulidad civil; y así por ejemplo, si el subastador era una persona que no podía comprar, que estaba inhabilitado para comprar, por ejemplo, el abogado del ejecutante (caso específico de inhabilidad contemplado en el Código). No es posible alegar nulidad de un remate por lesión enorme, porque existe una completa excepción que no la admite para la compraventa que se realiza a través de remates.

El remate judicial, como contrato, puede ser impugnado por inoponibilidad, es decir, no obliga a personas que no concurrieron a él; esta acción se tramita por cuerda separada.

H. Consignación, liquidación y pago.

El art. 509 CPC señala que los fondos provenientes de la realización de los bienes embargados, deben consignarse en la cuenta corriente del tribunal. Como regla general, no se procede al pago al acreedor, si hay apelación pendiente, a menos que este caucione las resultas de la apelación.

Ejecutoriada la sentencia definitiva de realización, se debe realizar la liquidación del crédito; y la operación de liquidación del crédito, es un trámite que lleva a cabo el secretario del tribunal, donde calcula el capital, los intereses, las costas que se hubieren fijado, y llega a una determinada cantidad. La práctica a hecho que se ordene que esta liquidación se ponga en conocimiento de las partes, otorgándoles un plazo de tres días para que hagan las acotaciones correspondientes, y en definitiva el tribunal fijará la cantidad líquida que debe pagarse al acreedor.

7.11.7 Existencia de hipotecas en favor de terceros.

Esta hipótesis supone que el ejecutante pretende pagarse con el producto de un bien raíz, que a su vez está hipotecado a favor de un tercero. Este fenómeno también se produce cuando el ejecutante es acreedor hipotecario y hay otros acreedores hipotecarios.

El derecho real de hipoteca concede al acreedor un derecho de preferencia y de persecución. En virtud del primero, si el bien es realizado el acreedor hipotecario se prefiere a todo otro acreedor y si hay varios acreedores hipotecarios, éstos entre sí se prefieren según el orden de sus respectivas hipotecas. El derecho de persecución, permite al acreedor perseguir el bien para realizarlo y pagarse con el producto de la venta, y este derecho subsiste aunque el bien haya salido del patrimonio del deudor y se encuentre en poder de un tercer poseedor, caso en el cual, desde el punto de vista procesal, existe un procedimiento que se denomina la “acción de desposeimiento contra el tercer poseedor de la finca hipotecada”.

En el juicio ejecutivo, cuando el inmueble que se pretende rematar tiene hipotecas si se aplicara in integrum el principio del derecho de persecución, no habría nunca subastador, porque lo adquiriría hipotecado y el acreedor hipotecario, titular del derecho real de hipoteca, lo podría perseguir su crédito mediante la acción de desposeimiento.

Frente a esta situación, el legislador del C.C. y posteriormente el del C.P.C., idearon el mecanismo de “*la purga de la hipoteca*”.

A. La purga de la hipoteca.

Etimológicamente purgar significa limpiar, purificar, por eso la purga de la hipoteca busca limpiar la hipoteca, de suerte que el subastador cuando compra el bien, se entiende que lo compra sin las hipotecas anteriores.

Las dos disposiciones que rigen este instituto son los arts. 2428 C.C. y 492 C.P.C. Estas disposiciones son de distinto tenor; la disposición del C.C., es importante tenerla presente sólo por razones de carácter histórico, porque lo que rige es la norma del C.P.C, que es modificadora o quizá derogatoria tácitamente de la norma del C.C.

Artículo 492. Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente citados conforme al artículo 2428 del Código Civil, podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados.

No diciendo nada, en el término del emplazamiento, se entenderá que optan por ser pagados sobre el precio de la subasta.

Si se ha abierto concurso a los bienes del poseedor de la finca perseguida, o se le ha declarado en quiebra, se estará a lo prescrito en el artículo 2477 de dicho Código.

Los procedimientos a que den lugar las disposiciones anteriores se verificarán en audiencias verbales con el interesado o los interesados que concurran.

El art. 492 C.P.C., regula la situación que se produce cuando el ejecutante es un acreedor hipotecario de grado posterior, en relación con los acreedores hipotecarios de grado preferente. Sin embargo, se ha estimado también que esta norma es enteramente aplicable cuando el acreedor ejecutante no es acreedor hipotecario, y en consecuencia se aplica o afecta a los acreedores hipotecarios del respectivo bien.

Asimismo hay que señalar que el art.492 C.P.C. tiene dos ámbitos de aplicación diversa:

A.1) Ejecución individual sobre el bien hipotecado (art. 492 incisos 1°, 2° y 4°).

Esta situación se presenta cuando es UN acreedor el que está persiguiendo el pago de su acreencia. En este los requisitos para que se produzca la purga de la hipoteca son:

i) *Debe tratarse de la venta de un bien raíz en remate público a consecuencia de un juicio ejecutivo.* El art. 2492 C.C. se refiere a “pública subasta”, por lo que hay que hacer el siguiente alcance: la pública subasta ordenada por el juez puede ser consecuencia de un título ejecutivo o bien puede ser consecuencia de una gestión no contenciosa, esto ocurre cuando la ley ordena en ciertos casos que bienes de los incapaces sean enajenados en pública subasta. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que la purga de la hipoteca sólo se produce cuando la enajenación del bien en pública subasta es consecuencia de la ejecución forzada en un juicio ejecutivo.

ii) *Que antes del remate se haya citado personalmente a los acreedores hipotecarios para que expresen lo conveniente a sus derechos.* Se ha entendido por citación personal sólo cuando el acreedor hipotecario es notificado personalmente o por el artículo 44 del C.P.C.

iii) *Que entre la citación al acreedor hipotecario y el remate, por lo menos haya mediado el término de emplazamiento.* La jurisprudencia mayoritaria ha estimado que cuando el C.C. y el C.P.C. se refieren al término de emplazamiento hay una remisión al término de emplazamiento del juicio ordinario de mayor cuantía (15 + 3 + TE).

Si al acreedor hipotecario no se le cita en la forma prescrita y transcurre el plazo para que haga uso de sus derechos, la sanción no es la nulidad del remate sino que las hipotecas no se purgan, en consecuencia, el subastador adquiere el bien con los gravámenes intactos y ese bien seguirá respondiendo de la respectiva acreencia hipotecaria.

De acuerdo a las normas del C.C., concurriendo los requisitos indicados, necesariamente se producía la purga de la hipoteca y los acreedores hipotecarios debían necesariamente concurrir al pago con el producto del remate, o sea, no podían reservarse sus respectivas hipotecas.

Sin embargo, ese sistema fue modificado por el C.P.C. que permite que los acreedores hipotecarios, en caso de que el ejecutante sea un acreedor valista o un acreedor hipotecario de grado posterior, se reserven el derecho y conserven sus hipotecas. Es decir, tienen un derecho alternativo: conservar sus hipotecas, siempre que sus créditos no sean exigibles; o bien, pagarse con el producto del remate. Este derecho para optar por conservar la hipoteca o pagarse con el resultado del remate, deben hacerlo valer dentro del término de emplazamiento, entendiendo que su silencio significa que opta por pagarse.

Todas las cuestiones que se susciten entre los acreedores hipotecarios y el ejecutante deben ser resueltas en audiencias verbales a las cuales citará el tribunal.

A.2 Ejecución colectiva sobre el bien hipotecado (art. 492 inciso 3°).

La ejecución colectiva se aplica cuando el deudor se encuentra en quiebra o se ha abierto concurso (cesión de bienes).

La ejecución colectiva desencadena una serie de mecanismos que van destinados a la realización de todos los bienes del respectivo deudor y repartir lo producido entre los acreedores en función de sus respectivas preferencias.

Los créditos se dividen en dos grandes grupos: los créditos valistas y los créditos preferentes; estos últimos a su vez se dividen según la preferencia la que puede derivar de un privilegio o de una hipoteca.

La regla general es la ejecución colectiva ordenada, más o menos simultánea, de todos los bienes del deudor. Sin embargo, si entre los bienes del deudor hay bienes raíces que están gravados a diferentes acreedores hipotecarios, se puede producir lo que denomina “el concurso particular de hipotecarios”, donde la ejecución respecto del bien hipotecado se circunscribe sólo a dichos acreedores hipotecarios; y

en consecuencia, separadamente del resto del patrimonio se produce esta realización del bien siguiendo las mismas normas del juicio ejecutivo.

7.11.8 Ausencia de postores

Si no se presentan interesados al primer remate, a los sucesivos remates se deberá también notificarse a los acreedores hipotecarios la cual debe hacerse personalmente, ya que la ley no distingue y también como medida de protección.

Art. 499: “Si no se presentan postores en el día señalado, podrá el acreedor solicitar cualesquiera de estas dos cosas, a su elección:

1º Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes embargados; y

2º Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo.”

En virtud de la norma transcrita, al acreedor le surge un derecho alternativo:

- Que se le adjudique a él la propiedad por los 2/3 de la tasación
- Que se reduzca prudencialmente dicha tasación o avalúo, y se llame a un nuevo remate, advirtiendo el legislador, que esta reducción prudencial no puede exceder de la tercera parte de dicha evaluación.

El acreedor tiene este derecho de pedir que se le adjudique el bien en las 2/3 partes del avalúo, porque el mínimo de las posturas en el primer remate es de 2/3 del avalúo; en consecuencia, se le adjudica el bien al acreedor por el mínimo de las posturas posibles.

Jurídicamente, el acto en virtud del cual se le adjudica el bien al acreedor, es una dación en pago, y en consecuencia, el crédito de la deuda se extingue hasta concurrencia del monto o valor de la dación en pago.

Si ha de procederse a un nuevo remate, el avalúo se reduce en 1/3 y de acuerdo con lo establecido en el art. 502 CPC, el plazo para la publicación de avisos se reduce a la mitad, pero no se procederá a esta reducción de plazo, si han transcurrido más de tres meses entre el primer remate fracasado y el inmediatamente posterior.

Si no se presentan postores al segundo remate, el art. 500 dispone que surgen para el acreedor tres posibles caminos:

- a) Que se le adjudique el bien en el nuevo avalúo, o sea, en el avalúo reducido.
- b) Que se saque nuevamente a remate al bien, en este caso, por el mínimo que el tribunal señale.
- c) Que se le entregue en prenda pretoria.

El inciso final del art. 500 CPC, señala que para optar por la dación en pago del respectivo bien, cuando se trata de una ejecución en moneda extranjera, debe previamente llevarse esta obligación a moneda nacional, mediante el respectivo certificado de paridad bancaria.

La prenda pretoria, se denomina también “anticresis judicial”. Para entender la anticresis judicial, es necesario referirse previamente a la anticresis civil, institución que está regulada en los arts. 2435 y ss. C.C., y que tiene muy poca aplicación práctica.

La anticresis es un contrato en virtud del cual, el deudor entrega un determinado bien al acreedor, que también puede ser un bien raíz, para que éste lo administre y se pague de su respectiva acreencia con los frutos. La anticresis, no otorga al acreedor que recibe el bien un derecho real, sino que simplemente un derecho personal y tampoco le otorga preferencia, de ninguna especie. Son estas dos limitaciones las que han determinado la obsolescencia de esta institución, porque el acreedor que recibe el bien por la anticresis, puede ser privado del bien por otros acreedores.

Esta institución del Derecho Civil, ha sido llevada al Derecho Procesal, y cuando en el segundo remate no se presentan postores, uno de los derechos alternativos del acreedor es solicitar que el bien se le entregue en prenda pretoria. En tal evento, el acreedor pasa a ser administrador del bien y como tal debe rendir cuenta periódica de su administración; en la cuenta de su administración, el colacionará las inversiones que realice para que el bien produzca frutos, y además puede colacionar una cantidad prudencial por honorarios o remuneración por la administración, y se puede incluso estipular, que los frutos primero se aplican al pago de los intereses, y sólo satisfechos estos, se van imputando al capital.

Esta es una situación trágica para el deudor: es desposeído del bien, el bien es explotado por el acreedor para pagarse, tiene que pagarle la administración por el bien, y la posibilidad de recuperarlo se posterga indefinidamente. El legislador comprende esta situación, y en el art. 501 CPC dice que si el acreedor impetra su derecho de que el bien se le entregue en prenda pretoria, tiene sin embargo el deudor, el derecho de solicitar que se saque el bien a remate por última vez, sin mínimo para las posturas.

Es importante también tener presente que la normativa que la regula, son los arts. 503 a 506 C.P.C. primeramente, y subsidiariamente como lo señala el art. 507 CPC, el Título XXXIX del Libro IV, arts. 2435 y ss. C.C. Cabe tener presente también, que no obstante haberse constituido el bien en prenda pretoria, se puede poner término a esta situación tanto a requerimiento del acreedor como a requerimiento del deudor, quien debe pagar todo el crédito y todo lo que el acreedor hubiese invertido para que el bien produjera frutos.

Además, en virtud del art. 507 CPC, si la prenda pretoria se constituye sobre bienes muebles, se entiende que es constituido también en prenda. Pero la regla general, cuando se trata de inmuebles, es que no constituyen preferencia de ninguna clase para el acreedor.

El art. 508 C.P.C., contempla una situación muy curiosa, que dice relación también con la prenda pretoria, pero no exclusivamente se refiere a ella:

Art. 508: *“Si los bienes embargados consisten en el derecho de gozar una cosa o percibir sus frutos, podrá pedir el acreedor que se dé en arrendamiento o que se entregue en prenda pretoria este derecho.*

El arrendamiento se hará en remate público fijado previamente por el tribunal, con audiencia verbal de las partes, las condiciones que hayan de tenerse como minimum para las posturas.

Se anunciará al público el remate con anticipación de veinte días, en la forma y en los lugares expresados por el artículo 489.”

Esta situación se refiere a cuando el bien embargado es un derecho real de usufructo. Cuando se embarga el usufructo, éste no es enajenado, o sea, no se puede sacar a remate para que un tercero adquiera este usufructo, sino que puede ser entregado al acreedor en prenda pretoria, para que se pague con los frutos, o bien puede ser subastado el derecho a arrendar el usufructo.

Es en este último caso, en que surge la siguiente situación: el usufructuario deja de recibir los frutos, y es el arrendatario quien los percibe; y el acreedor percibe la renta de arrendamiento.

Este arrendamiento se adjudica en remate, en donde se adquiere la calidad de arrendatario del respectivo bien.

Tema 8: Las Tercerías.

Todo el juicio ejecutivo está necesariamente constituido por dos cuadernos: el cuaderno principal o ejecutivo y el cuaderno de apremio, pero pueden surgir otros cuadernos, que son los de tercerías.

Es necesario tener presente la distinción entre las tercerías en la generalidad de los procedimientos y las tercerías en el juicio ejecutivo. En la generalidad de los procedimientos, las tercerías son admitidas sin mayores restricciones, siempre que el tercero tenga un derecho comprometido en la *litis*, y no tan sólo una mera expectativa. Se ha dicho que hay interés o derecho comprometido, cuando hay un contenido patrimonial en la pretensión que hace valer este tercero.

Este tercero puede asumir tres conductas distintas:

- **Tercero Coadyuvante:** es aquel cuyo interés comprometido es congruente ya con el interés del demandante, ya con el interés del demandado.
- **Tercero Excluyente:** es aquel que sostiene un derecho propio, incompatible con el del demandante y el del demandado.
- **Tercero Independiente:** es aquel que sostiene un derecho propio, pero que si es compatible con el demandante o con el demandado.

La gran diferencia entre las tercerías en general y las tercerías del juicio ejecutivo, es que en este último las tercerías están taxativamente numeradas por el legislador, de suerte que no es admisible otra

categoría de tercería, sino aquellas que precisamente se enmarcan en una de las cuatro que el legislador específicamente acepta. Este carácter de taxatividad de las tercerías, aparece de manifiesto en el art. 518 inciso 1º “En el juicio ejecutivo **sólo** son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende...”

Las cuatro categorías de tercerías que se admiten en el juicio ejecutivo son:

- Tercería de Dominio: el tercerista de dominio pretende dominio sobre el o los bienes embargados.
- Tercería de Prelación: el tercerista de prelación, pretende preferencia para pagarse sobre el producto de la enajenación antes que el ejecutante.
- Tercería de Pago: el tercerista de pago pretende concurrir al pago de su crédito, conjuntamente y a prorrata con el ejecutante.
- Tercería de Posesión: el tercerista de posesión, pretende que se le reconozca posesión sobre el bien embargado, y en consecuencia quedará cubierto con la presunción de dominio que ampara al poseedor.

8.1 Naturaleza jurídica de las tercerías.

Las tercerías se tramitan en ramo separado; y la tercería de dominio se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, con excepción de los escritos de réplica y dúplica. Esta circunstancia ha hecho pensar a algunos que las tercerías, particularmente la de dominio, son juicios dentro del juicio ejecutivo, y si se acogiese esta teoría habría consecuencias de gran importancia, por ejemplo, los poderes otorgados en el juicio ejecutivo no serían suficientes para ser usados en las tercerías; o se podría dictar autónomamente el abandono del procedimiento.

Mayoritariamente se ha llegado a la conclusión que las tercerías no son juicios independientes, sino que incidentes dentro del juicio ejecutivo.

Se ha dicho que cuando se trata de discutir el dominio de un bien, se requiere de un procedimiento de lato conocimiento por la envergadura de la decisión que se adopta.

8.2 Tercería de Dominio

El tercero pretende dominio sobre el bien embargado, en consecuencia es un tercero excluyente toda vez que su interés es incompatible con el del ejecutante y del ejecutado.

Además del dominio, existen otros derechos que se pueden hacer valer recurriendo al procedimiento de la tercería de dominio; y el primer derecho que admite este tratamiento es el derecho del comunero cuando se ha embargado la cosa común, aquí tenemos que distinguir dos situaciones que están separadamente tratadas por el legislador:

- a) El derecho del comunero cuando se ha embargado la cosa común.
- b) El derecho de los copropietarios cuando se ha embargado la cuota del ejecutado.

Respecto del embargo de la cosa común, considerando que pertenece a dos o más personas, en tal evento, el comunero que ve embargada la cosa común, puede con el argumento de la tercería de dominio, reclamar para que se declare que el embargo es sólo sobre la cuota y no sobre el bien todo (art. 519 inciso 1° C.P.C.)

Por mandato del art. 520 C.P.C., hay otros derechos que puede hacer valer el ejecutado, recurriendo al procedimiento de la tercería de dominio; cosa curiosa, porque técnicamente hablando no es una tercería, porque es el propio ejecutado, quien recurre a dicho procedimiento.

En general, los derechos que el ejecutado puede hacer valer por ésta vía tan particular, dicen relación con los criterios de separación de patrimonios consecuencia de las normas hereditarias. En general el heredero es sucesor del causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, sin embargo para morigerar este principio, que puede traer una serie de consecuencias terriblemente drásticas para el heredero, hay ciertas limitaciones que llevan aparejado separaciones de patrimonio, de manera que en definitiva el heredero no se vea perjudicado por las obligaciones que había contraído en vida el causante.

Todo lo que dice relación con estas situaciones de separación de patrimonios es lo que el ejecutado puede hacer valer en la ejecución, tanto por la vía de la excepción, si procediere, como por la vía del procedimiento de la tercería de dominio, en el entendido que teóricamente no es un tercero.

En el N° 2 del art. 520 CPC, se señala un derecho llamado de representación, que es una ficción jurídica donde el representante ocupa el mismo lugar jurídico que el representado.

El N° 3 expresa la alternativa de o recurrir al procedimiento de la tercería de dominio o hacer valer la correspondiente excepción.

8.2.1 Oportunidad para hacer valer la tercería de dominio.

Debe hacerse valer a partir del embargo, pues ésta es la situación que genera el conflicto para el respectivo propietario de la cosa, y como se desprende del art. 523 CPC, se puede intentar hasta el remate; producido que sea el remate, se extingue la posibilidad de intentar la tercería de dominio. Sin embargo, el propietario que ve perderse su bien por una ejecución iniciada en contra de otro, tendrá siempre en contra del subastador las correspondientes acciones reivindicatorias, o sea, la tercería es una vía (la más expedita) para reclamar dominio sobre la cosa embargada, pero esta vía no es excluyente para que posteriormente, si no se ha intentado la tercería de dominio se intente la vía ordinaria correspondiente.

La sentencia firme que se dicte en la tercería de dominio rechazándola, produce cosa juzgada; y en consecuencia, perdida que sea la tercería de dominio, no puede el propietario intentar por la vía ordinaria la misma acción, porque le opondrían la excepción de cosa juzgada.

El vendedor en el juicio ejecutivo es el ejecutado, o sea, el subastador tiene acción de reembolso contra el ejecutado y no contra el acreedor que se pagó, pero sus expectativas son cercanas a cero, porque si el ejecutado quedó ya en esa situación de perder sus bienes por la vía de remate, la posibilidad que tenga

otros bienes o fortuna para el reembolso son absolutamente remotas, o sea, es el subastador quien corre el gran riesgo.

8.2.2 Efectos de la interposición de la tercería de dominio.

Al respecto hay que distinguir entre efectos en el cuaderno ejecutivo y efectos en el cuaderno de apremio.

Respecto al cuaderno ejecutivo, la regla absoluta es que la interposición de la tercería de dominio no tiene ninguna influencia en él, sigue en consecuencia adelante con la tramitación de las excepciones si las hubo, la prueba, la sentencia y los recursos procesales, todo lo que pase en este cuaderno no es influenciable de manera alguna por haber insertado una tercería de dominio.

Respecto al cuaderno de apremio, la regla general es que la interposición de la tercería de dominio no produce un efecto suspensivo en éste, sigue adelante el apremio con la realización de los bienes embargados, pero con una característica, que el remate no se entiende ejecutado sobre el bien embargado, si no sobre los posibles derechos que sobre el bien embargado tenga el ejecutado (art. 523 inciso 2º CPC).

El subastador, que es el comprador, está comprando los posibles derechos del ejecutado sobre el bien, no el bien; si la tercería de dominio es rechazada, habrá comprado efectivamente el bien, si es acogida, el subastador no habrá comprado nada, o sea, la naturaleza del contrato que celebra el subastador es aleatorio, ya que queda sujeto a que la tercería de dominio prospere o no.

En general se ha aceptado que el subastador, que es un tercero ajeno al juicio, se haga parte como tercero coadyuvante en la tercería de dominio.

Excepcionalmente el apremio, respecto del bien al cual se refiere la tercería de dominio se suspende (y en consecuencia se suspende la realización del bien), cuando la tercería cumpla con dos requisitos copulativamente:

- se apoye en un instrumento público, y
- que éste instrumento público haya sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva.

En relación con el segundo requisito, estamos en presencia de un fenómeno procesal curioso, en general en nuestro derecho la simple presentación de la demanda no acarrea consecuencias jurídicas y todas las consecuencias, esencialmente las interruptivas, se producen a partir de la notificación legal de la demanda; sin embargo, aquí el legislador exige que el instrumento público que sirve de apoyo a la tercería sea otorgado con fecha anterior a la presentación y esto porque, el legislador ve con cierta

desconfianza a este tercerista, y se plantea que si por cualquier vía se infiltró que esta ya presentada una demanda, pudo haber colusión entre el que va a intentar la tercería y el ejecutado, y en consecuencia no acepta ningún instrumento que sea posterior a la presentación de la demanda.

El primer requisito, ha sido muy debatido y analizado; unos sostienen que el instrumento público debe ser precisa prueba del dominio que se ha invocado, y sólo en esa circunstancia sería posible suspender el procedimiento de apremio; sin embargo la posición mayoritaria y recogida por la jurisprudencia es que basta que el instrumento público sea un antecedente verosímil del dominio que se invoca.

Es interesante que el art. 523 inciso 1° señale que la tercería de dominio debe cumplir con los mismos requisitos que la demanda del juicio ordinario de mayor cuantía, y hay una expresa remisión al art. 254 C.P.C.; si no se cumple con estos requisitos la tercería será declarada inadmisible.

Las resoluciones que se dicten en la tercería de dominio, se rigen por las reglas generales de la apelación, con la modalidad que las apelaciones que se interpongan y sean admisibles se concederán en el solo efecto devolutivo (art. 523 inciso final).

Debe destacarse el efecto relativo de la tercería de dominio, en cuanto a que su posible consecuencia suspensiva se produce sólo respecto de los bienes objeto de la tercería, en relación a los demás bienes se sigue adelante su realización, como si la tercería no se hubiese interpuesto (art. 526 CPC).

En la tercería de dominio es demandante el tercero, y demandado el ejecutante y ejecutado (por ello puede ser tercero coadyuvante); en la acción ordinaria el demandante es el tercero y el demandado el subastador.

8.2.3 Embargo del bien común

En virtud del art. 519 el comunero puede, cuando se embarga el bien común, reclamar dominio de su cuota por la vía de la tercería de dominio.

El art. 524 razona a partir del momento en que se embarga la cuota del ejecutado sobre el bien común, o sea no se ha embargado el bien común sino la cuota. Si se embarga la cuota en una comunidad, ya sea de un bien mueble o inmueble, al acreedor se le reconoce un derecho alternativo:

- a) Insta por la realización de la cuota, de acuerdo a las reglas generales sobre realización de los bienes.
- b) Insta por la liquidación de la comunidad; en este caso se produce una subrogación, el acreedor se subroga en los derechos del comunero porque, como regla general, sólo al comunero le corresponde provocar la liquidación de la comunidad, sin embargo aquí a título excepcionalísimo el acreedor se subroga al comunero.

La ley no dice si este derecho de liquidar la comunidad se ejercita en éste juicio ejecutivo o en un procedimiento separado, por lo tanto hay que recurrir a procedimiento separado y por una razón muy fuerte de texto: que la liquidación de una comunidad es de arbitraje forzoso y en consecuencia, no es competente el juez ordinario para abordar la liquidación de la comunidad.

En la liquidación de la comunidad, existe una doble posibilidad en relación a lo que puede pasar con el deudor embargado:

- a) Que el comunero-deudor-ejecutado se adjudique el bien, en tal caso el acreedor embarga el bien.
- b) Que no se adjudique el bien, se convierte en acreedor de los otros comuneros y esta acreencia puede ser embargada por su acreedor.

Sin embargo, este derecho del acreedor de subrogarse al comunero ejecutado y provocar la liquidación puede ser resistido por los demás comuneros, y oponerse a ella (art. 524 CPC):

- a) Cuando exista motivo legal; esto ocurre cuando son legalmente indivisibles y en consecuencia los demás comuneros pueden oponerse, y también cuando se pacte la indivisión (5 años máximo). Al ejecutante le es oponible este pacto de indivisión, porque se está subrogando en los derechos del comunero, y por ende ocupa el mismo lugar jurídico que el ejecutado.
- b) Cuando la liquidación al producirse ocasiona grave perjuicio.

Por la sola circunstancia de interponerse tercería de dominio (regla que también es aplicable a las demás tercerías), el acreedor puede solicitar la ampliación del embargo, en virtud de lo establecido en el art. 456 inciso 2°.

8.2.4 Tramitación de la tercería de dominio.

La demanda, debe cumplir con los requisitos del art. 254 C.P.C. Excepcionalmente, según lo establece el art. 523 CPC, el tribunal de oficio puede declarar inadmisibile la tercería si no cumple con todos los requisitos de este artículo; a diferencia del juicio ordinario de mayor cuantía, en el cual el tribunal sólo puede rechazar o no admitir la demanda a tramitación cuando no se cumplen los tres primeros requisitos del art. 254 CPC.

La tercería de dominio se tramita según las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, sin los escritos de réplica y dúplica; se tramita por rama separada. En la tercería de dominio, es demandante el tercerista y son demandados tanto el ejecutante como el ejecutado.

Al tercerista de dominio, según el art. 521 inciso 2° CPC, le cabe también el derecho de sustituir el embargo. Del dinero, que substituye al embargo y que depositó el tercerista de dominio, se le hace entrega al ejecutante, y se produce jurídicamente, desde el punto de vista del pago, un pago por subrogación, ya que el tercerista aparece pagando una deuda ajena. En este caso el tercero se subroga en los derechos del ejecutante en contra del ejecutado.

Este derecho de sustitución del embargo que se contempla para el tercerista de dominio, no está contemplado para el tercerista de posesión. Esta situación es claramente una omisión del legislador, ya que por lógica también debería ser aplicable al tercerista de posesión.

8.3 Tercería de posesión.

La tercería de posesión fue introducida en virtud de una reforma al C.P.C. de 1988 y hasta entonces se la había aceptado sólo como una creación jurisprudencial frente a las dificultades que muchas veces surgían para acreditar el dominio de la especie embargada.

Actualmente está expresamente reconocida la tercería de posesión en el art. 521 CPC, que establece que la tercería de posesión se tramita incidentalmente y por cuerda separada.

En cuanto a los efectos de la tercería de posesión, hay que distinguir:

a) Efectos en el cuaderno principal. La interposición de tercería de posesión no tiene ningún efecto; el cuaderno principal sigue su curso como si no se hubiese intentado la tercería de posesión.

b) Efectos en el cuaderno de apremio (art. 522 CPC): la tercería de posesión puede suspender el apremio, cuando el tercerista acompaña antecedentes que constituyen a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca; por ejemplo, factura de los bienes comprados, escritura de compraventa del bien raíz, patentes, etc.

Al igual que en la tercería de dominio, la suspensión del apremio solo tiene efectos relativos, o sea la suspensión del apremio de la ejecución sólo es en relación con los bienes objeto de la tercería.

También razonablemente, aunque la ley no sea lo suficientemente clara, se debe reconocer al tercerista de posesión el derecho a substituir el embargo.

La resolución que se dicta en la tercería de posesión es una sentencia interlocutoria, porque en la medida que la tercería se tramita como incidente la resolución debe ser de tal naturaleza. Sin embargo, el asunto es discutible porque algunos autores han sostenido que la tercería de posesión es un conflicto distinto al principal, de suerte que la resolución tendría el carácter de sentencia definitiva. No obstante, la jurisprudencia y la práctica se han inclinado por calificarla como sentencia interlocutoria y, por lo tanto, aplicando las reglas generales, la apelación se concede en el solo efecto devolutivo cualquiera que se le apelante.

La tercería de posesión puede intentarse a partir del embargo y hasta la realización del bien.

8.4 Tercería de Prelación.

Como regla muy general, la tercería de prelación se refiere al derecho preferente de pagarse frente a determinados bienes que se realicen; por ejemplo, puede derivar del hecho de ser acreedor prendario y

tener prenda sobre el bien embargado. También la tercería de prelación puede invocarse cuando se ha embargado la totalidad de los bienes del deudor, y el acreedor invoca una preferencia de carácter general; como por ejemplo, el Fisco, las administradoras de fondo de pensiones, los trabajadores. En consecuencia, no tan sólo la tercería de prelación nace del embargo mismo, sino que puede ser consecuencia de una situación de carácter general si el deudor no tiene otros bienes sobre los cuales hacer efectiva su acreencia.

La tercería de prelación cuando deriva del embargo de bienes determinados, se puede intentar a partir del embargo y hasta el pago al respectivo acreedor.

Esta tercería de prelación, conforme lo manda el art. 521 CPC, se tramita incidentalmente. Y posibilita la ampliación del respectivo embargo.

En cuanto a los efectos de la tercería de prelación, hay que distinguir:

- a)** Efectos en el cuaderno principal: no produce ningún efecto; el cuaderno principal sigue adelante como si no se hubiese interpuesto la tercería de prelación.
- b)** Efectos en el cuaderno de apremio: tampoco produce ningún efecto, y sigue adelante el cuaderno de apremio hasta la realización de los bienes embargados, pero el pago queda en suspenso hasta que la tercería sea resuelta por sentencia ejecutoriada, (art.525 inciso 2°).

Curiosamente se requiere sentencia firme o ejecutoriada y no sentencia que cause ejecutoria, así aunque la apelación en contra de la resolución que acoge o rechaza la tercería de prelación se conceda en el solo efecto devolutivo, es necesario que la sentencia esté firme o ejecutoriada para poder proceder al pago del respectivo acreedor.

Los requisitos para que la tercería de prelación pueda prosperar es una cuestión de interpretación, la cual se desprende de la parte final del art. 527 CPC, y se ha entendido que aunque se refiere específicamente a la tercería de pago también es aplicable a la tercería de prelación.

La parte final del art. 527 CPC hace mención a “créditos ejecutivos que haga valer el tercerista”, de esta mención se ha concluido que tanto respecto del tercerista de prelación como respecto del tercerista de pago se requiere que su crédito tenga los mismos requisitos que el crédito que ejecutivamente invoca el ejecutante.

Dicho de otra manera, el tercerista debe estar premunido de título ejecutivo, la obligación debe ser líquida y actualmente exigible, y la acción ejecutiva no puede estar prescrita. Esto es perfectamente lógico, porque en definitiva el tercerista se está arrimando a un juicio ejecutivo, y el legislador acepta ésta pero siempre que se tenga la misma calidad jurídica que el acreedor ejecutante.

8.5 Tercería de Pago.

El tercerista de pago pretende concurrir con su crédito al igual que el ejecutante; esta tercería parte del supuesto que el crédito del ejecutante tenga la misma calidad que el crédito del tercerista. También se requiere que fuera de los bienes embargados en esta ejecución, no existan otros bienes del deudor, lo que significa que el legislador exige la prueba del hecho negativo para el tercerista (art. 527 CPC).

El art. 527 CPC establece también que la pretensión del tercerista de pago es concurrir a prorrata.

La oportunidad para intentar la tercería de pago es desde el embargo hasta el pago de la respectiva obligación.

En cuanto a los efectos de la tercería de prelación, hay que distinguir:

- a) Efectos en el cuaderno principal: no produce ningún efecto; el cuaderno principal sigue adelante como si no se hubiese interpuesto la tercería.
- b) Efectos en el cuaderno de apremio: se sigue adelante el apremio hasta la realización de los bienes embargados, pero se suspende el pago hasta que recaiga sentencia firme en la tercería. Se llega a esta conclusión, porque el legislador se refiere en forma más o menos conjunta a la tercería de prelación y a la tercería de pago, y si bien es cierto que sólo respecto de la tercería de prelación indica precisamente esta consecuencia, se ha entendido razonablemente que esta disposición también es aplicable respecto de la tercería de pago.

Al igual que la tercería de prelación, el tercerista de pago debe reunir respecto de sus créditos iguales condiciones que el ejecutante, y de esta manera el crédito debe constar de título ejecutivo, el crédito debe ser liquidado y actualmente exigible, y también la acción ejecutiva no debe estar prescrita.

Además de estos requisitos generales, debe el tercerista de pago acreditar que el deudor no tiene otros bienes sobre los cuales hacer efectiva su acreencia. Se trata claramente de la prueba de un hecho negativo, lo que es excepcional; para probar este hecho negativo es razonable también admitir prueba indirecta, por ejemplo la prueba de presunciones.

Producida la realización de los bienes, el reparto del producto se realiza a prorrata, o sea en proporción de sus respectivas acreencias. Además el tercerista de pago tiene derechos auxiliares, que están indicados en el art. 529 CPC. Estos derechos auxiliares son dos:

- Puede el tercerista de pago solicitar la remoción del depositario, alegando motivo fundado, y en tal caso el nuevo depositario será designado de común acuerdo por las partes, pero en caso de no existir acuerdo lo designará el tribunal.
- Intervenir en la realización de los bienes con las facultades del coadyuvante, o sea el tercerista de pago no tan solo interviene en su cuaderno de tercería, sino que puede intervenir en el cuaderno de apremio instando por la mejor realización de los bienes embargados.

La tercería de pago se tramita con forme a las reglas de los incidentes. La resolución que se dicta en la tercería de pago es una sentencia interlocutoria y la apelación se concede en el solo efecto devolutivo.

Sin perjuicio de la posibilidad de la tercería de pago, el acreedor que pudo ser tercerista puede iniciar una ejecución separada y en tal evento él no puede proceder a embargar nuevos bienes ni tampoco a reembargar los bienes embargados, sino que tiene derecho a pedir que en la primera ejecución se retenga del producto de la realización su parte proporcional.

Tema 9: Abandono especial del procedimiento en el juicio ejecutivo.

El abandono del procedimiento es una sanción por la inactividad, por el incumplimiento de la carga del impulso procesal (art. 153 inciso 2°).

En los procedimientos declarativos el abandono se produce por la sola circunstancia que existiendo la carga del impulso se deja de cumplir con esta carga por un período de seis meses. Este abandono es enteramente aplicable al juicio ejecutivo, siempre que no se haya dictado sentencia firme y es aplicable sólo en el cuaderno principal.

También en el juicio ejecutivo procede un abandono especial que tiene lugar en el cuaderno de apremio, una vez terminada la tramitación del cuaderno principal, sea por haberse dictado sentencia firme o por no haberse opuesto excepciones, caso en el cual se omite la sentencia y el mandamiento es actuación suficiente para seguir adelante la ejecución.

En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además, solicitar el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472. En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, en su caso. En el evento que la última diligencia útil sea de fecha anterior, el plazo se contará desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia definitiva o venció el plazo para oponer excepciones. En estos casos, si se declara el abandono del procedimiento sin que medie oposición del ejecutante, éste no será condenado en costas.



Observación

Unidad 10: Juicio Ejecutivo por Obligación de Hacer.

En el juicio ejecutivo por obligación de hacer se persigue el cumplimiento de una obligación de hacer que no sea la obligación de pagar una suma de dinero ni una obligación de entregar.

Tema 1: Requisitos de procedencia.

En una situación muy similar con el juicio ejecutivo por obligación de dar, en este juicio por obligación de hacer se requiere que la obligación conste en un título ejecutivo, que la obligación sea actualmente exigible, que la acción ejecutiva no esté prescrita. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el juicio ejecutivo por obligación de dar, aquí no se exige que la obligación sea líquida, porque no se puede

extrapolar del juicio por obligación de dar este concepto de “liquidez”, sino que se debe tratar de una obligación determinada. En consecuencia, se requiere:

- título ejecutivo,
- obligación determinada y actualmente exigible,
- acción ejecutiva no prescrita.

En el lenguaje del juicio ejecutivo por obligación de hacer, obligación determinada es el antónimo de obligación determinable, que es aquella que requiere una previa sentencia declarativa que señale su naturaleza. En este caso, la obligación es determinada cuando del título mismo se desprende inequívocamente su naturaleza, y de esta manera, no es necesario un procedimiento declarativo previo para llegar a dicha determinación.

Las reglas que regulan este juicio ejecutivo son:

- Las reglas especiales del Título II, Libro III (arts. 530 a 543 CPC).
- Las normas del párrafo primero del título I (normas del juicio ejecutivo por obligación de dar, en lo que se refiere al cuaderno ejecutivo).
- Las reglas comunes a todo procedimiento.
- Las normas del juicio ordinario de mayor cuantía.

Tema 2: Procedimiento.

Respecto del procedimiento en el juicio ejecutivo por obligación de hacer, la ley contempla dos procedimientos distintos, según sea la naturaleza de la obligación respectiva:

- Cuando la obligación consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una obligación.
- Cuando la obligación consiste en la ejecución de una obra material.

2.1 Cumplimiento de la obligación de suscribir un documento o constituir una obligación.

A esta materia se refiere el art. 532 C.P.C., siendo esta una norma muy escueta, el sentido que señala sólo que frente al incumplimiento del deudor será el juez de la causa quien suscriba el respectivo instrumento o constituya la obligación. En consecuencia, esta norma debe desglosarse, para así entender la manera de proceder.

2.1.1 Contenido de la demanda.

En la demanda, el acreedor, solicita que se requiera al deudor para suscribir un determinado instrumento, cuyas características señalará claramente en su libelo, que se le fije un plazo al efecto, y el apercibimiento de que si no lo hace, el juez lo suscribirá en su representación.

Las peticiones que se formulan en la demanda, se reflejan también en la naturaleza del mandamiento, que es sustancialmente diferente al mandamiento por obligación de dar. La forma de requerir al deudor es totalmente distinta, porque se le está requiriendo de pago, pero como las características de la obligación debida son distintas, se le requiere para que pague, en el sentido que suscriba el documento o constituya la obligación.

2.1.2 Posibles conductas del demandado.

- Una vez realizado el requerimiento, se allana al cumplimiento de la obligación, y va a la notaria respectiva y pura y simplemente firma el documento, o firma el instrumento constitutivo de la respectiva obligación.
- El deudor no opone excepciones ni hace nada, en tal caso transcurrido que sea el plazo que le ha fijado el mandamiento, el juez de la causa suscribirá el respectivo instrumento, cumpliendo así en representación del deudor.
- El deudor opone excepciones.

Las excepciones que el deudor puede hacer valer, son esencialmente las mismas que se contemplan en el juicio ejecutivo por obligación de dar, salvo aquellas que por sus características sean sólo aplicables a ese procedimiento; por ejemplo, no se podrá oponer como excepción el exceso de avalúo.

Si el deudor opone excepciones, será necesario dictar sentencia; sentencia que será de pago, porque está ordenando el cumplimiento de lo debido.

A esta sentencia es aplicable el art. 475 C.P.C., en el sentido que, como regla general, esta sentencia sólo se podrá cumplir si se encuentra ejecutoriada; o sea, aún cuando la sentencia desechase las excepciones del deudor, sólo se podrá cumplir cuando se encuentre ejecutoriada, no obstante concederse a su respecto la apelación en el solo efecto devolutivo. Sin embargo, haciendo aplicación del art. 475 CPC, se debe concluir que precisamente por tratarse de una sentencia de pago, puede cumplirse la sentencia también si el acreedor cauciona las resultas del respectivo recurso.

El plazo que el mandamiento otorga para que el deudor suscriba, tiene plena aplicación, primero, si el deudor voluntariamente se allana y suscribe o, subsidiariamente, si el deudor no opone excepciones, en cuyo evento el mandamiento hará las veces de sentencia y esta se podrá omitir. Pero si el deudor opone excepciones, la suscripción del documento quedará pendiente, como regla general, hasta la ejecutoria de la respectiva sentencia o subsidiariamente a un plazo anterior, siempre que el ganancioso de seguridades suficientes para que, si prosperase la apelación y fuese revocada la sentencia, pueda retrotraerse a la situación inmediatamente anterior.

Tema 3: Cumplimiento de la obligación de ejecutar una obra material.

Sobre el particular, debemos remitirnos a lo establecido en el art. 1553 C.C., norma que está en el Título XII del Libro IV sobre el efecto de las obligaciones, y que señala que:

“Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:

- 1º Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;*
- 2º Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;*
- 3º Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.”*

Las dos primeras formas son maneras directas de cumplir la obligación, ya sea por el deudor mismo, ya sea por un tercero a sus expensas; y la tercera, es una forma sustitutiva, porque la indemnización de perjuicios es sustitutiva de la obligación que primitivamente se contrajo.

De estos tres caminos alternativos, sólo dos son posibles de hacer efectivos por la vía ejecutiva: el camino del apremio o el camino de ejecutar la obra por cuenta del deudor. El tercer camino, el de la indemnización de perjuicios o pago por sustitución, nunca cabe en la vía del juicio ejecutivo, sino que será necesario un juicio de lato conocimiento para determinar la naturaleza y monto de los respectivos perjuicios.

3.1 Apremio al deudor para que ejecute el hecho convenido (arts. 533, 534, 535, 543 CPC)

Si el acreedor ha optado por apremiar al deudor, en la demanda se pide que se condene al deudor a ejecutar una determinada obra material, siempre que se encuentre debidamente especificada dicha obra en el título respectivo; se pedirá también, que se fije un plazo para iniciar la ejecución de la obra respectiva, bajo apercibimiento que si no inicia la obra en el plazo que se fije, se le apliquen los correspondientes apremios de multas o arrestos hasta por 15 días.

El mandamiento dirá: “un ministro de fe requerirá a... para que realice tal obra material, fijándose el plazo de tantos días para que de inicio a su ejecución, bajo apercibimiento de multas o arrestos que se repetirán en caso de no hacerlo”.

El deudor requerido, al igual que en la situación anterior, puede seguir tres caminos distintos:

- a) Se allana efectivamente a cumplir la obligación, e inicia su realización.
- b) No hace nada, en tal evento, al igual como ocurre en el juicio ejecutivo por obligación de dar, se omitirá la sentencia y el mandamiento servirá de suficiente actuación para ordenar los apremios correspondientes.

c) Oponer excepciones, y nuevamente son esencialmente las mismas excepciones que se pueden oponer en el juicio ejecutivo por obligación de dar, siempre que correspondan a la naturaleza de la obligación. Pero a estas excepciones se agrega la excepción de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida.

Si las excepciones son desechadas, deberá esperarse que la sentencia quede ejecutoriada para efectuar los apremios correspondientes; pero, también en este caso es aplicable el art. 475 CPC, en el sentido que si el ejecutante cauciona las resultas de la apelación, pueden desde luego iniciarse los apremios correspondientes.

Es interesante lo establecido en el art. 543 inciso 2º CPC; si se lee sólo el inciso 1º de este artículo, se llega a la conclusión que los apremios se pueden ir indefinidamente repitiendo. Pero el art. 543 en su inciso 2º CPC, contempla una forma de liberación del deudor, para evitar precisamente una situación extrema: si el deudor paga las multas que se le han impuesto y cauciona suficientemente las indemnizaciones correspondientes, cesa en consecuencia el apremio.

Pero esta situación, de caucionar las resultas del futuro juicio indemnizatorio, obligará al acreedor a iniciar, efectivamente, a *posteriori* un juicio declaratorio, donde se discutirá la naturaleza y monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de hacer.

3.2 Autorización para hacer ejecutar la obra a expensas del deudor (arts. 534 a 542 CPC)

Aquí se da una cosa muy curiosa: la obligación de hacer se convierte en obligación de dar, y hay una remisión al cuaderno de apremio para las obligaciones de dar.

De acuerdo a lo que señala el art. 536 CPC, el acreedor puede solicitar que se le autorice a llevar a cabo la obra por medio de un tercero y a expensas del deudor.

Este derecho del acreedor, lo puede ejercitar desde el momento en que la sentencia se encuentra ejecutoriada o desde que haya transcurrido el plazo sin que el deudor oponga excepciones. Además, este derecho puede ejercitarlo el acreedor también si el deudor, cuando se a optado porque sea el quien ejecute la obra, no ha iniciado los trabajos en el plazo fijado, o si habiendo iniciado dichos trabajos, los abandona sin causa justificada.

El art. 537 CPC señala como se procede: el acreedor demandante, junto con su solicitud de realizar la obra por un tercero y a expensas del deudor, presenta un presupuesto para la ejecución, el que se pone en conocimiento del deudor, quien tiene un plazo de tercero día para observarlo, y si no lo observa dentro de tercero día se tendrá como aprobado. Si se deduce objeción, esta objeción se tramita y se resuelve en la misma forma como se tramita y se resuelve la objeción de la tasación en el juicio ejecutivo

cuando debe realizarse previa tasación; o sea, hay una remisión sobre el particular a los arts. 486 y 487 C.P.C.

Una vez determinado el valor de la obra, mediante el mecanismo descrito en el art. 537 CPC, el deudor debe consignar el monto respectivo dentro de tercero día, a la orden del tribunal; para que se entreguen los fondos al acreedor a medida que la realización de la obra lo requiera.



Casos

El art. 539 CPC razona sobre la hipótesis que los fondos se agoten sin haber terminado el trabajo; en este caso, si el acreedor justifica que hubo error en el presupuesto o han sobrevenido circunstancias imprevistas que aumenten el costo de la obra, podrá ser el deudor obligado a consignación del suplementario (art. 539 CPC).

El art. 540 CPC señala que, toda vez que el acreedor se convierte en administrador de recursos ajenos para ejecutar la obra, y como tal debe rendir cuenta de la administración de los fondos del deudor.

El art. 541 CPC señala que si el deudor no consigna los fondos correspondientes, la obligación de hacer se convierte en una obligación de dar, porque el deudor está entregando dineros para una determinada finalidad; y consecuente con este principio que la obligación de hacer se convierte en obligación de dar, si no se consignan los fondos respectivos, se procede al embargo de los bienes del deudor y a su enajenación de acuerdo a las reglas del procedimiento de apremio, y por eso hay una expresa remisión al título inmediatamente precedente, que específicamente se refiere al procedimiento de apremio.

El art. 542 CPC dispone que el acreedor pueda hacer uso de otras vías para compeler al deudor en el cumplimiento de la obligación, siempre que si se ha usado esta vía, no se ha llegado a la consignación de los fondos o a la realización de los bienes del deudor.

Unidad 11: Juicio Ejecutivo por Obligación de no Hacer.

Respecto del juicio ejecutivo por obligación de no hacer, se aplican, en general, las mismas disposiciones del juicio ejecutivo por obligación de hacer; lo que es enteramente lógico, porque los casos excepcionales donde se puede pretender ejecutivamente el cumplimiento de una obligación de no hacer, y esta obligación de no hacer se traduce en la destrucción de una obra realizada, la destrucción de una obra realizada es precisamente una obligación de hacer, y en consecuencia hay una remisión general a las normas del juicio ejecutivo por obligación de hacer.

A este juicio se refiere sólo el art. 544 CPC, el que hace una remisión al art. 1555 C.C.

Art. 544 C.P.C.: *“Las disposiciones que preceden se aplicarán también a la obligación de no hacer cuando se convierta en la de destruir la obra hecha, con tal que el título en que se apoye consigne de un modo expreso todas las circunstancias requeridas por el inciso 2º del artículo 1555 del Código Civil, y o pueda tener aplicación el inciso 3º del mismo artículo.*

En el caso en que tenga aplicación este último inciso, se procederá en forma de incidente.”

Art. 1555 C.C.: *“Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho.*

Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.

Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo.

El acreedor quedará de todos modos indemne.”

En general, al legislador le repugna el hecho que la obligación de no hacer se traduzca en la destrucción de lo realizado; el legislador rechaza, en principio, que lo realizado tenga que destruirse. Y como regla muy general, el legislador opta por condenar al deudor que ha infringido una obligación de no hacer, con la correspondiente indemnización de perjuicios (art. 1555 inciso 1º C.C.).

La regla general es que la obligación de no hacer se convierta en una obligación de dar, que consiste en indemnizar de perjuicios si no se puede deshacer lo hecho. Pudiéndose deshacer lo hecho, hay que observar si la destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en vista al momento de contratar; si efectivamente la destrucción es necesaria, aún todavía puede ser oído el deudor que ofrezca el cumplimiento por sustitución. Y sólo si la destrucción es necesaria, y no hay forma de cumplimiento por sustitución, se procede a la destrucción de la obra respectiva.

Destruir la obra realizada, se convierte en una obligación de hacer, o sea, el deudor debe realizar las labores necesarias para destruir la obra realizada, y al efecto, se puede usar ya sea la vía del apremio, o bien la vía de que sea un tercero el que realice la destrucción a expensas del deudor.

Una modificación del año 1995 introdujo al **artículo 393 C.O.T.**, un nuevo inciso 4º, que tuvo por objeto evitar algunos abusos que se habían cometido por parte de algunos acreedores, que usaban indebidamente la fuerza pública otorgada en una ejecución en otra distinta a la que se había decretado, o amedrentaban a los deudores con el posible uso de la fuerza pública, para compelerlos al pago. Frente a esto se introdujo esta disposición: *“Los receptores sólo podrán hacer uso del auxilio de la fuerza pública que decreta un tribunal, para la realización de la determinada diligencia respecto de la cual fue autorizado. En uso no autorizado, o el anuncio, o la amenaza del uso del auxilio de la fuerza pública sin estar decretado, será sancionado en la forma prevista en el número 4º del artículo 532 de este Código.”*

Unidad 12: Ejecución de las Resoluciones Judiciales.

La ejecución de las resoluciones judiciales es, técnicamente hablando, un incidente especial. Esta materia está tratada en el Título XIX del Libro I, arts. 231 a 251 CPC; y distingue: cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales chilenos y cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros.

Tema 1: Cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales chilenos.

En relación con el tribunal competente, encontramos el art. 231 C.P.C. en relación con el art. 113 C.O.T.

La ejecución de las resoluciones judiciales corresponde a los tribunales que las hayan pronunciado en primera o en única instancia. Las resoluciones judiciales sólo deben cumplirse a partir de la ejecutoria de dicha resolución, o bien, en ciertos casos excepcionales, cuando esta resolución causa ejecutoria. Sin embargo, el inciso 2º del art. 231 CPC, al igual que lo que establece el art. 113 COT, establece una aparente excepción, en el sentido que ciertas y determinadas resoluciones pueden ser también ordenadas cumplir por un tribunal distinto, o sea, no por el tribunal que conoció del asunto en primera o en única instancia, sino por los tribunales que están conociendo de determinados recursos, en lo que diga relación con la tramitación de dichos recursos.

Estos tribunales, no tan sólo pueden ordenar las medidas de tramitación en lo que diga relación con dichos recursos, sino que también pueden ordenar el pago de las costas que se hubiesen causado en estos recursos, sin perjuicio de que el tribunal de primera o única instancia resuelva y ordene el pago de las demás costas.

El art. 232 C.P.C. en relación con el art. 114 C.O.T., señala quien es el tribunal competente para conocer de un nuevo juicio que sea indispensable iniciar, con el objeto de cumplir lo resuelto en uno anterior; en tal evento, el ganancioso puede, a su elección, recurrir al tribunal que conoció del asunto en primera o en única instancia o el que sea competente de acuerdo a las reglas generales.

Los arts. 233 CPC y siguientes señalan el procedimiento que debe aplicarse cuando se solicita el cumplimiento de la sentencia, sin iniciar un nuevo juicio, ante el tribunal que conoció del en primera o en única instancia. Esto se denomina, en el lenguaje de nuestra disciplina, “procedimiento de cumplimiento incidental del fallo”.

1.1 Procedimiento de cumplimiento incidental del fallo

El plazo para pedir el cumplimiento incidental del fallo es de un año, contado desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada o desde que cause ejecutoria. Naturalmente que, si el fallo contempla una obligación que se haya hecho exigible con posterioridad a este momento, el plazo se cuenta desde la exigibilidad de la obligación.

Si la ley no ha dispuesto otra forma de cumplirla, el tribunal ordenará su cumplimiento con citación, es decir, la parte respecto de la cual se está accediendo la actuación, tiene un plazo fatal de 3 días para deducir oposición. (art. 69 C.P.C.).

La notificación de esta resolución será por cédula al apoderado de la respectiva parte; entendiendo por apoderado de la respectiva parte a quien tiene poder en el juicio que se terminó y cuya sentencia se pretende cumplir. Además, el receptor debe enviar carta certificada a la propia parte contra la cual se pretende cumplir la resolución, la que debe ser enviada al lugar donde se notificó personalmente la respectiva demanda.

La ley se pone en el evento que el fallo deba ser cumplido respecto de un tercero, situación que es excepcional, porque normalmente respecto de los terceros los fallos judiciales son inoponibles. En estos casos excepcionales, la ley contempla que a estos terceros debe notificárseles personalmente.

El inciso final del art. 233 CPC, señala que las sentencias que ordenen prestaciones periódicas, se podrán cumplir en el plazo de un año desde que cada una de dichas prestaciones se haya hecho exigible.

Este plazo de citación se concede para que el pernicioso (la parte contra la cual se pretende el cumplimiento de la sentencia) alegue sus respectivos derechos, y oponga excepciones a este cumplimiento incidental. El legislador ve con particular desconfianza a este demandado que todavía se resiste al cumplimiento de lo resuelto, y de esta manera, el legislador ha limitado las excepciones que éste puede oponer, e incluso ha señalado en ciertas y determinadas situaciones requisitos de admisibilidad de las excepciones (art. 234 CPC).

Están taxativamente enumeradas las excepciones que la parte respectiva puede oponer, frente a esta pretensión de cumplimiento incidental. Además, en general, deben fundarse en antecedente escrito, pero en todo caso deben invocarse hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata. Estas posibles excepciones, que el deudor debe oponer necesariamente dentro del término de citación son:

- pago de la deuda;
- remisión de la deuda;
- concesión de esperas o prórroga del plazo;
- novación;
- compensación;
- transacción;

- haber perdido su carácter de ejecutoria (sea absolutamente o en relación con el art. 233 CPC);
- pérdida de la cosa debida, cuando se trata de la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto (remisión al art. 464 N° 15 CPC);
- imposibilidad de cumplimiento, cuando se trata de una obligación de hacer (remisión al art. 534 CPC).

Estas excepciones, salvo la de la pérdida de la cosa debida y la de la imposibilidad absoluta de cumplir, deben fundarse en antecedentes escritos. Y las excepciones de pérdida de la cosa debida y la de imposibilidad, deben estar revestidas de fundamento plausible, bajo apercibimiento de ser rechazadas de plano.

El legislador señala que el tercero que deduce oposición, puede hacerlo en el plazo de 10 días, pudiendo hacer valer las mismas excepciones que la parte, pero además hay una excepción particularmente contemplada para él, que es que la sentencia no le empegue, o sea, que la sentencia no le sea oponible (art. 234 inciso 2º CPC).

Opuestas que sean las excepciones, el tribunal examinará su admisibilidad, o sea, si están fundadas en hechos posteriores a la sentencia, si se fundan en antecedente escrito o respecto de alguna de ellas si están revestidas de fundamento plausible. Si estima que las excepciones no cumplen con los requisitos de admisibilidad, las debe rechazar de plano. Si por el contrario, estima que las excepciones son admisibles, dará a esta oposición tramitación incidental, y en consecuencia se dictará una nueva sentencia interlocutoria que acoja o deseche la oposición del deudor; esta sentencia interlocutoria es apelable en el solo efecto devolutivo (art. 194 N° 3 C.P.C.).

El inciso final del art. 234 CPC señala que la posibilidad de oposición por parte del pernicioso, es sin perjuicio de que este pueda pedir la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento; y así se entiende la remisión que hace este inciso final al art. 80 C.P.C.

Encontramos **dos posibles situaciones**: que el pernicioso o el tercero no se hayan opuesto al cumplimiento dentro del plazo de tercero o diez días según corresponda, y en tal evento se puede proceder derechamente al cumplimiento; o que el pernicioso o el tercero se hayan opuesto al cumplimiento, y esta oposición haya sido desechada por la sentencia interlocutoria respectiva.

En estos dos eventos se puede proceder propiamente al cumplimiento del fallo, y respecto de la forma del cumplimiento, debemos remitirnos al art. 235 CPC. Este artículo no señala una forma de cumplimiento, sino que varias formas de cumplimiento, según sea la naturaleza de la resolución que se trata de cumplir. Más aún, hay una regla supletoria final, en el sentido que se autoriza al juez, en caso que ninguna de las reglas anteriores sea enteramente aplicable, para adoptar las medidas convenientes o adecuadas para el respectivo cumplimiento.

Art. 235: “Si no ha habido oposición al cumplimiento de la sentencia solicitado conforme el art. 233 o ella ha sido desestimada por sentencia de primera o segunda instancia, se procederá a cumplirla, siempre que la ley no haya dispuesto otra forma especial, de acuerdo con las reglas siguientes:

1° Si la sentencia ordena entregar una especie o cuerpo cierto, sea mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega, haciéndose uso de la fuerza pública si es necesario;

2° Si al especie o cuerpo cierto mueble no es habido, se procederá a tasarlo con arreglo al Título XII del Libro IV y se observarán en seguida las reglas del número siguiente;”

Si el bien mueble no se encuentra en poder del deudor, la obligación se transforma en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. Se procede a la tasación de la especie, pero aquí el legislador no se remite las normas del juicio ejecutivo sino a las reglas de la tasación en materia no contenciosa, contenidas en los arts. 895 y ss. C.P.C.

Se trata de un procedimiento bastante simple de tasación: se procede al nombramiento de peritos conforme al art. 414 CPC; practicada la tasación, se depositará en la oficina a disposición de los interesados, los cuales serán notificados de ella por el secretario o por otro ministro de fe, sin necesidad de previo decreto del tribunal. Los interesados tendrán tres días para impugnar la tasación, se da traslado por días a la parte contraria de la impugnación (es una tramitación concentrada).

3° Si la sentencia manda pagar una suma de dinero se ordenará, sin más tramite, hacer pago al acreedor con los fondos rendidos, hecha la liquidación del crédito y de las costas causadas o se dispondrá previamente la realización de los bienes que estén garantizando el resultado de la acción de conformidad al Título V del Libro II.

Si no hay bienes que aseguren el resultado de la acción se procederá a embargar y a enajenar bienes suficientes de la parte vencida de acuerdo a las reglas del procedimiento de apremio, sin necesidad de requerimiento y deberá notificarse por cédula el embargo mismo y la resolución que lo ordena;”

Es una regla de frecuente aplicación. Se hace una remisión al Título V de las Medidas Precautorias.

4° Si la sentencia obliga a pagar una cantidad de un género determinado, se procederá de conformidad a las reglas del número anterior; pero si es necesario, se practicará previamente su valuación por un perito con arreglo al Título XII del Libro IV;”

Si se ordena pagar una cantidad de un género determinado, primero se observa si se ha retenido dicho género o si se ha adoptado una medida precautoria. Si se ha retenido dicho género, se procederá simplemente a la entrega de la cantidad debida; en cambio, si se han aplicado medidas precautorias, se debe realizar el objeto de la precautoria.

5° Si la sentencia ordena la ejecución o destrucción de una obra material, la suscripción de un documento o la constitución de un derecho real o de una obligación, se procederá de acuerdo con el procedimiento de apremio en las obligaciones de hacer; pero se aplicará lo prescrito en el número 3° de este artículo cuando sea necesario embargar y realizar bienes; y”

6° Si la sentencia ha condenado a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios y, de conformidad a lo establecido en el inciso 2 del art. 173, se ha reservado al demandante el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo, el actor deberá formular la demanda respectiva en el mismo escrito en que pida el cumplimiento del fallo. Esta demanda se tramitará como incidente y, de existir oposición al cumplimiento del fallo, ambos incidentes se substanciarán conjuntamente y se resolverán en una misma y única sentencia.”

Esto es lo que se llama “demanda con reserva”. Es un derecho alternativo:

- a) Se demanda al mismo tiempo la indemnización de perjuicios o la restitución de frutos. Acción declarativa y acción de condena.
- b) Se divide la pretensión: primero se hace valer la acción declarativa, dejando para el cumplimiento incidental del fallo la naturaleza y monto de la restitución.

Esta materia ya fue analizada a propósito del juicio ordinario de mayor cuantía.

El art. 325 inciso final es una remisión general a las reglas del juicio ejecutivo; pero es una remisión equivocada, y por tanto debe entenderse hecha al art. 773 y no al 774 del C.P.C.

1.2 Reglas generales de ejecución

1° Pago de Prestaciones Periódicas (art. 236):

Esta regla tiene mucha importancia, porque estamos frente a una sentencia que condena al deudor al pago de prestaciones periódicas, y si el deudor se retrasa en el pago de estas prestaciones, el acreedor puede pedir que el deudor sea condenado a consignar en un banco o institución financiera una cantidad tal que con los intereses se pague la prestación periódica. Esta solicitud se tramita incidentalmente.

Si el deudor no cumple con esta obligación de hacer este depósito, una vez accedida la solicitud, se procede al embargo conforme al art. 235 inciso 3°.

2° Artículo 237 C.P.C.:

Se pone en el supuesto de que teniendo la sentencia de condena, el acreedor no pida el cumplimiento incidental del fallo dentro del plazo, o porque recurrió a otro juez donde inició el correspondiente juicio ejecutivo. En este juicio ejecutivo, son sólo admisibles las excepciones que no se hayan hecho valer en el juicio anterior.

3° Artículo 238 C.P.C.:

El legislador se pone en la situación que, dada la naturaleza de la sentencia, no le sean aplicables ni las reglas generales ni las especiales. En tal evento, se le da la posibilidad al juez de adecuar el cumplimiento del fallo a las circunstancias, pudiendo aplicar las medidas conducentes al cumplimiento, es decir, se le faculta para imponer multas o arrestos.

4° Artículo 239 C.P.C.:

Este artículo tiene poca aplicación práctica, y su redacción puede conducir a equívocos. Esta disposición está relacionada con el derecho legal de retención.

Cuando se condena a restituir una cosa raíz o mueble, el deudor puede pedir el derecho legal de retención hasta que el acreedor le satisfaga determinadas prestaciones a que está obligado, o sea hasta que le pague lo que le debe.

Si este derecho no se plantea en el juicio principal, que es la regla general, se puede plantear en el cumplimiento incidental. Generalmente este incidente no suspenderá la restitución, salvo en los casos en que la ley así lo establezca.

5° Artículo 240 C.P.C.:

Es una regla muy importante. El inciso 1° señala el ámbito del imperio del tribunal; los tribunales no sólo están facultados para ordenar el cumplimiento del fallo, sino también para mantener lo cumplido, es decir, está facultado para tomar las medidas necesarias para la mantención de la respectiva resolución.

El inciso 2° señala el único caso de una situación penal descrita y sancionada en el C.P.C.; se tipifica una forma de desacato, que es el quebrantamiento deliberado de un mandato judicial. En este caso, se establece una sanción penal, que es la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.

6° Artículo 241 C.P.C.:

Establece el régimen de apelación, y se refiere al caso especial de la apelación en los juicios de hacienda. Esta regla repite la regla general, porque antes la regla general era diferente que la de ahora.

En los juicios de hacienda la apelación se concede en ambos efectos, pero para que no haya un retardo excesivo se coloca de inmediato en la tabla, y gozará de preferencia para su vista y fallo.

Todas las apelaciones, a excepción de este caso, que se deduzcan en el cumplimiento incidental del fallo se conceden en el solo efecto devolutivo.

Tema 2: Cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros.

El Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante es un tratado multilateral que sólo liga a los países signatarios que manifestaron su voluntad de ratificación, de manera que tienen un ámbito restringido.

Chile aprobó el Código de Derecho Internacional Privado con una muy importante reserva, que significa la preeminencia de la legislación chilena, presente y futura, respecto de aquellas normas. En consecuencia aquí se prefieren estas normas del C.P.C., sin perjuicio de que en lo supletorio y respecto de los países vinculados a este tratado multilateral se puede aplicar este Código de Derecho Internacional Privado.

El C.P.C. se remite a los tratados como forma de cumplir las resoluciones judiciales, de manera que aquí hay que entender que existe una doble remisión.

El criterio del legislador chileno es un criterio subsidiario en el sentido que va fijando reglas, en que unas se prefieren respecto de otras, en cuanto al cumplimiento de las resoluciones de los tribunales extranjeros.

No obstante lo antiguo de nuestra legislación, ésta dio un paso muy importante porque a falta de la aplicación de las reglas subsidiarias, reconoce eficacia a las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, aún cuando no haya tratado y aún cuando no sea aplicable la regla de la reciprocidad, que es una de las reglas que se establecen en cuanto al criterio del cumplimiento de estas resoluciones.

2.1 Reglas que se aplican al cumplimiento.

1º Existencia de Tratados Internacionales (art. 242 CPC):

Para el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en país extranjero, la ley chilena prefiere los tratados internacionales por sobre ella, y para la ejecución de estas resoluciones se deberán seguir los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados.

2º Criterio de la Reciprocidad (art.243 y 244 CPC):

Este criterio se aplica en la generalidad de las relaciones internacionales; a falta de tratado se aplica este criterio de reciprocidad. El criterio de la reciprocidad implica que nuestro país, le dará a las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, la misma fuerza que, en el país de origen de la respectiva resolución, se le da a las resoluciones dictadas por tribunales nacionales, es decir, si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile.

3º Artículo 245 C.P.C.:

Aún a falta de tratado, y en la imposibilidad de dar aplicación al criterio de reciprocidad, nuestro legislador reconoce las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados por el art. 245 C.P.C. Estos son:

a) Que estas resoluciones de tribunales extranjeros no contengan nada contrario a las leyes de la República. Pero no se tomarán en cuenta las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la substanciación del juicio.

Que las resoluciones extranjeras no sean contrarias a las leyes chilenas, significa que lo que éstas no pueden contrariar son las normas de orden público de nuestro país; esto se debe relacionar con el art. 1462 C.C.

El concepto de orden público es diferente al concepto de Derecho Público. En el Derecho Público la mayoría de las normas son de orden público, pero también existen normas de orden público en el Derecho Privado. Hay que tener presente que el concepto de orden público es un concepto esencialmente dinámico, que dependerá del respectivo lugar y momento en que se invoque.

b) Que las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros tampoco se opongan a la jurisdicción nacional.

Es importante señalar, que existen determinadas materias a las cuales sólo les son aplicables la jurisdicción nacional; así por ejemplo, la Constitución dice que todo lo que tenga que ver con la propiedad minera, será resuelto por tribunales ordinarios nacionales.

c) Que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa.

Lo que aquí debió decir el legislador es que, la parte contra la cual se invoca la respectiva resolución emanada de tribunales extranjeros, debe estar debidamente emplazada. No obstante, estar debidamente emplazada, la parte se puede oponer al cumplimiento de la resolución, si prueba que no pudo defenderse adecuadamente en el respectivo procedimiento.

d) Que las resoluciones emanadas de los tribunales extranjeros estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas.

Es importante tener presente que, todo lo hasta aquí dicho, no sólo es aplicable a resoluciones extranjeras en materia contenciosa, sino también a resoluciones extranjeras que se pronuncien sobre materias voluntarias (art. 249 C.P.C.).

Las resoluciones extranjeras que se pretenden cumplir en nuestro país, no necesariamente deben haber emanado de tribunales ordinarios o especiales extranjeros, sino que también pueden haber emanado de tribunales arbitrales extranjeros. Sea cual sea la naturaleza del tribunal extranjero que dictó la respectiva resolución, estas podrán hacerse cumplir en Chile.

Cuando las resoluciones han emanado de un tribunal arbitral extranjero, se hará constar su autenticidad y eficacia por el visto bueno u otro signo de aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país donde se haya dictado el fallo (art. 246 C.P.C.) . Sin embargo, este trámite de homologación del tribunal superior ordinario, sólo será necesario en cuanto sea obligatorio en el país de origen de la sentencia arbitral.

2.2 Tramitación del cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero.

La tramitación del cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero, se divide en dos partes:

- a) Procedimiento para cumplir la respectiva resolución, procedimiento llamado exequátur.
- b) Cumplimiento mismo de la respectiva resolución.

2.2.1 Tramitación del exequátur.

El art. 247 señala que, la resolución que se pretende hacer cumplir debe acompañarse a la Corte Suprema en copia debidamente legalizada, solicitando naturalmente dicho cumplimiento. Se distingue si la resolución es en torno a una materia contenciosa o respecto de una materia no contenciosa.

La situación más simple es si se trata de una materia no contenciosa. En tal evento, el tribunal pide informe al Fiscal Judicial y una vez evacuado el informe la sala respectiva pone el asunto en tabla y se procede a la vista de la causa de acuerdo a las reglas generales, y naturalmente a su posterior decisión.

Así se desprende, de los arts. 247 y 249 CPC. Si el asunto es de jurisdicción contenciosa, hay que aplicar lo establecido en el art. 248 CPC, en el sentido que de la solicitud respectiva, debe darse conocimiento a la parte contra la cual se pretende cumplir la resolución; este conocimiento que exige esta norma se realiza mediante formal notificación, y como se trata de la primera notificación en Chile de una resolución que va a afectar a la parte contra la cual se pretende cumplir dicha resolución, esta notificación debe realizarse en forma personal o sustitutiva de la personal.

El notificado, o sea, la persona contra la cual se pretende cumplir la resolución, cuenta con el término de emplazamiento para contestar o hacer presente lo que estime en el caso. Una vez evacuada esta respuesta, nuevamente la Corte Suprema manda los antecedentes al Ministerio Público, éste da su dictamen o vista, y evacuado este dictamen o vista, se ordena traer los autos en relación y se procede de acuerdo a las reglas generales.

Es importante también tener presente que, es posible que la Corte Suprema, si lo estima del caso, abra un término probatorio para resolver y recibir probanzas respecto de cuestiones de hecho que se pudiesen suscitar, y éste término probatorio y todo lo que dice relación con la prueba se tramita conforme a las reglas de los incidentes.

Eventualmente, aquí puede producirse la siguiente alternativa: si la Corte Suprema rechaza el exequátur, naturalmente ahí termina la tramitación; en cambio, si la Corte Suprema accede a la solicitud y concede el exequátur, esa decisión tiene ya precisamente al cumplimiento. El cumplimiento se pide ante el tribunal nacional que, si el asunto se hubiese suscitado en Chile, habría sido el competente para conocer de la cuestión en primera o en única instancia, o sea se ve en definitiva ante que tribunal, aplicando las reglas generales de la competencia, se habría planteado el asunto en Chile, y ante ese tribunal se acompaña todo lo actuado ante la Corte Suprema.

También puede ser que se pida a la propia Corte Suprema que remita los antecedentes a dicho tribunal, y es de ocurrir que ésta acceda; y en consecuencia los trámites de cumplimiento ante el tribunal de primera o de única instancia se realicen a partir de lo actuado ya ante la Corte Suprema.

En relación a como ordena el tribunal chileno, de primera o única instancia, el cumplimiento, hay que remitirse a las reglas generales, y en consecuencia, hay que aplicar los arts. 233 y ss. C.P.C., o sea, el tribunal respectivo ordenará el cumplimiento de la resolución con citación dentro del término, se podrá

oponer oposición, y si esta oposición es rechazada o no media oposición, se procederá al cumplimiento según la naturaleza de la respectiva resolución (art. 251 CPC).

Tema 3: Cumplimiento de las resoluciones judiciales pronunciadas por árbitros nacionales.

A esta materia se refieren los arts. 635 y 643 C.P.C.

El art. 635 CPC contiene las normas particulares de las reglas de los juicios seguidos ante árbitros de derecho, entendiéndose para este efecto, tanto árbitros de derecho propiamente tales como árbitros mixtos. El art. 643 CPC se refiere a los árbitros arbitradores, y lo interesante es que por la remisión que hace el art. 643 al art. 635 CPC, se llega a la conclusión que cualquiera que sea la naturaleza del árbitro, las resoluciones se deben cumplir en la forma como señala el art. 635 CPC.

Art. 635: "Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la dictó, si no está vencido el plazo porque fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento.

Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución.

Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto."

En relación con esta materia, hay que hacer una serie de distinciones previas. La primera distinción que hay que hacer es si se trata del cumplimiento de la sentencia definitiva o si se trata del cumplimiento de otra resolución. Como regla general, si se trata del cumplimiento de la sentencia definitiva, el tribunal único para ordenar su cumplimiento es el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, cuando se trata de una resolución distinta a la sentencia definitiva y requiere de alguna medida de compulsión, debe recurrir al tribunal ordinario respectivo para que las decrete.

Si se trata de la sentencia definitiva, en principio, quien pide el cumplimiento tiene un derecho alternativo, y este derecho alternativo es pedirlo ante el propio árbitro o pedirlo ante el juez que corresponda de acuerdo con las reglas generales, a elección de quien pida el cumplimiento. Sin embargo, para pedirlo ante el propio árbitro hay dos limitaciones de gran importancia:

a) sólo se puede pedir el cumplimiento ante el propio árbitro si el plazo de dicho árbitro se encuentra pendiente; si ha expirado el plazo del árbitro no se puede pedir el cumplimiento ante él;

b) si el cumplimiento importa procedimiento de apremio, siempre es sólo competente la justicia ordinaria; o si el cumplimiento afecta a terceros que no han sido parte en el compromiso, en los casos excepcionales en que puede ser cumplido respecto de terceros, también debe pedirse ante la justicia ordinaria.

Además de estas disposiciones, hay una serie de tratados internacionales muy importantes que regulan también formas especiales de cumplimiento, y aquí encontramos, entre otras, dos instituciones que tienen mucha importancia:

a) Arbitraje Internacional: Esta institución tiene distintas fuentes o vertientes, y las partes voluntariamente siempre pueden someter sus puntos a diferentes sedes arbitrales internacionales. Es frecuente, por ejemplo, que las partes recurran a una sede arbitral internacional para los países latinoamericanos e hispanos, de acuerdo con un determinado procedimiento, y adscrito a la Cámara de Comercio de Chile existe un centro de arbitrajes que está vinculado a esta forma de arbitraje internacional. Otra fuente de arbitraje internacional, muy importante también, es el Tribunal o la Corte Arbitral de París, que tiene un gran prestigio, sobretodo en asuntos mercantiles. Los respectivos textos contienen no sólo normas procedimentales respecto del desarrollo del juicio mismo, sino también normas particulares en relación con el cumplimiento de las resoluciones.

b) Existe todo un mecanismo para cumplir las resoluciones que se dicten en Chile o en el extranjero respecto de alimentos, y hay todo un sistema bastante expedito, y naturalmente que sea accesible a personas de escasos recursos, que permite un rápido y eficaz cumplimiento de dichas resoluciones.